

será por cinco años. A partir de ese plazo, concluye la locación.

Con ello volvemos sobre el tema de la existencia del plazo suspensivo o resolutorio. Respecto de esto, se aplican, en general, las mismas reglas que respecto de lo ya visto a propósito de la condición (v. *supra*, § 308, i).

1. Una institución de heredero no puede sujetarse ni a un plazo suspensivo: "Que Ticio sea mi heredero cinco años después de mi muerte", ni tampoco resolutorio: "Que Ticio sea mi heredero hasta tal día". De ponerse un plazo, se lo entiende como no escrito, como si el heredero hubiese sido instituido pura y simplemente (Inst., 2.14.9).

2. Una *stipulatio* puede hacerse con un plazo suspensivo, pero no resolutorio, es decir, *ad tempus*: "Prometes darme 10 áureos por año mientras viva". La obligación es entendida como pura y simple. El deudor continuará estando obligado por el *ius civile* como si se hubiera estipulado: "Prometes darme 10 áureos por año?" sin plazo, en forma perpetua (Inst., 3.15.3). Sería una forma de "renta vitalicia".

Pero luego de ocurrida la muerte del beneficiario, en caso de pretender seguir cobrando su heredero, el pretor concede al deudor ya la *exceptio doli mali* o la *exceptio pacti conventi* (Inst., *ibid.*; Paulo, D.44.7.44.1).

3. El legado puede estar sujeto a término o plazo. Hay acá una diferencia con la institución de heredero, que se explica por cuanto en ésta se trata de una continuación de la persona del causante, mientras que el legado es una forma de adquirir una propiedad o un crédito.

El plazo *ad quem* se puede aplicar, para favorecer al legatario con alimentos periódicos ("Que el heredero dé a Julia 100 por mes durante 10 años") o con una renta vitalicia ("Que el heredero dé a Ticio 50 áureos por año"). En este caso, a diferencia de lo que ocurría en la *stipulatio*, la obligación se extingue por el *ius civile* con el pago de la última cuota (Pomp., D.45.1.16.1). Se interpretaba que no hay un solo legado, sino muchos legados (Ulp., D.36.2.10), según las mensualidades y anualidades, etc., de tal modo que el término final, o la muerte del legatario, si era por vida de éste, más que "resolverse" el derecho, deja de ser exigible la que sería la cuota siguiente (v. Ulp., D.45.11.1 ss.).

4. En los contratos que no son de derecho estricto (así, la compraventa), se permiten pactos resolutorios sujetos a condición suspensiva: *in diem addictio*, *lex commissoria*, *pactum ad gustum* (v. *supra*, § 308.i.1). En otros, como el arrendamiento o la sociedad se suele fijar un plazo *ad quem*, pero más que "resolver" el contrato, directamente lo finaliza.

5. A su vez, los efectos resolutorios no se pueden aplicar a situaciones jurídicas absolutas, como, p.ej., la libertad (así, que mi esclavo sea libre hasta tal día; Paulo, D.40.4.33 ss.); la patria potestad (así, adoptar un hijo por cierto tiempo; Labeón-Paulo,

D.1.7.34), la propiedad y la servidumbre *ad tempus* (Diocl., FV 283) y el derecho hereditario.

En el derecho posiciónico se admite una propiedad temporalmente limitada, sujeta a efectos resolutorios. Pero sigue siendo inconcebible con la libertad, la patria potestad y el derecho hereditario (C.8.54.2).

§ 312. Efectos del término o plazo. Hay que distinguir entre la época anterior al cumplimiento del plazo y la posterior.

a) En el negocio sometido a condición hemos visto que hasta que ésta se cumpla, no existe propiamente una obligación (para los bizantinos: una "esperanza de obligación"). En cambio, en el negocio a plazo, éste existe desde su celebración, salvo que para ser exigible hay que esperar que ocurra el término o plazo (Paulo, D.45.1.48 pr.; Ulp., D.50.16.213; Inst., 3.15.2).

1. Si el acreedor pretende iniciar la acción de cobro antes del cumplimiento del plazo, incurre en *plus petitio tempore*, lo que determina en la época clásica y hasta que ocurran las reformas bizantinas, que perdiera el juicio.

2. Si el deudor quiere pagar antes de cumplido el plazo puede hacerlo (Cels., D.46.3.70). Pero una vez efectuado no puede intentar repetir lo pagado alegando que el pago se produjo por error (Paulo, D.12.6.10).

b) Una vez cumplido el plazo, el negocio se considera totalmente exigible. El cómputo del plazo se realiza una vez cumplido totalmente el último día del término, es decir, es exigible el día siguiente, puesto que hay que dejarle al deudor la discreción de dejarle el término completo (Inst., 3.15.2 *in fine*).

1. En el caso de que el promitente de una *stipulatio* se haya obligado a dar "en los días de tal feria", Sabino opinaba que se debía desde el primer día de dicha feria; en cambio, la opinión prevaleciente fue la de Próculo y los otros de su escuela, que no se podía exigir mientras quedara aún un pequeño lapso de feria (Venuleyo, D.45.1.148 pr.).

2. Incluso, si alguien ha prometido que hará una casa en un lugar dentro de los dos años, y aproximándose el vencimiento del plazo existe la razonable seguridad de que la casa no se edificará, hay que esperar para exigir lo debido el cumplimiento de los dos años, porque el término establecido no se cambia por un hecho posterior (Pap., D.45.1.124).

Si se tratara de un *iudicium bonae fidei*, si el acreedor tiene motivos para inquietarse acerca del cumplimiento de la obligación, puede pedir, antes del vencimiento del plazo, una caución (Pap., D.5.1.41).

§ 313. C) Modo. Se entiende por "modo" (*modus*) una carga impuesta a una persona beneficiada por un acto de liberalidad (legado,

donación, manumisión). Así, p.ej.: "Que mi heredero le dé a Ticio el fundo Tusculano, y que en él erija un monumento en mi memoria" (v. Javol., D.35.1.40.5), o dejarle al legatario 1.000 para que compre un esclavo ajeno y lo manumita (Ulp., D.40.5.7).

A diferencia de la condición, el beneficiario de la liberalidad no queda en suspenso. Así, el legado *sub modo* es exigible inmediatamente, si bien queda obligado a tener que cumplir el cargo ordenado, dando caución de ello al heredero (Valens, D.32.19).

1. En el derecho clásico, lo normal era asegurarse el cumplimiento del modo mediante una *cautio* (Jav., D.35.1.40.5). Si se trataba de una donación, se podía incorporar un *pactum fiduciae* a la *mancipatio*, o bien celebrar una *stipulatio*.

Si no se cumplía el cargo, se podía ejecutar la *cautio*, y también se otorgaba una acción de reintegro de la cosa dada (*condictio ob rem datorum*); Alejandro, C.4.6.2.

Si el modo consistía en una prestación a un tercero, en ciertos casos, se le puede conceder a dicho tercero una *actio utilis* para exigir la prestación (Diocl., FV 286; C.8.54.3).

2. Justiniano favorece el derecho del beneficiario del modo, otorgándole para su cumplimiento la *actio praescriptis verbis* (C.8.53.9 itp.).

A su vez, si un donatario no cumple la carga impuesta, el donante tendrá, para recuperar lo donado, además de la *condictio ob rem datorum*, una *rei vindicatio utilis* (C.8.54.1 pr. itp.).

VI. Representación en los negocios jurídicos.

§ 314. En el Derecho moderno y actual se acepta plenamente la idea de la representación. Consiste en que la celebración de un negocio jurídico se pueda llevar a cabo "en nombre y por cuenta" de otra persona, de tal modo que los efectos del negocio recaen directamente en ésta.

En Roma no existió esta idea de representación directa, utilizando otras vías ya para adquirir cosas o contraer obligaciones mediante la utilización de otras personas. No es la "representación directa" (actuar en nombre del representado), sino "indirecta" (actuar por cuenta del representado), tal como ocurre con la figura del mandatario (*infra*, § 439).

A) Caso de adquisición para el paterfamilias. El pater adquiere no solamente por actos realizados personalmente por él, sino también por intermedio de todos los integrantes de su familia que estén en *potestate* (así, los *filiifamiliae*, la *uxor in manu* y los esclavos; Gayo, 2.87-94; 3.163-167a).

1. Esto se explica, sin necesidad de hablar de representación, por la constitución misra de la familia romana. Los *alieni iuris* que la integran no tienen patrimonio propio (sin perjuicio de que pueden tener un *peculio*). Por tanto, son considerados como "instrumentos animados", "brazos largos" del pater, y en consecuencia todo aquello que obtengan ya por los actos formales o informales jurídicos, no lo adquieren para sí, sino que ingresan en el patrimonio familiar cuyo titular es el paterfamilias.

Así, pueden adquirir la propiedad o la posesión. Para el caso de una herencia, dado que se trata de una universalidad compuesta por bienes y obligaciones, se necesita la previa autorización del pater, y una vez aceptada, es como si éste fuera el heredero.

2. En cambio, en la época clásica, el pater no puede adquirir por medio de hombres libres que no estén como *alieni iuris* suyos (*per extraneam personam nihil nobis adquiri posse*; Gayo, 2.95).

Sin embargo, ya para el propio Gayo, aunque según él discutido, se puede adquirir la posesión por medio de un *procurator*, es decir, una persona a quien el pater encarga la administración de sus bienes (Gayo, 2.95). Esta posibilidad de adquirir la posesión por medio de otro será admitida por Neracio (D.41.3.41). Y será confirmada por una constitución de Severo y Antonino (C.7.32.1, año 196), en la cual se habla de *ratione utilitatis* (Paulo, C.1.2, *utilitatis causa*), aun cuando resulte ignorada por el beneficiario pero siempre que luego reconozca la adquisición. Todo esto es luego reconocido por Justiniano (Inst., 2.9.5).

En cambio, el *procurator* no puede adquirir la propiedad, salvo que ésta resulte como efecto de la posesión, vía *usucapio* o *longi temporis praescriptio* (C.7.32.1; Inst., 2.9.5). E incluso, para los bizantinos, se extiende también para el caso de que mi *procurator* hubiera comprado por mi mandato una cosa y se le hubiese hecho tradición de ella en mi nombre, adquiero la propiedad de ella, aun cuando lo ignore (Neracio, D.41.1.13; Ulp., D.41.20.2; Neracio, D.41.3.41 itps.).

3. En cuanto al tutor, se admitió que podía adquirir para el pupilo la posesión y la propiedad de las cosas, al igual que ocurre con el *procurator*. Ello pudo quizá ocurrir en la propia época clásica si es que el texto de Neracio (D.41.1.13.1) no está interpolado.

B) Caso de obligaciones a cargo del pater: El principio general del *ius civile* consiste en que sólo responden de las obligaciones las personas que las contrajeron. Quienes administran los negocios de otro, ya sea por ser un tutor o un curador, o por encargo directo —sea un mandatario o *procurator*— o por haber realizado una gestión útil —gestor de negocios—, si bien obran en interés ajeno, son en principio los responsables. La responsabilidad del "dueño del negocio"

se tratará como una relación interna entre éste y quien actuó en su interés.

Sin embargo, el pretor admitirá, en determinados supuestos, que por los negocios realizados por un *filius* o un esclavo suyo, se pudiera accionar directamente al *pater*. Es el caso de las *actiones adiecticiae qualitatis**. Pero esta responsabilidad "añadida" no significa la aceptación de la representación directa. El *pater* no responde en lugar de la responsabilidad del *alieni iuris* que obró como su agente, sino junto a ésta.

En el procedimiento judicial se admite que una o ambas partes puedan nombrar a alguien para que actúen en nombre de ellas. Es el caso del *cognitor** y del *procurator**.

VII. Ineficacia de los negocios jurídicos.

§ 315. Los juristas romanos, sin llegar a estructurar una teoría de la ineficacia de los actos y negocios jurídicos, establecieron, siguiendo los casos concretos, una terminología bastante imprecisa, la cual servirá luego como precedente del derecho posterior.

1 La doctrina moderna y actual hablará de casos de "nulidad" y de "anulabilidad", así como de "nulidad absoluta" y "nulidad relativa". En nuestro Código Civil se habla de "acto nulo" y de "acto anulable". El primero es cuando la invalidez aparece bien manifiesta, no necesitándose ninguna investigación para determinarla. Es en cambio "anulable" cuando la invalidez no aparece inmediatamente, sino que es necesario un examen o investigación para determinarla. Igualmente se habla de "nulidad absoluta" (cuando ella interesa al orden público y no podría nunca ser convalidada) y de "nulidad relativa" (cuando la invalidez interesa únicamente a una parte, la cual podría ratificar y confirmar el acto).

En Roma, la terminología no es tan precisa:

A) Para el *ius civile*, el acto ineficaz de manera absoluta es calificado de *nullum nullius momenti* (nulo en todo instante) o mera-

mente *nullum o inutile*. Ello ocurría (a) si no se habían realizado las solemnidades requeridas: así, p.ej., en una *mancipatio**, en una *stipulatio** o en testamento; (b) también cuando el acto o negocio ha sido prohibido por la ley y sancionado con la nulidad (*lex perfecta**; así, p.ej., actos realizados en contra de lo dispuesto por la *lex Aelia Sentia**); igualmente si por su naturaleza el acto es inmoral (*contra bonos mores*). En estas circunstancias, el acto o negocio carece totalmente de efectos.

B) Para el *ius praetorium*, no solamente existe esta "nulidad absoluta", sino que además permite que aun siendo el acto válido en principio, el demandado pueda alegar por alguna causa admisible su invalidez. En estos casos, el magistrado o denegará la *actio* (*denegare actionem*) o le concederá al accionado una *exceptio** o una *in integrum restitutio**. Con ello el acto o negocio queda invalidado. Se trataría acá de actos "anulables" de "nulidad relativa", por cuanto la causa de invalidez debe ser planteado por la parte.

1. Así, si se trata de una *stipulatio* donde el estipulador pregunta: "¿Me prometes dar 100 para que injurie a Ticio?", el acto es inmoral e inválido ("nulo") para el *ius civile* (Pomp., D.45.1.26-27). Pero si de la *stipulatio* lo único que surge es la promesa de pagar una suma de dinero, sin indicarse la causa, el negocio en principio es válido, pero suponiendo que la causa jurídica fuera inmoral, el pretor denegará la acción o le concederá al demandado una *exceptio doli*, si probare dicha circunstancia ("acto anulable"; Paulo, D.45.1.184 pr.; D.12.5.3).

2. La invalidez o ineficacia es por regla general definitiva. Pero a veces se permite que la parte perjudicada "convalide" el acto (caso de "nulidad relativa"). Así, si un *pater* reconoce con posterioridad el mutuo de dinero contraído por su *filius* en contra de lo dispuesto por el *s.c. Macedonianum**.

Los diversos casos de invalidez y nulidad serán examinados en cada una de las instituciones y negocios concretos.

CAPÍTULO 2

LAS OBLIGACIONES

I. Concepto de obligación.

§ 316. La palabra "obligación" es muy usada en el lenguaje coloquial. Se habla de que alguien tiene una obligación moral, o social o religiosa. Acá debemos advertir que la obligación jurídica tiene un sentido más fuerte y vigoroso. Sobre todo porque, a diferencia de estos otros casos, lo propio de la obligación es generar una *actio* en virtud de la cual el acreedor pueda exigir judicialmente el cumplimiento de ella.

1. En la denominación de *obligatio* aparece la idea de una atadura (*ligatio*) que une a dos personas que son llamadas "deudor" (*debitor*) y "acreedor" (*creditor*). Entre ellas existe un "vínculo" (en latín *vincula* = cadenas). Para expresarlo se usan vocablos como *nectere* (ligar, anudar) o *adstringere* (constreñir). A su vez, la extinción de una obligación es un *liberare* (liberar) o *solvere* (disolver, de ahí = pagar).

2. Esto se ve muy bien desde los comienzos de Roma. El negocio más antiguo para obligarse es el *nexum*. Si bien no lo conocemos totalmente, sabemos que se trataba de un negocio *per aes et libram*, igual que la *mancipatio*, pero a diferencia de ésta, que es un rito de adquisición de *potestas* sobre una cosa o una persona, el *nexum* opera efectos obligacionales. Se trataba de una "automancipación" que el deudor hacía de su persona, en garantía de que iba a pagar la obligación. Ello habla del vigor y de la importancia de lo que significaba obligarse en el derecho antiguo. Está conectada con la vía ejecutiva de la *manus iniectio**, que precisamente permitía, en caso de no satisfacción del acreedor por el pago de lo debido, en la reducción a la esclavitud.

3. Todo esto explica el carácter tan fuerte de *personalización* que tenía la obligación en Roma, lo cual será un inconveniente para la "cesión de créditos" y de "deudas", procedimientos sólo admitidos en forma muy lenta y pausada en el devenir histórico del derecho romano (v. *infra*, § 492 y ss.).

§ 317. Definición de obligación.

I. En las Institutas de Justiniano (3.13 pr.) se nos da la más conocida de las definiciones de *obligatio*: "vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de tener que pagar alguna cosa según el *ius* de nuestra *civitas*" (*iuris vinculum*,

quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura).

1. Se suele decir que en esta definición no figura el *creditor* (acreedor), lo cual no resulta totalmente cierto, puesto que tácitamente está, ya que no nos podemos deber nada a nosotros mismos; en consecuencia, lo que se debe, se debe a alguien, que es el "acreedor".

Al contrario, esta definición representa técnicamente la descripción del *status* en que se halla el *obligatus*. Éste se halla "atado", "constreñido" en una "necesidad", la de pagar algo. De ahí que los vocablos empleados se refieren casi con exclusividad a la situación del deudor: *dare debere* (deber dar; Gayo, 2.202; Javol., D.35.1.40.1; Celso, D.36.1.2; etc.); *facere debere* (deber hacer; Gayo, D.19.2.25.3; Ulp., D.25.3.1.15; D.7.1.13.4; etc.); *praestare debere* (deber prestar; Alf., D.9.2.52.3; Javol., D.12.2.52.3; Ulp., 38.2.7 pr.). Y también, en general, *obligatus esse* (estar obligado) y *dare facere praestare oportere* (tener obligatoriamente que dar, hacer y prestar).

2. De este modo, en los textos se da mayor relieve al aspecto pasivo del deudor, puesto que él es quien debe realizar la finalidad jurídico-económica de la obligación. Esta actividad es exclusiva suya, mientras que el acreedor no desarrolla, mientras exista la obligación actividad alguna. Indudablemente que el acreedor tiene un interés preciso en el cumplimiento, razón por la cual el *ius*, frente al incumplimiento del deudor le concede una *actio*.

Por ello, no resultaría estrictamente romano definir la *obligatio* como el "derecho de crédito", es decir, el "derecho subjetivo patrimonial que tiene el acreedor sobre el deudor para que éste tenga que darle algo". El concepto de derecho subjetivo es netamente moderno y extraño a la mentalidad romana. El acreedor tiene un interés, pero éste no aparece sustancialmente como un "derecho", sino como una expectativa que en último caso es protegida procesalmente (*actio*). Este interés puede ser concebido simplemente como un "crédito" como término correlativo del *debitum* del deudor.

Por esta circunstancia, los vocablos que se refieren al "acreedor" son más bien ocasionales. En la época clásica existen expresiones como *creditor* (préstamo) o *res creditae* (cosas prestadas), tal como se ve en la denominación de la *actio* (*condictio*) *certainae creditae pecuniae*. También existe *ius obligationis* (Ga-

yo, 2.14). Pero no significa "derecho de crédito", sino que se refiere a la *res incorporalis* que es la *obligatio*, así como *ius successionis* no es el "derecho a suceder", sino la *hereditas* en sí misma. A su vez, *adquirere obligationem* significa "hacerse acreedor y no deudor" (Jul., D. 23.2.46 pr.; D. 45.1.56.2; Ulp., D. 46.3.22; etc.).

En textos interpolados encontramos la expresión *ius crediti* (Calist., D. 48.7.7; D. 4.2.13; Ulp., D. 4.2.12.2), que tienen un cierto aire de "derecho de crédito", pero que también pueden entenderse como *ius creditoris* (posición justa de acreedor), en el sentido de poder reclamar una *actio*.

3. La expresión final *secundum nostrae civitatis iura*, hace referencia a que la expresión *obligatio* era propia del *ius civile*. Sobre "obligaciones pretorianas" v. *infra*, § 320.B.3.

II. Hay otra definición, que es de Paulo (D. 44.7.3 pr.), según la cual "la sustancia de las obligaciones no consiste en que se haga nuestra una cosa, o una servidumbre, sino en que otro se constriña hacia nosotros, a darnos, a hacernos o a prestarnos alguna cosa".

1. Aquí, la definición, acusada de interpolación, se concentra en distinguir dos aspectos en la obligación, los cuales son:

a) el "constreñimiento" en sí mismo, es decir, la *actio*, el deber, o como lo dice la moderna doctrina alemana el *Haftung* (= responsabilidad); y
b) la "deuda", es decir, "lo debido, el *debitum* o la *Schuld* de los alemanes.

2. Esto tiene importancia en las obligaciones nacidas de negocios formales en la época antigua. Así, en la nacida del *nexum*, no bastaba meramente pagar la "deuda", sino que para extinguir la "responsabilidad", era necesario realizar un rito especial: la *solutio per aes et libram**, forma que se aplica para la extinción de otras obligaciones (Gayo, 3.173-175). Lo mismo ocurre con la obligación nacida de la *sponsio stipulatio*. No bastaba pagar para quedar desligado; era necesario realizar un acto ritual contrario: la *acceptilatio*.*

En la época clásica, en cambio, el mero pago es la forma normal de extinguir la obligación. La *acceptilatio* es una forma general de remitir la deuda nacida de una *stipulatio*.

§ 318. Elementos de la obligación. En la obligación deben existir:

a) Las partes, es decir un "acreedor" y un "deudor". Ambos deben ser distintos, ya que si la misma obligación recayera en la misma y única persona, se daría el caso de "confusión" y ello arrastraría la extinción de ella. Así, A debe 100 a B, pero luego A instituye heredero a B, por lo que ésta sería acreedor y deudor de sí mismo.

Pueden existir pluralidad de acreedores o de deudores, pero dejando a un lado la situación interna que exista entre ellos, y la nacida entre acreedores y deudores, siempre se considera que hay una parte acreedora y otra deudora.

b) El vínculo de constreñimiento en que se halla el deudor. Este constreñimiento se hace efectivo por medio de una *actio in personam* (llamada a veces *condictio*).

c) La "prestación", que es el *debitum*, es decir, lo debido. Ésta debe consistir en un "dar" (*dare*), en un "prestar" (*praestare*) o en un "hacer" (*facere*).

La expresión *dare* se refiere al traspaso al acreedor de la propiedad u otro *iura in re aliena* sobre una cosa. También el tener que realizar servicios o trabajos (*dare operas*).

1. *Dare* tiene propiamente el sentido de que el deudor debe hacer que una cosa "se haga nuestra" (*ut nostrum fiat*; Gayo, 4.4). Así, el heredero debe cumplir el legado *per damnationem*, haciendo que ésta sea del legatario, si se trata de una *res mancipi*, por medio de una *mancipatio** o de una *in iure cessio**, entregándole la posesión, o por medio de una *traditio*, si se trata de una *res nec mancipi* (Gayo, 2.204). Igualmente si se trata de una *stipulatio*, en la cual el promitente se obligó a dar un fundo (*dare fundum*; Ulp., D. 45.1.75.10).

2. También consiste en un *dare* la constitución de un usufructo (Gayo, D. 7.1.3 pr.: *dare usufructum*), un uso, o una servidumbre.

3. Finalmente, el realizar determinados servicios. Así, la prestación de servicios, p.ej., por parte de un liberto (*dare operas*; Pomp., D. 38.1.8 pr.; D. id. 10 pr.). En cambio, si no se trata de "trabajos" (locación de servicios), sino de realizar una "obra" determinada (*opus*; locación de obra), la obligación consiste en un *facere*.

Facere hace relación con todo acto que implique un comportamiento determinado, incluso el abstenerse (*non facere*).

2. En D. 50.16.218 se nos da un sentido muy amplísimo de *facere*: "Comprende absolutamente toda causa de hacer, de dar, de pagar, de entregar dinero (*numeratio*), de juzgar y de andar". Pero el texto atribuido a Papiniano se considera interpolado.

El sentido propio de *facere* es más restringido, abarcando un comportamiento en conexión con un resultado final preestablecido. Así, si se ha estipulado la tradición de la posesión vacua de una cosa, o hacer una fosa, o construir un edificio (Ulp., D. 45.1.72 pr.; D. id. 75.7).

Precisamente tiene su importancia en la compraventa, ya que la obligación del vendedor no es un *dare* (constituir la propiedad en el comprador), sino en hacerle la *traditio* (considerada un *facere*) para

otorgarle el *lucere habere* (poder tener lícitamente la posesión).

3. También puede consistir en un "no hacer" (*non faciendo*), como, p.ej., "que no me sea lícito tener el esclavo Stichus" (Ulp., D. 45.1.75.7); o "que no cometáis dolo" (Paulo, D. 45.1.83 pr.).

Praestare significa en general el contenido de una obligación, esto es, la "prestación", aplicándose a veces en forma más restringida, en forma autónoma, para los casos en los cuales no hay propiamente un *dare* o un *facere*. Como, p.ej., cuando se garantiza algo ("prestar caución").

4. En algunos textos se habla de *praestare* en sentido muy genérico, comprendiendo al *dare* o al *facere*, es decir, hablando ampliamente de la "prestación" (así, Gayo, 2.202; D. 4.5.8; Javol., D. 24.1.50; Neracio, D. 17.1.35; Pomp., D. 17.2.60 pr.; etc.).

5. Pero con sentido más preciso y autónomo, atendiendo a su etimología (*praestare*) significa "constituir fiadores" y en general "garantizar". Así, garantizar el "peligro" (*periculum*) de una cosa (Jul., D. 23.3.46; Pomp., D. 25.10(11)), o la ausencia de dolo o de culpa, o el cuidado especial de la "custodia" (Pomp., D. 24.3.9; D. id. 67; Pomp., D. 26.7.17).

Y también se habla de *praestare* con el significado de resarcir el daño. Así, por la venta de una herencia (Javol., D. 18.4.8), o por la evicción* (Ner., D. 21.2.48), o en el condominio o en la sociedad (Jul., D. 10.3.25); etc.

Estas tres formas que puede asumir la prestación conforman todas las posibilidades de contenido de las obligaciones. Precisamente, lo típico de una *actio in personam* es que figura en la *intentio* de la fórmula la expresión *dare facere praestare oportet* (que se deba dar, hacer o prestar: Gayo, 4.2).

II. Clases de obligaciones.

§ 319. *Obligatio y actio*. Las obligaciones en Roma, sobre todo en el derecho antiguo y clásico, resultan individualizadas por las acciones que sirven para obtener su efectividad. De ahí que existe una conexión muy estrecha entre *obligatio y actio*. Ambas, una como causa y la otra como efecto, son dos términos correlativos, ya que una implica la otra. Precisamente, los dos títulos del Digesto (44.7) y del Código (4.10), consagrados a esta materia llevan el nombre *De obligationibus et actionibus* (Sobre las obligaciones y las acciones).

1. Cada obligación reconocida por el *ius civile* o amparada por el *ius praetorium* (u *honoraryum*) está asegurada por la existencia de una *actio*. La fórmula

respectiva está cuidadosamente redactada, pudiendo deducirse fácilmente la causa y el contenido de la obligación, y también contiene con precisión los distintos supuestos de la condena.

2. El número de las acciones con sus respectivas causas obligacionales es un "número cerrado" (*numerus clausus*). Las partes no pueden crear una obligación que no esté asegurada por una *actio*.

Este carácter cerrado se ve atenuado, por un lado por el fácil empleo de la *stipulatio*, que como promesa de pago permite fácilmente tornar obligatoria una prestación siempre que no sea ilícita o inmoral. Y por el otro, por la *potestas* de los pretores, que frente a un caso de obligación que no esté incardinada en el Edicto, podían otorgar, si la situación merecía amparo jurídico una *actio in factum*.

3. En el período posclásico, al desaparecer el procedimiento formulario y resolverse las cuestiones por la *extra ordinem cognitio*, se produce un resquebrajamiento del "número cerrado" de acciones, y en consecuencia de las obligaciones. Con Justiniano se trató de volver al sistema clásico, pero su aspiración fue más formal que sustancial, por cuanto se admitieron acciones nuevas surgidas de la misma naturaleza del negocio.

§ 320. Obligaciones civiles y obligaciones honorarias.

A) En principio, las obligaciones admitidas fueron aquellas establecidas según las formas y en los casos reconocidos por el *ius civile*. Dan nacimiento a una *actio civilis*. Están comprendidas no solamente las del antiguo derecho, sino también las admitidas con posterioridad por el propio *ius civile*, como p.ej. las obligaciones de buena fe, que dan lugar a un *iudicium bonae fidei*.

1. Algunas de estas obligaciones son consideradas de "derecho estricto", ya que son interpretadas de manera rigurosa y estricta por medio de una *actio stricti iuris**. Así en el caso de las obligaciones derivadas de la *stipulatio** y del legado *per damnationem**. La fórmula contiene la *intentio* redactada como *dare facere praestare oportet* (Que se deba dar, hacer o prestar).

2. En cambio, otras son consideradas "de buena fe". Dan lugar a un *bonae fidei iudicium**, que se caracteriza por cuanto se faculta al *iudex* para condenar por "todo aquello que el demandado deba al actor según los dictados de la *bona fides* (*quidquid dare facere oportet ex fide bona*). Puede, por tanto, examinar con libertad cuestiones como los intereses, los frutos, la compensación de créditos, así como las conductas dolosas, etc. Ello ocurre, p.ej., en negocios provenientes del *ius gentium*, admitidos por el *ius civile*, como la compraventa, la locación, la sociedad y el mandato, pero también en obligaciones

nacidas de negocios propiamente romanos, como la *fideiucia**, la tutela* y la dote* (*rei uxoriae**).

B) Las obligaciones "pretorias" son aquellas situaciones que se tornan exigibles por una *actio in factum* admitida por el pretor. También son llamadas "honorarias" (vocablo más amplio, ya que también fueron creadas por los ediles curules).

1. Se trata de casos en los cuales el magistrado, por razón de equidad, extiende bajo la forma de acciones útiles, analógicamente, formas de obligaciones que según el *ius civile* estricto no contarían con acción. Así, a veces se emplea la ficción de un elemento pedido por el *ius civile* (acciones ficticias*).

2. También son utilizadas para reprimir conductas dolosas. E incluso, en algún caso (como la *negotiorum gestio** y el depósito), la acción es *ex fide bona*.

3. Se ha destacado por parte de la doctrina que la *obligatio* es en la época clásica una institución exclusiva del *ius civile*, señalada por la expresión *dare facere praestare oportere*. En cambio, cuando el pretor amparaba al beneficiario de una situación obligacional se evitaba hablar de *obligatio* empleándose en cambio la expresión *actione teneri* (estar sujeto a una acción).

Se entendía que así como el pretor no puede crear un dominio distinto del *dominium ex iure Quiritium*, aunque sí proteger al que tenía cosas *in bonis** (llamada "propiedad bonitaria"), ni crear herederos, aunque sí proteger a los *bonorum possessores** (no la *hereditas* sino la *bonorum possessio*), tampoco puede crear obligaciones, aunque sí proteger por acciones determinadas situaciones obligacionales.

Sin embargo, hay textos, algunos interpolados, donde se habla de obligados pretorianos, donde se emplea *obligatus*; Gayo, 4.172; Ulp., D.46.1.8.2; D.2.15.4.1; Paulo, D.4.5.7.2; D.4.2.17; etc. En la época justiniana, al no existir el procedimiento formulario, esta diferencia carece de sentido.

Este problema quedó fijado, pese a ello, en la definición de *obligatio* (Inst., 3.13 pr.), donde la expresión final *secundum nostras civitatis iura* (según los derechos de nuestra civitas), haría referencia directa al *ius civile*.

§ 321. *Obligaciones naturales*. Tal como lo señalamos, existe una correlación entre *obligatio* y *actio*. La obligación propiamente dicha es aquella que está amparada por una acción. Sin embargo, en el siglo II d.C., a partir de Juliano, se hablará de "obligación natural" (*naturalis obligatio*) para designar ciertas obligaciones que carecen de acción, o de ejecutividad, pero que no obstante ello, producen ciertos efectos jurídicos.

1. El origen de estas obligaciones naturales parece haber nacido de las relaciones intrafamiliares. Así, la contraída por un esclavo, o por un *filius* o una *filia*, ya con un extraño o entre los hermanos o con el *pater* (Africano, D.12.6.33).

Gayo (3.119a) menciona en forma aislada el caso de las deudas de los esclavos, que fue quizá el caso más antiguo en la época clásica. El esclavo es incapaz de ser deudor respecto de su *dominus*, así como también en relación con un extraño. Si un esclavo promete algo a alguien no podía por ello obligarse civilmente, ni tampoco ser demandado ya que no podía actuar en justicia. Se entendía que era una *obligatio naturalis* (Ulp., D.47.7.14). Solamente en el caso de que el esclavo gozara de un *peculio*, los acreedores podían dirigir una *actio de peculio**, hasta el monto del mismo contra su *dominus*.

La *filia* y la *uxor in manu* tampoco se pueden obligar civilmente ni ser demandadas. En cambio, un *filius* podía obligarse. Incluso hasta podían ser demandados y condenados en un juicio, pero la ejecución del mismo carece de sentido, pues no tiene patrimonio. Se podía aquí hablar también de obligaciones naturales. Si los *filifamiliae* poseían un *peculium profectium*, los acreedores podían dirigir la *actio de peculio* contra el *pater*, hasta el importe del mismo. Pero si detentaban un *peculium castrense**, respecto del mismo se podía obligar civilmente y podían ser ellos mismos demandados, condenados y ejecutados por su monto (Gayo, D.5.1.4).

2. Luego, el número de obligaciones naturales se fue ampliando. Así se incluye el caso del *sui iuris* que por una *capitis deminutio* se ha hecho *alieni iuris* (Ulp., D.4.5.2.2). E igualmente, según una opinión mayoritaria, las obligaciones contraídas por el pupilo sin la *auctoritas* de su tutor (Pomp., D.46.1.2; Paulo, D.12.6.13.1; en contra, Licinio Rufo, D.44.7.58). Y la obligación extinguida por la *litis contestatio* (Jul., Paulo, D.12.6.60 pr.).

3. Posteriormente, en la época posclásica, se admiten otros casos: así, si un *filius* ha contraído un mutuo, en contra del s.c. Macedoniano* (Marciano, D.12.6.40 pr.; Paulo, D.14.6.10* itps.), o la obligación nacida de un simple pacto de pago de intereses (Ulp., D.46.3.5.2 itp.).

Los propios juristas admiten que sólo en forma abusiva se puede hablar aquí de "obligación" (Jul., D.46.1.16.4; Ulp., D.15.1.41). Pese a ello, estas obligaciones naturales producen los siguientes efectos:

a) Si el deudor paga lo debido, no puede repetir por la *condictio indebiti* dicho pago (Jul., D.46.1.16.4, Pomp., D.12.6.19 pr.).

b) Un crédito "natural" puede oponerse como compensación* a una obligación civil (Ulp., D.16.2.6).

c) Una obligación "natural" puede convertir-

se, por una novación*, en una obligación civil (Ulp., D.46.2.1.1).

d) Puede ser garantizada por una fianza, prenda o hipoteca (Jul., D. 46.1.7; D. id. 16.3; Marciano, D.20.1.5 pr.).

e) Es tenida en cuenta a los efectos del cómputo de la herencia y del *peculio* (Ulp., D.15.1.9.2; Pap., D.46.3.95.2).

1. En la época de Justiniano, se admitían las llamadas "obligaciones naturales impropias", entendiendo por tales aquellas motivadas por razones morales o de buenas costumbres. Así, si se prestan alimentos a ciertos parientes, sin estar obligado civilmente a ello (Mod., D.3.5.26.1), o si el liberto realiza obras a las cuales no está obligado (Ulp., D.12.6.26.12), o la constitución de una dote por una mujer que se creía obligada a ello (Jul., D.12.6.32.2). El efecto general es que pagada la obligación, no se puede repetir.

2. Un caso especial es el de las deudas de juego. Tal como se puede leer en el Digesto (11.5), el jugar por dinero estaba totalmente desacreditado. Más aún, estaba prohibido hacer apuestas por la ley Ticia, la ley Cornelia y un senadoconsulto desconocido, salvo en una competencia deportiva "para probar el valor" (Paulo, D. id.2; Marciano, D. id.3), o para los esclavos, jugando por la comida que se pone en la mesa (Paulo, D. id.4 pr.).

Por ser ilícita, no se puede reclamar entre los jugadores la deuda de juego, pero el que la pagó no puede repetir lo pagado. Esto se debe a que, por ser ilícito jugar, la acción es ilícita para ambas partes, estableciéndose que cuando haya dolo de ambas partes, resulta favorecido el que tiene la posesión de la cosa (*melius condicio est possidentis*).

Sin embargo, el *pater* tiene acción para reclamar lo perdido en el juego por un *filius* o un esclavo. Igualmente, se daba una acción contra el *pater* por lo que ganó el *filius* o el esclavo (Paulo, D.11.6.4.1-2).

En el Derecho moderno, en cambio, las deudas de juego se consideran "deudas de honor". Según A. d'Ors, (DRP, § 354) ello "refleja un determinado clima histórico-moral", y representa en los códigos uno de los principales ejemplos de obligación natural.

§ 322. *Clases de obligaciones por la prestación*.

A) *Obligaciones específicas y genéricas*. La prestación puede consistir en entregar una cosa perfectamente determinada (*species*), como p.ej. el esclavo Stichus, o cosas indeterminadas dentro del mismo género (*genus*), como, p.ej., un esclavo, tantas tinajas de vino o de aceite.

1. Si se trata de una obligación específica, en caso de perecer la cosa que se debía dar por caso fortuito, el acreedor queda libre. Así, si se ha prome-

tido por una *stipulatio* entregar el esclavo Stichus y éste muere, el deudor nada debe (Pomp., D.45.1.33).

2. En cambio, si se trata de una obligación genérica, ésta no se extingue por caso fortuito. Se aplica el principio de que "el género o la cantidad nunca perece" (*Genus aut quantitas nunquam perit*). En efecto, si se prometido entregar un caballo, siempre tendrá la posibilidad de dar uno, aunque haya perecido aquel con el cual pensaba pagar. Pese a ello, si el "género" queda delimitado dentro de ciertas cosas, podría ocurrir lo contrario. Así, el dinero es un género, pero si yo prometiera pagar "ciertas" monedas, p.ej. las que tengo en una caja y éstas se perdieran sin culpa mía, nada debo (Paulo, D.45.1.37).

3. En una obligación genérica, el deudor tiene, salvo convención contraria, la libertad de elegir. En la época clásica, podía entregar cualquiera dentro del género: así, un esclavo, aun de la peor calidad (Javol., D.17.1.52). Justiniano, siguiendo algunos precedentes del derecho clásico imperial, establece que se debe entregar una cosa de calidad media, ni la mejor ni la peor (Ulp., D.30.37 pr. itp.; Afric., D. id.110 itp.).

B) *Obligaciones divisibles e indivisibles*. Esta clasificación sólo tiene relevancia cuando existen dos o más acreedores o dos o más deudores. Se habla de "obligación divisible" cuando ésta puede cumplirse o exigirse por partes o en forma fraccionada, sin alterarse su finalidad económica. Cuando no es así, se habla de "obligación indivisible".

En general, la obligación de *dare* es "divisible", puesto que la propiedad puede constituirse *pro parte*. Así, p.ej., Ticio debe dar el esclavo Stichus a sus acreedores A y B. No obstante que el esclavo es físicamente indivisible, el cumplimiento de la obligación se puede hacer *pro parte*, es decir, Ticio se puede liberar entregando la 1/2 a A y la otra a B, que lo tendrán en condominio (Jul., D.45.1.54). Pero no sería "divisible" cuando el *dare* es de un *ius* indivisible (p.ej., una servidumbre predial; Afric., D.8.3.32; Ulp., D.45.1.72).

Si se trata de un *facere*, p.ej. hacer un *opus*, así una casa, la obligación es indivisible. Pero si se trata de servicios que pueden dividirse por su número o medida (*dare operas*), la obligación sería "divisible" (Jul., D.45.1.54.1).

Las obligaciones indivisibles pueden ser exigidas por cada acreedor a cada deudor. Se comportan igual que las obligaciones solidarias, pero a diferencia de éstas, dicho efecto de reclamo *in solidum* no surge por el vínculo "solidario" sino por la naturaleza de la prestación.

C) *Obligaciones alternativas y facultativas*. Se entiende por "alternativa" la obligación cuya prestación consiste en dos o más cosas designadas disyuntivamente. Así, p.ej., "¿Prometes dar-

me el esclavo Stichus o el esclavo Pánfilus", de tal modo que el deudor cumple la obligación, eligiendo él, en principio, cuál de los dos dará. El efecto principal es que si uno de los dos esclavos, p.ej. Stichus, muere, es debido el otro. Si bien se puede aplicar a los legados y a las compraventas, la estudiaremos a propósito de la *stipulatio* (infra, § 387.d).

En cambio, en la llamada "obligación facultativa", la prestación es única, pero el deudor se reserva la facultad de liberarse entregando una cosa distinta. Principalmente se aplica en el caso de existir una condena en un juicio *noxal*. Así, por el delito de un esclavo responde su *dominus* y su obligación (*in obligatione*) consiste en pagar la suma de dicha condena. Pero tiene la facultad (*facultas solutionis*) de liberarse entregando al esclavo en *noxam*.

1. La llamada *facultas solutionis* es prácticamente extraña a las estipulaciones, y en general a los demás negocios romanos (ver, sin embargo, Paulo, D.44.7.44.5). Los autores modernos la emplearán con mayor asiduidad, sobre todo para señalar que habiendo una sola prestación *in obligatione*, de perecer ésta por caso fortuito, la obligación se extingue, ya que la *facultas solutionis* aparece para el deudor sólo para liberarse de la obligación.

§ 323. Clases de obligaciones por las personas intervinientes.

Cuando existan pluralidad de acreedores o de deudores, se pueden dar las siguientes formas de obligarse:

A) *Obligaciones mancomunadas*. Por lo general, siendo la obligación divisible, los créditos y las deudas se dividen de acuerdo con los diversos acreedores o deudores.

1. Así, si existen cinco deudores y un solo acreedor, siendo la deuda de 100, se podrá reclamar de cada uno de ellos la parte proporcional que les correspondía: en este caso 20.

2. También, si son tres los acreedores y uno solo el deudor, siendo la deuda por 90, cada uno de los acreedores podrá reclamar su parte proporcional: en este caso 30.

B) *Obligaciones solidarias*. En algunos casos, principalmente en una *stipulatio*, o en un legado *per damnationem*, se puede establecer que cada acreedor pueda exigir la totalidad de la prestación (*in solidum*) al deudor (solidaridad activa). O también, existiendo varios deudores y un solo acreedor, éste puede también exigir el total de la prestación a uno sólo de los deudores, cualquiera de ellos, y éste está obligado a pagar *in solidum* (solidaridad pasiva).

1. Así, hay tres acreedores y un deudor, siendo la deuda de 100. Cualquiera de los acreedores puede exigir del deudor, y éste está obligado, el total de los 100. Tras lo cual, una vez pagados, queda liberado.

2. Hay un acreedor y cinco deudores, siendo la deuda por 100. Dicho acreedor puede reclamar el monto total a cualquiera de los deudores. El pago efectuado extingue la obligación.

Las diversas circunstancias de las obligaciones solidarias, las veremos a propósito de la *stipulatio* (infra, § 389-390).

C) *Obligaciones cumulativas*. Un deudor se puede encontrar obligado a tener que pagar la entera prestación a dos o más acreedores. Esto ocurre, p.ej., a propósito de las acciones *poenales**, ya que habiendo una pluralidad de coautores, cada uno de ellos está obligado por el monto de la pena. Igualmente, en el legado *per damnationem** efectuado en forma *disiunctim*: Así, "Doy y lego el esclavo Stichus a Ticio; doy y lego el mismo esclavo a Seyo". El heredero cumplirá este legado dando a uno de los legatarios el esclavo, y al otro su valor (*aestimatio*).

D) *Obligaciones ambulatorias*. Son denominadas así, ciertas obligaciones que carecen, de momento, de un acreedor o deudor determinado. Ello puede ocurrir en los siguientes casos:

a) El daño producido por un animal, esclavo o *filius*, debe ser demandado al dueño o *pater* que lo fuera no en el momento de la comisión del daño, sino cuando se produce la *litis contestatio** (Gayo, 4.75-77; Inst., 4.8.5).

b) La obligación del enfiteuta, superficiario o propietario provincial de pagar el *tributum* o el *stipendium*, aun cuando la falta de pago sea debido a personas que estaban anteriormente en esa situación (Papirio Justo, D.39.4.7: "son demandados los mismos predios, no las personas"; Pap., D.50.15.5.2).

c) La obligación de restituir lo adquirido por violencia en la *actio quod metus causa*, que responsabiliza a cualquiera que haya obtenido la cosa, o haya obtenido provecho con ella (Ulp., D.4.2.9.8).

d) La obligación que incumbe al heredero de realizar una prestación en favor de terceros cuya determinación corresponde a un tercero (Inst., 2.20.25-27).

e) La obligación de reparar el muro en la servidumbre *oneris ferendi**, que corresponde al que sea propietario del edificio sirviente en el momento de ser pedida la reparación, pudiendo ser exigida por quien lo sea del edificio dominante (Ulp., D.8.5.6.2).

III. Fuentes de las obligaciones.

§ 324. Se entiende por "fuentes" de las obligaciones aquellos actos, negocios o situaciones de los cuales nacen las obligaciones. Aparte de otras, las clasificaciones que ejercerán una importancia decisiva en los autores medievales y modernos son las establecidas en las Institutas de Gayo y de Justiniano.

1. Gayo (3.88) nos dice que la "principal división (de las obligaciones) abarca dos clases: pues toda obligación nace o de un "contrato" (*ex contractu*) o de un "delito" (*ex delicto*).

1. Para F. Schulz (DRC., § 799), Gayo se habría inspirado en la lectura directa o indirecta de Aristóteles, cuando en su *Ética nicomaquea* (113a) habla de los negocios privados (acá emplea la palabra *synallagma*, dándole un sentido muy amplio) diciendo que de algunos surge "voluntariamente" una obligación (p.ej., la venta, el préstamo de dinero, la fianza, el préstamo de cosa, el depósito, el arrendamiento) y de otros que implican "involuntariamente" una obligación (a veces secretamente, como el hurto, o a veces por el empleo de la fuerza, como el homicidio o el robo).

2. Sea cierta o no esta referencia aristotélica, lo cierto es que esta clasificación gayana se corresponde perfectamente con la del filósofo griego. Para Gayo, hay ciertas situaciones en las cuales se busca voluntariamente "contraer una obligación" (*contrahere obligationem*), mientras que en otros, el que queda como deudor no la busca deliberadamente, pero ella se produce (caso de los "delitos").

3. Sin embargo, el mismo Gayo se encuentra con una duda, que plantea en 3.91, a propósito del "pago de lo no debido", es decir, cuando alguien por error paga algo que en realidad no debe, creyendo que existía una obligación. O también paga de más: debía 100 y paga 120. No había acá ninguna duda que el pretor concedía la *condictio indebiti*, por la cual se podía repetir lo pagado y no debido, o pagado de más. Esto fue así, salvo para las llamadas después obligaciones "naturales".

El problema para Gayo era que existiendo acá una obligación, su fuente no encuadraba en la bipartición que él había establecido. En efecto, no provenía de un "delito", pero tampoco directamente de un "contrato", ya que "aquel que da con ánimo de pagar quiere más bien extinguir que contraer un negocio (*contrahere negotium*).

II. En una obra posterior, atribuida a Gayo (*Res cottidianae sive Aurea* = "Asuntos cotidianos o Reglas de oro"), aparece una nueva clasificación, que amplía la anterior, al decir que "las obligaciones nacen o de un contrato, o de un delito, o por cierto derecho propio, según las varias figuras de causa (*ex variis causarum fi-*

guris)"; D.44.7.1 pr. De este modo, la clasificación pasa a ser tripartita, buscando con la expresión "varias figuras de causa", explicitar la insuficiencia que tenía la que había dado en sus Institutas.

1. También Ulpiano (D.44.7.25.1) nos presenta una clasificación de las acciones que tienen que ver con las obligaciones, y según la cual, unas nacen de un contrato (p.ej., compraventa, arrendamiento, etc.); otras de un hecho (acá involucra los delitos: p.ej., el *furtum* o el daño), y otras que son por el hecho (p.ej., la que tiene el patrono contra el liberto que lo ha citado en juicio en contra de lo dispuesto en el Edicto del pretor).

2. A su vez, Modestino en el párrafo de D.44.7.52 pr. —manipulado por los bizantinos— nos dice que "Quedamos obligados o por recibir una cosa, o por unas palabras, o por ambas cosas a la vez (o por escritura, aquí suprimido por los compiladores), o por el consentimiento, o por la ley, o por el *ius honorarium*, o por necesidad (del mismo *ius*), o por delito".

Los primeros casos hacen referencia a las situaciones contractuales referida por el mismo Gayo (obligaciones que se contraen *re, verbis, re et verbis* (*litteris, consensu*). A ello se agregan no sólo el delito (*peccatum*), sino también la "ley" (cuando hacemos algo preceptuado o en contra de lo preceptuado), lo que surge del *ius praetorium* (dejado extrañamente por los bizantinos) y la "necesidad" (como en el caso del "heredero necesario").

III. Finalmente Justiniano, distinguiendo más precisamente lo que Gayo denominaba *variae causarum figurae*, acerca algunas figuras al "contrato", denominándolas "como nacidas de un contrato" (*quasi ex contractu*), y otras al "delito" (*quasi ex maleficio*). De este modo, la clasificación se hizo cuatripartita: *ex contractu, ex maleficio, quasi ex contractu y quasi ex maleficio* (Inst., 3.13.2).

1. Igualmente, cabe agregar que para los bizantinos, una obligación puede surgir directamente de lo preceptuado por una *lex*, para lo cual se introduce la *condictio ex lege* (Paulo, D.13.2.1; D.44.7.41 pr., tps.).

2. Con la expresión *quasi*, empleada por los compiladores, se considera una aproximación de las obligaciones a las figuras del contrato y del delito. Pronunciadamente, como se ve en la Paráfrasis de Teófilo (3.27.3 y 4.5), la aproximación se hace más sustancial, ya sobre la misma causa de las obligaciones: de este modo, en forma muy sutil, el *quasi ex*, se sustantivizó, hablándose directamente de "cuasi contrato" y de "cuasi delito".

Esta última forma es la que pasará al derecho moderno, y representa la base sustancial de la sistemática actual.

§ 325. *Contrato*. La expresión "contrato" (*contractus*) conoce en su desarrollo histórico una interesante evolución. Podemos distinguir tres grandes momentos:

A) En un comienzo, la manera usual de obligarse era por medio de ritos muy específicos, que no son considerados propiamente contratos. Tal el caso del *nexum* (que exigía las formas *per aes et libram*), y el de la *sponsio** y la *stipulatio**. Aquí, lo estrictamente formal y solemne predomina sobre cualquier otro aspecto de fondo.

B) Ya en la época clásica se denota una mayor señalización de las causas eficientes de producir obligaciones por medio de un negocio. De este modo, junto a ciertas formas formales (caso de la *stipulatio* y de las *obligationes litteris*), las obligaciones también se pueden contraer por negocios no-solemnes (caso p.ej. del mutuo, o de los contratos consensuales). Sin embargo, el aspecto específico de cada contrato predominará sobre un concepto genérico, lo mismo que su consideración objetiva, sobre la subjetiva.

C) Finalmente, y sobre todo por la consideración de que todo contrato conlleva una convención, es decir, el consentimiento, el aspecto subjetivo de la voluntad de las partes tendrá, sobre todo en el derecho bizantino, una especialísima importancia.

De este modo, finalmente, la idea de contrato parece encaminarse a la reunión de cuatro requisitos: a) se trata de un negocio en el cual debe existir un consentimiento (*consensus*); b) tendiente a hacer nacer obligaciones; c) pero que tiene un *nomen* propio, basado en una causa específica; d) y es por ello que cada contrato está protegido por una *actio*.

1. Es curioso, pero el vocablo *contractus*, en el sentido jurídico de "contrato", no solamente no es usado por ninguno de los autores literarios ni historiadores de la época republicana ni primera época clásica.

Parece ser que el primer uso no jurídico del cual se tiene noticias es Varro (*de re rust.* 1.58): habla de las uvas, manzanas y frutos que cuelgan, diciendo que se sabe cuándo se las puede comer por el cambio de color y su "estado de disecación" (*contractu acinorum*). Y el más antiguo uso jurídico, lo encontramos en Aulo Gellio (*Noct. Att.* 4.4), quien hablando de Servio Sulpicio y de su libro de *dotibus*, aplica el vocablo a los *sponsalia*: *is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia* = "Se llamaban *sponsalia* cuando se contrajeron las estipulaciones y las *sponsiones*".

Pero obsérvese, dato significativo, que la expresión jurídica *contractus* no figura en el Edicto Perpetuo.

2. En latín, se conoce el verbo *contrahere* (contraer), haciéndose de él muchas aplicaciones: *contrahere*

frontem (contraer la frente), *membra* (los miembros), etc., o también *contrahere amicitiam* (contraer una amistad), o *odium* (odio).

Precisamente Gayo, que no era un jurisconsulto, sino un enseñante, para explicar a sus alumnos este problema de la fuente de las obligaciones, recurrió a la expresión *contrahere obligationem* (contraer una obligación). Y así, como para la otra fuente existía una palabra precisa (*delictum*; o *maleficium*), para hablar de las formas voluntarias de contraer una obligación, produjo un deslizamiento del *contrahere* al participio pasivo *contractum* (lo contraído), y de allí resultó fácil, como suele ocurrir gramaticalmente, el paso al sustantivo *contractus*.

3. Para esta época, estas expresiones están referidas al *negotium contrahere* (contraer un negocio), y *contractum*, lo mismo que *contractus*, no son sino formas elípticas de referirse al *negotium contractum* o *contractus negotii*.

Obsérvese que cuando Gayo se refiere a lo que comúnmente se entiende que son clase de contratos (3.89), en realidad está hablando de las "obligaciones contraídas" (*quae ex contractu nascuntur*) diciéndonos que "una obligación es contraída por la cosa (*re*), por palabras (*verbis*), por escrito (*litteris*), o por el consentimiento (*consensu*). Y luego no vuelve a hablar de "contrato", sino de que "la obligación se contrae [...]" (3.90: por la cosa; 3.92: por palabras; 3.128: por escrito; y 3.135: por el consentimiento).

De este modo, no surge directamente la importancia del *consensus*, cuanto el del vínculo obligatorio que se contrae. El sustrato objetivo del negocio es lo que tiene importancia, ya por las formas empleadas o por la causa que se denota. Desde este punto de vista es sintomático que el "consentimiento", aunque tácitamente presente, sólo esté subrayado para los "negocios consensuales", pero no para los demás. En la base del *contractus* está el elemento objetivo del *negotium contractum*.

Es por ello que lo que interesa es la presencia de la forma del negocio (caso de la *stipulatio*, o de las obligaciones *litteris*), o la causa por la cual nace la obligación (caso de las obligaciones reales: quedo obligado a devolver por aquello que he recibido, p.ej., en préstamo —mutuo—. Incluso hasta hay casos en los cuales el consentimiento parece faltar, o por lo menos no ser relevante: caso de la *dotis dictio* y del *iusiurandum liberti**, negocios en los cuales no hay una pregunta y una respuesta, como en la *stipulatio*, sino solamente la afirmación de obligarse del deudor.

4. Un párrafo importante es la cita de Labeón dada por Ulpiano (D.50.16.19), que no parece haber sido objeto de mayor manipuleo, por lo que se puede considerar genuina.

Se dice allí que algunas cosas "se hacen" (*aguntur*), como sucede cuando se hace por palabras (*verbis*), como en la *stipulatio*, o por la cosa (*re*), como en el mutuo. Y también acá debió de haber figurado por escrito (*litteris*) suprimido por los compiladores.

Otras "se gestionan" (*gerantur*), es decir, son hechas sin palabras (sería el caso de la "gestión" de negocios).

Y otras "se contraen" (*contrahantur*), y ello ocurre cuando "la obligación se contrata en forma reciproca, de uno respecto de otro (*contractum*... *multro citroque obligationem*), como ocurre, p.ej., en la compraventa, en la locación, en la sociedad (y debió haber agregado el mandato).

Esto significa que para Labeón, el concepto de "contrato" es aplicado de manera restringida, a los denominados "contratos consensuales", que son precisamente aquellos que los griegos denominaban propiamente *synallagma*, debido a que son negocios bilaterales de los que surge la reciprocidad de las obligaciones. Estos por ser "sinallagmáticos" son propiamente contratos.

5. Un hito importante en la evolución del contrato romano se puede ver en el análisis de la "convención", realizada en el título del Digesto sobre los pactos (*De pactis*; 2.14). Toda esta sección debió haber sido trabajada cuidadosamente por los bizantinos, pero quedan rastros de lo que debieron ser los textos genuinos.

Según nos lo dice Ulpiano, la palabra *conventio* es un vocablo genérico, ya que sirve para designar todo negocio, sea para celebrarlo o para transigir. Pero su elemento determinante es el "consentimiento", explicando que así como *con-venire* se dice de cuando dos o más personas acuerdan "venir" y encontrarse en un mismo lugar, así también en *consensus* hay un *con-sentire*, cuando por diversos movimientos del ánimo, se encaminan a un mismo parecer (D.2.14.1.3).

Y agrega la cita de Sexto Pedio, a la que califica de "elegante", según la cual "no hay ningún contrato, ninguna obligación, que no contenga en sí una *conventio*, ya se haga de obra o de palabra" (D.16.1.1).

De este modo, se da ahora la prevalencia a lo "subjetivo" del negocio, expresado en el *consensus*. Ciertamente es que el propio Gayo, cuando hablaba del problema del "pago de lo no debido", se expresaba acerca del *animus* del que paga, quien piensa más en extinguir que en contraer el negocio. Pero ahora es S. Pedio el que de una manera genérica, y no para un caso particular como en el mutuo, se refiere al *consensus* como elemento básico de todos los contratos.

6. Sin embargo, pese a la importancia dada al *consensus* por lo afirmado en el párrafo de Ulpiano, no hay que sacar conclusiones apresuradas. Los caracteres específicos de cada contrato continúan siendo importantes. Así, la caracterización de *obligari re, verbis, litteris*, sigue vigente, a los efectos de respetar las formas o la causa. Pese a la constatación genérica del *consensus*, los romanos continuaron observando que el sustrato negocial era ineludible de ser tenido en cuenta.

En cambio, una de las aplicaciones mayores que

dar la entrada a los contratos innominados de la *conventio*. Los que producen copia del contrato (*actus*), como p.ej. sociedad, etc. (Ulp.,

admitida con el *in alium contractum* una causa, lo mismo hay una causa que me dieras contrato innominado "synallagma" (Ulp.,

cepto de contrato es amplio que el *ayana* (*re, verbis*), las figuras de los

pre a acentuar el cual alcanza su en su Paráfrasis *entio* y *consensus* siones.

de contratos, si de los contratos en la mera *ex-sus*. Había siem-no hay causa no (Ulp., D.2.14.7.4). admitida por la *io*. Y además, las la que determina

la voluntad", so-ablecer cualquier romano, y menos gos modernos, de eden hacer nacer, r obligaciones. El se reduce a una odo que cada una mera convención

realizada por los os".

incipio, la pala-ficado de acuer-nervar los efec-ley de las XII delito de inju-ero, que sea el ubrió la injuria-or—, salvo que En efecto, *pac-*mente con *par*

(como "transacción" que pone fin a una controversia: *Festo, y pactonem*; Ulp., D.2.14.1).

c) En la época clásica, el *pactum* era entendido principalmente como un acuerdo entre el acreedor y el deudor, tendiente a demorar o dejar sin efecto la obligación. Así, un *pactum conventum* de otorgar un mayor plazo para el pago, o el *pactum de non petendo*, de no reclamar la deuda.

El pretor los admite, diciendo en el Edicto que "mantendré los pactos convenidos" (*Pacta conventa...servabo*; Ulp., D.2.14.7.7), pero no les otorga una acción, sino una excepción, ya que el "nudo pacto no produce obligación, pero produce excepción" (Ulp., D.2.14.7.4).

1. Así, si por el *pactum de non petendo*, el acreedor convino con el deudor no reclamar la deuda, si lo hiciera entonces el pretor protege a este último con la *exceptio pacti conventi* (excepción de pacto convenido; Paulo, D. 2.14.3.1; Gayo, 4.122).

2. Adviértase que el *pactum*, no productor de acción pero sí de excepción, se contraponen solamente a la *stipulatio*, que sí produce acción para el acreedor.

B) Un sentido especial tenían los pactos que se agregan a un negocio (*pacta adiecta*), tendientes a modelar los efectos de éste. Esto no debe verse como una excepción a la regla ya señalada de que el pacto sólo produce *exceptio*, ya que si produce acción, ésta no nace del pacto, sino del contrato al cual está agregado.

a) 1. En los negocios que dan lugar a una *actio stricto iure*, como la *stipulatio* o el mutuo, no se puede hablar en el derecho clásico de *pacta adiecta*. En el primer caso, la obligación está conformada por las palabras empleadas en dicho negocio, por lo que no existe eficacia de acción para los pactos convenidos fuera de dicha forma. Lo mismo ocurre con el mutuo, ya que su naturaleza implica que hay que devolver la misma cantidad de cosas, por lo que un pacto de usura (para que me devuelvas más dinero que el que he prestado, carece de efectos; Ulp., D.12.1.11.1). Para tornar válidos los intereses (*usurae*) es necesaria una *stipulatio*.

2. Sin embargo, los bizantinos, poniendo en primer lugar la vigencia del *consensus*, admitirán que se puedan agregar pactos en estos negocios. Así, respecto de la *stipulatio*, aprovechando la desvirtuación de este negocio realizada en la época posclásica (Paulo, D.12.1.40; D.2.14.4.3), y extendiéndolo al mutuo (Ulp., D.12.1.7).

Pero le establecieron un límite, admitiendo los pactos que eran favorables al demandado (*pacta pro reo*), manteniendo una actitud distinta respecto de los que agravaban la situación del deudor, tales como por lo general el pacto de intereses (Paulo, D.2.14.17

pr., Ulp., D.12.1.11.1). Sin embargo, admitieron la inserción en el mutuo de un *pactum pro actore*, como, p.ej., el pacto de solidaridad activa, que no hace a la naturaleza del mutuo y hubiera requerido una *stipulatio* (Paulo, D.45.1.71 pr.; C.4.25 pr., 9 y 12, itps.); y también el que permita al deudor hacer pagos parciales (Mod., D.22. 1.41.1).

b) 3. En cambio, los negocios que daban lugar a *iudicia bonae fidei**, podían gozar del agrado de pactos. Los *pacta adiecta* se consideran agregados al contrato respectivo.

Aquí, los romanos hicieron una distinción entre *pacta ex continenti* y los *pacta ex intervallo*. Los primeros son aquellos que formaban parte misma del contrato. Por tanto, pueden ser demandados con la acción respectiva. En cambio, los segundos son aquellos que se han convenido con posterioridad al negocio. Estos no daban lugar a una acción, sino solamente a una *exceptio* (Ulp., D.2.14.7.5). Se los considera como distintos al negocio en sí mismo.

4. Los bizantinos reelaboraron este tema en los *iudicia bonae fidei*. Establecieron así diferenciaciones entre *pacta ex continenti* y *pacta ex intervallo*, pero también entre *pacta pro actore* y *pacta pro reo*, y más aún entre pactos que "agregan algo" al contrato y pactos que le "quitan algo" (Pap., D.18.1.72 pr. itp.). Además, en general que entiende que los *pacti conventi* se comprenden (igual que para los clásicos la *exceptio doli*), en los *iudicia bonae fidei* (Ulp., D.2.14.7.5).

La idea central para los bizantinos está dada por la "naturaleza del contrato" (*natura contractus*), entendiendo por tal la caracterización que el *ius* le da a él. En general, se entiende que los *pacta ex continenti* hacen a dicha naturaleza, pero *ex intervallo*, el actor podía hacerlo cumplir con la acción y el demandado podía ampararse en una *exceptio*, siempre y cuando no afectara la "naturaleza del contrato" (p.ej., un pacto desligando las fianzas dadas), pero no mutando el precio de la compraventa; puesto que siendo ésta un elemento esencial del negocio, se altera todo el negocio, entendiéndose que habría una nueva compraventa (Pap., D.18.1.72 pr., Paulo, D.2.14.7.6).

C) Si bien la regla general fue la que los *nuda pacta* no producen obligaciones, sino excepciones, los bizantinos establecieron que podían existir pactos que dieran origen a una acción. Así, Paulo denomina *legitima conventio* la que se confirma por alguna ley, "y por tanto, a veces por el pacto hace o se pierde una acción, siempre que esté apoyado en ley o senadoconsulto" (D.2.14.6). Son los denominados "pactos vestidos" (*pacta vestita*).

1. Por un lado, el pretor admita que ciertos acuerdos o convenios gocen de la protección de una acción. Se los acostumbra denominar "pactos pretorios", pero esta terminología es desconocida por los juristas ni

tampoco se los presenta así en el Edicto. En realidad se trate de ciertas situaciones que el pretor consideró que debían ser protegidas mediante una *actio in factum*, otorgándoles determinados efectos *regies*.

Podemos mencionar entre ellas: a) el *pignus** o *hypotheca**, b) el *susciendum voluntarium** empezado en los juicios; el *constitutum** y los *recepta* (el *receptum argentarii**, el *receptum nautarum*, *cauponum*, *stabularium**, el *receptum arbitri**).

2. Los bizantinos denominarán *pactio legitima*, aquellos pactos protegidos por leyes (constituciones imperiales), entre los cuales podemos mencionar el *pactum dotis** y el *pactum donationis**, así como el compromiso arbitral*.

De este modo, cuando estamos en la época bizantina, nos encontramos que el cuadro contractual está genéricamente planteado sobre la base de la "convención", en la cual se destaca el *consensus**. Por un lado tenemos las convenciones "que pasan al nombre propio de un contrato" (compraventa, locación, sociedad, etc.). Por el otro, las convenciones "que no pasan a otro contrato" (es el caso de los "contratos innominados"). Y finalmente, tenemos que agregar la situación de los "pactos vestidos". Todo ello desdibuja mucho la idea clásica del contrato que pone en primer plano la relación jurídica sustancial. Pase a ello, no se afirma una idea plena de libertad contractual sobre la base del acuerdo de las partes.

1. Es indudable que con los bizantinos se ha producido una extensión de la idea de contrato. El mismo pacto será definido en términos muy cercanos al contrato: "Es pacto el consentimiento de dos o más sobre una misma cosa convenida" (Ulp., D.2.14.1.2 itp.). Pero por el otro lado se sigue afirmando que "cuando no subsiste ninguna causa, es sabido entonces que por la convención no puede constituirse obligación. Por consiguiente, el nudo pacto no produce obligación, sino que produce excepción" (Ulp., D.2.14.7.4).

2. Además, la propia idea de los "contratos innominados" está siempre basada en una causa, cual es

la de la dación de una cosa (Gayo, 2.14.48). Por eso, Aristón se permite hablar de *synallagma* (Ulp., D.2.14.7.2).

§ 327. *Quasi ex contractu*. Esta clase de fuentes de las obligaciones establecida por los compiladores, tiende a agrupar aquellos casos, ya protegidos en la época clásica por el pretor de situaciones parecidas a un contrato, pero donde falta el *consensus* entre las partes, pero de las cuales nacen obligaciones.

Justiniano menciona en sus *Institutas*: la "gestión de negocios" (*negotiorum gestio**; 3.27.1), la "tutela y curatela" (3.27.2), la comunidad incidental (3.27.3), el legado (3.27.5) y el pago de lo no debido (3.27.6).

§ 328. *Delitos y quasi ex delicto*. Estamos acá en presencia de actos ilícitos sancionados con una pena. Ésta es generalmente pecuniaria, y en favor de la parte que sufre el menoscabo delictual se otorgan acciones *poenales**.

Teniendo su fuente en el *ius civile*, las figuras delictuales fueron el *furtum*, la *rapina*, el "daño causado injustamente" (*damnum iniuria datum*) y las *iniuriae*.

Pero el pretor otorgó acciones *in factum* para sancionar determinadas conductas, que son consideradas "delitos pretorios". Dentro de ellos, tenemos el "dolo" (*dolus malus*), el *metus* (miedo o coacción). Igualmente, acciones *in factum* que eran de carácter penal, como: a) la llevada a cabo contra el *iudex* que obra dolosamente al pronunciar la sentencia (*si iudex litem suam fecerit*); b) contra quienes habían vertido o arrojado cosas a la calle (*actio de effusis et deiectionis*); c) contra quien tiene colocada o colgada alguna cosa en su casa, expuesta a una vía pública (*actio de posito et suspensio*); d) contra los navieros (*nautae*), fondistas (*cauponae*) y dueños de establos (*stabularii*) por hurtos y daños cometidos por sus dependientes.

Estos últimos casos serán considerados por los bizantinos para configurar la clase especial de los *quasi ex delicto* (v. *infra*, § 357, A-D).

CAPÍTULO 3 LOS DELITOS

§ 329. *Noción de delito.* Delito es un acto antijurídico que lesiona a alguien y que está sancionado con una pena (*poena*).

En el lenguaje de los autores clásicos, sólo se emplea este vocablo —*delictum*, también *maleficium*— para aquellos casos propios del *ius privatum* que provocan una obligación penal (*obligatio ex delicto*) y son perseguibles por una acción penal (*actio poenalis*), sean éstas del *ius civile* o del *ius praetorium*. En cambio, *crimen* designa el acto antijurídico que lesiona primordialmente a la comunidad y que son castigados mediante un juicio público a una pena corporal o pecuniaria:

1. De este modo, el *delictum* (delito privado) se opone a *crimen* (delito público). Aquí nos ocuparemos sólo de los primeros.

Para tener una idea, los *crimina* configuraban casos como los homicidios, los sacrilegios, la traición (*perduellio*), etc. Los casos los encontramos en el libro 48 del Digesto. Son juzgados por tribunales especiales como *questiones perpetuae*. Las penas podían variar, desde la pena capital (muerte, esclavitud), la *deportatio* (que suple la anterior *interdictio aquae et ignis*), la *relegatio in insulam*, la *flagellatio*, el azotamiento (*verberatio*), el trabajo en minas, etc. Ver Inst., 4.18.

2. En cambio, el *delictum* da lugar al nacimiento de una *actio poenalis*, mediante la cual se persigue el cobro de una *poena*, que si bien en un principio fue corporal, en el procedimiento pretorio consistió en una suma de dinero, con la cual se castigaba al autor del daño.

Esta acción penal no es incompatible con el ejercicio de alguna acción reipersecutoria, la cual se puede acumular. Así, p.ej., quien ha sufrido un *furtum* tiene la *condictio furtiva* y la *rei vindictio* para recobrar la cosa hurtada. Pero, además, tiene la *actio furti*, con la cual se castiga al ladrón con una pena pecuniaria (*duplum*, *tripulum* o *quadruplum* del perjuicio ocasionado).

3. En el derecho posclásico tiende a desdibujarse la diferencia entre *delicta* y *crimina*. Justiniano restablece el derecho clásico de los delitos privados, pero le da mayor importancia a la persecución criminal que a la privada (Ulp., D.47.2.92(94) it., donde se nos habla que "hoy se ejerce las más de las veces criminalmente la *actio furti*, sin perjuicio de la acción civil").

§ 330. Para la comisión de un *delictum* se requiere generalmente una intención maliciosa (*dolo malo*), si bien por una interpretación jurisprudencial para el delito de daño sancionado por la ley Aquilia, basta meramente la culpa (Gayo, 3.211).

Como lo que interesa es que el delincuente sea capaz de cometer el delito con esa intención, basta que sea *impuber puertati proximus** (Gayo, 3.208), pudiendo serlo un esclavo, el pródigo, o la mujer. En cambio, no son imputables el *infans**, el *impuber infantiae proximus** o el demente.

§ 331. *Acciones penales.* Las acciones penales tienen rasgos propios que hay que destacar:

A) Si existieran varios delinquentes, la *actio* los engloba a todos ellos de manera "cumulativa", de tal modo que todos y cada uno de ellos debe satisfacer la pena por entero. Así, si son cuatro quienes han cometido un *furtum nec manifestum* (la pena es el *duplum*), aquel a quien le hurtaron la cosa podrá perseguir por la *actio furti nec manifesti* a cada uno por separado, con lo que obtendrá ocho veces el valor de la cosa, amén de la restitución de ella que es debida por la *condictio furtiva* o la *rei vindictio* (Ulp., D.47.2.21.9; D.9.2.11.2; C.4.8.1).

1. Este carácter cumulativo se aplica a la acción penal, no a la acción reipersecutoria, puesto que si en el ej. dado uno restituye la cosa, libera a los demás.

2. Algún paliativo se dio en favor del dueño de una "familia" de esclavos que habían hurtado. La pena era una sola, considerando la unicidad del dueño de la familia —aquí significa el conjunto de los esclavos de un *pater*—, "para que no arruinen el patrimonio de su *dominus* (Ulp., D.47.8.1 pr.).

Igual solución, por una constitución de Severo y Antonino, respecto de los publicanos que formaban una *societas* que hubieran cobrado algo ilícitamente (Mod., D.39.4.6).

B) Las acciones penales son pasivamente intrasmisibles, de tal modo que sólo es responsable el autor del delito, no sus herederos (Gayo, 4.112).

1. Esto es así si el acusado muere antes de la *litis contestatio*. Pero si ésta ocurrió, es decir, si el

juicio, quedó probado, así como el estado de sentencia condenatoria, los herederos debían responder (Gayo, D.50.17.133).

2. Justiniano, sobre la base del principio del enriquecimiento indebido, permitirá la *actio poenalis* contra los herederos, hasta el límite de su enriquecimiento por lo logrado por el delito (Pap., D.50.17.33 it.; Venulayo, D.42.8.11, recogiendo la opinión del sabiniano Cassio; Paulo, D.44.7.35 pr., it.).

En cambio, desde el punto de vista activo, las acciones penales son transmisibles, ya que son de contenido económico, salvo aquellas como, p.ej., la de injurias, de las que se dice que "respiquen venganza" (*vindictam spirantes*), que afectan más los sentimientos personales que los patrimoniales (Gayo, 4.112; Ulp., D.47.1.1.1).

c) Si el autor del delito era un *filius in potestate* o un esclavo, el *pater* o el *dominus*, podía escapar de su responsabilidad entregando dicho hijo o esclavo, por medio de una *mancipatio*, a quien sufrió el perjuicio, en carácter de *noxae datio* (Gayo, 4.75-79). Si no optaba por este procedimiento, debía pagar él mismo la pena del delito (Gayo, D.9.4.1).

1. Justiniano, impulsado por motivos morales, a los que no son ajenos los principios cristianos, eliminará la *noxae datio* de los hijos e hijas, manteniéndola sólo en el caso de los esclavos (Inst., 4.8.7). Ya en la época clásica, por razones humanitarias no se practicaba la *noxae datio* de una hija. Gayo (4.75 y ss.) habla sólo del caso del *filius*, no de la *filia*.

I. Furtum.

§ 332. El *furtum* consiste en el apoderamiento de una cosa mueble ajena, considerándola como propia, en contra de la voluntad de su dueño.

1. La figura del *furtum* se irá configurando lentamente. Por cierto que excedió lo que hoy día se conoce por "hurto", pues englobaba otras situaciones.

a) En principio, el *fur* (= ladrón) es quien se lleva una cosa (*Fur* viene de *fero* = "llevo o transporto") cuya posesión o tenencia está en manos de otro, sin autorización suya (Paulo, 2.31.1; D.47.2.1.3).

b) Ya en el siglo II a.C., también será *furtum* el retener la cosa de otro, en contra de su voluntad: p.ej., el depositario o el comodatario que ocultan la cosa depositada o prestada para quedarse con ella (Gayo, 3.195; Paulo, D.47.2.1.2).

c) Quien se apodera de una cosa que halló perdida (no la abandonada), ya sea que sepa de quién es o lo ignore; Ulp., D.47.2.43.4-11).

d) Quien a sabiendas, de mala fe, ha vendido o dado la cosa de otro (Inst., 2.6.3); o ha recibido, en

esas condiciones, dineros que no eran debidos (Sev., D.13.1.18; Ulp., D.47.2.43 pr.).

e) Ya en época posterior, también la destrucción maliciosa de los documentos donde se evidenciaba una deuda (Ulp., D.47.2.27.3).

2. Se ve, por todo esto, lo difícil que es lograr una definición omnicompreensiva del *furtum*. La idea primera de sacar una cosa ajena del lugar donde está (*amotio*; de ahí, escamotear), se completará, según Sabino (A. Gell., 11.18.20), con la *adfectatio* (= tocar, poner la mano en la cosa, por supuesto contra la voluntad de su dueño, poseedor o tenedor). De ahí que los autores prefieran emplear el vocablo más genérico y omnicompreensivo de *contractatio* (= manejo; control de la cosa para sí; Gayo, 3.195; Paulo, 2.31.1; D.47.2.1.3).

§ 333. Formas de cometer el *furtum*. a) En principio consiste en la sustracción o desplazamiento de la cosa (*contractatio rei*, o también *furtum rei*; Paulo, D.47.2.1.3). Aquí entrarían todas las variantes mencionadas en el párrafo anterior.

b) Pero también se consideró *furtum* el abuso que se produjera en el uso de una cosa confiada a alguien (*furtum usus*). Así, si a alguien se le prestó un juego de platería para cenar y se lo llevara al extranjero; o un caballo, para un paseo y se lo llevara a la guerra (Gayo, 3.195; Inst., 4.1.6). Igualmente comete el *furtum usus* el depositario que usara de la cosa depositada (Gayo, 3.196) y el acreedor prendario que usara la cosa dada en *pignus* (Inst., 4.1.6; Gayo, D.47.2.54 pr.).

c) Por último, cuando el propietario de una cosa dada en prenda (Inst., 4.1.1; Paulo, D.47.2.15 pr.), o dada en usufructo (Paulo, D.47.15.1), se apodera de esa cosa. Aquí, se da la circunstancia de que el dueño de la cosa comete *furtum* apoderándose de su propia cosa. Pero en realidad no se considera el dominio de ella, sino la posesión de la cosa que había entregado y debía respetar (*furtum possessionis*; Gayo, 3.200; Inst., 4.1.10).

Estas tres formas (*furtum rei*, *furtum usus* y *furtum possessionis*) no deben ser consideradas clases distintas de *furtum*, sino simplemente modalidades en su comisión. El delito es siempre único en estos casos.

§ 334. Sobre qué puede recaer un *furtum*. Se debe tratar de una cosa mueble. Sabino sostuvo que también podía ocurrir con un inmueble (A. Gellio, 11.18.13), pero esta opinión —que habría sido seguida por su escuela— fue rechazada, incluso por el mismo Gayo (2.51, D.41.3.38; Ulp., D.47.2.25 pr.).

1. El apoderamiento doloso de un fundo turna vicios la posesión, lo que tendrá efectos para la

solución de los interdictos posesorios, pudiendo constituir un *crimen*, pero no un *delictum*.

Justiniano, receptando constituciones anteriores, lo tipificará como *invasio*, con la pérdida de la cosa si la realiza el propietario. Si fuera un tercero, después de haberla restituído, será obligado a pagar el valor de ella (Inst., 4.2.1; Valentiano, Theodosio y Arcadio, C.8.4.7).

También se puede cometer el *furtum* de personas libres, como p.ej., si se sustrae la libertad de los *filiifamiliae*, de la *uxor in manu* (Gayo, 3.199; Inst., 4.1.5).

2. En estos casos, la *actio furti* podía ocurrir juntamente con el crimen de "plagio" (secuestro o enajenación de personas libres, D.43.11).

Para recuperarlas no se podía usar de la *condictio furtiva* (Paulo, D.47.2.38.1), pero sí de la *rei vindictio* (Ulp., D.6.1.1.2). Pero lo más práctico era interponer un interdicto de *liberis exhibendis vel ducendis*, para que se presentara ante el pretor aquel que estaba in *potestate* (D.43.30; EP, § 262).

3. La pena del delito por la *actio furti*, no está calculada sobre el valor de la persona sustraída, puesto que no se puede apreciar en dinero el valor de una persona libre. Se la calculaba sobre el interés del *pater*. Teófilo establece que en este caso la *actio furti* va por aquello que sea el "interés" (*Furti autem agit in id quod interest*), y cita como ej. el caso del hijo instituido como heredero con la condición "que se encuentre en tal ciudad a la muerte del testador", y el ladrón se lo ha llevado a otra, por lo que incumplida la condición, se pierde la herencia. Por ello, la cuenta de esta pérdida deberá entrar en la estimación del perjuicio.

§ 335. *Animus furandi*. Quien comete un *furtum* debe actuar con dolo (*dolus malus*). También será denominado *animus* o *adfectus furandi* (Gayo, 2.50; 208; 4.178), que consiste en el conocimiento que tiene el ladrón (*fur*) de que está actuando contra la voluntad del *dominus* de la cosa.

1. Para la existencia del *furtum* no basta la mera intención. Es necesaria la sustracción de la cosa (*contractatio rei*; Paulo, D.41.3.18). Así, si alguien con propósito de hurto entra en una casa, abriendo o rompiendo una puerta, pero sin alcanzar a sustraer una cosa, no existe aún el *furtum*.

2. No se admite el *furtum* por mera culpa. Así, quien creyó que contaba con la voluntad del dueño y no era así, no comete *furtum* (Ulp., D.47.2.46.7).

En la definición de *furtum* de Paulo (D.47.2.1.3: "apoderamiento fraudulento de una cosa") se emplea la palabra *fraudulosa*, muy rara para su época (nos había de un manejo del párrafo por los compiladores,

hay que interpretarla como la exigencia del dolo, tal cual lo había dado el mismo Paulo (2.21.1): "Ladrón es aquel que con dolo malo se apodera de una cosa".

3. El fraude, como tal, no es *furtum*, debiendo actuarse por la *actio de dolo*. Sin embargo, se puede dar el caso que mencionó Ulpiano (D.47.2.52.21): "Quemodo yo prestarle dinero a Ticio, hombre honesto, mas lo sustituya por otro Ticio (es decir, otra persona) pobre y lo hiciste como si él fuera rico, y dividiste con él el dinero recibido". En este caso, Ticio al recibir el dinero comete *furtum*, y quien obró como agente también, por ser su cómplice (*furtum ope consilio factum*).

§ 336. Por las características del *furtum*, quien lo comete debe haber adquirido un provecho respecto de la cosa hurtada (ya la cosa misma, su uso o su posesión). Si se ha apoderado de una cosa ajena para dañarla o destruirla, entonces no es *furtum*, sino el delito de "daño" (*domnum*) sancionado por la *lex Aquilia* (Paulo, 2.31.35; Ulp., D.9.2.41.1; D., id. 27.25).

1. En algunos textos, se suele encontrar la expresión *animus lucri faciendi* (o *animus lucrendi*). Incluso en la época clásica (Sabino en A. Gell., 11.18.20). Será muy del gusto de los bizantinos que lo interpolarán en algunos párrafos (así, Paulo, D.47.2.1.3; Inst., 4.1.1). Pero si tenemos en cuenta el interés del *fur* al cometer el *furtum*, vemos que en la práctica se confunde con el dolo de él (*animus furandi*).

Clases de *furtum*

§ 337. *Furtum manifestum* y *furtum nec manifestum*. Desde antiguo se distinguió entre estos dos géneros. Se considera que es *manifestum* cuando el ladrón es sorprendido *in fraganti*, es decir, en el momento mismo de cometerlo (Inst., 4.1.3; Ulp., D.47.2.3 pr.); o llevando la cosa hurtada a un lugar destinado a guardarla (Inst., *ibid.*; Ulp., D.47.2.5 pr.). Cuando no se dan estas condiciones, el *furtum* es *nec manifestum* (Gayo, 3.185; Inst., *ibid.*).

1. La cuestión de cuando el *furtum* era *manifestum* mereció la atención de los clásicos. Por Gayo (3.184) y Paulo (2.31.2) nos enteramos que existían cuatro opiniones:

a) para algunos es *manifestum* cuando el ladrón es aprehendido (o queriendo aprehender) en el momento mismo que está hurtando;

b) para otros, también si se lo aprehende en el lugar del *furtum* (en la casa, en el olivar, en la viña);

c) otros van más lejos: cuando se lo aprehende en el transporte de la cosa hurtada al lugar donde la pensaba guardar; y

d) según la tesis más amplia, cuando se lo hubie-

miendo la cosa hurtada en su poder.
2. Gayo se inclina por la segunda opinión, que dice ser la prevaliente en su época, reduciendo la tercera, ya que existía una seria duda sobre si el llegar a dicho lugar (en el que espera guardar la cosa) le tardará un día o incluso varios días, ya que sucede a menudo que los ladrones intentan transportar las cosas sustraídas a otras ciudades o provincias" (Gayo, 3.184).

Sin embargo, prontamente se impone la tesis de Juliano (Ulp., D.47.2.3.2), según la cual es *fur manifestus* quien es aprehendido con la cosa hurtada, antes de que hubiese llegado con ella al lugar donde la había destinado.

Justiniano termina aceptando esta posición (Inst., 4.1.3). En cuanto a la duda de Gayo, se resuelve con la opinión de Paulo: "Adonde hubiere determinado permanecer aquel día (ei diei *furtum*) con la cosa hurtada" (D.47.2.4). Una vez que la llevó al sitio destinado ese día, aunque sea sorprendido más tarde con la cosa hurtada, es *fur nec manifestus* (Ulp., D.47.2.5.1).

Antiguamente, también se consideraba *manifestum* cuando el autor del *furtum* era sorprendido teniendo la cosa en su casa, como resultado de un registro ritual (*perquisitio lance et licio*; Gayo, 3.192.4).

3. Según Gayo, aquel que quería hacer este ritual investigador debía estar desnudo (*nudus*), cubierto sólo por un taparrabos (*lucium*) y llevando en la mano una bandeja o plato (*lanx*). De este modo debía entrar en la casa de aquel respecto de quien entendía que tenía la cosa hurtada.

4. Gayo describe irónicamente esta *perquisitio*, a la que trata de "ridícula". Posiblemente este ritual tenía alguna significación religiosa que no ha sido aclarada.

Lo interesante es que aquí, no obstante que el *fur* no había sido aprehendido *in fraganti*, ni tampoco transportando la cosa, el *furtum* era calificado de *manifestum*. Este registro ritual fue empleado en los tiempos primitivos (XII Ts. 8.15b) y desapareció con el advenimiento de la *lex Aebutia* (mediados siglo II a.C.; A.Gell., 16.20.8).

§ 338. Según la ley de las XII Tablas (8.14), el *furtum manifestum* era castigado con la muerte, si el ladrón era un esclavo; en cambio, si se trataba de un hombre libre, era azotado y se lo declaraba *addictus** (Gayo, 3.189). Si el *furtum* era *nec manifestum*, la ley decenviral establecía la pena del *duplum* (8.15).

En el procedimiento formulario, el pretor otorgaba la *actio furti manifesti* por el *quadruplum* del valor de la cosa (Gayo, 3.189; EP, § 125). En cuanto a la *actio furti nec manifesti*, se la otorgaba por el *duplum* continuando la mis-

(Gayo, 3.190; EP, § 128). Justiniano mantendrá estas mismas penas (Inst., 4.1.5).

1. Respecto del ladrón hombre libre, los antiguos discutían sobre si por la *addictio* se convertía en un esclavo o se colocaba en una situación de *adjudicatus* (Gayo, 3.189).

2. La ley de las XII Tablas (8.12) permitía matar impunemente al ladrón sorprendido en la noche. Y también, si sucedía de día, estando el ladrón armado y luego que al afectado requiriera a viva voz auxilio de sus vecinos (*exploratio*); Cic., *pro Tullio*, 21.47.50; XII Ts. 8.13.

§ 339. Otros casos de acciones por el *furtum*. También existieron otros casos de hurto, o mejor, de acciones *furti*:

a) La *actio furti concepti*, que se daba a quien sufrió el *furtum* y que luego, en presencia de testigos —no por la forma ritual de la *perquisitio lance lictique*—, había buscado y encontrado (*conceptum*) en casa de alguno, aunque no fuera el ladrón (Gayo, 3.186; Inst. 4.1.4). La pena era por el *triplum* (Gayo, 3.191; Inst., *ibid.*).

1. Para Servio Sulpicio y Sabino, se trataba de una clase distinta de *furtum conceptum*. Lo mismo que hablarán del *furtum oblatum* (Gayo, 3.183). En cambio, para Labeón, sólo había dos clases de *furtum*: el *manifestum* y el *nec manifestum*, tratándose estos casos, más que géneros del *furtum*, de especies de la *actio furti* (Gayo, 3.183, quien se adhiere a esta última posición, pese a referirse luego al *furtum conceptum* —3.186— y al *furtum oblatum* —3.187—).

b) La *actio furti oblata* supone el caso siguiente: una persona ha llevado la cosa hurtada a tu casa, con la intención de que fuera encontrada en tu casa antes que en la suya. En este supuesto, se te concede esta *actio furti oblata*, contra aquel que te la ha trasladado (*oblatum*), por más que no sea el ladrón (Gayo, 3.187; Inst., 4.1.4). La pena era del *triplum* (Gayo, 3.191; Inst., *ibid.*).

c) La *actio prohibiti furti* se daba por el *quadruplum* contra aquel que se opusiera voluntariamente a que se investigara el *furtum* (Gayo, 3.183; 192).

d) La *actio non exhibiti furti*, mencionada por Justiniano, de pena desconocida, contra aquel que no presentase o exhibiese la cosa hurtada que ha sido buscada y hallada en su casa (Inst., 4.1.4).

Todas estas acciones relacionadas con el registro domiciliario, cayeron en desuso y fueron abolidas por Justiniano; los que hubiesen recibido y ocultado una cosa hurtada, quedan sujetos a la *actio furti nec manifesti*. Para la legis-

lacion, existen el *furtum manifestum* y el *nec manifestum* (Inst., 4.1.4).

1. Sin embargo, se mantenían ciertas acciones *in factum* por el *duplum*. Así:

a) la *actio de signo iuncto*, para quien hubiere hurtado un madero (*signum*), o materiales ajenos, habiéndolos empleado en una edificación (EP, § 131.4; Ulp., D.47.3.1 pr.);

b) una acción contra aquel que por testamento se le ordenó la libertad, y antes de adida la herencia, se apoderó con dolo de bienes que debían ser del heredero (EP, § 136.3; Ulp., D.47.4.1 pr.).

c) Una acción contra los dueños de una nave, una posada o un estable (*naves, caupones, stabularii*), por el *furtum* cometido por ellos o sus dependientes a sus clientes (EP, § 136.9; Ulp., D.47.5 pr. y 2).

d) Para el caso de una "familia de esclavos" hubiese cometido un *furtum*, para evitar que el *dominus* tuviera que responder en forma cumulativa por todos ellos arruinándose, se le permite que pague la estimación de la pena como si el *furtum* hubiese sido cometido por un solo hombre libre (EP, § 137.10; Ulp., D.47.6.1).

e) Una acción por el *furtum* cometido por una "familia de publicanos" con ocasión de la recaudación de impuestos (EP, § 138. 11).

f) Una acción contra los que furtivamente hubieran cortado árboles. Ésta es distinta de la *actio de arboribus succisis*, en la cual la pena era de 25 ases por cada árbol abatido, mientras que acá es por el *duplum* del interés (EP, § 139.12; Paulo, D.47.7.1).

§ 340. Ejercicio de la *actio furti*. La *actio furti*, que tiene los caracteres ya señalados para las acciones *poenales*, es de carácter infamante (Gayo, 4.132; Inst., 4.16.2) y le compete:

a) por supuesto, al dueño de la cosa hurtada; b) pero también a aquel que aun no siendo dueño de la cosa, le interesa que ésta no fuera hurtada (Gayo, 3.203; Inst., 4.1.13).

1. En doctrina, se suele hablar de casos de procedencia de la *actio furti* por "interés positivo" o por "interés negativo".

En el primer caso están quienes tienen un interés directo en la cosa, que han perdido por el *furtum*. Así, el acreedor pignoraticio si le han sustraído el *pignus* (tanto por un tercero, como por el propio dueño; *furtum possessionis*; Gayo, 3.204; Inst., 4.1.14; el poseedor de buena fe (Gayo, 3.200; Inst., 4.1.10); el usufructuario, el usuario, el colonos (Ulp., D.47.2.14.2).

Pero, no le tendría el comprador, a quien aún no se le hizo *traditio* de la cosa. La *actio furti* le tiene el vendedor, si bien Ulpiano y Juliano recomiendan que éste cada la acción (lo mismo que la *condictio furtiva*) al comprador (D.47.2.14 pr.; D.47.50(82) pr.). Pero si se operó la tradición de la cosa comprada, es el comprador quien tiene la *actio furti* (Inst., 4.1.15).

2. En cambio, sería procedente esta acción por "interés negativo", en el caso de aquellos que detentan la cosa, pero sobre ellos pesaba la responsabilidad por "custodia". Siendo así, a ellos les interesaba devolver la cosa al dueño.

En el caso del tintorero (*fullo*) y del sastre (*sarcinator*) a quienes se le han entregado vestimentas para limpiarlas o remendarlas, mediante un pago. El dueño de estas cosas no tendría un interés directo, por cuanto podrá reclamar contra ellos por la acción nacida de la *locatio et conductio*, siempre y cuando que sean solventes, es decir, si pueden pagar al propietario la estimación de la cosa.

Si lo son, la *actio furti* corresponde al tintorero o al sastre. Pero si no lo son, entonces le compete propiamente al dueño (Gayo, 3.205; Inst., 4.1.15).

También le corresponde la *actio furti* al comodatario (Gayo, 3.206; Inst., 4.1.16), puesto que está responsabilizado por la guarda de la cosa. Pero Justiniano le permite al dueño optar por reclamar contra el comodatario por la *actio commodati*, o ir contra el ladrón por la *actio furti*. Pero elegida una vía, salvo caso de ignorancia o duda acerca del *furtum*, no puede intentar la otra.

En cuanto al depositario, como éste no tiene la custodia de la cosa y no responde por *furtum*, salvo que hubiera mediado dolo, carece de interés en la conservación de la cosa. Por tanto, la *actio furti* no le corresponde a él, sino al propietario (Gayo, 3.207; Inst., 4.1.17).

§ 341. La *actio furti* se lleva a cabo contra el ladrón (*fur*). Pero también contra el cómplice en la acción delictiva. Sería el caso de que el *furtum* fuera realizado "con la ayuda y el consejo" (*ope consilio*) de otro. Así: hago caer tus monedas para que otro te las arrebathe; te obstruyo el camino a fin de que otro te quite una cosa tuya; o hago huír tus ovejas o tus bueyes para que otro los tome (Gayo, 3.202; Inst., 4.1.11). Quien ha obrado como cómplice (*ope consilio*), y no directamente como coautor, es perseguido por la *actio furti nec manifesti* (Paulo, D.47.2.34).

1. La expresión *ope* se refiere a la "ayuda material". *Consilio* al "consejo", "instigación" de cometer el dolo furtivo (Padio-Ulp., D.47.2.50.2). "Se considera que da «consejo» aquel que persuade y mueve, instruyendo a otro con su consejo para cometer el *furtum*; presta su «ayuda» el que aporta su servicio y colaboración para sustraer las cosas" (Ulp., D.47.50.3).

El "consejo" y la "ayuda" sólo tienen consecuencias si es que realmente se ha seguido el apoderamiento de la cosa (Ulp., D. id. 52.12).

2. El haber actuado con "ánimo de broma" (*lascivialis*), pero sin ánimo de colaborar con el *fur*, no incurriría al autor por la *actio furti*; pero si con

ello provocó un *damnum*, sería perseguido por la *actio vi facti* de la *lex Aquilia* (Ulp., D.47.2.50.4).

§ 342. Tal como dijimos, por la *actio furti* se puede perseguir el pago de una pena. Sin perjuicio de ello, para recuperar la cosa hurtada, el dueño tiene que elegir entre la *rei vindicatio* y la *condictio furtiva* (Ulp., D.13.1.1).

1. Si se conoce quién es el poseedor de la cosa hurtada, la *rei vindicatio* tiene la ventaja de que se puede ejercer contra todo detentador, ya sea el ladrón, sus herederos o aun un tercero de buena fe quien no puede oponerle la *usucapio*, precisamente por tratarse de una cosa hurtada. También en la última época contra el *fictus possessor* o aquel que con dolo ha dejado de poseer.

2. La *condictio ex causa furtiva* (luego directamente *condictio furtiva*) tiene la particularidad de representar una anomalía, puesto que no se le podría conceder a un propietario, quien no podría reclamar que "se le debe dar —dare= pasar la propiedad—", puesto que es suya. Sin embargo, se la estableció "por odio a los ladrones" (*odio furum*; Gayo, 4.4; Inst., 4.6.14).

No se concede contra todo poseedor, como en la *rei vindicatio*, sino sólo contra el ladrón o sus herederos. Tampoco contra el cómplice, es decir, quien ha cooperado *ope et consilio*, aunque tenga que responder por la *actio furti* (Ulp., D.13.1.5).

Tiene la ventaja de que se pueda perseguir incluso la cosa que se ha extinguido (se debe la *estimatio*, es decir, su valor; Ulp., D.13.1.8 pr.), puesto que el ladrón está siempre en mora (Tryfon, D.13.1.20), lo que no se puede hacer por la *rei vindicatio* (Gayo, 2.79, in fine).

En la práctica se impone la *condictio furtiva* cuando se trata del *furtum* de dinero, o cosas consumibles, o en general cosas que no es posible identificar y que no podrían ser reivindicadas. El demandado condenado deberá satisfacer el más alto valor que tenga la cosa (Ulp., D.13.1.8), con sus frutos y accesorios o su *assimatio* con intereses (Paulo, D.13.1.3; Ulp., D.8.2).

3. El dueño tiene también la *actio ad exhibendum*, para que se le exhiba la cosa, de tal modo que pueda reconocerla. De este modo puede preparar la *rei vindicatio*. Es arbitraria, ya que el juez, en caso de no exhibirse la cosa puede estimar *ex bona et aequo* la satisfacción que se debe al actor (Inst., 4.5.31).

§ 343. El *furtum* será siempre considerado un *delictum*. Pero también se irá forjando la idea de la configuración de ciertos casos como *criminalia*. Así, la *lex Cornelia de sicariis* castigaba en forma pública al ladrón armado, la *lex Julia de peculato*, el robo de cosas públicas, sagradas o religiosas, y también otros casos, como el hurto de bestias, en caminos públicos, con ruptura, etc.

Para la época de Justiniano, quien sufrió el *furtum* podía recurrir antes a la justicia penal ante el gobernador o el *praefectus vigilum*, y luego al juicio privado (Jul., D.47.2.56.1; Ulp., D.47.2.92).

II. Rapina.

§ 344. Originalmente, el robo (acto con violencia) no aparece distinto del *furtum*. Pero, según nos cuenta Cicerón (*pro Tullio*, 8), el pretor M. Terencio Liculo (año 76 a.C.) sancionó los actos violentos realizados por hombres reunidos y armados, debido a los excesos que se cometieron en las guerras sociales. Parece ser que al comienzo se persiguió la acción violenta productora de daños, pero prontamente se le agregó el caso de "bienes arrebatados por medio de la violencia". Esto conformó una sola acción, conocida como *actio vi bonorum raptorum* (Ulp., D.47.8.2.17), que abarcaba ambos supuestos: la comisión de "daños" por parte de robo (*bona vi rapta*).

En un principio se exigió la presencia de hombres reunidos y armados que actuaran con violencia (Cic., *pro Tullio*, 3.7). Pero luego se admite una interpretación más amplia, de tal modo que el delito podía ser causado por una sola persona "armada", o por una "banda" (*hominibus coactis*), ya armada o desarmada (Ulp., D.47.8.2.7 it.; Lenel, § 187).

1. Los textos del Digesto (47.8) han sido manipulados por los bizantinos, lo cual crea problemas para la interpretación de este delito en la época clásica y lo que quisieron hacer los compiladores.

En el Edicto figuraba un título *De hominibus coactis et vi bonorum raptorum* (§ 187, "Sobre los hombres reunidos en banda y sobre las cosas arrebatadas con violencia").

De la integración del párrafo de Ulpiano (D.47.8.2 pr. y ss.) donde figuraba el texto del pretor y sus comentarios, con las restituciones efectuadas por Lenel, podemos considerar la existencia de los siguientes casos:

a) Se castigaba el hecho de haber reunido hombres formando una banda para cometer daño en forma intencionada (con dolo malo) a otro (D.47.2 pr.), abarcando tanto el caso de haberse actuado en forma armada como sin armas (D.47.7.1).

b) Igualmente si dichos hombres reunidos en banda arrebatan bienes, usando de la violencia armada o de la violencia común sin armas (D.47.2 pr. 1.7).

c) La jurisprudencia amplió la posibilidad de comisión de estas dos hipótesis (daño y arrebatado de bienes) para el caso de que las realizara un hombre sólo "armado", haciendo violencia (D.47.2.7).

De estas formas, se trataba de casos de *furtum*.

a) de *damni iniuria dati*, agravados por el hecho de haber actuado en banda o con violencia (Jul., Ulp., D.47.2.10).

2. Según la restitución de Lenel, la propuesta del Edicto que menciona Ulpiano (D.47.8.2 pr.) debía ser así (poniendo entre paréntesis lo que debía figurar genuinamente):

"Si se dijere que con dolo malo se le causó daño a alguien por hombres reunidos (y armados), o si se dijere que (con violencia) fueron robados bienes, contra el que se dijere que hizo esto, dará acción (por el *quadruplum*, en el año contado desde que la cosa fue arrebatada, y luego del año por el *simplum*, en juicio recuperatorio). También, si se dijere que lo hizo un esclavo (o una familia de esclavos), dará acción noxal contra el *dominus*".

3. Según lo ha estudiado Lenel, el texto del Edicto hablaba en principio de "dolo malo", interpretándose que dentro de tal concepto quedaba involucrada la "violencia" ("porque el que obró con violencia, obró con dolo malo"). Pero en el caso de "banda de hombres reunidos y armados", para la hipótesis de "daño" se podía actuar con "dolo" aun sin emplear la "violencia" (así, p.ej., encerrando ganado ajeno para que no pastara; D.47.2.20).

En cambio, si el delito lo cometía un hombre solo "armado", debía emplear la "violencia".

Así, el párrafo de Ulpiano (D.47.8.2.7), según la restitución de Lenel, debía ser así, en su versión originaria: "Así también, si dijeras que uno solo (armado) causó el daño, no creo que sean deficientes las palabras del Edicto; porque cuando se dice: 'habiendo reunidos hombres (armados)', debemos entenderlo así que uno solo (armado) hubiere hecho violencia, o siendo hombres reunidos, ya sean armados o desarmados, está sujeto a este Edicto".

4. Pero en el caso, no de "daño", sino de "bienes arrebatados" en ambos casos era ineludible que se ejerciera violencia. De lo contrario no nos explicaríamos la diferencia con el *furtum*, como figura agravada de este delito, y más precisamente el nombre de la acción que era *actio vi bonorum raptorum* (acción de bienes arrebatados con violencia) (Ulp., D.47.2.17).

5. Los bizantinos hicieron desaparecer la palabra "armados", lo cual es congruente con su decisión de abrogar el interdicto *de vi armata*, hablando simplemente de violencia (interdicto *unde vi*), lo que explica las interpolaciones a los textos. Pero también emplean ambivalentemente "dolo malo" y "violencia". Todo esto engendra no pocas dudas y algunas contradicciones, pero como dice Lenel, "ello encuadra perfectamente con las costumbres de los compiladores que no se hacen problemas por tan poca cosa".

§ 345. *Actio vi bonorum raptorum*.

a) En la época clásica, esta acción opera, aun cuando la rapina sea de una sola cosa mueble, y por más que su valor fuera insignifi-

cante, como *actio utilis* por el *quadruplum* si se la ejercía dentro del año, y por el "simple" trascurrido éste (Gayo, 3.209; Inst., 4.2 pr.). Tiene carácter infamante (Gayo, 4.182). Tenía siempre naturaleza penal, siendo compatible con la *rei vindicatio* y la *condictio furtiva*, para recuperar la cosa robada o su valor.

b) En cambio, para Justiniano será considerada una "acción mixta", de tal modo que era penal por el *tripulum* y por el *simplum* restante era considerada reipersecutoria (Inst., 4.2 pr.; 4.6.19).

1. Con lo cual, curiosamente, y pese a lo que dice Justiniano de que "habría sido ridículo hacer de mejor condición al que arrebatara con violencia que al que sustrae clandestinamente", si se trataba de un delito *manifestum*, la *actio furti manifesti* aparece como más lucrativa, puesto que es integralmente penal por el *quadruplum*, mientras que el contenido de la segunda, lo es en tal carácter sólo por el *tripulum*. Además, el que ejerce la primera puede añadir la acción reipersecutoria de la cosa, lo cual no puede hacer el que ejerza la segunda.

2. En el fondo, la rapina, como lo dice Gayo (3.209), es siempre también un *furtum*, si bien calificado. Por eso es que se puede usar también la *actio furti*. En la época clásica, siendo ambas penales, durante el año útil, se podía usar una u otra, lo cual tenía importancia si el delito era *nec manifestum*, puesto que la pena se agravaba del *duplum* al *quadruplum*. Pero, pasado el año, la *actio furti* (tanto *manifesti* como *nec manifesti*) tenía la ventaja de ser "perpetua" (Gayo, 4.111), y por valores superiores al *simplum*.

3. En la época clásica, está discutido sobre los efectos de esta acumulación de acciones. Para Justiniano, si se ejerce la *actio vi bonorum raptorum*, se deniega luego la *actio furti*; pero incoada primero ésta, se puede accionar por la primera "para que uno consiga lo que de más hay en ella" (Paulo, D.47.8.1 it.).

Así, si se hubiera actuado por la *actio furti nec manifesti* y se consiguió el *duplum*, se puede accionar luego por la *actio vi bonorum raptorum*, para lograr el *tripulum*, y hasta el *quadruplum* si no se hubiera logrado la restitución de la cosa.

4. Quien, sin actuar con dolo malo, hubiera arrebatado una cosa creyendo que es suya, y pensando, por ignorancia del derecho, que un propietario puede recobrar la cosa, aun con violencia, de los poseedores, debía ser absuelto; tampoco podía ser perseguido por la *actio furti* (Inst., 4.2.1).

Sin embargo, "por temor de que cubriéndose con tales pretextos no hallen los ladrones medios de ejercitar impunemente su avaricia" se establecieron algunos principios por la vía de constituciones imperiales.

Así, Marco Aurelio estableció que si un acreedor, en lugar de pedir judicialmente la cosa que se le

debe, la tomaba directamente del deudor, contra su voluntad; entonces perdía el *ius crediti*. Y como Marciano reparara en el caso de que ello se hubiera hecho sin violencia, el mismo emperador dijo: "Y crases tú que solamente hay violencia si se hiciese a hombres? Hay violencia también siempre y cuando alguno no reclama por medio del juez lo que cree que se le debe" (Calistrato, D.48.7.7).

Igualmente, por la constitución de Valentiniano, Theodosio y Arcadio (C.8.4.7; año 289) se estableció que en caso de arrebatar bienes con violencia, e incluso invadir inmuebles, creyendo que eran suyos, si eran cosas de quien arrebató o invadió, perdía la propiedad; si no, después de haberla restituido está obligado además a pagar su valor (Inst., 4.2.1). Era un castigo para quienes quisieran hacerse justicia por mano propia.

5. En Inst., 4.2.2, se agrega el caso de la *actio vi bonorum raptorum* para el supuesto de alguien que tuviera una cosa ajena por arriendo, comodato, depósito o el asumido la responsabilidad por culpa y ella le hubiera sido arrebatada con violencia. Tiene esta acción, no para hacerle dar la propiedad, sino en tanto y en cuanto que "tengan algún interés, aunque sea poco, en la conservación de la cosa" (Ulp., D.47.3.2.24).

6. Finalmente, la *actio vi bonorum raptorum* no es incompatible con el ejercicio de la acción pública dada por la *lex Julia de vi privata* (Ulp., D.47.3.2.1).

§ 346. Otras acciones vinculadas a la violencia. En el Edicto, aparte del título "Sobre los hombres reunidos (en bandos) sobre las cosas arrebatadas con violencia" (§ 187), figura también una acción de *turba* (§188), de la cual habla Ulpiano (D.47.8.4), cuando alguno formando parte de una "turba" (personas que ocasionan un tumulto) ocasiona un daño: la pena era del *duplum* dentro del año y luego la acción era por el *simplum*.

Igualmente, figura una acción especial (de incendio ruina naufragio *rate nave expugnata*, § 189), cuando alguien aprovechándose de un incendio, ruina, naufragio, barca o nave expugnada robó alguna cosa, o la recibió con dolo malo. La pena era del *quadruplum* dentro del año desde que hubiera sido posible ejercer la acción, y por el *simplum* después del año (Ulp., D.47.9.1 pr.).

III. Damnum iniuria datum.

§ 347. El delito de "daño causado injustamente" (*damnum iniuria datum*) estaba contemplado en la *lex Aquilia* (un plebiscito debido al tribuno Aquilio; año 287 a.C.).

1. Con anterioridad, ya desde las XII Tabas, estaba contemplado un régimen casuístico de daños sancionados con penas. Al establecer la *lex Aquilia* un sistema genérico para los daños injustos, muchas de

estas acciones quedaron abolidas, absorbidas ahora en la nueva ley. Sin embargo, otras continuaron. Así:

a) La *actio de pauperie*, para el caso de que un cuadrúpedo causara daños (*pauperies*) a una cosa ajena, sin haber mediado algún acto imputable al dueño de dicha cosa. El dueño del animal debía pagar el perjuicio o entregar al animal en *noxam* (Ulp., D.9.1.1 pr.; Inst., 4.9; EP, § 75).

b) La *actio de pastu pecoris*, por la cual se reparaba de igual forma que la anterior, el daño causado por animales que pastaran en terreno ajeno (Ulp., D.19.5.14.3; EP, § 76).

c) La *actio de arboribus succisis* establecida por las XII Tabas, por la cual se pedía el corte de árboles ajenos (8.11), quedó subsumida en la *actio arborum furtim caesarum* (acción por los árboles cortados furtivamente) (D.47.7; EP, § 139). Bastaba con el corte, sin necesidad de realizar un *furtum* de los árboles: "corta furtivamente un árbol el que lo corta clandestinamente" (Paulo, D.47.7.5.1). El pretor concede una acción por el *duplum*, reemplazando la pena decenal de 25 asses por cada árbol cortado (Ulp., D.47.7.7).

d) También el daño conocido como "corrupción del esclavo ajeno", da lugar a la *actio de servo corrupto*, con pena del *duplum* del deterioro del esclavo (Ulp., D.11.3.1 pr.; EP, § 63 (62)).

§ 348. Casos previstos por la *lex Aquilia*. Esta ley tiene tres capítulos, de los cuales sólo nos interesan para este delito el primero y el tercero.

En el capítulo I se castiga la muerte de un esclavo ajeno o de un animal cuadrúpedo de rebaño ajeno (Gayo, 3.210; D.9.2.2 pr.; Inst., 4.3 pr.).

En cambio, en el tercero se prevén toda otra clase de daños, es decir, los no contemplados en el anterior (así, heridas a un esclavo ajeno o a los animales allí mencionados, también ajenos), como también daños a otros animales, quemaduras, fracturas o rupturas de cosas ajenas, etc. (Gayo, 3.217; Ulp., D.9.2.27.5; Inst., 4.3.13).

1. El capítulo II se refería al caso del *adstipulator* que en fraude del acreedor principal liberó por una *acceptilatio* al deudor de la prestación de dinero. Contra él había una acción por el monto equivalente al perjuicio (Gayo, 3.215). En la época de Justiniano ya no estaba en uso (Inst., 4.3.12).

2. En el caso del capítulo I, cabe señalar que el único daño contemplado es la "muerte" del esclavo o del animal cuadrúpedo gregario ajeno.

Precisamente, debían ser gregarios, es decir, que están en rebaños. Así, las ovejas, las cabras, los bueyes, los caballos, los mulos y los asnos. Había una duda con los cerdos, que se resolvía en sentido afirmativo ya desde la época de Labeón.

En cambio, se excluía a los perros, como a las bestias feroces. En cuanto a los elefantes y los came-

llos, que son calificados de "mixtos" (prestan servicios como los jumentos, pero son salvajes por naturaleza), también se los considera comprendidos en la *lex Aquilia* (Gayo, D.9.2.2.2).

§ 349. El daño debe ser producido intencionalmente, "injustamente". Los clásicos, prontamente, no sólo lo admitieron cuando la acción productora del daño era intencional (dolo), sino también por imprudencia o negligencia (culpa); Gayo, 3.211; Inst., 4.3.2-3).

1. Incluso, basta la *levissima culpa* (Ulp., D.9.2.44 pr.). La comprensión de la culpa obliga a una casuística muy especial y muy interesante. Así, leyendo los casos citados en Inst., 4.3.3 ss., podemos observar el grado de afinamiento con que los juristas clásicos tomaron este concepto.

Así, si alguno, practicando con arco y flechas, mata al esclavo ajeno que pasaba, había que distinguir si sucedía en un campo militar, es decir, propio para estas prácticas, no había culpa; si, en cambio, si no se daba esa circunstancia (Inst., 4.4).

Si podando un árbol se hería o mataba al esclavo ajeno, había que distinguir si se trataba de un camino público, o lejos de él; si se advertía de ello con gritos, o no (Inst., 4.5); etc.

2. No hay culpa si se actúa "en defensa propia" (Paulo, D.9.2.45.4), puesto que se permite "repeler la fuerza con la fuerza", siempre y cuando no se exceda (Paulo, D.9.2.45.4.1).

Tampoco existe culpa si se ha cometido el daño en "estado de necesidad". Tal cual lo dice Celso, corresponde aplicar la *lex Aquilia* "a no ser que se hubiera obrado coaccionado por una fuerza mayor", dándose como ejemplo el caso de que alguien destruyese la casa de un vecino para evitar que el fuego de un incendio llegase hasta él (Celso-Ulp., D.9.2.49.1; D.47.9.3.7; ver variantes en Ulp., D.43.24.7.4).

§ 350 Acciones en favor de quien sufrió el daño.

I. *Actio legis Aquiliae*. En un principio, el propietario de la cosa "dañada" tenía la *manus iniectio*. El pretor la reemplazará por la *actio legis Aquiliae*. Tenía un carácter penal: a) es nozal (Gayo, 4.75); b) se extingue por la muerte del delincuente (Gayo, 4.75), aunque no por su *capitis deminutio* (Gayo, 4.77); c) si existan coautores, todos son perseguidos en forma cumulativa, debiendo cada uno responder por el total de la pena (Ulp., D.9.2.11.2).

1. La acción se da al heredero de quien ha sufrido el daño, pero no contra el heredero del victimario, aunque se termina admitiendo la responsabilidad de éste hasta el monto que por el daño se hubiera enriquecido (Ulp., D.9.2.23.8).

A) La pena, para el caso del daño del capítulo I, consistía en el "mayor valor" que hubiera tenido la cosa durante el año anterior, computado hacia atrás del hecho dañoso (Gayo, 3.210; Ulp., D.9.2.21.1). Para el caso de daños del capítulo III, el "mayor valor" que hubiera tenido la cosa en los treinta días anteriores (Gayo, 3.218; Ulp., D.9.2.29.8).

1. El "mayor valor" podía o no coincidir con el valor en el momento del daño. Así, si se mató un esclavo cojo o tuerto, pero que dentro del año anterior estaba íntegro, el valor, evidentemente, variaba, pues había que pagar el valor del esclavo íntegro (Gayo, 3.214; Inst., 4.3.9).

2. Los juristas agregaron, por interpretación, todo el daño causado al propietario. Así, p.ej., si se mataba un esclavo instituido heredero, se tomaba en consideración no sólo el valor del esclavo, sino también el de la herencia (Neracio-Ulp., D.9.2.23 pr.; Inst., 4.3.10). Igualmente si se hubiera matado a un esclavo comensante, o un caballo de una cuadriga, o una mula de una yunta, se tomaba en consideración el desmedro que había sufrido el grupo (Paulo, D.9.2.22.1).

B) Esta acción tiene el carácter de la "litis-crescencia" contra el demandado que negaba el hecho (no su cuantía). En caso de proseguir la acción y ser condenado quien negaba, el monto del hecho dañoso (*infirmitas*), la pena ascendía al *duplum* (Ulp., D.9.2.25.2; D.47.23.10; Gayo, 4.171; D.47.2.1).

1. Gayo (4.9) la menciona como acción "mixta" (es decir, en parte "reipersecutoria" por la indemnización del valor de la cosa y en parte "penal", precisamente por la posibilidad de la "litis-crescencia", con la cual la condena podía elevarse al *duplum*). E igualmente, por la posibilidad de tener que pagar más que el *simplum*, por la cuestión del "mayor valor" (eventualmente algo más que la estimación de la cosa dañada; 3.214). Justiniano, por estas dos razones, la califica de "mixta" (Inst., 4.6.19), a pesar de haberla llamado "penal" en Inst., 4.3.3.

C) La *actio legis Aquiliae* "directa" sólo se da, en principio, cuando el daño se ha ocasionado de manera "directa" (Gayo, 3.219: causar el daño con su propio cuerpo; Inst., 4.3.16). De ahí que la romanística suele usar la expresión *damnum corpore corpori datum* (daño causado por el cuerpo del victimario (*corpore*) sobre el cuerpo de la víctima —*corpori*—). P.ej.: si mato al esclavo ajeno con una lanza o una espada).

D) Además, la *actio legis Aquiliae* es concedida sólo al propietario de la cosa dañada (*eris = dominus*; Ulp., D.9.2.11.6), y por ser del *ius civile*, que sea ciudadano romano.

II. Pero el pretor, cuando no se cumplían estas condiciones, concedía *actiones in factum* y *actiones utiles*.

1. La denominación de estas acciones es empleada ambivalentemente en los textos del Digesto. Gayo (3.219) las llama *actiones utiles*. Otras veces *actio in factum*, *accommodata legi Aquiliae* (Pomp., D.19.5.11) o *actio in factum ad exemplum legis Aquiliae* (Neracio, D.9.2.53).

2. Justiniano (Inst., 4.3.16) establece la diferencia del siguiente modo: a) cuando se da el doble requisito del *corpore corpori* corresponde la acción directa; b) cuando el daño no se ha producido por la acción directa del victimario (*corpore*), corresponde una *actio utilis*; y c) cuando no se ha provocado un "daño" directo a la víctima, es decir, falta el *corpore*, se da una *actio in factum* (caso de quien, por compasión, desata al esclavo ajeno para que pueda huir).

Pero este criterio, más bien propio de los bizantinos, no concuerda con otros pasajes del Digesto, donde se llama *actio in factum* a lo que Justiniano denomina *actio utilis* (así, Ulp., D.9.2.9.2; D.11.8; D.11.17 pr.; etc.).

3. Como dato curioso, los escollastas (sch. 3a Basil.) dicen que la *actio utilis legis Aquiliae* es una subdivisión de un género más amplio representado por la *actio in factum*, de tal modo que toda *actio utilis* es una *actio in factum*, pero, no al revés, es decir que hay *actiones utiles* que no son *actiones in factum*.

El pretor parecería no haberse preocupado demasiado por esto. La denominación genérica de *actio utilis in factum legis Aquiliae*, le servía para concederla a veces con una fórmula ficticia o *in factum*. Los efectos prácticos de estas acciones, a pesar de que algunos autores establecían que eran por el *simplex*, eran iguales a los que se podía lograr con la acción directa (principio general en Paulo, D.3.5.47.1; D.9.2.12).

A) Así, si el daño no se había producido en forma directa (*corpore corpori datum*), el pretor concede una *actio in factum*, siempre y cuando se entendiera que se había actuado como causa de la muerte o del daño (*causam mortis praestare; causam damni praestare*).

1. El análisis casuístico que nos trae el capítulo del Digesto sobre la ley Aquilia (9.2), es uno de los que despiertan mayor interés.

Así, como supuestos de daños producidos en forma indirecta (*corpore non corpore*), Gayo nos menciona el caso de quien encierra al esclavo o al animal ajenos, y los deja morir de hambre; o el de quien hace ascender al esclavo ajeno a un árbol, o descender a un pozo, y se fractura una pierna; 3.219.

En cambio, arrojándolo desde lo alto a un río, de tal modo que se ahoga, se entiende que la muerte ha

sido realizada en forma directa (Celso-Ulp., D.11.7.7). Pero no si le hostigo el caballo que viene cabalgando un esclavo ajeno y éste cae en el río y se muere; o si lo llevo a una emboscada y otros lo matan (Ulp., D.11.9.3). Corresponde acá la *actio in factum*.

2. Interesante es el caso del médico y del medicamento. Labeón distingue: si el propio médico se lo administró directamente con sus manos al esclavo enfermo y éste muere, corresponde la *actio legis Aquiliae directa*. En cambio, si le dio el medicamento al esclavo para que el mismo lo ingiera, se entendía que más que matarlo el médico, éste había "dado causa para la muerte" y correspondía la *actio in factum* (Labeón-Ulp., D.11.1.1).

3. En los casos anteriores, si bien *non corpore* (es decir, por actuar directo del agente), el daño había sido, sin embargo, *corpore* (el cuerpo de la cosa sufre ya la muerte, lesiones, rupturas, etc.). Pero podía ser que no se ocasionara un "daño" a la cosa, aunque sí un perjuicio al propietario. Así, p.ej., si encuentro al esclavo ajeno encadenado, y por compasión lo libero para que pueda huir, no lo daño al esclavo, aunque sí al propietario. En este caso éste tendrá contra mí la *actio in factum*. Advuértase que si lo libero de sus cadenas para quedarme con él estaría cometiendo *furtum* (Ulp., D.4.3.7.7; Inst., 4.3.16).

Otros ejemplos de cuándo corresponde la *actio in factum* sin haberse producido *damnum corpori*: tomar una cosa ajena, p.ej. una copa y arrojarla al mar (Ulp., D.19.5.14.2); haber mezclado arena al trigo, de manera que resulte difícil la separación (Ulp., D.9.2.27.20); etc.

B) La acción directa de la *lex Aquilia* se concede al propietario civil. Sin embargo, el pretor concede una *actio utilis* a algunos que no lo son, como p.ej. al poseedor de buena fe (Ulp., D.9.2.11.8; D.11.17 pr.); al usufructuario y al usuario (Ulp., D.11.1.10); al acreedor prendario (Ulp., D.9.2.17); y posteriormente también al colono (Ulp., D.9.2.27.14 itp.).

Igual solución, si era un extranjero: el pretor concede una *actio utilis*, con fórmula ficticia, fingiendo la ciudadanía romana; era válida tanto si el extranjero era el actor como el demandado (Gayo, 4.37).

C) Si la víctima que sufre el daño era un hombre libre, no un esclavo, y no estaba implicado el delito de "injurias", podía concedérsele una *actio legis Aquiliae utilis* (Ulp., D.9.2.13 pr.).

1. Figura el caso del zapatero que tiene por aprendiz un hombre libre, y como no ejercía bien el oficio le da un golpe en la cerviz con una horma, con tal vehemencia que le hace saltar un ojo. Según explica Juliano, el *pater* del aprendiz tiene la *actio ex loco* (por la locación que implicaba el aprendizaje), "porque aunque se haya concedido a los maestros la leve

corrección, sin embargo, ésta no guardó moderación". Pero también le compete la *actio utilis* de la ley Aquilia por el daño. No así la acción de injurias (*actio iniuriarum*), "porque esto no se hizo por causa de inferir injuria, sino por enseñar" (*praeceptiendi*; Jul., Ulp., D.19.2.13.4).

D) Igualmente el pretor prevé ciertos casos especiales: a) si el daño ha sido producido por hombres reunidos en banda (*damnum vi hominibus armatis coactisve datum*), la pena es del *quadruplum* (*actio vi bonorum raptorum*); b) o producido aprovechando la ocurrencia de un incendio, naufragio, etc., con pena también del *quadruplum*; c) o producido por una "turba", con pena del *duplum* (ver *supra*, § 346).

IV. Iniuriae.

§ 351. El vocablo *iniuria* tiene varios significados. Ante todo, para designar todo aquello que es contrario al *ius* (*omne quod non iure fit*; Inst., 4.4 pr.). En sentido más particular: a) la falta cometida con dolo o culpa, tal como ocurre con la comisión del *damnum iniuria datum* de la ley Aquilia; o b) como acá se contempla en el delito de *iniuriae*, donde se pena toda afrenta (*contumelia*, del verbo *contemnere*: ultrajar, despreciar), tanto física como moral, producida a una persona libre.

A) En el régimen de la ley de las XII Tabas, las *iniuriae* aparecen configuradas como lesiones físicas: así, si alguien rompiera a otro un miembro (*membrum ruptum*: roto, separado; 8.2); si alguien quebrara el hueso de otro (os *fractum*; 8.3); y también cualquier otra afrenta física (*iniuria*: p.ej., una bofetada; 8.4).

B) Pero más adelante, el concepto de *iniuriae* se va ampliando. El pretor entenderá por tales no sólo las afrentas físicas (golpear a otro con los puños, o con una vara, o azotarlo), sino también las dirigidas por medio de palabras ya verbales o ya escritas (Gayo, 3.220).

1. En el Edicto figura un *edictum generale* (EP, § 190), al cual se agragan edictos especiales que contemplan afrentas particulares. Así: a) el caso del *convicium* (§ 191), referido a las vociferaciones públicas realizadas contra alguien *adversus bonos mores*; b) la *adtemptata pudicitia* (§ 192), consistente en ultrajes al pudor respecto de una mujer casada o de un impúber, apartándolos el acompañante (*comitem abducere*), o siguiéndolos con términos insinuantes; c) la *infamatio* (§ 193); p.ej., haciendo pública una *bonorum venditio* respecto de alguien que en realidad no es deudor, sabiendo que nada le debe; o escribiendo un libelo infamante; d) el azotar o flagelar al esclavo ajeno (§ 194).

§ 352. Se entiende además que las *iniuriae* no solamente pueden ser consideradas contra un hombre libre en particular, sino, además, se la puede sufrir por los *fili* que están *in potestate*, o también por la *uxor*. Habrá tantas injurias y tantas acciones como el número de personas injuriadas. Así, si se injuria a mi hija Ticia, casada con Mevio, no sólo tendrá acción dicha hija, sino también podré accionar yo, así como el marido (Gayo, 3.221; Inst., 4.4.2).

1. En cambio, por la injuria hecha al marido no puede accionar la *uxor*, porque como dice Paulo, "es equitativo que las mujeres sean defendidas por sus maridos, no los maridos por la mujer" (D. 47.10.2; Paulo, 5.4.3; Inst., 4.4.2).

2. En C.9.35.2, se dice que "el marido por pudor en la *uxor* y el *pater* por la estimación de los hijos, se entienden padeciendo la propia injuria".

En cambio, la injuria cometida al esclavo, en principio, no configura responsabilidad. Pero se admite la acción por el *dominus*, cuando injuriando al esclavo, se quiere afrentar a su dueño, poniendo en evidencia un ultraje a él. Pero se debe tratar de hechos graves. Así, se concede la acción cuando se azota o flagela al esclavo (EP, § 194), pero no cuando meramente se le da un golpe de puño o meramente se le insulta en su persona (Gayo, 3.222; Inst., 4.4.3).

§ 353. Para que existan *iniuriae*, es necesario el dolo, o sea, la intención de realizar el acto de manera deliberada. Si se efectúa por simple chanza (*animus iocandi*); p.ej., si golpease a otro por broma, o luchando en un juego, no existiría ninguna *iniuria* (Ulp., D. 47.10.3.3).

1. Los posclásicos hablarán de *animus iniuriae faciendae*, o *adfectus iniuriae faciendi*, lo que señala una tonalidad distinta. Así, en el caso de la *infamatio* (EP, § 193), es decir, insultos públicos, el dolo, o sea, el acto deliberado, coincide con el ánimo de injuriar.

2. Pero en el caso de la *adtemptata pudicitia* (EP, § 192), el hecho de cortejar a una *materfamilias*, por ser *adversus bonos mores*, basta con el dolo de hacerlo, aunque no se tenga la intención de insultarla. Ver, así, la solución dada por Ulpiano al caso de quien se acerca a una mujer vestida como una prostituta; aunque fuere *materfamilias*, no ha ido *adversus bonos mores*, y por ello no se tiene contra él la acción del Edicto (D.47.10.15.15).

§ 354. En la ley de las XII Tabas, las penas de las *iniuriae* estaban tarifadas del siguiente modo: a) en el caso del *membrum ruptum*, correspondía el talión (mutuarse el mismo miembro al otro), a menos que por un pacto se solu-

cionara económicamente la afrenta; b) en el caso del *os fractum*, la pena era de 300 ases si se trataba del hueso fracturado de un hombre libre, y de 150 ases si se trataba del de un esclavo; y c) por las otras *iniuriae*, la pena era de 25 ases. Como lo dice Gayo (3.222), se consideraba que estas penas eran suficientes en aquellos tiempos de extrema pobreza.

1. En los tiempos posteriores, estas penas eran ridículas, por la desvalorización monetaria del as. Aulo Gellio (20.1.13) cita el caso, recogido por Labeo, de la singular costumbre de un tal Lucio Veracio, hombre desalmado y extremadamente malévolo, para quien su mayor placer consistía en ir por la calle y abofetear a quien se le ocurriese. Le seguía un esclavo con una bolsa de ases en la mano; y en cuanto el amo aplicaba una bofetada, el esclavo, según lo dispuesto en la ley, le entregaba al ofendido los 25 ases.

En la época clásica, el pretor, movido por lo ridículo de las penas, e igualmente por un sentido de *humanitas*, concedía una *actio iniuriarum*, que era penal (Gayo, 4.112) y cuya condena aportaba la infamia (Gayo, 4.182).

Por esta *actio iniuriarum aestimatoria*, el pretor permitía que el ofendido estimara el monto de la *iniuria*, y el juez, probada la misma podía condenar *ex bono et aequo* por el monto pedido o uno menor. Pero si se trataba de una "injuria grave" (*atrox iniuria*), el pretor fijaba el mismo el monto, y el juez, por respeto a la autoridad del pretor, no se atrevía a disminuir ese monto (Gayo, 3.224).

2. Para considerar *atrox iniuria* había que tener en cuenta las circunstancias del hecho (*ex facto*): p.ej., el haber herido o flagelado a alguien; las circunstancias del lugar (*ex loco*): p.ej., si ha ocurrido en el teatro o en el foro; las del ofendido (*ex persona*): p.ej., si un hombre de baja condición injuria a un senador o a un magistrado (Gayo, 3.225; Inst., 4.4.9).

3. Si el demandado es declarado inocente, se le concedía a éste contra el que había sido actor, un *contrarium iudicium* por la décima parte de la pena pretendida (Gayo, 4.177).

4. La *actio iniuriarum* se extingue por la *dissimulatio*, es decir, por el perdón del ofendido que olvida —disimula— el ultraje recibido (Inst., 4.5.12; Ulp., D.47.10.11.1; C.2.22.1, 7.13.3).

§ 355. Por la *lex Cornelia de iniuriis*, de la época de Sylla (año 81 a.C.), se había instaurado un proceso criminal respecto de determinadas formas de *iniuriae*: el "golpear" (*pulsatio*), el "azotar" (*verberatio*) y la violación de domicilio (*vi domum introitus*). Es decir, se trata de casos de *iniuriae* (no verbales ni escritas), sino cometidas por la mano (Ulp., D.47.10.5 pr.).

En la legislación justiniana se amplían los casos de la *lex Cornelia* a todos los casos de *iniuriae*, pudiéndose optar entre el juicio criminal o la *actio iniuriarum* (Inst., 4.4.10).

1. Según podemos apreciar en Paulo (5.4.4; 8; 11; 13 ss.), las penas para ciertas injurias en el juicio criminal eran muy rigurosas. Así, para un atentado con violencia al pudor, la muerte; para el crimen de calumnia, la *relegatio in insula*, o la destitución de su orden; el exilio, el metal o los trabajos forzados, según los casos.

V. Actos ilícitos sancionados por el pretor.

§ 356. Las figuras analizadas hasta ahora como delitos (*furtum, rapina, damnum iniuria datum* e *iniuriae*) corresponden al *ius civile*. Pero, a su vez, el pretor fue estableciendo determinadas acciones penales *in factum* para castigar determinadas conductas que consideraba reprensibles.

Así, dos acciones muy importantes que configuraban delitos pretorianos, fueron la *actio quod metus causa*, para castigar a los que obraban con coacción (v. *supra*, § 306), y la *actio de dolo malo*, respecto de quienes empleaban dolo en los negocios (v. *supra*, § 305).

1. También podemos mencionar:

a) la *actio de albo corrupto* (EP, § 7), por la cual se pena con 50.000 sestericios al que altera el texto del *album* del Edicto; esta acción era "popular", es decir, la podía intentar cualquier ciudadano;

b) la *actio de servo corrupto* (D.11.3; EP, § 63), contra aquel que, actuando con dolo, corrompiera a un esclavo ajeno, siendo la pena por el *duplum*;

c) una *actio in factum* contra el agrimensur que con dolo hubiere dado medidas falsas (D.11.6; EP, § 89);

d) la *actio de sepulchro violato* (D.47.12; EP, § 93) por la que se castiga la violación, edificación o inhabilitación de un sepulcro. Era una acción popular. Si la ejercía aquél a quien correspondía el sepulcro, el pretor admite la *caestimatio* que éste efectúe. Si fuera otro, la pena era de 100.000 sestericios en caso de violación, y de 200.000 sestericios en los otros casos.

e) Por una disposición del Edicto de los ediles curules, se prohibía tener animales peligrosos sin atar (*edictum de feris*; EP, § 295). Se daba una acción por el daño que hubieren causado, con una pena de 200.000 sestericios si era la muerte de un hombre libre, la *caestimatio* que se realizara por el actor en caso de heridas, y por el *duplum* del daño en los otros casos.

Y así, un número mayor de acciones.

§ 357. Hay ciertos casos en el Edicto del Pretor, que luego serán consignados especial-

mente por Justiniano como *quasi ex delictis* (Inst., 4.5).

A) En primer término, el caso del juez que hace suya la causa (*Si iudex litem suam fecerit*). Esta expresión "hacer suya la causa" significaba que el juez había asumido el juicio para sí, con todas las consecuencias a su cargo. Esto ocurre cuando el juez ha obrado en forma parcial, y ya por soborno o por amistad (o enemistad) —formas dolosas— o ya por imprudencia o negligencia —formas culposas— hubiera dado la sentencia en fraude de la ley (Ulp., D.5.1.15.1; Gayo, D.50.13.6).

El pretor concedía una *actio in factum*, dejando al arbitrio prudente y equitativo del sentenciante, el monto de la condena (EP, § 59).

1. Hay ciertos problemas de interpretación entre el texto de Ulpiano (D.5.1.15.1), que habla del caso del dolo del *iudex*, estableciendo la condena en el monto del juicio (*vera aestimatio litis*) y el de Gayo (D.50.13.6), quien agrega también la imprudencia, y deja librado el monto de la condena a lo que el *iudex* encuentre equitativo.

Nos parece sensata la argumentación de Lenel, quien establece que había una sola fórmula (y no dos, una para el dolo y otra para la imprudencia), reduciéndose la *condemnatio* en la forma amplia señalada, es decir, por lo que determine el juez: *Quantum ob eam rem tibi videbitur...*

B) La *actio de effusis et deiectis* era concedida contra el *habetator*, es decir, el "habitador" que esté ocupando un edificio (sea propietario, locatario o lo detente a título gratuito), desde el cual se haya derramado (*effusum*) o arrojado (*deiectum*) algo que produzca daño a alguien que pasaba por allí (EP, § 61; D.9.3; Inst., 4.5.11).

1. Si se dañaba una cosa había que pagar el *duplum* del perjuicio ocasionado; Inst., 4.5.1.

Si se había producido una herida a un hombre libre, la acción era redactada *in bonum et aequum*, debiéndose reparar la totalidad de los daños producidos (así, los gastos médicos, y el lucro cesante por incapacidad); Inst., *ibid.*; Gayo, D.9.3.7.

En caso de muerte de un hombre libre, la pena era de 50.000 sestericios (50 sólidos de oro, en época de Justiniano); Inst., *ibid.*

2. La acción se da contra quien "habita" cuando se arroja o se derrama alguna cosa, no contra el dueño de la casa (salvo que sea al mismo tiempo "habitador"). No se exige ni dolo ni culpa directa, penándose el hecho del derramamiento o el arrojado de cosas (Ulp., D.9.3.4).

Pero si un *filius* ocupa una habitación separada de la de su *pater*, y desde ella se ha arrojado o vertido alguna cosa, en principio, según Juliano, no

hay acción contra el *pater* (ni de *peculio* ni *noxal*) y hay que actuar contra el *filius* (Gayo, D.44.7.5.5; Inst., 4.5.2).

Y si bien esto es así, en caso de que el *filius* haya sido condenado, el *pater* resulta responsabilizado por la *actio iudicis*, de tal modo que podía ser demandado pero sólo hasta el monto del *peculio* del *filius* (Ulp., D.9.4.35).

3. Se entiende que esta acción es penal, dada por la equidad (*ex bono et aequo*), porque es de pública utilidad que sin miedo y sin peligro se vaya por los caminos (Ulp., D.9.3.1.1).

Además, en principio es "popular" y perpetua. Si se trata de un daño a un esclavo o a una cosa, entendiéndose que es un daño pecuniario pasa al heredero, pero no se da contra el heredero del *habetator* (Ulp., D.11.5.5).

Pero si se ha ocasionado la muerte de un hombre libre, la acción es sólo anual, pero no pasa al heredero por derecho hereditario (el cuerpo de un hombre libre no admite estimación alguna; Gayo, D.9.3.7), porque es penal y popular. La puede ejercer cualquiera, pero si son varios los que la piden, tienen prevalencia los parientes (Ulp., D.11.5.5).

Si se trata de daños a un hombre libre, éste tiene una acción perpetua; pero si otro intenta la acción, debe ser dentro del año; tampoco compete a los herederos por derecho hereditario, puesto que no es un daño pecuniario (Ulp., *D.11.5.5*).

C) Contra aquél que había derramado (*effusum*) o suspendido (*suspensum*) en un cobertizo o en un balcón que dan a un lugar por donde transite gente, alguna cosa cuya caída pueda ocasionar daño a alguien, el pretor concedía la *actio de posito et suspensio*. Era *popularis* (la podía ejercer cualquiera) y no necesitaba la prueba del dolo o de la culpa, pudiendo el actor obtener 10.000 sestericios (10 sólidos de oro en tiempos de Justiniano); EP, § 62; Ulp., D.9.3.5.6 ss; Inst., 4.5.11).

1. En esta acción *in factum*, el pretor pena el solo hecho de haber puesto o suspendido sobre la vía pública alguna cosa susceptible de dañar si se cayera, protegiendo a los paseantes (Ulp., D.9.3.5.11).

2. La acción se dirige contra quien puso o suspendió la cosa, y también contra aquel que consintió que se pusiera (Ulp., D.9.3.5.10 y 12).

Respecto del caso del *filius*, ocurre lo mismo que en el delito anterior (v. *supra*, este § B.2).

D) Los transportistas marítimos (*nautae*), los que están al frente de un albergue o posada (*caupones*) o de establos (*stabularii*) resultan responsabilizados por el hurto o el daño ocasionado a los viajeros respecto de las cosas o mercancías "que hubiesen recibido para que estén a salvo" (*recepta res salva fore*; Ulp., D.4.9.1 pr.),

realizados por sus empleados u otros pasajeros (Ulp., D.4.1.8; Gayo, D.4.2; Inst., 4.5.3).

1. La *actio*, era *in factum* por el *duplum* (Ulp., D.4.9.7.1), entendiéndose que había culpa por parte del dueño en la elección de tales empleados (Inst., 4.5.3; Ulp., D.4.9.7), cuanto también por el deber de custodia (Gayo, D.4.9.5).

No se responde si el hecho ha ocurrido por "fuerza mayor" (nauffragio, ataque de piratas, etc., Ulp., D.4.9.3.1), ni tampoco si se advirtió a los pasajeros que guardarán sus cosas y éstos aceptaron hacerlo (Ulp., D.4.9.7 pr.).

2 No solamente están comprendidas las cosas "recibidas para que estén a salvo", sino también los

vestidos que se usarán y las demás cosas que tenemos para el uso cotidiano (Ulp., D.4.9.1.6).

3. En caso de individualizarse el culpable del robo o del daño, está abierta la vía para la *actio furti* o la *actio legis Aquiliae*, pudiendo optar el perjudicado por alguna de ellas o por esta *actio in factum* (Ulp., D.4.7.5.1 pr.; 2-3).

Quien ha entregado cosas a estas personas, tendría igualmente las acciones de restitución, como la de locación (si medio precio) o la de depósito. Si el pretor otorga esta acción, es para reprimir la conducta de los *nautae*, *caupones* y *stabularii* que hubieran tenido que impedir el hurto o los daños por parte de sus empleados u otros pasajeros (Ulp., D.4.9.3.1).

CAPÍTULO 4

OBLIGACIONES QUE SE CONTRAEN POR LA COSA LOS PRÉSTAMOS (CONTRATOS REALES)

§ 358. *Características.* Gayo (3.90-91) nos habla de "obligaciones contraídas por la cosa", y lo mismo ocurre en las Institutas de Justiniano (3.14 pr.; *Re contrahitur obligatio*). A su vez, en el Edicto figura el título 17: *De rebus creditis* (Sobre las cosas prestadas). De ahí que aquí estamos en presencia de *préstamos*.

a) La característica fundamental es que se ha operado por parte de alguien la *traditio* de una o varias cosas, de tal modo que por el hecho de haberlas recibido nace la obligación de devolverla a quien se la entregó. Puede ir acompañada, y generalmente es así, de un convenio previo, que es el que aclara la "causa" de la entrega. Pero puede suceder que éste no exista (caso, p.ej., del "pago de lo indebido") y, sin embargo, la obligación de devolver nace lo mismo. Dicho más simplemente, la obligación nace propiamente de la entrega de la cosa (por ello es *obligatio re*), y no del convenio. Así, una mera convención de querer prestar una cosa a otro no engendra una obligación civil (Paulo, D.45.1.68).

b) Dentro de los préstamos, tenemos que comprender las figuras que luego, para los bizantinos, serán los "contratos reales". Primero, y ante todo, figura el *mutuo*, en el cual alguien da por *traditio* una cosa fungible (generalmente dinero), de la cual adquiere el dominio, pero que obliga al *accipiens* (el que recibe, por ej., el dinero) a devolver tanto cuanto recibió. Y también, el *comodato*, o "préstamo de uso" de una cosa que se tiene en tenencia, y el *depósito*, que sería un "préstamo de guarda", respecto de una cosa que se tiene también en tenencia. Y el *pignus* (prenda), o "préstamo de garantía", respecto de la posesión que el deudor ha dado al acreedor (Gayo, D.44.7.1.3-6; Inst., 3.14.2-4).

Pero *credere* (o *res creditae*) abarca otros supuestos, por cuanto es un vocablo genérico, p.ej., respecto del *mutuo* que es una especie. De ahí que existan otras *dationes* que originan obligaciones real de restituir: a) para conseguir algo del *accipiens* (ob *rem*); b) por una causa determinada (ob *causam*); y c) por causas eventuales (ex *eventu*). Justiniano, aparte de considerar las cuatro figuras de "contratos reales", denominará

a las *dationes ob rem*, contratos reales innominados, y las otras dos clases (ob *causam* y ex *eventu*), como cuasicontratos.

Vemos, por ello, que *credere* (o *res creditae*) que obligan a la restitución, es un género; respecto del cual, p.ej., el *mutuo* es tan sólo una especie (Paulo, D.12.1.2.3).

Contratos reales

I. Mutuo

§ 359. *Concepto.* El *mutuo* (*mutuum*) es un préstamo de dinero o de otras cosas fungibles y consumibles (vino, aceite, etc.), que consiste en la atribución de su propiedad a quien las recibe, el cual queda obligado a restituir una cantidad igual de éstas y no las mismas que ha recibido. Es un "préstamo de consumo" (Gayo, 3.90).

1. *Mutuum* se forma a partir del verbo *mutare* (= "cambiar de lugar", "desplazar" y en consecuencia "cambiar en propiedad". En realidad no hay un enriquecimiento, puesto que si se presta algo, no pierdo nada, puesto que tú comienzas a debérmelo (*res alienum*: "dinero ajeno"). Si bien puede consistir en cosas fungibles y consumibles, lo más típico del *mutuo* es el préstamo de dinero.

El requisito esencial del *mutuo* es la transmisión de la propiedad a quien recibe la cosa. Si no se produce esa transmisión, la obligación no comienza (Paulo, D.12.1.2.2; Paulo 2.14.17). Es, por tanto, una *obligatio ex re* (comienza cuando el mutuario recibe la cosa, o sabe que es suya). Como ya lo dijimos, una promesa de *mutuo* o un convenio de que te daré algo en *mutuo* es algo preliminar; no basta para tener por perfeccionado el *mutuo* y no engendra obligación civil (Paulo, D.45.1.68).

2. Además se considera que se tuvo que haber convenio entre las partes el acuerdo de que lo que se daba lo era en *mutuo* (Paulo, D.44.7.3.1). Si se da o se recibe con otra intención, p.ej. para donar o tener en depósito, no hay *mutuo* (Ulp., D.12.1.18 pr.).

§ 360. *Formas de constitución del mutuo.* La forma normal de constituir el mutuo es la entrega del dinero por una *traditio* del mutuario o prestamista, al mutuario o prestatario. Pero también tenemos otros casos, en los cuales, aunque no se haya realizado en dicha forma, lo mismo constituye un mutuo:

a) Te doy monedas en depósito, y luego te permito usarlas y gastarlas: el depósito se convierte en mutuo (Nerva-Próculo-Marcelo, Ulp., D.12.1.9.9).

b) Tú eres mi mandatario, y te he indicado que lo que recibas en pago de un deudor mío, lo puedas gastar en carácter de mutuo (Pap., Ulp., D.17.1.10.4).

c) Si le indico a un deudor mío que el dinero debido por él se lo dé a otro (*delegatio*) de tal modo que mi deudor primero extingue la obligación, y el tercero que ha recibido el dinero lo tiene en carácter de mutuo (Ulp., D.12.1.15; Afric., D.17.1.34 pr.).

d) En general, indicando a otro, p.ej., mi banquero (*argentarius*), que siguiendo mis instrucciones, dé dinero a otro (Ulp., D.12.1.9.8; Paulo, D.45.1.126.2).

e) Cuando se da a otro una cosa para que la venda y retenga el precio obtenido como mutuo. Si te di la cosa con intención de que la vendieras, y ella se pierde antes de la venta, la responsabilidad por la pérdida será para mí. Si, en cambio, te la di, porque me habías pedido dinero y no lo tenía, entonces la responsabilidad es tuya (Ulp., D.12.1.4 pr.; Ulp., D.12.1.1 pr.).

§ 361. *Acciones.* El mutuo obliga al mutuario a devolver la misma cantidad de cosa prestada. No la misma cosa (como en el comodato o en el depósito), ni tampoco otra cosa distinta (sería una permuta); Paulo, D.2.4.17 pr.; D.12.1.2 pr.

Para poder exigir la acción tiene la *actio (condictio) certae creditae pecuniae*, cuando se trataba de sumas de dinero. Si era de otras cosas fungibles y consumibles, se concedía la *condictio certae rei (quantitatis)*, que los bizantinos denominarán *condictio triticaria* (Ulp., D.13.3.1; EP, § 95).

1. La fórmula de la *actio (condictio) certae creditae pecuniae* es "abstracta" (no se menciona la causa de la obligación): "Si aparece que N.N. deba dar (*dare oportere*) 10 000 sesteracios a A.A., entonces *iudex* condena a N.N. a dar a A.A. 10.000 sesteracios. Si no resulta probado, absuélvelo".

2. La fórmula de la *condictio certae rei (quantitatis)*, también abstracta tiene una *intentio certa*, pero incerta la *condemnatio*: "Si aparece que N.N. deba dar (*dare oportere*) 100 medidas de óptimo trigo africano, por cuanto sea el valor de la cosa, condena a N.N. por ese monto de dinero en favor de A.A. Si no resulta probado, absuélvelo".

3. Los dos casos proceden de la reforma realizada por la ley *Asutia*, sobre la base de la transformación de la *legis actio per conditionem*.

§ 362. *Intereses.* El mutuo es gratuito. Sólo se debe devolver la cantidad prestada. Los intereses (*usurae*) no resultaban naturalmente de la esencia del mutuo. Pero se podían agregar. Para ello había que celebrar una *stipulatio* especial (*stipulatio usurarum*); o también establecer el mutuo con una *stipulatio* que abarque el capital (*sors*) y los intereses (*usurae*), es decir, la *stipulatio sortis et usurarum* que permitía luego reclamar ambos importes en forma conjunta.

1. Si se establecían intereses por meros pactos, éstos no podían ser exigidos por una *actio* (los pactos no generan acciones); pero si se hubieran pagado voluntariamente, entonces pueden ser retenidos por el mutuante mediante una *exceptio*, salvo que sobre-pasaran la tasa legal (Ulp., D.12.6.26 pr.).

En la época clásica, los intereses estaban en el orden del 1 % mensual, siendo denominados *centessimae usurae* o *halendariae* (porque se cobraban el día 1 de cada mes —*kalendae*—, generando la *actio kalendarii* (Pap., D.26.7.39.14). La legislación cristiana se mostró restrictiva, prohibiendo la usura a los senadores (CTh.2.23.3; año 397). Justiniano fijó la tasa ordinaria en el 6 % anual (C.4.32.26.1), pero estableció algunas tasas distintas: así, para los *negotiatores*, el 8 %; para las *illustrae personae*, el 4 %, y para los agricultores un poco más del 4 % (4 1/6 %).

2. En un tipo especial de mutuo, el *fenus nauticum* (o *pecunia traecticia*) el interés solía ser mayor. Ello era debido a las características de este préstamo vinculado con las actividades marítimas. El prestamista prestaba dinero al armador del barco que iba a comerciar mercaderías, pero tomaba para sí el riesgo de la travesía, de tal modo que sólo podía reclamar lo prestado cuando dichas mercaderías llegaran sanas y salvas a puerto. Era una forma de "seguro", por lo que se explican los intereses más altos, que cubrían el riesgo (D.22.2; C.4.33).

Ya desde la época clásica se estableció que los intereses nunca podían superar el doble del capital (*supra duplum*), y si lo excedían, y se hubiera pagado, se podían repetir por dicho exceso (Ulp., D.12.6.26.1; Caracalla, C.4.32.10). Justiniano siguió también este criterio (Nov.121.2).

También estaba prohibido el "anatocismo", es decir, el cobrar intereses de intereses, capitalizándolos (Marciano, D.22.1.29; Ulp., D.12.6.26.1), si bien se puede ver en Cicerón que primero se prohibió el anatocismo que implicaba la capitalización mensual (*ad Att.* 5.21.11), y luego, la anual (s.c. cit. en *ad Att.* 5.21.13). Justiniano prohibió incluso la convención por la cual el deudor aceptaba la conver-

sión de intereses vencidos en capital (C.4.32.28; año 529).

§ 363. *Senatusconsultum Macedonianum.* Es de la época de Vespasiano (Suet., *Vesp.*, 11), quien habría renovado los principios de una ley de Claudio (Tác., *Ann.*, 11.13). La medida fue tomada debido a la situación particular de los jóvenes romanos que solían pedir sumas de dinero, a veces a intereses elevados para gastarlas en costumbres disipadas. Según se contaba, parece ser que uno de ellos, de nombre Macedo —de ahí el nombre del s.c.—, apremiado por un usurero, dio muerte a su padre para heredarlo y de este modo pagar y seguir gozando de crédito.

Según este s.c. Macedoniano, se le niega la acción a quien hubiera dado en mutuo dinero a un *filius*, aun cuando la *actio certae creditae pecuniae* se la quiera ejercer después de la muerte del pater. El pretor estaba autorizado a denegar la *actio*, pero por regla general acataba lo dicho en el s.c. insertando una *exceptio* en la fórmula, en obediencia al s.c. (Ulp., D.14.6.1 pr.; EP, § 279).

1. En general, el préstamo de dinero hecho a un *filius* era válido *iure civile*, a pesar de que no adquiría la propiedad de lo recibido, por cuanto era del pater. Si bien el prestamista podía accionar contra él, la condena se tornaba imposible por cuanto no tenía patrimonio. Sólo podía cobrarse el prestamista cuando el *filius* se hiciera *sui iuris*.

De ahí que el s.c. Macedoniano, con evidente propósito moral, negara la *actio* aun después de la muerte del pater, con lo que desalentaba que se diera dinero en mutuo a los jóvenes que estaban *in potestate*.

2. Los efectos del s.c. Macedoniano se extendieron también a la *filia* (Ulp., D.14.6.9.2), y también al nieto que hubiera actuado por mandato del hijo (Jul., D.14.6.14).

En principio, lo que estaba prohibido era el préstamo de dinero. No el mutuo por otras cosas fungibles y consumibles, salvo que con ello se quisiera cometer fraude al s.c.; así, si se daba en mutuo trigo, vino o aceite para que el *filius* los vendiera y se aprovechara del dinero obtenido (Ulp., D.14.6.7.3). Lo que se permitía era un mutuo módico, por una suma razonable que el *filius* pide por razón de estudios, y su padre acostumbraba dársela (Ulp., D.14.7.13).

3. El *debitum* de un mutuo en dinero a un *filius* no resultaba nulo, si bien el acreedor no puede hacerlo efectivo. Pero si el *filius* o su pater pagan, no pueden luego repetir lo pagado (Marciano, D.12.6.40; Ulp., D.14.6.9.4). Los bizantinos hablan de que dicho *debitum* es una obligación natural (Paulo, D.14.6.10).

El s.c. no se aplica: a) si el *filius* podía obligarse por sí, por tener un *peculium castrense* (Ulp., D.14.6.2); b) si por error excusable el prestamista creía tratar con un *sui iuris* (Ulp., D.14.3 pr.); c) si se hizo el mutuo con el consentimiento del pater (C.4.28.2, año 198); sería el caso de la posibilidad de las acciones *adiecticiae qualitatis*: así, si el pater lo autorizó (*actio quod iussum*), o si lo puso como agente suyo (*actio exercitoria*, al frente de una nave; *actio institoria*, al frente de un negocio); o si el pater se enriqueció con el mutuo (*actio de in rem verso*); (Ulp., D.14.12); d) si el *filius* al tiempo del préstamo era soldado (C.4.28.7.1; año 530).

II. Comodato.

§ 364. *Concepto.* El comodato (*commodatum; utendum dare*) es el préstamo otorgado por el comodante al comodatario de una cosa corporal no consumible, para que éste la use gratuitamente durante cierto tiempo, debiendo luego restituirla. Es lo que se denomina un "préstamo de uso".

El comodatario es un simple detentador de la cosa, quedando la posesión en el comodante (Pomp., D.13.6.8; Ulp., D.14.9).

1. La cosa prestada debe ser no consumible, puesto que luego hay que devolver esa misma *species*. Pero se permite dar en comodato una cosa consumible al solo efecto de exhibirla (*ad pompam vel ostentationem*; Ulp., D.13.6.3.6).

2. Lo típico del comodato es su gratuidad. Si hubiera que pagar algo por el uso de la cosa, estaríamos en presencia de una *locatio et conductio* (Ulp., D.13.6.5.12).

3. Se puede dar en comodato incluso una cosa ajena que poseemos, aún sabiendo que no nos pertenece. Así, el ladrón o el poseedor de mala fe pueden efectuar este préstamo (Paulo, D.13.6.15; Marcelo, D.14.16).

§ 365. *Obligaciones del comodatario.* El comodatario debe usar de la cosa teniendo en cuenta la naturaleza de ella y también lo convenido entre las partes. Así, si te presté un caballo para tus ocupaciones diarias y tú lo llevaste contigo a la guerra, deberás responder no sólo por la *actio commodati*, sino también por la *actio furti usus* (Gayo, 3.196; Ulp., D.13.6.7.8; Inst., 3.14.2).

En principio, el préstamo de uso gratuito es efectuado en el interés del comodatario. Por ello su responsabilidad se acrecienta. No sólo queda obligado por el dolo y por la culpa, sino también por la *custodia* (Ulp., D.13.6.5.2; Gayo, 3.206). En virtud de ella, debe poner en la cosa la misma diligencia que pone en sus cosas una *diligentissimus paterfamilias* (Gayo, D.13.6.18 pr.).

Los bizantinos hablan de *exacta diligentia*, no bastando haber tomado con la cosa prestada el mismo cuidado que tiene costumbre de dar a las suyas propias, si es que una persona más cuidadosa hubiera podido conservarla (Inst., 3.14.2).

1. Todo ello lleva necesariamente a una casuística muy interesante. El caso más relevante es el del *furtum* de la cosa. Así, si la cosa dada en comodato era hurtada por un tercero, el comodatario responde siempre de ella. Es por ello que por su interés en la cosa, se le concede al comodatario la *actio furti* (Gayo, 3.206; Ulp., D.13.6.10.1; Pap., D.47.2.78 pr.).

El *furtum* puede ser considerado como un caso fortuito. (*casus minor*). En cambio, no responde por un caso de *vis maior*, como puede ocurrir ante una fuerza irresistible: así, si le ha sido arrebatada por una banda de ladrones, o por piratas, o en un naufragio o en un incendio, si no ha mediado culpa del comodatario o si pudiendo salvar las cosas dadas en comodato, prefirió las suyas (Inst., 3.14.2; Ulp., D.13.6.5.4; Gayo, D.fid.18 pr.).

Pero se aclaraba al respecto que había que distinguir entre estos dos supuestos: si te había dado la cosa para que la llevases en un viaje y has sufrido el ataque de piratas o enemigos, o ha sucedido un naufragio, entonces cesaba la responsabilidad del comodatario. Pero si, en cambio, te la he prestado simplemente para que la uses y tú la llevas en un viaje, aun cuando te sucedan esas mismas circunstancias, deberás responder (Gayo, D.13.6.18 pr.; Inst., 3.14.2).

2. Normalmente los esclavos no son vigilados, por lo que, en principio, no responde el comodatario por la custodia. Pero si se trata de un esclavo que estaba preso, o de tal edad que necesitase custodia. Y también si asumió el comodatario la responsabilidad por custodia (Ulp., D.13.6.5.6).

3. A veces el interés del comodato, que normalmente lo es en interés del comodatario, puede serlo en interés común de éste y del comodante. Así, p.ej., hemos invitado tú y yo a cenar a un amigo común, y yo te presté la platería; o si he prestado a mi esposa o a mi uxor cosas para su atavío más decente; o si quien ha organizado una representación ha dado cosas en comodato a los comediantes. En estos casos, el comodatario responde sólo del dolo (Ulp., D.13.6.5.10; Gayo, D.fid.18 pr.).

4. La cosa debe ser devuelta en el estado normal que tenía. Por tanto, el comodatario responde de todo deterioro que no fuere ocasionado por un caso de "fuerza mayor" (por ladrones en banda, piratas, etc.), Ulp., D.13.6.3.1).

Si el daño fue causado por un tercero el comodatario podía devolverla tal cual estaba, porque "con qué cuidado pudo conseguir que por otro no pudiera causarse daño con injuria?", teniendo el propietario la acción de la *lex Aquilia* (Juliano, D.9.2.11.9, D.13.6.19) Pero en la última época clásica, predomi-

na la opinión de Marcelo acerca de que pueden existir excepciones: así, si el comodatario pudo vigilar para que no se causara el daño, o si éste fue ocasionado por la propia persona que puso para vigilar (Marcelo-Ulp., D.19.2.41).

§ 366. *Actio commodati*. El comodante tenía la *actio commodati* para lograr recuperar la cosa prestada, y ello debía ocurrir cuando por las características del préstamo se entendía que había concluido el comodato. O si había un plazo, había que respetar éste (Ulp., D.13.6.5 pr.), no pudiéndose reclamar antes (Paulo, D.fid.17.3).

1. Esta *actio* era *in factum*. Se habla de que en la época clásica existió también una *formula in ius*. Esto ocurre por el texto aislado de Gayo (4.47). Pero ello resulta muy dudoso, temiéndose una interpolación posterior.

De haber sido *in ius* tuvo que haber sido *ex fide bona*. Por un lado, Gayo mismo no incluye la *actio commodati* en la lista que hace de las *actiones bonae fidei* (4.62). Y en el Edicto, esta *actio commodati* no figura en el tít. *De bonae fidei iudiciis*, sino en la de los préstamos de cosas: *De rebus creditis* (EP, § 98).

2. En los textos bizantinos figura como *actio bonae fidei* (Ulp., D.13.6.3.2 it.; Inst., 4.6.28) Ello resulta congruente con la idea justiniana de considerar al *commodatum* como un "contrato real", al igual que el *depositum*.

Igualmente, se habla de una *actio commodati contraria* (Paulo, D.fid.17.2), que tiene el comodatario para exigir del comodante el reintegro de ciertos gastos ocasionados por el cuidado de la cosa (así, los gastos por enfermedad de un esclavo prestado; no así su manutención, que corresponde al comodatario; Gayo, D.13.6.18.2); o para reclamar los perjuicios sufridos por haber entregado el comodante, a sabiendas, la cosa con defectos (así, vasos con desperfectos, habiéndose derramado el vino o el aceite; Gayo, D.fid.18.3); o por quitarle la cosa intempestivamente (Paulo, D.fid.17.2).

3. Esta forma presenta también problemas, por lo menos para su existencia en el derecho clásico. Trebacio (Paulo, D.4.3.18.3) consideraba que el remedio era la *actio de dolo* ejercida por el comodatario, por lo que se puede pensar que frente a un reclamo de entrega intempestiva, sería suficiente la *exceptio doli*.

En cambio, los textos bizantinos hablan de la posibilidad de una *compensatio* (propia de los *iudicia bonae fidei*) respecto de la *actio commodati directa*, pero como, ésta podía traer problemas, por el carácter gratuito del comodato o porque los daños reclamados fueran superiores al valor de la cosa, se consideró necesaria la *actio commodati contraria* (Gayo, D.13.6.18.4 it.).

III. Depósito.

§ 367. *Concepto*. El depósito es un contrato de buena fe, por el cual una persona (depositante) entrega a otra (depositario) una cosa, confiándole su guarda. El depositario se obliga a devolverla cuando el depositante se la reclame.

1. En el derecho arcaico existía una *actio* contra el depositario inñ por el *duplum*. Se trataba de una *actio poenalis* (no exactamente la *actio furti nec manifesti*) que tendía a reprimir la violación de la lealtad (*fides*). En aquellos tiempos, era usual el poner bajo el resguardo de otro las cosas valiosas cuando alguien se debía ausentar.

2. Aparece luego una *actio in factum* contra el depositario-que actuó con dolo-cuya condena era por el *simplex*; pero se agravaba por el *duplum* cuando el depósito había sucedido por causa de tumulto, incendio, ruina, naufragio, debido al estado de necesidad que rodeó la entrega.

Más adelante, en la república tardía, o comienzos de la época clásica, apareció la *actio in ius* que contenía la cláusula *ex fide bona* (Gayo, 4.47, que nos tras ejemplos de las dos fórmulas).

3. A partir de entonces, el depósito puede ser considerado un contrato. La obligación es *obligatio re*, puesto que la obligación de restituir nace después de haberse recibido la cosa (Pomp-Ulp., D.16.3.1.11), por lo que se podría considerar un "préstamo de guarda". Pero en el Edicto, la *actio depositi* no figura en el tít. *De rebus creditis* sino en el *De bonae fidei iudiciis* (EP, § 106) Esto es debido a la importancia especial de la *fides* que intervenía en el negocio, lo que determinará consecuencias distintas que para los demás préstamos.

§ 368. Contenido del contrato de depósito.

a) El depositario adquiere sobre la cosa no la *possessio*, sino la mera *detentio* (tenencia), quedando la propiedad y la posesión en manos del depositante (Florentino, D.16.3.17.1).

1. Según narra Gayo (2.60), el depósito podía hacerse transmitiendo la propiedad de la cosa mediante una *fiducia cum amico*: Así, Ticio transmite a Sempronio una cosa por la *mancipatio* o la *in iure cessio*, para que éste la guarde como si fuera propia. Al volver Ticio, por la *fiducia* Sempronio se la debía retransmitir por los mismos modos. Si existía algún problema en la devolución y posterior retransmisión, bastaba con que Ticio poseyera la cosa durante un año, para que se operara la *usureceptio*, forma especial de *usucapio* (Gayo, 2.69).

La *fiducia cum amico* quedaba reservada a las *res mancipi*. En el caso de una *res nec mancipi*, se podía obtener efectos análogos. Se hacía una *traditio*, prometiendo el que se quedaba con la cosa, por un *stipulatio*, retransmitirla al propietario.

2. En el depósito, como sólo se da la tenencia al depositario, puede darse en guarda una cosa ajena (Paulo, 2.12.1 = Coll.10.7.1). Por ello, puede hacerlo el poseedor y también el ladrón (Tryf., D.16.3.31.1).

b) El depósito es gratuito. Si mediara una retribución, entonces debe ser entendido como una *locatio et conductio* (Ulp., D.16.3.1.9; Inst., 3.26.13). Sin embargo, Justiniano admitirá que no es contrario a la naturaleza del depósito el pago de una módica merced (Ulp., D.47.8.2.23; D.13.6.5.2 itps.).

c) La principal obligación del depositario es la conservación de la cosa que le ha sido entregada. Le está prohibido el uso de ella, bajo pena de incurrir en *furtum usus* (Gayo, 3.196; Inst., 4.1.6).

d) A diferencia del comodatario, que se responsabiliza por la "custodia" de la cosa prestada, el depositario responde sólo por el dolo (Gayo, 3.207; Inst., 3.14.3). Ello se explica por cuanto el contrato, gratuito, es en neto interés del depositante, de tal modo que suya es la responsabilidad, en caso de culpa por haber elegido a un depositario negligente (Ulp., D.13.6.5.2; Inst., 3.14.3). Por tanto, el depositario no responde por el *furtum* de la cosa depositaria (Inst., *ibid.*). Pero hay ciertos casos en los cuales el depositario tiene que responder también por la culpa.

1. Así, se agrava su responsabilidad: a) si se ha pactado que el depositario responda por la culpa (Ulp., D.16.3.1.6), o por el *periculum* de la cosa (Ulp., D.2.14.7.15); b) si el depositario se ofreció directamente a serlo (Jul-Ulp., D.16.3.1.35); c) si el depósito se hizo en interés exclusivo del depositario (así, el depósito "irregular" de una suma de dinero; Ulp., D.12.1.4 pr.).

Sin embargo, ya en la época clásica se admite que la *culpa lata*, es decir, la culpa grave queda comprendida en el dolo (Celso, D.16.3.32; "si alguno no es diligente de la manera que requiere la naturaleza de los hombres"), siendo de ella responsable el depositario.

2. En cambio, no se puede pactar que el depositario no responderá por su dolo, porque va contra la *fides* del contrato (Ulp., D.16.3.1.7).

e) Finalmente, el depositario debe devolver la cosa cuando se la reclame el depositante, incluso antes de haber vencido el plazo que hubiere, puesto que se entiende que éste fue establecido en favor suyo (Ulp., D.16.3.1.45-46).

§ 369. *Clases especiales de depósito*. El depósito normal, "regular", consiste en la guarda de una cosa mueble. Pero se contemplan ciertas clases especiales:

A) *Depósito necesario* (*depositum miserabile*). Cuando el depósito se efectuaba bajo la presión de una irresistible necesidad (así, en caso de tumulto, incendio, ruina o naufragio), entonces se agravaba la responsabilidad del depositario que ha tenido que ser elegido en circunstancias tan apremiantes.

Por ello, la *actio depositi* era por el *duplum* contra el depositario que se niega a restituir (Ulp., D.16.3.1.1; EP, § 106).

1. Si se dirigía contra el heredero del depositario, éste debía responder por el dolo del causante, por una acción anual y sólo por el *simplum*. En cambio, si se trataba de dolo del heredero, la acción era perpetua y por el *duplum* (EP, § 106; Ulp., D.16.3.1.1 ss.; Neracius, D.f.d. 18).

B) *Depósito irregular* (*depositum irregulare*). Durante la época clásica, el dinero sólo podía ser objeto de depósito cuando el depositante lo hubiera entregado en una bolsa o en un cofre cerrado o sellado, de tal modo que cuando lo reclamara el depositante, había que restituir dicho recipiente (Alfeno, D.19.2.31). En cambio, si se entregaba dinero amonedado, ello representaba un mutuo, con la posibilidad de usarlo quien lo recibía, siendo reclamable dicha suma por la *actio (condictio) certae creditae pecuniae*.

1. Esto es lo que resulta de la lectura de textos como el de Ulpiano (Nerva, Práculo, Marcelo-Ulp., D.12.1.9.9); Paulo (D.16. 3. 1.34); Papiniano (D.f.d. 24), todos los cuales fueron interpolados por los bizantinos.

Las prácticas bancarias, usuales en los derechos helenísticos, establecieron la posibilidad de considerar el depósito de dinero, como un *depositum irregulare*, de tal modo que el depositario podía usar de este dinero y devolver, cuando le fuera reclamado por el depositante, una suma equivalente (Ulp., D.16.3.1.34; Pap., D.f.d. 24 itps.).

2. Este negocio se parece mucho al mutuo. Sin embargo, se puede establecer una diferencia: a) en el caso del mutuo, el dinero es dado en interés del mutuario que lo pidió, y si se establecieron por una *stipulatio* intereses, en interés de ambas partes; b) en el caso del depósito de dinero, el negocio es en el solo interés del depositante.

Por ello, el depositario, en principio, sólo debe devolver el mismo monto de monedas que le fueron entregadas (Alfeno, D.19.2.31), salvo que se hubiera pactado lo contrario (Pap., D.16.3.26.1) o se hubiera incurrido en mora (Pap., D.f.d.25.1). Todo ello podía ser exigido por la *actio depositi*, que es *bonae fidei*.

En cambio, de haber sido un mutuo, el que entregaba dinero sólo lo podía reclamar mediante la

actio certae creditae pecuniae, que era de derecho estricto, y no abarcaba los intereses, salvo que hubieran sido estipulados. Eran las mismas partes, las que debían dar a entender si se seguía un negocio u otro.

Pero los juristas tienden a utilizar más la *actio certae creditae pecuniae* que la *actio depositi*. (Ulp., D.12.1.9.9).

C) *Secuestro* (*sequestrium*). En este caso, dos o más personas resuelven encomendar la cosa a otro, como depositario (*sequester*). Éste deberá guardarla y devolverla, no a cualquiera de los codepositantes, sino al que resulte vencedor, ya de un litigio, o de una apuesta (Paulo, D.16.3.6). El efecto principal es que el secuestratario es considerado *possessor*, gozando de la protección interdicial (Florentino, D.16.3.17.1). El pretor concede contra el secuestratario una *actio in factum* (*actio sequestrataria*; Ulp., D.4.3.9.3; Pomp., D.16.3.12.2).

1. La posesión es sólo *ad interdictum*. Los otros beneficios posesorios, sobre todo la *usucapio*, no le corresponden. La restitución debe ser efectuada a la parte que triunfe y a quien haya que devolver la cosa, salvo que se le hubiera dado la cosa por otra finalidad que la guarda (Jul., D.41.2.39).

§ 370. *Actio depositi*. Podía ser ejercida bajo la forma de *actio depositi directa* (es la que tiene el depositante contra el depositario para que entregue la cosa y responsabilizarlo por los daños y perjuicios sufridos); pero también existía la *actio depositi contraria*, que tenía el depositario contra el depositante para hacerse pagar los gastos ocasionados por el depósito (EP, § 106, Modest., Coll.10.2.5), así como los daños que le ocasionó (así, un esclavo indolente; Afric., D.47.2.61.5).

1. En Gayo (4.182), la *actio depositi*, sin más, dada la implicancia de la *fides*, ocasiona la infamia. Para Justiniano, sólo la *actio depositi directa*, no la *contraria* (Inst., 4.16.2).

2. En la época clásica, el depositario, al ejercer la *actio depositi contraria*, podía oponer la compensación y valerse del *ius retentionis*, es decir, no entregando la cosa hasta que se le pagara. Justiniano suprimió estos derechos (C.4.34.11).

IV. Pignus (prenda).

§ 371. *Terminología. Concepto*. La palabra *pignus* sirve tanto para designar la garantía prestada al acreedor (con o sin *traditio* de la cosa), tanto como la cosa misma que constituye dicha garantía.

1. Cuando se trata de *pignus* con desplazamiento de la cosa (*traditio*), estamos en presencia de lo que

en el derecho actual se denomina "prenda". En cambio, en caso de *pignus* sin desplazamiento, estamos ante la *hypotheca*. En términos de derecho moderno, ambas formas del *pignus* constituyen "derechos reales de garantía". Todo ello ha sido estudiado a propósito de los *iura in re aliena* (ver *supra*, § 235 y ss.).

Acá, lo que vemos es la *obligatio ex re*, que nace para el acreedor a causa de habérsele realizado la transmisión de la cosa (caso típico de la "prenda"), que deberá restituir luego de haberse pagado la obligación principal. Será considerada por Justiniano un "contrato real" (Inst., 3.14.4).

§ 372. *Derechos y obligaciones del acreedor prendario*. Esta obligación se contrae *ex re*, es decir, a partir del momento en que el deudor — u otra persona — le hace entrega de la cosa en garantía al acreedor (Gayo, D.44.7.1-6).

a) El acreedor detenta la posesión de la cosa, pero simplemente a título de garantía. Es así que por ser poseedor tiene la protección interdicial, pero no puede, en principio, usar de la cosa, ya que cometería *furtum usus* (Gayo, D.47.2.54 pr.). Es un verdadero "préstamo de garantía".

b) El acreedor, mientras detenta la cosa es responsable por los daños ocasionados a ella, no sólo por dolo, culpa, sino también por *custodia* (los bizantinos la denominarán *diligentia in custodiendo*). Su responsabilidad es igual a la del comodatario. Por ello responde también por el *casus minor* (así, por el *furtum* de la cosa; Gayo, 3.203-4; Ulp., D.13.7.13.1; Paulo, D.f.d.14 (se debe comportar como un *diligens paterfamilias*).

c) El acreedor debe devolver la cosa dada en *pignus* cuando se ha satisfecho la obligación. La restitución debe efectuarse con todos sus accesorios y frutos (Ulp., D.13.7.22 pr.). En caso de no hacerlo así, el deudor tiene contra él la *actio pignoratitia*, para que se lo condene a devolverla (Ulp.; D.13.7.9.3; EP, § 99).

1. En la época clásica, esta *actio pignoratitia* tenía una *formula in factum*. Resulta muy improbable que para esos tiempos se haya admitido una *formula in ius* (v., sin embargo, C.4.24.6, año 225).

Justiniano, en cambio, la considera *in ius* y la ubica entre las *actiones bonae fidei* (Inst., 4.6.28). Del mismo modo, habla de una *actio pignoratitia contraria* (posiblemente en la época clásica, los mismos efectos se conseguirían por la *actio negotiorum gestorum contraria*).

El cambio tiene importancia, por cuanto por ser un "préstamo de garantía", bastaba la *actio in factum*; en cambio, la configuración del *pignus* como "contrato real", facilitaba la redacción *in ius*.

2. Por la *actio pignoratitia contraria*, puede reclamar el acreedor del deudor: a) cuando, sin saberlo,

se le dio en prenda una cosa ajena, o se ocultó la que estaba pignorada, o cuando el deudor cometió algún otro fraude (*stellionatus*), y de este modo no puede cobrarse (Paulo, D.13.7.16.1; Ulp., D.f.d.1.2); b) para reclamar los gastos necesarios que debió realizar respecto de la cosa pignorada (Pomponio, D.13.7.8 pr.; Ulp., D.f.d.25).

d) Sobre los *pacta conventa* que se solían intercalar al *pignus*, ver *supra*, § 290.B.

Otras daciones crediticias

§ 373. I. *Dationes ob rem*. Se trata acá de daciones efectuadas por una persona con el fin de obtener de la otra, que la recibe, algo lícito. Pero como acá no se da ninguna de las figuras de los "contratos nominados", quien recibe no se obliga civilmente a hacer o a dar nada, y por ello no se cuenta con una *actio* para conseguir la contraprestación convenida.

Sin embargo, en caso de no haberse logrado lo pactado o convenido, quien recibió la *datio* y no cumplió su parte, está reteniendo la propiedad recibida sin causa, y entonces corresponde que ella sea restituida por una *condictio*.

1. Así, supongamos el caso de que A hubiera dado algo a B para que éste le diera una cosa a A, ante el incumplimiento de B, A no le puede exigir que cumpla lo acordado, pero podía obtener la restitución de su *datio* mediante la *condictio ob rem dati re non secuta* (Celsus, D.12.4.16).

Está fundada en que la *datio* de una cosa se ha realizado, pero por una causa que no se ha cumplido. A su vez, si A ha realizado un hecho en favor de B para que éste le dé una cosa y éste no se la da, acá la *condictio* no se podía emplear, puesto que la idea de restitución de un hecho resultaba inaplicable. La acción que correspondía era la *actio de dolo malo* (Paulo, D.19.5.5.3).

2. Un paso importante lo da — como ya lo hemos visto — el jurisconsulto Arístón (fines del siglo I o comienzos del siglo II d.C.). Preguntado por Celsus, respondió que si alguien dio una cosa para que otro le diera otra cosa, nace la obligación, puesto que "subsiste la causa", operando entonces la correspondencia de las prestaciones (la *ultra citroque obligatio*), por lo que se daría un *synallagma* (contrato).

No se nos dice qué *actio* propone Arístón, pero inmediatamente se nos habla de la controversia entre Juliano, quien menciona una *actio in factum*, y Mauricio, quien da la solución de una *actio civilis incerti* (Ulp., D.2.14.7.2).

§ 374. Los llamados "contratos reales innominados". Estos diversos casos de *dationes ob rem* que no entraban en las figuras nomina-

das de contratos (verbales, literales, reales y consensuales), fueron tratados por los posclásicos bajo la denominación de "contratos innominados".

Estos casos están descritos en un párrafo del Digesto (19.5.5) atribuido a Paulo —muy manipulado por los bizantinos— donde se los presenta en un cierto orden lógico organizado sobre la base de que se trate de un *dare* o de un *facere*:

a) *Do ut des* (Te doy para que me des): A entrega su casa para que B le entregue la suya.

b) *Do ut facias* (Te doy para que tú hagas algo): A da una cosa para que B realice un determinado acto; así, la manumisión de Stichos.

c) *Facio ut des* (Hago algo para que tú me des algo): A manumite un esclavo para que B le dé un esclavo suyo.

d) *Facio ut facias* (Hago algo para ti para que tú hagas algo para mí): A construye una casa en un fundo de B para que éste construya otro en el fundo de A.

La particularidad de estos convenios consiste en que, desde el momento en que una parte cumple su parte, ello produce efectos jurídicos, para exigir el cumplimiento de lo convenido con la otra. Estos denominados "contratos innominados" se comportan como "las obligaciones *ex re*".

Estos casos están protegidos por la *actio praescriptis verbis*, que con Justiniano es considerada acción de buena fe (Inst., 4.6.28; Ulp., D.43.26.2.2 itp.).

1. Tal cual se le hace decir a Celso, la denominación proviene que cuando existe una obligación y no está protegida por una acción, hay que recurrir a la "acción de palabras prescritas": "pues cuando faltan los nombres corrientes y usuales de las acciones, ha de actuarse por la acción de palabras prescritas" (D.19.5.2).

2. También es denominada por los bizantinos como *actio in factum civilis* (Pap., D.19.5.1.1-2), lo cual es algo inaceptable para los clásicos, puesto que *actio civilis* y *actio in factum* se oponen en el procedimiento formulario.

a) Por medio de ella, la parte que ha cumplido con su obligación puede obtener, ya que se le haga efectiva la contraprestación, o en general que se le entregue una suma que equivalga al interés que tuvo el actor (*quod interest*; Paulo, D.19.5.5.1; D. id.7 y 9 itps.).

b) Pero no desaparece la *condictio* clásica (*condictio ob rem dati o condictio causá data causa non secuta*). Mediante ella, quien cumplió con su obligación, sin haberlo hecho la otra parte, en lugar de pedir la contraprestación, prefiere pedir la resolución del negocio. Así, si

había dado una cosa o una suma de dinero, que se le restituya. Si había realizado un hecho, que se lo indemnice por el importe que se calcula el interés que habría tenido en caso de no haberlo realizado (Paulo, D.19.5.5.1).

c) Finalmente, Justiniano concede a quien cumplió una *condictio ex poenitentia*, por la cual, antes de que la otra parte hubiera cumplido su obligación, se arrepentía y pedía la restitución de lo dado (Ulp., D.12.4.3.2-3; D.id.5 pr., 1-2; Gayo, D.17.1.27.1; itps.).

1. Esta forma de resolución por arrepentimiento —distinta de la anterior, donde la resolución se daba por falta de cumplimiento— es una creación puramente justinianea.

Ha provocado extrañeza, pues conlleva la posibilidad de romper una convención sin el acuerdo de la otra parte y sin haber mediado incumplimiento de ésta. Se la quiere explicar diciendo que en los casos en que se habla de esta *ius poenitendi*, se refieren al tipo *do ut facias*, y tienen un cierto parecido con el mandato o la fiducia: así, te doy dinero para que manumitas a Stichos; o te doy una suma para que viajes a Capua. Es como si el mandante hubiera ordenado algo a la otra parte y luego se arrepintiera, revocando lo mandado hacer.

§ 375. *Principales casos*. Dentro de la variedad de estos contratos innominados, hay que subrayar algunos de ellos que son más importantes:

A) *Permuta (permutatio)*. A conviene entregarle a B la propiedad de un esclavo y B a darle la propiedad de un juego de tazas a A. Es un típico caso del tipo *do ut des*. Como mera convención consensual no tiene efectos, pero sí a partir de que una de las partes realice su *datio*. Configurado como "contrato" es, pues, "real", dando posibilidad a la parte que cumplió a pedir el cumplimiento de la otra por la *actio praescriptis verbis*, o la resolución de él ante el incumplimiento de la otra (*condictio causa data causa non secuta*); Paulo, D.19.4.1.2-3.

1. En la época clásica, los sabinianos pretendían que fuera considerada compraventa, idea que no prevaleció. Su interés era que al considerárselo un contrato consensual, como la compraventa, se podía pedir el cumplimiento, ofreciendo la entrega de la cosa obligada o haciendo la *datio*. Al no ser considerado tal, el mero *consensus* no valía, por lo que no se producían efectos hasta que una de las dos partes no realizara su *datio* (Diocl. y Maxima, C.4.64.3).

2. A diferencia de la compraventa, la obligación no consiste en pasar la posesión de las cosas, sino la propiedad de ellas. Los justinianeos admiten para la *permutatio* la garantía de los vicios redhibitorios*

(Ulp., D.21.1.19.5 itp.; Paulo, D.19.4.2 itp.), así como la promesa de la garantía de evicción* (Celso, D.12.4.16, in fine, itp.).

B) *Aestimatum*. En este caso, A entregaba a B determinadas cosas (generalmente mercancías), fijándole un valor determinado (*aestimatum*), para que B las vendiera al precio que quisiera. Por aquellas que lograba vender, B podía retener el exceso, pagando solamente a A la estimación ya fijada. Si B no vendía las cosas, debía restituirlas a A. A éste, se le concedía una *actio aestimatoria*, para lograr el pago de lo estimado o la devolución de las cosas no vendidas (Ulp., D.19.3.1; Paulo, D.id.2; itps.).

1. Este negocio era conocido en la época clásica, discutiéndose si se estaba en presencia de una compraventa, de una locación de servicios o de una sociedad (Ulp., D.id.1 pr.).

Se cree que una *actio de aestimato* figuraba ya en el Edicto (EP, § 112), sirviendo como antecedente de la posterior *actio praescriptis verbis*. Es curioso que en casos semejantes se habría otorgado la *actio pro socio* (Ulp., D.17.2.53.7, D.id.44).

2. El *periculum* de la cosa corría a cargo de quien las había recibido (Ulp., D.id.1.1). En la época clásica, la situación era distinta: era responsable quien las recibía en el caso de que él fuera quien había tomado la iniciativa del negocio; si la había tenido el dueño de ellas, el riesgo era a su cargo; y si la iniciativa fue común, quien las recibió respondía del dolo y de la culpa (no de la custodia); Labeón-Pomp., Ulp., D.19.5.17.1.

C) *Precario (precarium)*. Succedía cuando alguien pedía (*precare* = rogar) al dueño de una cosa, generalmente tierras, que le permitiera gratuitamente el uso en posesión de ella.

En la época clásica, el dueño podía reclamarla a su voluntad, gozando de un *interdictum de precariis* (Paulo, D.43.26.14; Ulp., D.47.2.14.1.1), y por supuesto de la *rei vindictatio*.

Pero en el Bajo Imperio se produjo una aproximación con el comodato, y según una glosa de las Sentencias de Paulo (5.6.10) y la *interpretatio* que acompaña a la *Lex Romana Visigothorum*, se le dio al dueño una *actio civilis* como en esa época se le daba al comodante.

Terminó por convertirse en un "contrato real innominado", protegido por la *actio praescriptis verbis* (Ulp., D.43.16.2.2; en D.id.1.3, se denota la aproximación al comodato; itps.).

§ 376. II. *Dationes ob causam*. Esto ocurre cuando se ha realizado una *datio*, pero falla la causa de ella, ya por no acaecer o ser errónea que existiera. De este modo, quien ha recibido

la *datio* carece de causa para retener la misma y debe restituirla.

1. Los juristas clásicos se basan en la consideración del fracaso o de la falla de la causa, de tal modo que la imposición de la obligación de restituir nace de la retención incausada del accipiens. Es una de las creaciones más novedosas y valiosas de los juristas romanos que no se encuentra en los otros pueblos antiguos.

2. Justiniano establecerá el principio general del "enriquecimiento sin causa", esto es, que resulta equitativo por el *ius naturae* "que nadie se haga más rico en forma injustificada con detrimento de otro" (*Ius naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorum*; Pomp., D.50.17.206; D.12.6.14 itps.).

A) El caso principal es el "pago de lo no debido" (*solutio indebiti*). Se trata del supuesto de que por error A pague a B una deuda inexistente (Ulp., D.12.6.1 pr.). Por la *condictio indebiti* (D.12.6; C.4.5), quien recibió el pago debe restituirla la cosa o la suma pagada, o su valor si la cosa hubiese perecido (Pomp., D.id.7).

1. Esto puede ocurrir respecto de una cosa pagada pero no debida. Así, A creía que le debía a B un esclavo y se lo dio, pero la obligación era inexistente. Igualmente, si se pagó una suma de dinero creyendo que se debía, o, debiendo 100, A pagó a B 120, A tendrá la *condictio indebiti* por los 20 pagados de más.

Para que proceda la *condictio indebiti* es necesario:

a) Que lo pagado por una parte a la otra no sea realmente debido.

1. Se debe tratar de una obligación "civil". Pero no procede si la obligación es natural. Así, p.ej., si el *dominus* que debía algo a su esclavo, se lo pagó una vez manumitido, aun creyendo que existía alguna acción contra él, estamos en presencia de una "obligación natural", y no cabe la *condictio indebiti* (Tryfon., D.12.6.64).

Tampoco, si se pagara el préstamo de dinero hecho a un *filius* en contra de lo dispuesto por el s.c.Macedoniano* (Marciano, D.12.6.40 pr.).

3. Tampoco si se pagó por error una obligación antes de vencido el plazo (Paulo, D.12.6.10).

4. Igualmente, no corresponde la *condictio indebiti* cuando alguien, para evitar un juicio que conllevara la condena al *duplum* por "inrescencia", paga directamente el *simplum*, no puede luego repetir lo pagado.

Esto sucede, p.ej., en el caso de la *actio legis Aquiliae*. A demanda por un daño injusto a B. Paga directamente el *simplum*, pero si se le concediera la

condictio indebiti, alegando p.ej. que el daño no había sucedido, estaría discutiendo su responsabilidad penal, evitando la "litiscrescencia".

Lo mismo ocurre en el caso del legado *per damnationem*. Quego ampliado por Justiniano a todos los legados y fideicomisos, por cuanto el juicio respectivo conlleva en caso de negarse la responsabilidad, el peligro de la condena por el *duplum*, o sea, la "litiscrescencia"; Inst., 3.27.7.

5. Si se paga lo no debido a un procurador, procede la *condictio indebiti* contra él, si es que no hubo ratificación del mandante; de haberla habido la acción es contra éste (Paulo, D.12.6.6.1-2).

b) El pago debe haberse producido por error, es decir, ignorando quien lo hace que no se debía. Pero si, a sabiendas, alguien paga algo que no se debe, no tiene la *condictio indebiti*, entendiéndose en este caso que lo ha hecho *donationis causa* (Ulp., D.12.6.1.1; D.12.6.3=PV. 266; Jul., D.41.4.7.2).

c) El pago debe ser aceptado por el supuesto acreedor de buena fe. Si a sabiendas de que nada se le debe recibe el pago, procede en este caso no la *condictio indebiti*, sino la *condictio furtiva* (Scév., D.13.1.18; Ulp., D.47.2.43 pr.).

1. El caso del pago de lo indebido era ya conocido por Gayo (3.91), quien no ve claro el problema de si la obligación se ha nacido de un "negocio contraído". Luego en *Res cottidianae* (D.44.7.5.5.3), lo ubica entre las *variae causarum figurae*. Justiniano lo considera un *quasi ex contractu*, asemejándolo al "mutuo" (Inst., 3.27.6).

B) Dentro de este grupo también procede la obligación *re* de restituir, cuando la *datio* se ha producido como consecuencia de un convenio ilícito o immoral. Así, te di una suma de dinero para que no mates a un hombre, o para que me devuelvas un depósito. Acá falla la causa, por ilicitud, por lo que deviene injusta la retención de la cosa. Se concede acá la *condictio ob turpem causam* (D.12.5; C.4.7).

Si sólo es ilícito para quien recibió la *datio* (así, p.ej., te di dinero para que no cometieras un delito), tengo esta *condictio* para que me lo restituyas (Paulo, D.12.5.1.2). Pero si el que hizo la *datio* está incurso en la causa immoral o delictiva (p.ej., te doy este dinero para que mates a Ticio), entonces carece de derecho a la restitución (Paulo, D.12.5.3). Y si se intentara la *condictio*, puede ser repelido por la *exceptio doli*, quedando la *datio* para quien la recibió (Paulo, D.12.5.8).

1. Esto significa que cuando la causa torpe es común, queda favorecido quien la recibió. Esto se explica porque ha existido dolo recíproco, y en el

derecho posclásico, tal cual lo vimos a propósito de las "deudas de juego" (*supra*, § 321.e.2), rige el principio de que "cuando el dolo recae sobre quien da y quien recibe, es mejor la condición de quien posee".

2. Justiniano engloba en esta rúbrica el caso de la *condictio ob iniustam causam* (D.12.5: *Condictio ob turpem vel iniustam causam*). Sería para el caso de causas prohibidas, así las donaciones entre marido y mujer.

C) Otros casos de *datio ob causam*, en los cuales había obligación de restituir, era cuando se había realizado por una causa determinada, y luego ésta desaparece (*condictio ex causa finita*). La casuística es muy amplia. Así, cuando se dio la dote, y luego el matrimonio no se realizó (Ulp., D.23.3.7.3); o cuando el comodatario pagó el valor de la cosa dada en comodato, la cual no pudo restituir por crearse pérdida y luego ésta aparece (Ulp., D.12.7.7.2); etc.

1. Aclaremos aquí que en la época clásica, para todos estos casos de *dationes ob causam*, es decir, cuando se había realizado una *datio* y fallaba la causa de ella, lo que se concedía por el pretor era la *condictio certae rei*, que tenía tres fórmulas (EP, § 95). Si lo que se había dado era dinero, funcionaba la *condictio certae creditae pecuniae*. Si se había dado una cosa determinada se otorgaba la *condictio certae rei*. Si se había dado una cantidad de cosas fungibles, se concedía la *condictio certae quantitatis* (*condictio triticaria*).

2. Las denominaciones que hemos dado a las acciones de restitución obedecen a nombres posteriores, admitidos finalmente por Justiniano. Incluso, ampliando los supuestos que hemos visto, concede una *condictio sine causa*, para cualquier caso donde no exista una causa —involucrando también el caso de la causa finita— o que ésta no sea justa (Ulp., D.12.7.1.1 ss.).

3. Con ello se abre la posibilidad de extender la *condictio* a casos que no hayan sido previstos.

Esta *condictio sine causa*, puede también emplearse para un *incertum* (Jul., D.12.3 itp.). Con ello se desvirtúa el concepto de la *condictio* clásica, que se basa siempre en una *datio*, que conlleva la idea de algo determinado.

Igualmente establecerá una *condictio ex lege*, para aquellos casos en que una nueva ley hubiera introducido una obligación y no se previno qué clase de acción la protegería (D.13.2; C.4.9). Y también una *condictio generalis*, para reclamar por cualquier obligación nacida de contrato, siempre y cuando se reclame un *certum* (Ulp., D.12.1 pr. ss., itps.).

Estos dos últimos casos no corresponden a la *condictio* clásica, significándose con ello la expresión bizantina de establecer acciones generales y concurrentes entre sí, para colmar las lagunas que existieran. Corresponden a la misma técnica legislativa de la *actio praescriptis verbis*.

§ 377. III. *Dationes "ex eventu"*. Finalmente, habría ciertos casos muy especiales en los cuales se concede la *condictio*, pese a que no ha habido una *datio* inicial y voluntaria que permita hablar de *creditum*.

1. La terminología de estos casos especialísimos la tomamos de A. d'Ors (DRP, 400): *ex eventu* hace relación a circunstancias eventuales. Los alemanes hablan de "dación perfeccionada a posteriori".

2. Se trataría de casos en que no ha habido propiamente *datio*, es decir, constitución de la propiedad, p.ej. por no ser el dador propietario de la cosa entregada. Así, el mutuo hecho con dinero ajeno. Pero si el deudor lo consumió, quien prestó tiene la *condictio* contra él (Jul., D.12.1.19.1).

Del mismo modo, si se ha donado *mortis causa* una cosa ajena, y ella le ha sido dada al donatario, no hay *datio*, ya que nadie puede "dar" lo que no es suyo. En el caso de que el donatario la usucapiere, la *datio* se ha producido por este hecho posterior. Pero el donante, aún vivo, tiene la *condictio* (Jul., D.39.6.13 pr.).

El caso más citado es el de la *condictio furtiva*. Normalmente la *condictio* supone la *datio* previa. En el caso del ladrón, éste se había apoderado de la cosa (no había *datio*, por eso no es propietario porque el *furtum* no es título de dominio). Sin embargo, se le concede la *condictio furtiva*, por "odio a los ladrones" (*odium furum*; Gayo, 4.4). Ahora bien, aun cuando la cosa no se pueda reivindicar, p.ej. por haberse consumido o destruido, el dueño tiene la *condictio furtiva* contra el ladrón para reclamar su valor, porque éste está siempre en mora (*fur semper in mora videtur*; Ulp., D.13.1.8.1).

Préstamos pretorios

§ 378. El pretor admite ciertos casos especiales de convenios no sancionados por el *ius civile*, pero a los cuales concede acciones. Como se trata en forma general de retención de cosas ajenas, en forma amplia los podemos considerar también "préstamos".

1. En el título sobre los "créditos" (*De rebus creditis*) menciona tres casos de acciones: a) la *actio de pecunia constituta*, que protege el pacto de *constitutum* ("préstamo de plazo"); b) la *actio commodati* ("préstamo de uso"); y c) la *actio pignoratitia*, vinculada con la retención indebita del *pignus* ("préstamo de garantía") por parte del acreedor.

Del *commodatum* y del *pignus*, que contaban indudablemente con acciones *in factum*, es decir, "pretorianas", se duda acerca de que en la época clásica hayan existido fórmulas *in ius*. Serían, pues, "préstamos pretorianos". Para evitar una mayor complicación al estudiante, ya los hemos tratado involucrando

dolos en los "contratos reales", siguiendo con ello el criterio de Justiniano y los bizantinos (v. *supra*, comodato, § 364 y ss.; *pignus*, § 371 y ss.).

2. Asimismo, en el título XI del Edicto (*De receptis*) figura la *actio recepticia*, otorgada contra el banquero que asume una deuda ajena, y que sería un "préstamo de solvencia".

§ 379. I. *Constitutum*. Estamos acá en presencia de un convenio —se lo suele denominar *pactum*— vinculado con una deuda preexistente. Por medio de él, sin emplear formas solemnes, se fija un plazo (o uno nuevo, si ya existía alguno) para el pago de dicha deuda. Ésta puede ser "propia" (*constitutum debiti proprii*) o "ajena" (*constitutum debiti alieni*) (D.13.5, C.4.18).

A) *Constitutum debiti proprii*. Veámoslo en un ejemplo: A debía la suma de 100 a B por un mutuo, la cual debía pagar en las calendas de marzo. Al convenirse el *constitutum* (de *constituere* = "fijar un día") ambas partes acordaban que la suma fuera pagada en las calendas de julio. De ahí que puede ser concebido como un "préstamo de plazo", pudiendo retener el deudor la suma debida durante cierto tiempo más.

El *constitutum* no produce una novación. De este modo, el acreedor tiene ahora dos acciones: la *actio* (*condictio*) *certae creditae pecuniae*, por la deuda existente del mutuo, a la que se agrega ahora la *actio de constituta pecunia*, las cuales pueden ser ejercidas en forma alternativa. Pero, por supuesto, el deudor debe pagar una sola vez, de tal modo que una vez satisfecha la obligación y extinguida ésta, no corresponde volver a reclamarla (Ulp., D.13.5.18.3).

1. En cuanto a la razón de ser del *constitutum*, el deudor obtenía un beneficio, al serle ampliado el plazo. Se consideraba que la convención era un acto de *fides*, por lo que se lo debía proteger jurisdiccionalmente (Ulp., D.13.5.1 pr.).

Pero, fuera de este beneficio, la situación del deudor se agravaba. En efecto, ahora existen contra él dos acciones excluyentes: la del crédito y la nueva del *constitutum*. Por eso resulta problemática verlo como un *pactum*, pues éste tiende a mejorar y no a empeorar la situación del deudor.

2. En cuanto al acreedor su situación es mejor, de tal modo que puede conseguir más que con la acción nacida del mutuo o de la *stipulatio*. Éstas abarcan sólo la suma prestada o prometida; no así los perjuicios debidos por la mora, puesto que la fórmula contenía una *condemnatio certa* (Paulo, D.2.14.17 pr.; Ulp., D.12.1.11.1).

En cambio, por la *actio de constituta pecunia* se debe, no sólo la suma debida, sino también los perjuicios moratorios (la fórmula hablaba de *neque solvere, neque fecisse* —ni pagar, ni haber hecho lo convenido—; Ulp., D.13.5.16.2, EP, § 97).

Por otra parte, podía estar acompañada de una especie de apuesta judicial, la *sponsio dimidia pars* (Gayo, 4.171). Así, a requerimiento del acreedor actor, el deudor demandado debía prometer el pago extra de la mitad de lo reclamado si perdía el juicio; y lo mismo debía prometer, recíprocamente, el actor. Se usaba también para la *condictio certae creditae pecuniae*, pero sólo por un tercio; no como en la *actio de constituta pecunia*, por la mitad.

Para que se pudiera reclamar el *constitutum* era necesario:

a) Debía existir una obligación preexistente. En principio debía consistir en una suma de dinero (de ahí su vinculación con la *actio condictio certae creditae pecuniae*). Pero se la admitió también para cosas ciertas (C.4.18.2.1 B). Justiniano terminó admitiéndolo sobre toda clase de cosas (C.4.18.2, año 531; Ulp., D.13.5.1.3 itp.).

1. Si bien, el crédito debía existir al momento del *constitutum*, se podrían dar casos en los cuales era debido, aunque la obligación primera no existiera; así, si se debió una cosa que luego dejó de existir; o se tratara de una obligación con acción temporal y había vencido el tiempo (Ulp.-Celsus-Jul.D.13.5.18.1).

b) Que se hubiera "constituido" un nuevo plazo. Más tarde se admitió que en caso de haberse realizado el *constitutum* pero sin término, él era lo mismo exigible, en un plazo "módico" (*modicum tempus*), que Justiniano estableció en 10 días (Paulo, D.13.5.21.1 itp.).

c) Que el *constitutum* se relacione con la obligación preexistente. Por ello el actor debía no sólo probar el *constitutum*, sino también el crédito anterior (Ulp., D.13.5.11 pr. y 1; Paulo, D.13.5.12).

B) *Constitutum debiti alieni*. En este caso, A debía a B la cantidad de 100. Sobre esta obligación, un tercero (C) celebra un *constitutum* con el acreedor (B). Éste tiene, por tanto, la *condictio certae creditae pecuniae* contra A y la *actio de constituta pecunia* contra C. En el fondo, funcionaba como una fianza (Ulp., D.13.5.5.3.4).

Pero difiere de la fianza personal (*fideiussio*), ya que se celebra consensualmente, y no por medio de una *stipulatio*. Si se hubiere "constituido" por deuda ajena, por una suma mayor, queda siempre reducida al monto de la obligación principal (Ulp., D.13.5.11 pr. y 1).

C) A medida que va desapareciendo el procedimiento formulario, el *constitutum* clásico se irá desdibujando.

El *constitutum debiti proprii* quedó con Justiniano convertido en un pacto protegido ("pacto vestido") por el cual se podía conceder un plazo nuevo a toda clase de obligaciones. A su vez, el *constitutum debiti alieni* fue asimilado a la *fideiussio*.

§ 380. II. *Receptum argentarii*.

1. El verbo *recipere* significa "tomar sobre sí", "asumir un encargo, un emprendimiento". En el Edicto, bajo la rúbrica *De receptis* (tit. 11, §§ 48-50) se agrupan tres acciones, relacionada con el *receptum argentarii*, el *receptum arbitrii* y el *receptum nautarum, cauponum, stabulariorum*. El caso que nos interesa acá es el primero. Del *receptum arbitrii* hemos ya hablado en *supra*, § 156. Y del *receptum nautarum, cauponum, stabulariorum* lo hemos hecho en *supra*, § 357.D.

En el caso del *receptum argentarii*, estamos en presencia de una "asunción de responsabilidad por deuda por parte de un banquero". Así, A debía 100 a B. Para su mayor comodidad o por necesidad, A le requería a su banquero (*argentarius*) C que se hiciera cargo de pagar dicha suma al acreedor B. En caso de aceptarlo, B tenía una *actio recepticia* contra el banquero C.

1. Esta práctica, netamente bancaria, se realizaba en forma informal. No era necesario una *stipulatio* por la cual el *argentarius* prometiera pagar. El banquero actuaba como agente financiero de su cliente, ya contando con dinero de éste, o ya adelantándole dinero en descubierto.

Se parece mucho al *constitutum debiti alieni*. Pero a diferencia de éste, que requiere siempre una obligación preexistente, por lo que es un negocio "causado", el *receptum argentarii* es "abstracto", es decir, no interesa si hay o no una obligación preexistente. Por ello el acreedor que reclama por la *actio recepticia*, sólo tiene que probar el *receptum*, es decir, la "asunción de la deuda por el *argentarius*", sin necesidad de probar otra obligación.

2. Justiniano termina asimilando al *receptum* con el *constitutum debiti alieni*, haciéndole perder su carácter de "abstracto". Desaparece la *actio recepticia*, y sólo queda la *actio de constituta pecunia* (C.4.18.2 a, año 531; Inst., 4.6.8).

CAPÍTULO 5

(OBLIGACIONES QUE SE CONTRAEN VERBIS)

ESTIPULACIONES (CONTRATOS VERBALES)

§ 381. *Concepto*. La *stipulatio* es la forma más sencilla y ordinaria por la cual se puede hacer nacer una obligación. El futuro acreedor (*stipulator*) preguntaba en forma solemne al futuro deudor (*promissor*) si prometía dar, hacer o prestar (*dare, facere, praestare*) algo, y este último contestaba congruentemente y en forma inmediata que lo prometía y a partir de ese momento quedaba obligado. Así, en un sencillo ejemplo, el *stipulator* preguntaba: "¿Me prometes dar 100?", y el *promissor* contestaba: "Lo prometo".

1. Es propiamente una "obligación contraída por palabras" (Gayo, 3.92; Inst., 3.15). Los bizantinos lo considerarán como "contrato verbal". Desde este punto de vista está muy lejos de ser considerado un *synallagma*, como ocurre con la compraventa y demás contratos consensuales. Es más bien una "promesa de pago". Por ello es análogo a nuestro actual "pagaré" (también es una promesa de pago; no un contrato), con la diferencia que la constitución de la obligación no es escrita, sino verbal.

2. Es una creación típicamente romana, que es ajena a otros derechos de la Antigüedad. Se basa fundamentalmente en el respeto a la palabra dada. Uno de los rasgos del Derecho Romano es su predilección "oralista", a diferencia de los pueblos heleno-orientales, que acostumbraban obligarse en forma "escrituraria".

3. En cuanto a la denominación, se la hace derivar de *stipulus* (como lo *firmus* = lo firme, lo fijado, lo establecido). Esto está afirmado por Paulo (5.7.1) y reconocido por Justiniano (Inst., 3.15 pr.) donde no se desecha que provenga también de *stips* (moneda). También se la aproxima con *stipula* (brizna de paja) que las partes rompían en señal de cumplimiento de lo prometido (Isidoro, Orig. 5.24.30).

El respeto a la palabra dada queda señalado también como respeto por la *fides* (lo cual no significa que la obligación nacida corresponda a las de "buena fe", sino que es de derecho estricto). La costumbre era que luego de celebrada la promesa de pago, las partes se daban recíprocamente las diestras (*dextrarum iunctio*). La mano derecha, desde la época del

rey Numa Pompilio era considerada el asiento de la diosa *Fides* (Plut., Numa, 16).

4. Reconoce una forma más antigua: la *sponsio*. Ésta se caracterizaba por el empleo del verbo *spondere* (*Centum mihi dari spondes?* preguntaba el acreedor; *spondeo*, contestaba el deudor). Este verbo, que sólo podía ser empleado por los ciudadanos romanos (Gayo, 3.93), tenía un significado religioso, por lo que según algunos era un juramento; para otros un "voto" (*votum*). *Spondeo* debía sonar a algo así como "Prometo solemnemente por mi *fides*".

Se la empleaba en los votos o promesas a las divinidades, como también en los esponsales (*sponsalia*), e incluso en los tratados internacionales, uno de cuyos ejemplos más famosos fue la realizada por el general romano Postumio para celebrar el pacto con los Samnitas, luego del episodio de las Horcas Caudinas (Tito Liv., 9.11).

5. La fusión de la *sponsio* con la *stipulatio* se debió producir en época temprana, puesto que ya en la ley de las XII Tablas se podía reclamar por *stipulatio* por medio de una de las *Legis actiones*: la *l.a. per iudicis vel arbitri postulationem* (Gayo, 4.17a).

Si bien Gayo (3.93) considera la *stipulatio* como un negocio del *ius gentium*, porque también se podía obligar por ella los extranjeros, engendra obligaciones *iure civile* y sólo da lugar a acciones de derecho estricto.

Por su carácter "abstracto", la *stipulatio* será ampliamente empleada para obligarse por cualquier clase de obligaciones. Más aún, como lo veremos por la *stipulatio Aquiliana*, se podían novar todas las otras obligaciones ya contraídas.

6. La obligación nacida de la *stipulatio*, aparte del cumplimiento efectivo, puede también extinguirse mediante un acto formal y verbal, realizado en forma análogamente opuesta a ella: la *acceptilatio*. La fórmula era así: el deudor pregunta ahora al acreedor: "¿Lo que yo te prometí ¿lo tienes por recibido (*acceptum*)?", y éste respondía: "Lo tengo" (Gayo, 3.169; Inst., 3.29.1).

§ 382. *Requisitos de la celebración*. No obstante la sencillez de las formas, para que la *stipulatio* fuera válida había que cumplir ciertos

requisitos, que en la época clásica eran de observancia rigurosa:

a) Las partes debían estar presentes. Debían saber hablar y entenderse por medio de las palabras. Por ello los mudos —que no pueden hablar— ni los sordos —que no pueden escuchar— no podían realizar la *stipulatio* (Gayo, 3.105; Inst., 3.19.7).

1. Para los romanos, la presencia de las partes tenía un valor psicológico muy fuerte, mucho mayor que el que tiene un documento escrito, que el promitente puede firmar sin haber leído o sin conocer su contenido.

2. Justiniano nos aclara que cuando se habla del sordo se está refiriendo a aquel que no oye nada, no a aquel que lo hace con dificultades (Inst., 3.19.7; Gayo, D.44.7.1.15). Lo importante es que las dos partes no sólo deben pronunciar las palabras sino que se puedan entender recíprocamente (Gayo, 3.105).

b) Todo debe suceder en un solo y único acto (*unitas actus*). La interrogación debe ser seguida inmediatamente por la respuesta sin que exista un intervalo entre una y otra (Venuleyo, D.45.1.137 pr.). En consecuencia, no se puede celebrar entre ausentes (Gayo, 3.136).

c) La respuesta debe ser totalmente congruente con la pregunta. Las fórmulas empleadas debían ser las propias para obargarse: *¿Si, Dari spondes?* (*¿Prometes solemnemente dar?*) — *Spondeo* (Lo prometo solemnemente). *¿Promittis?* (*¿Prometes?*) — *Promitto* (Prometo).

Fideipromittis? (*¿Prometes por la fides? — Fideipromitto* (Prometo por la fides).

Dabis? (*¿Darás?*) — *Dabo* (Daré).

Facies? (*¿Harás?*) — *Faciam* (Haré).

Pero no hay congruencia si yo estipulo que me has de dar 10 y tú prometes darme 5, o al revés; o si yo estipulo pura y simplemente y tú prometes bajo condición (Gayo, 3.102; Inst., 3.19.5).

1. Salvo el caso del verbo *spondere*, que sólo puede ser usado por los ciudadanos romanos, el resto de las formas también puede ser usada por los extranjeros. Podían ser expresadas en otro idioma; así, en griego (Gayo, 3.93) o en cartaginés o en asirio, siempre y cuando ambas partes comprendan la misma lengua, o exista un intérprete veraz (Sabino-Ulp., D.45.1.1.6).

d) Se solía, desde antiguo, hacer la *stipulatio* en presencia de testigos, pero no formando parte del acto; sino para tener luego una prueba (no son *ad solemnitatem*, sino *ad probationem*). Igualmente, ya en tiempo de Cicerón, era común redactar un escrito complementario (*cautio*

o *instrumentum*) tendiente a tener una prueba segura. Pero en los tiempos clásicos, la *stipulatio* fue oral; dicho documento hacía a la evidencia probatoria, más segura que los testigos.

§ 383. Esta forma, sencilla y segura de la *stipulatio* clásica, se irá deteriorando. No debió de ser ajeno a este deterioro, la *constitutio Antoniniana* del 212 d.C., al otorgar la ciudadanía romana a la gran masa de los habitantes del Imperio.

a) Por un lado, el sentido de la palabra oral prometida, propia de los romanos, chocaba con el gusto helénico-oriental por los documentos escritos. Esta forma se llegó a usar (Paulo, 5.7.2), pero no se consumó la desaparición de la *stipulatio*.

b) Pero por otro lado, se fueron aflojando las exigencias de la *stipulatio*. Así, ya en época del emperador León (año 469) se dictó una constitución por la cual se dispuso el uso de las palabras solemnes, pudiéndose emplear cualesquiera, siempre y cuando expresen claramente la voluntad de las partes y éstas acepten (C.8.37.10).

1. Ya en la época clásica, Gayo expresa sus dudas respecto a alguna incongruencia de los verbos empleados. Así, si alguien es interrogado *Dari spondes?* y no responde, *Spondeo* (*dari*), sino *Promitto* o *Dabo* (3.95).

Pero en el Digesto aparecen párrafos de autores clásicos posteriores —algunos sospechan que están interpolados— que demuestran una mayor libertad. Así, no es necesario que la respuesta sea inmediata, de tal modo que si alguien preguntaba, el otro se marchaba, y volvía y respondía, la *stipulatio* era válida (Ulp., D.45.1.1).

También la falta de congruencia entre pregunta y respuesta, no vicia necesariamente el negocio. Si al estipulante le agradaba la variación en la respuesta y la aceptaba, se entendía que se celebró otra *stipulatio* (Ulp., D.45.1.1.3).

Igualmente, si A preguntaba estipulando por 10 y B respondía que prometía pagar 20, la obligación se consideraba válida por 10; lo mismo al revés, si A estipuló por 20 y B prometía dar 10, era válida por 10. Se da como razón que en los 20 están comprendidos los 10 (Ulp., D.45.1.4); cfr. Paulo (D.50.17.110 pr.): "en lo que es más, está siempre comprendido lo que es menos", es decir, la *stipulatio* resulta siempre válida por la suma menor.

El problema de la sospecha de interpolación es paralelo al célebre paso de Pedio, citado por Ulpiano (D.2.14.1.3), en el cual se afirma que "no hay ningún contrato, ninguna obligación que no encierre en sí una convención, tanto se haga por entrega de una cosa como por palabras, pues también la estipulación, que se hace por palabras, es nula si no encierra un consentimiento".

Esta importancia dada al consentimiento verbalizado, es lo que permite aceptar finalmente esta debilitación de la "congruencia". La afirmación del "consentimiento" la encontramos en otros párrafos (Paulo, D.45.1.83.1; Venuleyo, D.45.1.1.1; Pap., D.2.15.5, respecto de la *stipulatio Aquiliana*).

Lo que llama la atención es que los redactores de las Institutas de Justiniano (3.19.5) sigan insistiendo en la congruencia, repitiendo el párrafo de Gayo (3.102), dando como ej. el estipular por 10 y prometer por 5, lo que según el texto hace inútil la *stipulatio*.

2. Además, en las prácticas helenísticas, la *stipulatio* era prácticamente hecha en un documento escrito (*cautio*), en el cual se hacía constar la presencia de las partes y lo que éstas se dijeron. Dado el papel principal que pasó a tener este documento como instrumento probatorio, cabe dudar si realmente se habían llevado a cabo los requisitos clásicos, o si se trataba directamente de un acto escrito.

Justiniano, queriendo mantener un delicado equilibrio entre lo clásico y lo posclásico, mantuvo la *stipulatio* como una *obligatio verbis*, decidiendo por una constitución del año 531 (C.7.37.14) que era válida la redacción de un documento donde constara que el acto tuvo lugar y que las partes estuvieron presentes. Pero para preservar el valor esencial de la forma oral, estableció que este documento sólo podía ser atacado si el deudor probaba que él o el acreedor había estado ausente todo el día de la ciudad en que se dijo haber celebrado la *stipulatio*.

Además, insiste en el consentimiento que está presente en la *stipulatio* (Inst., 3.19.13: *ex consensu contrahentium stipulationes valent*), de tal modo que vale como "promesa de pago consensual", con las consecuencias más arriba señaladas.

§ 384. *Acciones*. De una *stipulatio* válida nacía una *actio civilis in personam*. El nombre exacto no aparece siempre, aunque algunos prefieren hablar en forma genérica de *actio ex stipulatu*.

A veces se puede accionar por lo prometido respecto de un *certum*, sea "dinero cierto" (*certa pecunia*), una "cantidad de cosas fungibles determinada" (*quantitas*), o una "cosa cierta" (*certa res*), por lo que la podríamos denominar con el nombre no clásico de *actio certi*.

En otros casos, si lo prometido es un *incertum*, se concede la *actio incerti* (o también llamada más específicamente *actio ex stipulatu*).

1. En el Edicto, bajo la rúbrica *Si certum dare* (§ 95), el pretor ofrece tres fórmulas, por las cuales se puede reclamar "dinero cierto" (*certa pecunia*), una "cantidad de cosas determinadas" (*quantitas*) o una "cosa determinada" (*certa res*):

a) La *actio (condictio) certae creditae pecuniae*, la misma que se aplica para la devolución del mutuo. Por ella se puede reclamar una suma de dinero prometida por la *stipulatio*.

b) Había otra fórmula cuando se reclamaba no dinero, sino una cantidad (*quantitas*) definida de cosas (así, tantas medidas de trigo africano). Los bizantinos la denominarán *condictio triticiaria*.

c) La tercera fórmula era para reclamar la entrega de una cosa determinada. No parece haber tenido un nombre propio (*condictio certae rei*?).

2. Estas tres fórmulas son genéricas para la dación de una *certa pecunia*, de una *quantitas*, o de una *certa res*, ya que valen tanto para el cumplimiento del mutuo o de la *stipulatio*. Pero en el Edicto (§ 55) aparece otra fórmula para accionar contra alguien que hubiera prometido un *incertum*. Así, la *stipulatio*, prestada por un fiador, garantizando una suma incierta de dinero por el deudor (Gayo, 4.136-7), o si hubiere prometido un *faceps*.

A diferencia de las tres fórmulas anteriores, acá se aplica solamente en caso de haberse prometido un *incertum* por una *stipulatio*. Por ello, a esta *actio incerti* se le puede aplicar propiamente el nombre de *actio ex stipulatu*.

3. Curiosamente esta denominación no aparece en las fuentes clásicas, pero tampoco se descarta su uso, incluso generalizado, llamando *actio ex stipulatu* a cualquier *actio* que se pedía tanto *ex certum* como *ex incertum* (Ulp., D.2.14.10.1; Paulo, D.46.1.132; D.33.4.11). Lo que ocurre es que serviría, en el caso del *certum* para diferenciar técnicamente que la causa es una *stipulatio*, y no un *mutuo*. En los casos de *actio certi* no aparece mencionado el negocio.

4. Para Justiniano, esta variedad queda reducida a dos acciones: a) la *condictio* si se reclama un *certum*; y b) la *actio ex stipulatu*, si se reclama un *incertum* (Inst., 3.15 pr.).

§ 385. *Carácter abstracto de la stipulatio*. La *stipulatio* supone siempre un acuerdo previo que debió haber sucedido entre las partes, pero esta "causa" (entendida acá como "causa fuente") no debe ser probada a los efectos de su reclamo judicial. Por eso se dice que es un negocio "abstracto", es decir que en principio no interesa la causa. Lo único que cuenta es la "promesa de pago" a que se ha obligado el promitente respecto del estipulador.

Debido a ello, la práctica de la *stipulatio* ofrecía un campo de aplicación muy amplio. Podía servir para comprometer por un mutuo, o para constituir una dote, o para donar. También en una compraventa se podía optar por formalizarla por medio de *stipulationes* recíprocas del vendedor y del comprador. Fue muy usada en negocios de garantía, para afianzar personalmente al deudor, o en el caso de la *cautio fructuaria*, o la *cautio legatorum*, etc.

Más aún, a partir de la célebre construcción de la *stipulatio Aquiliana* (denominada así por haberla inventado G. Aquilio Galo), cualquier obligación de cualquier especie, civil o natural, podía ser novada mediante la formalización de una *stipulatio* (Inst., 3.29.2; Florentino, D.46.4.18).

Pese a ese carácter abstracto, en ciertos casos, podía interesar la causa, y el pretor podía otorgar al deudor una *exceptio doli* o de otra especie.

1. Así, p.ej., A ha pedido dinero a B. Éste dice que se lo dará, pero previamente le pide que se haga la *stipulatio*. Si luego B, de buena o de mala fe, no le da el dinero por el cual se realizó el negocio, cuenta con la *condictio* para reclamarlo. Pero como esto es inequitativo, ya que está pidiendo un dinero que no ha prestado, el pretor le otorga al deudor la *exceptio doli mali* (Gayo, 4.116a). Acá el pretor ha tomado en consideración la "causa" de la *stipulatio*, que era un mutuo.

2. Lo mismo ocurre si, por coacción, tú te has obligado a prometerme por una *stipulatio* una cosa determinada. Si yo ejerciera la *condictio*, me la podrías repeler por la *exceptio quod metus causa* (Gayo, 4.117).

3. Supongamos ahora que en la pregunta de la *stipulatio* se haya establecido la causa como condición. Así, "¿Prometes darme 1.000 como dote?". Si luego no suceden las nupcias, indudablemente el promitente queda obligado, pero si es demandado podrá oponer la *exceptio doli mali* (Ulp., D.23.3.21).

4. Igualmente, si se vende y compra algo, no por la forma consensual de la compraventa, sino empleando dos estipulaciones recíprocas; así: "¿Prometes darme 100 por la cosa que te he vendido?" y "¿Prometes darme la cosa que te he comprado?". Si el vendedor pretende cobrar la suma prometida como precio antes de haber entregado la cosa, el comprador demandado puede oponerle la *exceptio rei non traditae* (excepción de cosa no traditada), negándose a pagar. Se ve acá cómo si bien las estipulaciones son unilaterales, la *exceptio* puede enlazar casos de obligaciones estipuladas en forma recíproca.

§ 386. La *exceptio non numeratae pecuniae*. El ejemplo dado de posibilidad de una *exceptio doli*, está vinculado con el tema de la *exceptio* (y *querella*) *non numeratae pecuniae*.

Si un *stipulator* no había en realidad entregado el dinero por el cual se había realizado la estipulación (*pecunia numerata*), o le había sido entregado en menor cantidad; en tiempos de Gayo, el *promissor* (el deudor) tenía, como hemos visto, la *exceptio doli mali*. Pero según las reglas procesales le correspondía a él la targa de la prueba (*onus probandi*) de que no había recibido el dinero o el total de él, lo cual, como

ocurre con los hechos negativos, puede resultar difícil.

Esta situación fue revertida por el emperador Caracalla, quien por una constitución del año 215 otorga al deudor la *exceptio non numeratae pecuniae* (excepción de dinero no entregado; *numratio* = contar el dinero para entregarlo). Mediante ella, era el actor quien debía probar que el dinero fue entregado (C.4.30.3). Esta excepción privilegiada sólo podía oponerse durante un año; con posterioridad, el demandado sólo podía oponer la *exceptio doli*.

Pero el acreedor podía usar de una argucia: dejaba transcurrir el año sin demandarlo, y entonces al hacerlo luego del año, volvía a dejar al deudor con que sólo podía usar de la *exceptio doli*. Por ello es que apareció la denominada *querella non numeratae pecuniae*, que seguía el procedimiento *extra ordinem*. Mediante ella, el deudor no debía esperar ser demandado por el acreedor, sino que tomando la iniciativa, incoaba esta querella con el mismo efecto que la *exceptio*, es decir que era el acreedor quien debía probar la entrega del dinero.

Estas medidas significaban, para este caso de *stipulatio* por *pecunia numerata*, la posibilidad de llegar a la causa de la obligación, no obstante el carácter, en principio "abstracto", de ella.

1. Diocleciano aumentó el plazo de un año a cinco (C.4.30.9 itp.) y Justiniano lo redujo a dos años (C.4.14 pr.), tras lo cual caducaba, extendiendo tanto la *querella* como la *exceptio* a toda clase de obligaciones de entregar dinero o cosas.

Eximí del plazo de caducidad a los menores (C.2.40(41).5; año 531). A su vez, para evitar abusos, terminó castigando a los deudores que alegaban no haber recibido el dinero y luego perdían el juicio, con el pago del doble de la cantidad debida al acreedor (Nov.13.3, año 536).

I. Modalidades de la *stipulatio*.

§ 387. La *stipulatio* puede ser pura y simple, pero también se puede dar el caso de que quede sujeta a ciertas modalidades. Entre éstas podemos citar: a) la condición; b) el plazo; c) el lugar; d) la alternativa; y e) la *accessio*.

a) Sobre la condición, v. *supra*, §§ 307-309.

b) Sobre el plazo, v. *supra*, §§ 310-312.

c) Lugar: Se suele usar insertar en la *stipulatio* la indicación de un lugar donde hacerse el pago. Así, "¿Prometes darme en Cartago?" (Inst., 3.15.5).

1. El promitente se obliga a cumplir su obligación en el lugar fijado en la *stipulatio* (Ulp., 13.4.9).

2. El *stipulator* debe demandar el cumplimiento en dicho lugar. Si demanda en otro lugar, incurre en principio en *pluris petitio loco*, perdiendo el juicio. El pretor remediaba esta situación por la *condictio de eo quod certo loco*.

3. Muchas veces, el agregado del "lugar de pago" importaba un "plazo tácito", ya que si se prometido entregar en Cartago, se entiende que debo tener el tiempo suficiente para ir a Cartago (Inst., 3.15.5).

Por ello, si se prometido en Roma dar hoy en Cartago, la *stipulatio* es nula (*inutilis*), ya que es imposible (Inst., 3.15.5; Ulp., D.45.1.4.14; Paulo, D.45.73 pr.).

Sin embargo, Gayo (D.45.1.14.14) señala un caso en que podía ser válida: si lo he instruido a mi administrador (*dispensator*) en tiempo anterior de que le dé lo prometido al administrador del *stipulator*, también previamente advertido.

d) Alternativa (*modus*). Se trata de una *stipulatio* en la cual se ha prometido una u otra cosa. Así, "¿Prometes darme el esclavo Stichus o 100?". Ambas cosas integran la obligación, pero para cumplirla hay que dar solamente una de las dos (Paulo, D.44.7.44.3).

1. En principio, quien elige la cosa con la cual cumplirá la *stipulatio* es el deudor, salvo que el acreedor se haya reservado este derecho. Así, "¿Prometes darme el esclavo Stichus o 10, según yo quiera?".

Si por error el deudor creyera no tener esta opción y da una de las dos cosas al acreedor, tiene la *condictio indebiti* para recobrarla y dar la otra (Jul., D.12.6.32.3).

Más complicado es si por error ha dado las dos cosas. Tiene la *condictio indebiti*, pero el problema es determinar ahora de quién es la opción, ¿del deudor o del acreedor? Celso, Marcelo y Ulpiano consideraban que era el acreedor quien podía optar entre las dos cosas la que debía devolver, puesto que pensaban que el acreedor ahora se había vuelto deudor. En cambio, Juliano y Papiniano opinaban que la opción continuaba siendo del deudor, criterio que sigue Justiniano (C.4.5.10).

2. En caso de pérdida de una de las dos cosas, había que distinguir:

a) si la elección, como es normal, es del deudor, sin interesar si la pérdida fue por caso fortuito o por su culpa, se debe directamente la otra;

b) si la elección era del acreedor, si la cosa se perdía por caso fortuito, sólo podrá demandar por la otra. Pero si la pérdida ocurrió por culpa del deudor, el acreedor puede pedir ya la otra o el valor de la que pereció (Paulo, D.18.1.34.6; Pap., D.46.3.95 pr. y 1).

3. El caso de la llamada "obligación alternativa" hay que distinguirla de la llamada "obligación facultativa". En la primera habíamos visto que hay dos prestaciones en la obligación (*in obligatione*), separadas por la conjunción "o". En cambio, en la "faculta-

tiva", en la obligación (*in obligatione*) hay solamente una prestación, pero se le concede al deudor la posibilidad de liberarse pagando otra prestación (ésta está *in solutione*).

Así, p.ej., si se ha estipulado que me dieras un fundo, y que si no me dieras dicho fundo me dieras 100, la primera prestación, la de dar el fundo está *in obligatione*; la otra, la de dar 100 está para el pago (*in solutione*; D.44.7.44.5).

El efecto principal que la diferencia de la "alternativa" es que acá, en la "facultativa", hay unidad de objeto. Por ello, si por caso fortuito perece la prestación que está *in obligatione*, se extingue la responsabilidad. Si en cambio perece la que está *in solutione*, la obligación permanece; lo único que pierde el deudor es una eventual facilidad de pago.

e) *Accessio*. Paulo (D.44.7.45.4) se refiere a este caso, como el agregado de otra persona a los solos efectos de recibir el pago en lugar del acreedor. Así: "¿Prometes darme 100 a mí o a Seyo?".

En este caso (*solutionis causa adiectio*; Pap., D.46.3.95), el deudor cumple la obligación entregando la suma de dinero ya al acreedor o a Seyo (Gayo, 3.103a; Inst., 3.9.4).

1. Se sólo utilizar este procedimiento cuando el *stipulator* debía estar ausente, p.ej. por un viaje, y no podía recibir el pago.

2. Quien ha sido facultado para cobrar, es a ese solo efecto. No puede ejercer ninguna acción de cobro (Paulo, D.46.3.44.6). Una vez cobrado por Seyo, éste debe devolverle la suma al *stipulator*. Las relaciones entre ambos generan una especie de mandato, con la particularidad de que el acreedor no puede revocar el poder, ya que éste figura en la *stipulatio*. Sólo se extingue por la muerte de Seyo (Jul., D.45.1.55), lo mismo que si se ha hecho el pago al acreedor, o si éste inició la *condictio certae creditae pecuniae* contra el deudor y se operó la *litis contestatio* (Ulp., D.46.3.57.1).

II. *Stipulationes* nulas.

§ 388. A veces, en los textos se utiliza la expresión *nullius momenti est* (no existe) o *inutilis* (inútil, inválida).

1. Sin embargo, esta terminología que podría hacer pensar en alguna eventual diferenciación entre "inexistencia" y "nulidad", no está sino imperfectamente delineada. Respecto de las *stipulationes* inválidas los juristas no se preocuparon por lograr una mayor precisión. Los vocablos generalmente utilizados son los ya mencionados, y preferentemente el de *inutilis*.

A) Tanto Gayo (3.97 ss.) como Justiniano (Inst., 3.19) nos citan casos de *stipulationes*

inútiles, cuando fallan por la carencia de razonabilidad.

1. Así, la hecha por un *furius*, puesto que "no comprende lo que hace" (Gayo, 3.106; D.44.7.1.12; Inst., 3.19.8). Tampoco la hecha por un *infans* o un *infantiae proximus* (Gayo, 3.109; Inst., 3.19.10).

2. El pupilo, aun sin la *auctoritas* de su tutor, puede ser *stipulator*, ya que se trataría de una deuda que le será debida. En cambio, no puede ser *promissor*, esto es, obligarse respecto de otro por la *stipulatio*, sin la *auctoritas* del tutor (Gayo, 3.107; Inst., 3.19.9). Igual régimen rige respecto de la mujer sujeta a la *tutela mulierum*, mientras ésta existió (Gayo, 3.108).

3. También carece de seriedad estipular dar una prestación imposible. Así, dar un hombre libre al que se creía esclavo, o a un esclavo muerto al cual se creía vivo, o un lugar sagrado o religioso, al cual se creía que era una cosa *in commercio* (Gayo, 3.97; Inst., 3.19.1-2).

O una cosa que no existe en la naturaleza, p.ej. un hipocentauro (Gayo, 3.97a; Inst., 3.19.1). También si se ha estipulado bajo una condición imposible de cumplir. Así, p.ej., "si toques el cielo con un dedo" (Gayo, 3.98; Inst., 3.19.11).

Y también es inútil la *stipulatio* por la cual alguien ha estipulado que le sea dada la cosa propia, ignorando que sea suya, puesto que no le puede ser dada a alguien la cosa que ya es suya (Gayo, 3.99; Inst., 3.19.2).

El principio general es una "obligación no puede consistir en algo imposible de cumplir" (*impossibilium nulla obligatio est*; Celso, D.50.17.135).

Hay ciertos casos especiales de *stipulationes* inútiles:

1. Así, la *stipulatio post mortem*: "¿Prometes darme 100 después de mi muerte?" o "¿Prometes darme 100 después de tu muerte?". Se trata de sutilezas excesivas de la jurisprudencia clásica. Si se las veía inválidas es porque "se ha considerado inelegante hacer nacer la obligación en la persona del heredero" (Gayo, 3.100).

1. También se consideraba *inutilis* estipular así: "¿Prometes dar el día anterior al que yo muera?" o "El día anterior al que tú mueras", puesto que no se puede conocer "el día anterior de la muerte de alguien", sino después que ésta ocurra.

Se interpretaba que tenía efectos hacia el pasado y de algún modo se parece a estipular así: "¿Prometes dar a mi heredero?, a la cual se consideraba manifiestamente inútil (Gayo, 3.100).

En cambio, los juristas permiten que se estipule así: "¿Prometes dar en el momento en que yo muera?", "en el que tú mueras", juzgándose que la obligación era conferida para el último momento de la vida del *stipulator* o del *promissor* (Gayo, 3.100).

2. Igualmente era inválida la *stipulatio* hecha por alguien que esté *in potestate*, de que se le daría después de la muerte de su *dominus* o de su *pater*. Así, el esclavo no podía estipular: "¿Prometes darme después de la muerte de mi *dominus*?", ni el *filius*: "después de la muerte de mi *pater*", puesto que la *stipulatio* por la que adquiriría el *dominus* o el *pater*, no habría producido ninguna acción en vida, sino después de su muerte (Gayo, 3.101; Inst., 3.19.13).

Justiniano (C.8.37(38).11, año 526; C.4.11.1, año 531) dio validez a todas estas estipulaciones *post mortem*, y considerando que se trataba de "nimias sutilezas de palabras", derogó el principio de invalidez, de tal modo que es lícito "que las acciones y las obligaciones comiencen en los herederos y contra los herederos".

II. *Stipulatio en favor de un tercero*. La *stipulatio* es un acto que obliga directamente al *promissor* con el *stipulator*. De ahí que la forma corriente, perfectamente válida, era: "¿Prometes darme 100?". En cambio, establecida en favor de un tercero, resulta inválida (*inutilis*). Así, Ticio interroga a Sempronio: "¿Prometes dar 100 a Seyo?". Seyo es un tercero, y, por tanto, no es un acreedor; no tiene acción contra Sempronio. Y en cuanto a Ticio, tampoco lo es, ya que no existe ninguna prestación en favor suyo. Esto se enuncia con la regla clásica de que "nadie puede estipular en favor de otro" (*alteri stipulari nemo potest*; Gayo, 3.103; Inst., 3.19.4).

1. La razón de ser de este principio estaría en que el estipulante carece de interés en la promesa (Ulp., D.45.1.38.17; Diocl. y Maxim., C.8.39.3). Pero esto no aparece como totalmente cierto, pues razonablemente el *stipulator* debe tener siempre un interés en realizar la *stipulatio*, aunque más no sea para donar algo a un tercero.

Quizá el verdadero motivo es la inexistencia en Roma de la "representación directa", lo cual se veía en el principio de que no podemos "adquirir para nosotros por medio de una persona extraña". En forma inversa, podemos adquirir por aquellos que están en nuestra *potestas*.

Por ello resulta válida la *stipulatio* hecha por el *pater* para que se le dé algo al *filius* o al esclavo propio. Como están *in potestate*, la prestación es siempre adquirida por el *pater* (Gayo, 3.103; Inst., 3.19.4). En el texto justinianeo se establece que "Si tú estipulas en favor de aquel que se halla bajo tu *potestas*, adquieres para tí, porque tu palabra es como la palabra de tu hijo, lo mismo que la de éste es como la tuya respecto de las cosas que puedes adquirir".

En la época clásica, Gayo nos plantea dos casos que no producirían los efectos de la regla *alteri stipulari nemo potest*:

a) Cuando, a los solos efectos del pago, se agrega en la pregunta a un tercero. Así, "¿Prometes darme 100 a mí o a Ticio?". Es el caso de la *solutionis causa adiectio* (agregado de otro por causa de pago; Gayo, 3.103a; Inst., 3.19.4; ver *supra*, § 387.e).

b) Cuando sucediera de esta manera: "¿Prometes darme 100 a mí y a Ticio?". Los sabios pensaron que la *stipulatio* era válida, pero sólo para mí, quien podía reclamar los 100, como si no se hubiera agregado el nombre de Ticio. En cambio, los *proculianos* estimaron que sólo podía reclamar la mitad (la *mis*), y que por la otra parte la *stipulatio* era inútil (Gayo, 3.103).

2. Justiniano se inclinará por el parecer *proculiano* (Inst., 3.19.4). Sin embargo, la tesis *sabiniana* parece haberse mantenido para la compraventa. Así, Javoleno (D.18.1.64) nos trae el caso de la compra de un fundo "para mí y para Ticio", opinando "que se ha de considerar como superflua la persona de Ticio, y que por lo tanto me pertenece la compra de todo el fundo". La solución justinianea debía operar para las prestaciones divisibles, no para las indivisibles.

Hacia finales de la época clásica se comienza a admitir una excepción para el caso de una *donatio sub modo*, es decir, una donación "con cargo". Así, "¿Prometes darme *donationis causa* un fundo, el cual luego de tal tiempo se lo deberá dar a Ticio?". Ticio es un tercero, pero por constituciones imperiales mencionadas en los *Fragmenta Vaticana* 286 (aunque sin especificar), por un criterio de *benignitas* (*benignae iuris interpretationes*), se le otorgó acción para reclamar la entrega del fundo, una vez cumplido el plazo.

En el derecho justinianeo, si bien se mantuvo el principio del *alteri stipulari nemo potest* (Inst., 3.19.4), éste se inserta netamente en el criterio del "interés" del *stipulator* (Inst., id.19.20). De este modo, "si alguno ha estipulado que, cuando a él le interesase, se le diese a otro, entonces la *stipulatio* es válida" (Ulp., D.45.1.38.22 itp.).

3. Esto se podía lograr, p.ej., superponiendo una *stipulatio poenae*: "¿Prometes darme 100 a Ticio, y si no lo haces, prometes tú darme tanto a mí?". Aquí, el interés del *stipulator* —estableciendo una cláusula penal superior a la prestación— obligaba más aún al deudor (Inst., 3.19.19; Ulp., D.45.1.38.17).

4. Igualmente, cuando por una *stipulatio* un tutor cede la administración de la tutela a su *co-tutor*, obligándolo a que los bienes del pupilo serán custodiados y mantenidos a salvo (*rem pupilli salvam fore*). Acá, el interés aparece para el pupilo, que es

un tercero, pero también el tutor que estipula tiene acá "interés", puesto que es responsable de la mala administración. (Inst., 3.19.20; Marcelo-Ulp., D.45.1.38.17).

5. También, si estipulá "que se le diera a mi *procurator*", o "a mi acreedor", tengo interés, p.ej., para evitar que se me aplique una "cláusula penal", o que los fundos pignorados sean vendidos (Inst., 3.19.20; Ulp., D.45.1.38.23).

En general, salvo los casos mencionados por Gayo o el de la *donatio sub modo*, se consideran no clásicos, siendo los textos interpolados.

III. *Caso de la promissio a cargo de un tercero*. En el caso anterior se trataba de la *stipulatio* en favor de un tercero. En cambio, acá se trata de que la prestación sea cumplida por un tercero. Así, A pregunta: "¿Prometes que Ticio me dé 100?", y B responde: "Prometo". Como se ve, B está prometiendo, no por él, sino por un tercero. La *stipulatio* es inválida, puesto que el promitente no se ha obligado por él, y en cuanto al tercero es una persona ajena al acto.

Ello no obstante, podría ser válida si el promitente se compromete a hacer algo para que el tercero dé; así, p.ej.: "Prometo que haré que Ticio dé 100", ya que en realidad se comprometo personalmente para influir sobre Ticio para que éste dé (Inst., 3.19.3). En estos casos, se la acompañaba con una "cláusula penal", a cargo del promitente, para el caso de que el tercero no efectuó el hecho (Inst., 3.19.21; Ulp., D.45.1.38.2).

1. También es válida cuando alguien se compromete a que un tercero comparezca en juicio. Celso entiende que es válida, aun cuando no hubiera mediado "cláusula penal", lo que acepta Ulpiano, "porque quien promete que otro comparecerá, promete esto: que él hará que comparezca" (D.45.1.81 pr.).

2. E igualmente cuando un *procurator** estipula la *cautio ratam rem dominum habiturum*, prometiendo que el dueño del asunto por quien está actuando, ratificará todo lo que haga en el juicio (Gayo, 4.84; Inst., 4.1.1-pr.).

III. Pluralidad de *stipulatores* o de *promissores*.

§ 389. Hasta ahora hemos tratado la *stipulatio* como una promesa de pago hecha por un promitente (*promissor*) a un estipulante (*stipulator*). Pero tanto del lado de la parte acreedora como de la deudora, podían intervenir dos o más personas. Se pueden dar los siguientes casos:

1. Podía ocurrir que la *stipulatio* se realizara de manera simple, sin hacer alusión a la totalidad de la prestación. Así, A pregunta: "¿Me

prometen dar 100? y B y C contestan: "Lo prometemos". En este caso, los promitentes están obligados cada uno de ellos por una parte viril, es decir, A podrá accionar contra B para que pague 50 y contra C para que pague los otros 50 (Pap., D.46.2.11.1-2). Es lo que suele llamarse una obligación simplemente mancomunada.

1. Sucede lo mismo en una *stipulatio* entre Ticio y Sempronio. Este último es el deudor, pero muere. La parte que le corresponde pagar se divide por partes viriles entre sus herederos.

2. También se puede dar que la pluralidad sea de los acreedores (p.ej., A, B y C), respecto de los cuales el deudor promete dar 60. Cada uno de los acreedores podrá reclamar su parte viril, es decir, 20.

3. La mancomunada se da siempre y cuando que la prestación sea "divisible". Cuando no lo es, no se podrá dividir, y el acreedor o acreedores podrá demandar el total. Pero esto, que será similar a la obligación *in solidum*, es consecuencia directa de la indivisibilidad de la prestación.

II. Supongamos ahora este otro caso. Se trata de un acreedor A y de dos promitentes B y C.
A: B, ¿me prometes dar 100?
C, ¿me prometes dar los mismos 100?
B y C: Lo prometemos (o cada uno por separado: Lo prometemos).

Este supuesto es conocido como *solidaridad pasiva*. B y C deben 100 a A, quien puede reclamar el total (*in solidum*) a B o a C. Cada uno de ellos debe la prestación íntegra (Inst., 3.16 pr.). El pago efectuado por uno de ellos cumple la obligación (Ulp., D.45.2.3.1; Inst., id.1).

III. Se trata, ahora, de dos *stipulatores* A y B, quienes interrogan al deudor C:

A: C, ¿me prometes dar 100?

B: C, ¿me prometes dar los mismos 100?

C Prometo darles 100 a cualquiera de vosotros.

Este caso es conocido como *solidaridad activa*. Tanto A como B pueden reclamar de C los 100, pero si éste paga a A, ha cumplido la obligación y nada debe a B; Inst., 3.16.1.

1. En los textos se habla de *duo rei stipulandi* y de *duo rei promittendi* (Inst., 3.16; D.45.2), y alguna vez de *coarctus* (Ulp., D.34.3.3.3), de donde deriva la denominación de "correalidad" empleada por los modernos.

2. El problema que se presenta es si en estos casos hay una sola obligación, o hay tantas como coestipulantes o copromitentes existan. Acá hay que distinguir según el aspecto con que se mire la obligación.

Si lo hacemos en relación con el objeto, hay una unidad de prestación: es la misma cosa la que es debida a cada uno por cada uno en su totalidad.

Mirado desde este punto de vista, se puede decir que hay una sola obligación (Javolenus, D.45.2.2; Ulp., D.1d.3.1; Jul., D.1d.6.3). Por ello, pagando uno, los demás quedan liberados.

Pero si se considera desde las personas, tanto si la solidaridad es pasiva o activa, hay un vínculo distinto entre cada acreedor y cada deudor (Pap., D.45.2.9.2). De ahí que Venuleyo pueda hablar para el supuesto de dos promitentes solidarios que hay dos obligaciones (D.45.2.13).

3. Ciertamente es que estos vínculos se hallan conectados por la prestación única, pero se podría dar el caso de que, respecto de uno de los acreedores o de los deudores, la obligación fuera nula. Así, p.ej., A y B son deudores solidarios. Si A queda exento de la obligación por una *capitis deminutio*, el otro no queda libre (Pomp., D.45.2.19).

O también, que uno de los deudores haya visto extinguida a su respecto la obligación solidaria por "confusión" (p.ej., por ser heredero del acreedor). El otro deudor queda, sin embargo, obligado.

Y también si el acreedor concedió a uno de los deudores un *pactum de non petendo* tomando en consideración solamente su persona (*in personam*). Sólo lo beneficia a él, pero no aprovecha al otro. Pero si dicho pacto fue *in rem*, es decir, no en consideración a la persona, sino a la obligación misma, entonces sí se benefician todos (Paulo, D.2.14.25.1).

Debido a esta pluralidad de vínculos, uno de los promitentes puede ser obligado pura y simplemente y el otro bajo condición o plazo. El acreedor podrá demandar directamente al primero, pero respecto del segundo habrá que esperar el resultado de la condición o el vencimiento del plazo (Inst., 3.16.2).

4. Cuando hay dudas sobre la cuestión de saber si la obligación es simplemente mancomunada o solidaria, se presume lo primero, porque la solidaridad es algo excepcional (Pap., D.45.2.11.1-2).

5. La solidaridad puede nacer también de otras fuentes. Así,

a) Por testamento, si se instituye un legado *per damnationem* se ha ordenado "Que mi heredero Lucio Ticio o mi heredero Mevio den algo a Sayo (Pomp., D.30.8.1).

Justiniano mantiene esta regla respecto de la solidaridad pasiva, pero no en caso de solidaridad activa, del tipo Lucio Ticio o Mevio. Interpretando la conjunción "o" como "y", los legatarios son considerados acreedores parciales. Para que surja la solidaridad es necesario una disposición expresa e indubitada del testador (C.6.38.4.1).

b) Por delitos, y en general por disposición legal. Así, respecto de la *condictio furtiva* (Diocletiano y Maximiano, C.4.8.1); también de los condenados por una sentencia (Alejo, C.7.55.1); de los que derramen líquidos en la vía pública (Ulp., 9.3.3); etc.

c) En la época de Justiniano se aplica a muchos negocios, dependiendo de la voluntad de las partes. Así, la solidaridad se generaliza a la compraventa, la

locación, el depósito, el comodato (Pap., D.45.2.9 pr.; Ulp., D.13.5.5.15; Ulp., D.19.2.13.9 ítps).

de carácter autónomo e independiente de la cesión (C.8.39.1.1 ítp.).

§ 390. En la época clásica, si un acreedor accionaba contra uno de los deudores solidarios, se consideraba que por el efecto de la *litis contestatio* se producía el consumo de la *actio*, lo que impedía una nueva *actio*, ya por parte de otro acreedor, o contra otro deudor (Javol., D.45.2.2; Scév., D.13.1.18).

Justiniano produjo la muy importante decisión de eliminar el efecto extintivo de la *litis contestatio* respecto de las obligaciones solidarias. El ejercicio de una nueva *actio* sólo se ve impedida cuando el deudor había pagado la prestación debida o satisfecho de otro modo al acreedor (C.8.40.23, año 531).

1. De este modo, si un acreedor no había podido lograr la satisfacción plena de la obligación por parte de un deudor, podía demandar a los restantes.

2. Lo que ocurrió fue que la tarea de interpolación de los textos del Digesto no fue realizada con proflijidad, por lo que permanecieron sin manipuleo textos clásicos que daban la solución anterior.

Esto produjo una complicada y estéril discusión entre los romanistas del siglo XIX, acerca de la existencia de dos clases de solidaridad: a) cuando la obligación se extinguía solamente por la satisfacción total de ella, se hablaba de "obligaciones solidarias"; y b) cuando la obligación se extinguía también con el consumo de la acción, por efecto de la *litis contestatio*, se hablaba de "obligaciones correales".

§ 391. El problema que se plantea en los casos de solidaridad es el del reembolso, ya del acreedor que cobró el todo por parte del deudor respecto de los coacreedores, ya del deudor que pagó el todo al acreedor respecto de los codeudores.

En el derecho actual se habla en este caso de "acción de regreso". Pero en Roma, ésta no existía, puesto que de la *stipulatio* solidaria no se derivaba *ipso iure* la posibilidad de reclamar dicho reembolso, puesto que no se entendía derivarse de este acto ninguna relación jurídica entre los acreedores o deudores entre sí.

Sin embargo, ello podía ocurrir si entre los coestipulantes o entre los copromitentes existían relaciones jurídicas internas, que podían fundar el reembolso. Así, una sociedad (Ulp., D.35.2.62 pr.), o un mandato. En el primer caso, había que actuar por la *actio pro socio* o la *actio communi dividundo** (que ponía fin a la *communio* habida). En el segundo, por la *actio mandati* contraria.

1. El otro recurso que tenían era la cesión de acciones entre los coacreedores o codeudores. Justiniano terminó concediendo una acción de reembolso

IV. *Stipulationes* accesorias.

La *stipulatio* normal puede contener añadidos, los cuales se pueden referir a la estipulación misma (caso de la "estipulación penal"), como también al agregado de personas, que sin ser propiamente las partes que han estipulado, cumplen el papel, ya de reforzar la figura del "acreedor" (caso del *adstipulator*), o ya para adelantar la situación del deudor (caso del *sponsor*, del *adpromissor*, que son fiadores; luego la fianza personal se unificará en la persona del *fideiussor*).

§ 392. I. *Estipulación penal*. En una *stipulatio* se puede agregar una cláusula que establezca una pena para el caso de incumplimiento. Así, si alguien estipula que otro haga alguna cosa, puede añadir lo siguiente: "¿Prometes, para el caso que no se hiciera, darme 100 áureos a título de pena?" (Pap., D.45.1.126.3). De este modo, existe la prestación principal, y en forma condicionada, para el caso de que no se cumpla, figura la obligación de tener que pagar la "pena".

1. La *stipulatio poenae* tenía una gran ventaja cuando, p.ej., se había estipulado un *facere* o dar otra cosa que no fuera dinero. La pena fijada era una especie de prefijación de los daños y perjuicios que se ocasionarían. El acreedor no quedaba expuesto al *arbitrium* del juez (Inst., 3.16.7; Ulp., D.45.1.65).

2. Más que como cláusula accesorias, es una obligación condicional (la condición consiste en que no se cumpla la prestación primera).

No cumplida ésta, el acreedor puede optar entre pedir la prestación primera o la pena, sin poder acumular ambas acciones. Sin embargo, se admite que en caso de haber pedido la pena, podía, siendo de buena fe, ejercer la originaria, pero sólo para poder pedir lo que podía obtener en más. En cambio, si había optado por reclamar la originaria, no podía luego accionar por la pena (Jul., D.19.1.28).

Pese a ello, se admitió la acumulación si ésa fue la voluntad de las partes. Así, si se estipuló dar una suma de dinero, la cláusula penal podía representar los intereses debidos por la mora por retraso en el pago; siempre que no excediera el monto legal fijado para los intereses (Pap., D.21.1.9).

Si el deudor pagó la "pena", goza de la *exceptio doli* para el supuesto de que el acreedor intentara accionar por la obligación primera.

3. La cláusula penal se puede agregar no sólo a la *stipulatio*, sino a cualquier obligación de derecho estricto o de buena fe, incluso a una obligación natural.

§ 393. La *adstipulatio*. El *adstipulator* es un acreedor adjunto en quien el acreedor principal deposita su confianza para el cobro de la obligación. Podía tener lugar del siguiente modo:

A: "Ticio, ¿prometes darme 100?"

Ticio: "Prometo".

B (preguntando con el consentimiento de A:

"Ticio, ¿me prometes dar los mismos 100?"

Ticio: "Te lo prometo".

1. Examinemos lo ocurrido. La primera *stipulatio*, celebrada entre A y Ticio, es la principal. La segunda, celebrada entre B y Ticio, es adjunta de la primera y ésta es la llamada *adstipulatio*: B cumple el papel de *adstipulator* (*ad* = junto al *stipulator*).

Ticio, como deudor debe solamente 100, suma que deberá pagar a A o a B, quienes a su vez le podrán reclamar dicha obligación. Obviamente, pagando a uno de ellos Ticio ha satisfecho lo prometido.

2. Esta figura se diferencia de dos casos, que nos podrían confundir: el caso de la *solutio in causa adiectio* y el de la existencia de dos o más acreedores solidarios (*plures rei stipulandi*).

a) En el supuesto de que en la *stipulatio* se haya agregado otra persona *solutio in causa* ("¿Prometes darme 100 a mí o a Mevio?"), ésta está solamente incorporada a la *stipulatio*, con una única finalidad: recibir el pago. No es un coacreedor y por ello no podría reclamar los 100 a Ticio.

b) En el caso de dos o más acreedores *in solidum*, todos ellos son acreedores principales. En cambio, el *adstipulator* es meramente un acreedor adjunto. Puede por ello reclamar los 100 a Ticio, lo mismo que el acreedor principal, pero su función es accesoria. Lo que cobra no es para él, sino que debe devolver lo abonado al *stipulator* principal. La relación entre éste y el *adstipulator* es análoga a la del "mandato". Por ello, si el *adstipulator* no le devuelve lo cobrado al *stipulator*, éste puede reclamársela por la *actio mandati* (Gayo, 3.111).

¿Cuál era su utilidad? Aparte de obrar como mandatario del *stipulator*, en la época clásica, Gayo le asigna la función de poder hacer efectiva una *stipulatio post mortem* (Gayo, 3.117).

3. Como sabemos, la *stipulatio post mortem* era *inutilis* (Gayo, 3.100). Pero si se le agregaba una *adstipulatio*, la obligación era válida (aunque no lo fuera la *stipulatio*). Así:

A: "Ticio, ¿prometes darme 100 después de mi muerte?"

Ticio: "Prometo".

B "Ticio, ¿prometes darme esos mismos 100?"

Ticio: "Prometo".

Luego de la muerte de A, el *adstipulator* podía accionar contra Ticio; si bien debe devolver lo pagado a los herederos de A, quedando obligado por la *actio mandati* (Gayo, 3.117).

De esta modo, vemos que el *adstipulator* fue una especie de fiduciario del *stipulator* principal. Si yendo en contra de la *fides* en el depositada, el *adstipulator*, actuando de manera fraudulenta, le hacía una remisión de la deuda al obligado, mediante una *acceptilatio*, entonces quedaba responsabilizado por una *actio* establecida en el capítulo II de la *lex Aquilia* (Gayo, 3.215).

4. En tiempo de dicha *lex Aquilia*, todavía no existía el mandato como contrato. Ya en la época de Gayo, a pesar de que existe ya el mandato, se la sigue manteniendo, debido a que la acción nacida de la *lex Aquilia*, tiene el carácter de "litisrescencia", es decir que en caso de oposición del *adstipulator* demandado, si éste era vencido en el juicio, la condena se elevaba al *duplum* (Gayo, 3.171).

La *adstipulatio* estaba prácticamente en desuso hacia el final del siglo II d.C. Gayo (3.110, 114; 117) es la principal fuente de información. Justiniano no la menciona para nada, siendo reemplazada por el mandato.

§ 394. *Stipulationes* accesorias a la *promissio*. Estas *stipulationes* funcionan como "garantías" o "fianzas" respecto del *promissor* (Gayo, 3.115).

A) En un principio apareció la figura del *sponsor*, a la que luego se agregó la del *fideipromissor*. En la primera había que emplear el verbo *spondere*, reservado a los ciudadanos romanos. En cambio, la *fideipromissio*, mucho más amplia, permitía su uso por parte de los extranjeros. Se sigue con ello el mismo desenvolvimiento ocurrido con la *sponsio* y la *stipulatio*.

1. En el caso de la *sponsio* (accesoria), luego de haberse celebrado la *sponsio* principal, el *sponsor* era interrogado así: *Idem dari spondes?* ("¿Te comprometes solemnemente a dar lo mismo?").

Hay que advertir que en un sentido amplio, *sponsio* hace referencia a toda estipulación en la que se emplea el verbo *spondere*. En cambio, en un sentido más restringido (el aquí usado) significa una estipulación de garantía.

En cambio, en la *fideipromissio* (accesoria), luego de haberse celebrado la *stipulatio* principal, el *fideipromissor* era interrogado así: *Idem fideipromittis?* ("¿Prometes por tu *fides* a lo mismo?"); Gayo, 3.116.

El régimen de la *sponsio* y el de la *fideipromissio* era prácticamente el mismo:

a) Ambas eran accesorias respecto de la *stipulatio* principal, no de una obligación principal. Ineludiblemente sólo podían afianzar una *stipulatio* (Gayo, 3.119), pero no las obligaciones nacidas de otra fuente, a menos que hubieran sido novadas en una *stipulatio*.

b) Este carácter accesorio no afecta la *sponsio* ni la *fideipromissio*, en caso de invalidez de la *stipulatio* principal. Al igual que en el caso de la *adstipulatio*, aunque la *stipulatio* principal fuera inválida, estas formas de garantía eran eficaces.

2. Así, si la estipulación era una *stipulatio post mortem* (*inutilis*), la *sponsio* o *fideipromissio* accesorias eran exigibles. Lo mismo si la mujer o el pupilo hubiesen prometido algo por una *stipulatio* sin la auctoritas del tutor, tanto el pupilo como la mujer no eran ejecutables, pero si el *sponsor* o el *fideipromissor* (Gayo, 3.119).

c) Sin embargo, la accesoriedad funciona en cuanto al contenido de la *stipulatio* principal. Así, como obligación accesoria, no podían exceder lo prometido en la *stipulatio* principal. De este modo, si se había prometido 100, no se podía en las formas accesorias obligarse por 200; aunque sí por menos, p.ej. por 50 (Gayo, 3.126: "Lo accesorio no puede contener más que lo principal").

d) Eran estrictamente personales, de tal modo que muerto el *sponsor* o el *fideipromissor*, no se transmitía la obligación a sus herederos (Gayo, 3.120).

§ 395. En cuanto a los efectos jurídicos, aunque se produce una "solidaridad pasiva", el deudor principal y los fiadores accesorios no son *plures rei promittendi* (es decir, ambos principales), al igual que lo que sucedía con la *adstipulatio*, donde tampoco *stipulator* y *adstipulator* son *plures rei stipulandi*. En realidad, son dos actos distintos, y la garantía hasta podía ser dada más tarde. La identidad no está en lo debido, sino en la promesa realizada.

El acreedor podía reclamar la totalidad de lo prometido tanto al *promissor* principal, como al *sponsor* o *fideipromissor* accesorios. Estos no tienen el derecho de pedir que primero se accione contra el *promissor* y luego se vaya contra ellos (el *beneficium excussionis*).

1. Sin embargo, lo usual era primero ir contra el *stipulator*. Cuando el acreedor se dirigía directamente contra los fiadores, él hacía pensar en que el deudor principal era insolvente, provocando murmuraciones que afectaban el honor tan preciado que se tenían los romanos; incluso, si se lo hacía con propósito de difamar al deudor principal, podría dar ocasión a que éste intentara la *actio iniuriarum* (v. Gayo, 3.223; D 47.10.19).

Satisfecha la obligación, ya por el deudor principal o por el fiador, ésta se extinguía, y si el acreedor remitía la deuda a uno de sus dos deudores por *acceptilatio*, ambas obligaciones

quedaban extinguidas. Si era necesario acudir al reclamo judicial, los efectos de la *litis contestatio* no afectaban otras acciones posteriores. Esto se debe a que el *promissor* principal y fiadores accesorios no eran "deudores solidarios" (*plures rei promittendi*).

2. Así, si el acreedor demandaba al *promissor*, la obligación principal se extinguía por la *litis contestatio*, pero no afectaba la obligación accesoria del *sponsor* o del *fideipromissor*, porque la existencia de ésta no dependía de la existencia de la obligación principal.

Al revés, si se demandaba al *sponsor* o al *fideipromissor*, la obligación accesoria de éstos quedaba extinguida por la *litis contestatio*, pero no se afectaba la obligación principal del *promissor*.

§ 396. *Leyes especiales*. Dada la importancia prevaqueciente que tuvieron en Roma las "garantías personales" respecto de las "garantías reales" (v. *supra*, § 285), fueron de uso corriente no sólo en las épocas clásica y posclásica, sino con anterioridad. Muestra de ello es que en el período republicano existieron algunas leyes tendientes a simplificar y aclarar la situación de los fiadores:

a) Por una *lex Furia* (siglo II a.C.), sólo aplicable en Italia, no en provincias, se determinó que las fianzas de los *spondes* y *fideipromissores* caducaban al cabo de dos años (Gayo, 3.121).

b) Una *lex Publilia* (siglo IV a.C.) fijó que si el *sponsor* (no se hablaba del *fideipromissor*) había pagado la deuda y no era reembolsado en el plazo de seis meses por el deudor principal, tenía una *actio depensi*, que era por el *duplum* (Gayo, 3.127).

En la época clásica, tanto el *sponsor* como el *fideipromissor* disponen de la *actio mandati contraria* (o de la *a. negotiorum gestorum contraria*) para reclamar el desembolso (Gayo, *ibid.*).

c) Cuando se trataba del supuesto de varios *spondes* o *fideipromissores*, se entendía, en principio, que el acreedor podía reclamar el todo de lo afianzado (*in solidum*) a quien eligiera de entre ellos; pagando se extinguía la obligación.

Pero en virtud de una *lex Appuleia* (siglo II, pero anterior a la *lex Furia*), se consideró que entre dichos fiadores se establecía una especie de sociedad, de tal modo que si uno de ellos pagó más allá de la parte viril que le correspondía, podría ir contra los otros cofiadores, por el excedente (Gayo, 3.122).

La mencionada *lex Furia* (sólo para Italia) dio un paso más. El acreedor no podía reclamar a los *spondes* y *fideipromissores* más allá de la parte viril que le correspondía a cada uno, lo que significaba la división *ipso iure* de las garantías (Gayo, 3.121).

Y otra ley (de la misma época), la *lex Ciceronia* obligaba al acreedor a manifestar públicamente la

cantidad de *sponsos* o *fideipromisores*, así como la cantidad que afianzó cada uno de ellos. Si no lo hacía, los fiadores tenían derecho a interponer dentro de los 30 días una acción prejudicial (*praedictum*) para averiguar si dicha proclama fue hecha, y si se decidiera que no ocurrió, entonces quedaban liberados (Gayo, 3.123).

c) Por último, por una *lex Cornelia* (época de Sylla, año 81 a.C.) se prohibió que un mismo fiador se obligara respecto del mismo acreedor por una cantidad superior a los 20.000 sestericios. Si excedía dicho monto, la fianza sólo era válida hasta lo permitido. Se quería evitar que una misma persona quedara atada por razón de fianza a la misma persona. Ello provocaba que se tendiera a una pluralidad de fiadores, si el caso lo requiría (Gayo, 3.124).

§ 397. *Fideiussio* Hacia finales de la República aparecerá una forma más perfeccionada de fianza: la *fideiussio*. A diferencia de los casos anteriores (*sponsio* o *fideipromissio*), ahora no se garantiza la "promesa" (*stipulatio*) del deudor principal, sino que el *fideiussor* se obliga por el *debitum* de la obligación principal, declarándose responsable de él. La forma usual era así:

A: "Ticio, ¿me prometes dar 100?"

Ticio: "Lo prometo".

A: "Mevio, lo que me debe Ticio, ¿te obligas a que sea soportado por tu *fides*?"

Mevio: "Me hago cargo de ello por mi *fides*".

1. Como se ve, ya no se trata de una *stipulatio* accesoria de otra *stipulatio*, sino de una *stipulatio* que implicaba una obligación accesoria de otra obligación principal. Lo que se afianza es la prestación misma de la obligación principal.

§ 398. Efectos de la *fideiussio*

a) Por la forma empleada de la *fides* (al igual que ocurría con la *fideipromissio*) puede ser usada tanto por ciudadanos romanos, como por extranjeros.

b) Al no requerir necesariamente una *stipulatio* principal, por la *fideiussio* se pueden garantizar toda clase de obligaciones, no solamente las contraídas en forma verbal, sino también en forma real (p.ej., un mutuo), en forma literal, o en forma consensual (p.ej., una compraventa). Y no importaba si la obligación garantizada era civil o natural (Gayo, 3.119a; Inst., 3.20.1).

1. El carácter "accesorio" ahora cumple efectos en forma amplia. Por ello, al igual que en las formas anteriores, un *fideiussor* no podía garantizar una obligación que fuera superior al monto de la principal (Gayo, 3.126).

Pero a diferencia de la *sponsio* y de la *fideipromissio*,

missio, en las cuales de ser inválida la *stipulatio*, lo mismo valían, acá, si la obligación principal era nula *ab initio* la *fideiussio* también era nula. Para ser válida la garantía, debía ser válida la obligación principal, ya *civilliter* o ya *naturaliter* (Gayo, 3.126).

c) Por haber garantizado la obligación principal, la *fideiussio* se transmite a los herederos del fiador (Gayo, 3.120).

d) La *fideiussio* no tiene ningún plazo de caducidad. En tal sentido no le es aplicable lo que dice la *lex Furia* (en Italia), de que la *sponsio* o *fideipromissio* accesorias, caducaban a los dos años (Gayo, 3.121).

2. En cambio, le es aplicable la limitación de la *lex Cornelia* (Gayo, 3.124). Pero esta ley irá cayendo en desuso en la época posclásica. Justiniano no la menciona (Inst., 3.20).

§ 399. *Relación entre el acreedor y los obligados*. Siendo varios deudores por el mismo crédito, a menos que se hubieran obligado solamente por una parte (Pap., D.46.1.51 pr.), quedaban obligados cada uno por la totalidad del *debitum* (*singuli in debitum*), aun cuando esto no hubiera sido expresamente dicho (C. Severo y Antonino, 8.4k.). Esto se desprende del resultado de su respuesta: *Idem fideiubeat Fideiubeo*.

A) El acreedor podía dirigir la acción de cobro —salvo que hubiera mediado alguna convención contraria, estableciendo algún orden en la ejecución— ya contra el deudor principal, ya contra el fiador (C. Antonino, 8.41.5; C. Dioc. y Maxim., C.4d.19 y 21). Pero iniciada la acción y operada la *litis contestatio*, se operaba la consumición de la acción, de tal modo que se excluía una nueva demanda por el mismo asunto (*eadem res*). Así, si la demanda contra el deudor principal no ha sido satisfecha al acreedor, éste no podrá luego demandar al *fideiussor*, y recíprocamente (Paulo, 2.17.16; Gordiano, C.8.41.16, año 241).

1. Se plantea acá el mismo problema que respecto de los deudores solidarios. Este problema recién será solucionado por Justiniano, al suprimir para estos casos el efecto consuntivo de la *litis contestatio* (C.8.41.28; año 531; ver *supra*, § 390; *infra*, § 400, A). Mientras tanto, se practicaron algunos remedios, que sirvieron de paliativos, pero para los cuales se necesitaba la colaboración del acreedor.

2. Así, un procedimiento empleado para remediar esta situación fue la *fideiussio indemnitis*, la cual integraba la *stipulatio* de la *fideiussio*. En este caso, el garante se obliga a pagar sólo en el caso de que el acreedor no hubiera sido satisfecho por el deudor principal. ("Tomo bajo mi *fides* todo aquello que en cuanto de menos hubieras conseguido de Ticio").

Ello obligaba a tener que demandar primero al deudor principal, y sólo después al garante. En realidad, no es propiamente una *fideiussio*, ya que no se obliga a lo mismo, sino que se responsabiliza a pagar una indemnización por lo que no pague el acreedor principal, la cual sería condicional, supeditada a lo que no pague este último (Pap.-Paulo, D.45.1.116; Paulo, D.46.3.21; v. Celso, D.12.1.42).

3. Otro procedimiento era que el fiador amenazaba de ser demandado, daba mandato al acreedor para accionar contra el deudor principal, a cuenta y riesgo del *fideiussor* (Inst., 3.26.2). De este modo, el acreedor, al haber aceptado este mandato, debía dirigirse primero contra el deudor principal, pero si éste no le satisface la deuda en forma total podrá ahora accionar contra el *fideiussor*, no como tal, sino como mandante por medio de la *actio mandati contraria* (Paulo, D.17.1.45.7).

B) A su vez, en caso de pluralidad de *fideiussores*, no les fue aplicable la *lex Furia* (tampoco la *lex Apuleia* ni la *Cicereia*), que obligaba a la división de responsabilidad, por su parte viril. De este modo, todos debían responder *in solidum*.

Sin embargo, por una epístola de Adriano, se extendió el beneficio de la división. Según lo allí dispuesto, el acreedor es compelido a reclamar contra cada uno de los *fideiussores* —que fueran solventes antes de la *litis contestatio*— a pagar sólo su parte viril (Gayo, 3.121; Inst., 3.20.4).

2. Pero, a diferencia de lo que indicaba la *lex Furia*, a) la división no se produce de pleno derecho (*ipso iure*), sino que el *fideiussor* demandado debía pedirlo; y b) la división no tiene lugar entre todos los *fideiussores*, sino sólo entre aquellos que son solventes en el momento de la *litis contestatio*. Por ello, hasta ese momento los *fideiussores* responden de la insolvencia de los otros (Gayo, D.46.1.25; Pap., D.46.51.1 y 4).

3. El acreedor podía por ello iniciar la demanda *in solidum*, debiendo en este caso uno de los *fideiussores* pedir la división usando de la *exceptio* "si también ellos no fueran solventes" (Paulo, D.46.1.28). Con ello, corría a su cargo probar la solvencia de los otros. Si no lo probaba, y por ello sólo uno de los *fideiussores* fuera solvente, entonces éste debía responder *in solidum*.

Si un *fideiussor* pagaba el todo, en caso de insolvencia del deudor principal, el sólo soportará el perjuicio, por no haber usado del beneficio de división del rescripto de Adriano (Inst., 3.20.4).

§ 400. *Relación entre el deudor y los fideiussores*. El reembolso —acción de regreso— del *fideiussor* que pagó respecto del deudor principal, está concebido en el mismo marco que

los deudores solidarios. En principio, no tiene derecho a este reembolso, salvo que existiese entre ellos una situación jurídica especial (p.ej., el mandato); de ser así, el *fideiussor* que pagó podía exigir el reembolso por la *actio mandati contraria* (Gayo, 3.127; Inst., 3.20.6). En su caso, aun cuando no hubiera directamente mandado expreso o tácito (así, p.ej., si alguien salía de fiador por una persona ausente), el *fideiussor* gozaba de la *actio negotiorum gestorum** (Paulo, D.17.1.20.1).

También, en la época clásica, se podía utilizar el procedimiento de que el *fideiussor* podía ofrecer al acreedor la dación de lo debido, no tanto entendido como "pago" sino como que "le ha vendido el crédito" que tiene contra el deudor (Paulo, D.46.1.36). De este modo, este *fideiussor* gozará de la "cesión de las acciones". Podrá demandar al deudor principal en nombre del acreedor y como él mismo acreedor. Y además, contra los otros fiadores, sobre la base de la división de la obligación en los términos del rescripto de Adriano (Severo y Antonino, C.8.41.2, año 207).

1. Como lo veremos, un crédito no puede ser transferido a otro. Pero sí le puede ceder las acciones, constituyendo al cesionario como un *procurator*, si bien en el propio interés de éste (*procurator in rem suam*).

De este modo, si bien se había desinteresado al acreedor, la obligación no quedaba extinguida. Más que a título de "pago", era una "venta de las acciones" (Paulo, D.46.1.36). Se debía contar con el consentimiento del acreedor, pero el pretor auxiliaba en este caso al fiador, compeliendo al *stipulator* a ceder las acciones cuando se ofrecía pagar la totalidad (Jul., D.46.1.17; C. Severo y Antonino, C.8.41.2; C. Dioc. y Maxim., *id.*, 21).

2. El beneficio que podía tener el cesionario es que al poder ejercer la acción de la obligación principal, gozaba de todas las garantías de prenda o hipoteca que podría tener ésta.

§ 401. *La fideiussio en la época de Justiniano*. En los textos de las Institutas, del Digesto y del Código ha desaparecido toda referencia a la *sponsio* y a la *fideipromissio*. Ellos han sido totalmente interpolados, suplantando esas formas y reemplazándolas por la *fideiussio*, que queda como única garantía estipulatoria.

Las características principales de la *fideiussio* para esta época son las siguientes:

A) Modificó los efectos de la *litis contestatio*, que como habíamos visto, impedía que luego de haberse demandado al deudor principal o a un *fideiussor*, se pudiera demandar el cobro en forma sucesiva a los distintos obligados (C.8.41.28 pr.; I.3, año 531). Sólo quedan éstos libres de persecución por parte del acreedor cuando éste ha sido totalmente satisfecho.

B) El *fideiussor* goza de tres beneficios:
a) el beneficio de *excusión* (*beneficium excusationis*). En caso de ser demandado el fiador, gozaba de una *exceptio*, obligando al acreedor a que primero accionara contra el deudor principal (Nov. 4.1, año 535), agotando las posibilidades de pago de éste;

b) el beneficio de *división* (*beneficium divisionis*). Cada uno de los *fideiussores* podía rechazar el reclamo que excediera a la parte viril que le correspondiera pagar, pidiendo la división de la obligación respecto de los coñadores solventes al momento de la sentencia (Nov. 97.1; año 539).

c) el beneficio de *cesión de acciones* (*beneficium cedendarum actionum*). Habíamos visto que en la época clásica el fiador que ofrecía satisfacer en forma íntegra al acreedor, podía obtener la "cesión de las acciones" contra el deudor principal y otros fiadores.

Justiniano, en el año 535 (Nov. 4.1, *in fine*), otorga el *beneficium cedendarum actionum* en forma general a todo *fideiussor*, sin necesidad de la expresa cesión de su acción.

V. La *intercessio*.

§ 402. El vocablo *intercessio* hace en general referencia a la intervención de una persona, ya garantizando en forma personal o real, así como sustituyendo a un deudor.

La *intercessio*, como toda actividad propia de los banqueros, era considerada un negocio viril. Por ello, en el siglo I d.C. se sancionó el *senatusconsultum Velleianum*, que prohibió los actos jurídicos por medio de los cuales las mujeres se hacían responsables de deudas ajenas. Esto se refería a dos casos: a) que la mujer pudiera prestar una fianza garantizando la deuda de otro (*sponsio*, *fideipromissio*, *fideiussio*); b) el préstamo de dinero hecho a una mujer que ésta transfería inmediatamente a otra persona (Ulp., D. 16.1.2.1). De este s.c. surgirá una defensa para la mujer (*exceptio s.c. Velleiani*), así como dos acciones para casos especiales en favor del acreedor (*actio restitutiva* y *actio institoria*).

I. *Exceptio s.c. Velleiani*. 1. El acto de *intercessio* realizado por la mujer no era nulo para el *ius civile*, pero se le otorgaba a ésta una *exceptio* que el pretor introducía de oficio en la fórmula (*exceptio s.c. Velleiani*).

La mujer perdía la *exceptio* si el acreedor probaba que, a sabiendas, había actuado dolosamente haciéndole creer que el acto era en su beneficio (Paulo, D. 16.1.23; D. id. 30 pr.).

Igualmente no gozaba de la *exceptio* cuando realmente la deuda era propia. Así, si Mavia pide un

préstamo a A y éste le da el dinero a B quien se lo trasfiere a Mavia, la cual aparece que es fiadora de B. En la realidad económica todo el provecho es para Mavia, por lo que este caso no entra en el s.c. (Calistrato, D. 16.1.21 pr.; Gayo, D. id. 13 pr.).

Lo mismo sucedía si le da el dinero a Seya para que le pague a un acreedor mío, aunque esté pagando la deuda de otro; se obliga por el mandato, por lo que perece que es en causa propia.

2. Si no obstante lo dicho en el s.c. la mujer paga, dicho pago es repetible por la *condictio indebiti*, salvo que ella hubiera pagado a sabiendas que no estaba obligada a hacerlo; así, p.ej., mediando un documento que lo probara.

Justiniano entenderá que la mujer podía renunciar a la excepción, en forma independiente del pago; así, aceptando el juicio en su contra por ser fiadora, dando caución de que no usará la *exceptio* (Pomp., D. 16.1.32.4; Ulp., D. id. B.10. itps.).

II. *Actio restitutiva*. Si la mujer hubiese salido fiadora de otro y hubiese extinguido la obligación (p.ej., por medio de una "novación"), el pretor le concede al acreedor esta *actio restitutiva*. Así, A le había prestado dinero a B. Mavia, por medio de una *stipulatio* novatoria, asume para sí la obligación, de manera gratuita, es decir, sin recibir nada del deudor B. Ella está amparada por la *exceptio* y A no tendría acción contra B por haberse extinguido la obligación por la novación.

Sin embargo, el pretor ampara al acreedor por esta nueva acción, con fórmula ficticia, fingiendo que la *intercessio* no tuvo lugar (EP, § 105; Ulp., D. 16.1.5.7-13; Gayo, D. id. 13.1-2).

III. *Actio institoria*. Se concede esta acción para que el acreedor pueda reclamar del deudor respecto del cual medió la *intercessio* de una mujer.

Así, p.ej., A quiere prestar dinero a B, pero interviene Seya para que preferentemente el dinero le sea dado a ella. A se lo da, y ella inmediatamente se lo da a B. Se considera que la mujer obró como fiadora. Pero a A se le da esta *actio institoria* para reclamar de B, por el mismo género de obligación por el cual se obligó Seya; así, p.ej., por una *stipulatio*.

La fórmula es ficticia, fingiéndose que la obligación no tuvo lugar por la *intercessio* de la mujer, sino que era como si hubiera nacido directamente en el deudor ("como si hubieras convenido ex *stipulatu*"; EP, § 105; Ulp., D. 16.1.8.14-15).

VI. Promesas de pago unilaterales.

Hay dos casos en los cuales es posible contraer obligaciones por medio de palabras (*obligationes verbis*); pero a diferencia de lo que ocurre en la *stipulatio*, no hay una pregunta del acreedor seguida de la respuesta del deudor,

sino que éste se obliga directamente. Por ello, Gayo los denomina *uno loquente* (sólo habla uno; Gayo, 3.95a, 96).

§ 403. *Datio dotis*. Se trata de la promesa solemne de dote, que podía ser hecha solamente por la misma mujer que se va a casar, por su *pater* y también por un deudor de la mujer que actuara por orden suya (Gayo, 3.95a).

1. La fórmula era así: *Dos filiae meae erunt centum* (La dote de mi hija serán 100). La mujer la podía constituir si era *sui iuris* y con la *auctoritas* de su tutor. Si la constituía el *pater*, era denominada "profecticia". Si la "decía" el deudor, "adventicia" (Ulp., 6.2-3).

2. Se la solía realizar con los *sponsalia*, pero también prometer al marido luego de las nupcias (Gayo, 3.95a). La acción por la que se podía reclamar en caso de incumplimiento, es la misma que si fuera una *stipulatio* (C. 5.12.1, año 201: *condictio o actio ex stipulatu*).

3. No hay que confundirla con la *promissio dotis*, que es posterior y que consistía en una *stipulatio* (pregunta y respuesta), prometiendo la dote.

4. En el derecho posclásico, la *datio dotis* cayó en desuso. Según una constitución de Teodosio y Valentiniano del año 428, bastaba un simple pacto verbal o escrito por el cual se conviniera la dote, sin necesidad siquiera de *stipulatio* (C. 5.11.6).

§ 404. *Iusiurandum liberti*. Era el juramento por el cual el liberto, mediante promesa

unilateral (*uno loquente*), se obligaba a hacer a su patrono un regalo (*donum*), un servicio (*munus*) o trabajos (*operae*). Como dice Gayo (3.96), es el único caso en que una obligación se podía contraer por un juramento.

1. La forma usual era un juramento (*iusiurandum*) del esclavo antes de ser manumitido. Con ello el *dominus* se aseguraba la prestación, puesto que si bien el esclavo es incapaz de derecho, podía prestar un juramento religioso.

Luego de manumitido, era seguido por un segundo juramento, ya que se pensaba que el primero no arrastraba total responsabilidad civil, aunque sí religiosa (Venuleyo, D. 40.12.44 pr.). También se admitió, en lugar de este segundo juramento, una *stipulatio* (Venuleyo, *D. ibid.*; Pomp., D. 38.1.8 pr.; Paulo, D. id. 37 pr.).

2. Si bien en el texto de Gayo, reconstituido, se habla de *donum*, *munus*, *operae*, la acción que tiene el patrono es denominada *actio operarum* (EP, § 140), dándose a la palabra *operae* un sentido muy amplio, abarcativo de las demás prestaciones (Ulp., D. 38.1.7.3; Paulo, D. id. 37 pr.).

Según Lenel, era una *actio civilis* (fórmula *in ius concepta*), redactada sobre el modelo de la *condictio certae rei* (Pomp., D. 38.1.4: compara las *operae* a la *pecunia credita*; de donde habría un paralelismo con la *actio certae creditae pecuniae*). Aunque, para otros, la *condemnatio* era *incerta*, dejándose al juez la valuación de los "días" de las *operae*, ya que éstas eran computadas en forma diaria (Paulo, D. 38.1.1).

OBLIGACIONES LITERALES
(CONTRATOS LITERALES)

§ 405. Gayo (3.128-134) nos habla de que se podían contraer obligaciones *litteris* (por "letras", es decir, escritos o documentos), haciendo especial referencia a los *nomina transcripticia*. Estos están vinculados con las anotaciones vinculadas con el *codex accepti et expensi* (libro del Haber y del Debe), de tal modo que las anotaciones allí realizadas, cuando correspondían a efectivas transferencias de dinero, hacían nacer obligaciones.

1. Todo este tema es bastante dificultoso y oscuro. Prácticamente las únicas fuentes de información están representadas por estos párrafos de Gayo y por las indicaciones accidentales de algunos autores como Cicerón (*pro Roscio com.*, 5.14; *pro Caec.*, 6.17; *in Verr.*, 2.276.186, *id.*, 2.139.102; *ad Att.*, 4.17 (18).2; *ad Fam.*, 7.23; *de off.*, 3.14.59); Plauto (*Truc.*, 1.51-54); Plinio (*HN.*, 2.7.22); Ps.Asconio (*in Verr.*, 2.1.60); Séneca (*de ben.*, 2.23.2-3 y 3.15.2); Val.Max. (S.2.2), etc. Todos estos textos hacen meras referencias, y en suma los puntos importantes quedan sin establecer claramente el funcionamiento total del sistema.

2. En principio, está referido a la costumbre que tenía el *pater* de llevar escrupulosamente sus cuentas patrimoniales en una especie de borrador (sería algo así como un "libro diario") llamado *adversaria*, con tablas distintas para las "entradas" (*accepta*) y para las "salidas" (*expensa*). Periódicamente, lo habitual era en forma mensual, se trasladaban las anotaciones a un libro más importante llamado *codex* o *tabulae*.

3. Estas anotaciones sirven en principio para llevar la contabilidad e incluso como medio de prueba respecto de los actos realizados. Se anotaba el nombre (*nomen*) de la persona que había dado, p.ej., dinero en mutuo, o el del que había pagado. Prontamente, la designación del *nomen* pasa a la designación genérica del negocio mismo. Y más particularmente *nomina* sirve para designar los créditos obligacionales.

Pero estas anotaciones, como elementos probatorios de los créditos, llevados a cabo en forma unilateral, conformaban los *arcaia nomina*, es decir, la enumeración de los créditos provenientes de la "caja familiar" (*arca*). Gayo tiene especial cuidado en indicarnos que como meros escritos probatorios, estos *arcaia nomina* no engendraban "obligaciones literales" (3.131). Así, si se había recibido dinero en prés-

tamo, la obligación era *re*, no *litteris*. Por ello es que los extranjeros podían usar esta forma de contabilidad, puesto que ellos podían obligarse por la dación (*numratio pecuniae*) del mutuo (Gayo, 3.132).

4. Pero si las dos partes del negocio convienen una de ellas en tener la suma de dinero como ya *numerata*, es decir, como dada (*pecunia expensa-lata*), y la otra por *numerata* y recibida (*accepta relata*), aunque ello no hubiera ocurrido, aceptando ambas que se anotara en el *codex* del acreedor, entonces sí vemos aparecer una obligación que nace *litteris*. Acá, la escritura no es meramente una prueba, sino que de ella surge una obligación civil. Las expresiones *nomen facere*, *nomina facere* designan la creación de esta especie de obligación (Cic., *in Verr.*, 2.1.136; *de off.*, 3.4; Paulo, D.2.14.15; Pomp., D.33.1.1).

5. Esta obligación *litteris* guarda una neta analogía con la *stipulatio*. La diferencia es que en ésta la obligación surge *verbis*, por el consentimiento del *stipulator* y del *promissor*. En cambio, acá surge por el convenio de las dos partes, de las cuales una de ellas la "transcribe" en su *codex* y la otra que pide que así se haga.

A diferencia de la obligación *verbis*, esta otra *litteris* puede ocurrir entre ausentes (Gayo, 3.138). No hay necesidad de palabras formales, sino que basta la orden de una de las partes y la aceptación por parte de la otra (Gayo, 3.137).

6. Para la época de Cicerón la práctica privada del *codex* era usual y propia de *patres diligentes*. Este autor las califica de "eternas, santas, demostrativas de la perpetua estimación de la *fides* y de la *religio*" (*pro Quinct. comoed.*, 3.2). Pero según las fuentes literarias, para el siglo I de nuestra era estas prácticas del *codex* por parte del *pater* se habían dejado de usar.

Los últimos que conservaron esta forma fueron los banqueros (*argentarii*). Prueba de ello, por lo menos para la época republicana, es el caso de Plauto (*Truc.*, 1.51ss.), donde se nos pinta a los banqueros en su escritorio (*mensa*) en el *Forum* rodeados de cortisanas y jóvenes disipados. También Terencio (*Phormio*, 5.89) da testimonio de esta actividad.

Se nos habla también de las operaciones de los *pararii*, que eran banqueros intermediarios entre mutuantes y mutuarios, facilitando la operación cuando el que necesitaba dinero no lo tenía, o se debía recurrir al préstamo de varios mutuantes a la vez

(Sén., de ben., 2.23.1; 3 y 3.15.2; Cic., ad Att., 4.17(18).2).

Gayo, en forma curiosa, habla de estas obligaciones *litteris* sin hacer ninguna mención ni de las prácticas familiares, ni tampoco de las de los *argentarii*.

§ 406. *Clases de nomina transcripticia*. Gayo (3.128) nos habla de dos formas de operar por los *nomina transcripticia*:

a) *a re in personam*. Esto ocurría cuando ya existía otro negocio; p.ej., una compraventa, o una locación, por la cual tú me debes dinero. En este caso, yo hago figurar en el *acceptum*, de manera ficticia, que tú me has pagado esa suma; pero al mismo tiempo la anoto en la tabla del *expensum*, como dinero entregado a ti. En virtud de dicha *expensilatio*, se produce una novación objetiva*, por cuanto se ha transformado la primera obligación, de naturaleza consensual, en una nueva obligación, que a partir de ahora es "literal" (*litteris*).

b) *a persona in personam*. Así, si Ticio me debe 100, pero Sempronio, a su vez, le debe 100 a Ticio, hago la anotación de tal modo que, habiéndolo convenido con las partes, dejo de ser acreedor de Ticio, anotando en el *acceptum*: "He recibido de Ticio" (*acceptilatio ficticia*). Pero al mismo tiempo, habiendo delegado Ticio su deuda en Sempronio, lo hago figurar ahora como deudor mío, anotando en el *expensum*: "Entregado a Sempronio por 100". De este modo, las antiguas obligaciones quedan novadas ("novación subjetiva"), de tal modo que la doble operación se ha simplificado: sólo queda la obligación de Sempronio hacia mí por 100 (Gayo, 3.130).

1. Podemos hablar en este caso de "delegación de deuda". Ticio es el "delegante", Sempronio el "deudor delegado" y yo el "delegatario". Es fácil entrever que este tipo de operaciones servía contablemente a los *pararii* o *argentarii* para sus negocios en la intermediación de dinero.

2. Por una cita de Velio Longo (*de orthographia*, 60), sabemos que para anotar una "entrada" (*acceptum*), se solía emplear la forma *acceptum a Titio*, en lugar de *acceptum a Titio*. El empleo de la forma anticuada *af*, denota una cierta antigüedad de estas prácticas.

3. Conforme a las características de las anotaciones, aparece claro que el nacimiento de la obligación *litteris* se opera a partir de la *expensilatio*. De ahí que este vocablo aparece preferente en Gayo (3.137-8).

Por las características de los *nomina transcripticia*, sólo se podían anotar sumas de dinero. El reclamo se hacía por la *condictio certae creditae pecuniae* (Cic., *pro Q. Roscio com.*, 4-5).

4. Como lo indica el propio nombre del *codex accepti et expensi*, había que anotar las "entradas" y las "salidas". De este modo, se supone que ambas partes debían anotar el "crédito" y la "deuda", lo cual podía tener importancia para su confrontación en caso de juicio.

Pero lo decisivo era el libro del acreedor. Este debía probar: a) la *transcriptio* en sus tablas; y b) el consentimiento del deudor en que ésta se hiciera (Cic., *pro Roscio com.*, 3.3; Sén., de ben., 3.15).

En el título *De edendo* (D.2.13) figura una acción para que los *argentarii* exhiban la cuenta que les pertenece, con expresión de día y año (Ulp., D.4.1; EP, § 9.2). Es probable que entre sus distintas aplicaciones de operaciones bancarias, en su origen se haya referido también a los *nomina transcripticia*.

5. En el caso del *argentarius*, lo que se debía reclamar era la suma resultante del "debe" y del "haber", estando obligado a compensar las "entradas" y "salidas" habidas con su cliente (Gayo, 4.64 ss.).

6. La obligación *litteris* ejecutable (la *expensilatio*) no puede quedar sujeta a condición, bajo pena de nulidad (Pap., FV, 329), aunque sí a plazo (Cic., *Ad fam.*, 7.23).

En principio tiene las características de una obligación "abstracta" (no interesa la causa de la obligación), ya que basta probar la *expensilatio* consentida. Pero, sin embargo, se deduce de Cicerón (*de off.*, 3.14.59) que respecto de una compra "transcrita" en un *codex* (a propósito del célebre caso de la compraventa de Canius habiendo mediado el dolo del vendedor; ver *supra*, § 305.1), se permite la *exceptio doli mali*, lo cual relativiza, lo mismo que respecto de la *stipulatio*, el carácter abstracto de la obligación *litteris*.

§ 407. *Chirographa* y *syngraphae*. Los *nomina transcripticia* (la *expensilatio*), lo mismo que en su comienzo la *stipulatio*, estaban reservados a los ciudadanos romanos. Respecto de la *stipulatio*, hemos visto que prontamente se amplió a los extranjeros. En cambio, respecto de los *nomina transcripticia*, hubo una discusión entre los juristas. Según estableció Nerva (proculiano), esta forma de obligarse era propia del *ius civile* y por ello sólo podía ser usado entre romanos. En cambio, para Sabino y Casio está visto que si el *nomen transcripticium* se hace *a re in personam*, también se pueden obligar los extranjeros; pero no así si se hace *a persona in personam* (Gayo, 3.133).

1. Esta distinción que hacen los sabinianos puede tener que ver en lo que cuenta Tito Livio (35.7.2) acerca del procedimiento usado por los romanos para evitar las prohibiciones de las leyes de usura.

Como los extranjeros no estaban sometidos a ellas, los usureros romanos recurrían a ellos como intermediarios, de tal modo que luego de realizado el mutuo por intereses prohibidos, se novaba la obligación *re*

en *litteris*, por medio de la correspondiente *expensilatio* en una *transcriptio a persona in personam*. De este modo, el extranjero quedaba convertido en nuevo acreedor y el deudor no podía oponerle las leyes romanas que prohibían determinados intereses.

Esta situación terminó con la sanción de la *lex Sempronia* (año 122 a.C.), por la cual las reglas romanas respecto de los préstamos de dinero se aplicaban también a los extranjeros.

Quizá por esto fue que los sabinianos hicieron la distinción: la *expensilatio a persona in personam*, se prestaba para este juego de los acreedores romanos con los intermediarios extranjeros, por lo que no aspeataban su uso por parte de quien no fuera ciudadano romano. Nerva, en cambio, se mantiene en la regla restrictiva, por la cual los extranjeros no podían usar de ninguna manera las dos formas de *nomina transcripticia*.

Gayo (3.134), luego de hablar de los *nomina transcripticia*, parece buscar una cierta equivalencia de éstos con ciertas formas documentadas provenientes del Oriente romano. Estas son los *chirographa* y las *syngraphae*. Respecto de éstos dice que "se considera que nace —de ellos— una "obligación literal" (*litterarum obligatio*), y que es un género de obligación propio de los extranjeros.

El *chirographum* (también a veces *chirographus*) es un escrito emanado de la propia mano del deudor, donde se reconocía una deuda, sellada por él y entregada al acreedor. En cambio, la *syngrapha* (a veces *syngraphus*; pero en plural siempre *syngraphae*) eran dos o más documentos sellados por las diversas partes, de los cuales se entregaba uno de ellos a cada parte (Asconio —o Ps. Asc.—, *Ad Cic. in Verr.*, 2.1.36; 60; 91).

1. Estaban en uso desde la época republicana. Las *syngraphae* parecen ser anteriores (Plauto, *Asinaria*, 4.1.1; Cic., de leg., 3.8; in *Verrem*, 2.1.36). Pero también fueron las primeras en desaparecer. En la recopilación justiniana no encontramos ninguna mención de ellas; en cambio, la mención de los *chirographa* es más frecuente.

2. Se discute sobre si se trataba de documentos probatorios o productores de obligaciones. Gayo se expresa de un modo muy particular. No dice, como de los *nomina transcripticia* que "se forma una obligación literal" (*litterarum obligatio fit*), sino solamente "se considera (fieri videtur) que nace una obligación por escrito (*litterarum obligatio*)". Además, la diferencia de la *stipulatio*: "dejando bien entendido que en este caso no se ha realizado ninguna *stipulatio*" (3.134).

Cabe entender por ello que de estos documentos no nace propiamente una obligación civil, como ocurre con la *stipulatio* y con los *nomina transcripticia*. Pero, sí, por asimilación obligaciones para las relacio-

nes con extranjeros. Eran así una forma de establecer una obligación literal para el uso de o con los extranjeros.

3. Por medio de ellos se podía reconocer una deuda actual (así, p.ej., la nacida de una venta, una locación, etc.), pero de tal modo que extinguían las obligaciones primeras, novándolas en la obligación literal. O también una deuda futura (Gayo, *ibid.*), de ahí que el *chirographum* se parece a nuestro actual "pagaré".

Sin embargo, hay que distinguirla de otros documentos que eran meramente "probatorios" (*instrumentum, scriptura, libellus, charta, chartula*; Gayo, D.22.4.4; Constantino, C.4.21.15).

4. Con el tiempo el *chirographum* tiende a aproximarse a la *cautio*, que si bien en principio era un documento probatorio de la *stipulatio*, comenzó a ser en la época posclásica directamente una promesa escrita de pagar una suma de dinero (*certa pecunia*), así, p.ej., un mutuo de dinero. Ya en una constitución de Alejandro Severo se califica de obligación a la *cautio* (C.4.30.7). Y por otra de Arcadio, Honorio y Teodosio, se ve cómo por la *cautio* se forma una obligación *litteris* (C.2.4.6).

§ 408. *La obligatio litteris en Justiniano*. 1. Tal como lo vimos, la práctica de los *nomina transcripticia*, de uso en la época republicana, desaparece prontamente y en silencio. Ello debió ocurrir ya antes de Gayo, no obstante que éste los da como "actuales" para su época. Ello no significó que no existiera la actividad bancaria en Roma, último reducto de los *nomina transcripticia*, sino un cambio en la técnica de las operaciones que realizaban los *argentarii*, sobre todo por la aparición y desenvolvimiento que tuvo el *constitutum* (v. *supra*, § 379).

1. Esta figura podía consistir en el *constitutum debiti proprii*, que permitía que el *argentarius* aceptara un plazo (o uno nuevo si ya existía alguno) respecto de una obligación en dinero, y también podía serlo como *constitutum debiti alieni*, en el caso de que el banquero avanzara la deuda de otro. También existía el *receptum argentarii* (un banquero asume directamente una deuda ajena, comprometiéndose a pagarla). Justiniano terminó por asimilar esta última figura con el *constitutum debiti alieni*, haciéndole perder su carácter "abstracto" (es decir que no interesaba la causa), haciéndolo "causado" (C.4.18.2, año 531; Inst., 4.6.8).

2. Por estas formas, vemos cómo los banqueros podían operar de un modo más concreto y práctico con sus clientes. Así, se desprende de lo que dice Labeo acerca de las "cuentas de los banqueros" (*rationes argentarii*), que consistían ya en cantidades debidas recíprocamente por los contratantes (*ultra citra dandi accipiendo*), ya en forma unilateral por causa de un préstamo (*credendi*), o por el dinero que

por su causa se comprometió a pagar (*obligandi solvendi rei*); Lab.-Ulp., D.2.13.6.3. Buena parte del título *De edendo* (D.2.13), está dedicado precisamente al deber de los *argentarii* de presentar dichas cuentas.

Justiniano dedica el capítulo 3.21 de sus Institutas a hablar de la "obligación literal". Luego de señalar la obsolescencia de los *nomina transcripticia*, se refiere a la posibilidad de que alguien quede obligado *litteris*. Parece referirse a un documento en el cual "alguno escribiera deber algo" (*si quis debere se scripserit*), y dice al respecto que "por la escritura se obliga" (*scriptura obligatur*), y por ello "de ella nace la *condictio*". Este único párrafo, luego de estas señalizaciones, está referido a que si alguien demanda esta *obligatio litteris* y no se le había pagado la suma de dinero puede oponer la *exceptio non numeratae pecuniae* (v. *supra*, § 386).

1. Esta referencia tan escueta de la *obligatio litteris* por parte de los compiladores, ha motivado muchos comentarios. Algunos piensan que por un espíritu de esquema, Justiniano trató de mantener acá el género de "obligaciones literales" que había seguido Gayo en sus Institutas, que como sabemos fue el modelo sobre el cual actuaron los colaboradores bizantinos. Y que en realidad acá confundió los documentos meramente "probatorios" con aquellos que daban nacimiento a una obligación.

2. El problema es muy oscuro. Theófilo (3.21) dice que "sin embargo, si hoy día buscas diligente, encuentras en la vida cotidiana que existen estas obligaciones literales, las cuales tienen otra forma y otras figuras". Ello conduciría a que, más que imaginar este género, la forma *litteris* de algún modo debió existir.

Se podría pensar en la *cautio*, como probatoria de la *stipulatio*, pero el texto de Justiniano aclara especialmente "que la escritura obliga y da origen a la *condictio*, a falta, bien entendido, de la *obligatio verbis*", es decir, precisamente de la *stipulatio*.

Por el otro lado, en el Digesto aparece mencionado el *chirographum*, entendido como promesa escrita de pagar una suma de dinero determinada, por lo general, a propósito de un mutuo (Scév., D.2.14.47.1; D.22.3.44; Modest., D.22.1.41.2; D.22.3.24). Además, en el Código, aparece que se puede oponer la *exceptio non numeratae pecuniae* respecto de un *chirographum* (Alej., C.4.30.5) y también el *chirographum* aparece en otros párrafos (Dícel y Maxim., C.8.43.14; 15; 18, 22 y 25).

3. Si bien esto conduciría a que alguna forma de

obligatio litteris existió en la época de Justiniano, es curioso que en III.21, no reproduce en forma total, sino parcial, el giro empleado por Gayo (3.134). Este hablaba de "deuda actual" (*si quis debere se scribat*), pero también de "deuda futura" (*aut daturum se*). Justiniano se refiere sólo a la "deuda actual" (así, la debida por un mutuo respecto del cual se firma un documento).

También es llamativo que no exista en el Digesto un título sobre estas *obligationes litteris*, y que en D.44.7.1.1 (*Res cottidianae*) se reproduce el texto paralelo de Gayo (3.89), diciendo que "las obligaciones se contraen o *re o verbis o consensu*" callando *litteris*. Esto causa extrañeza, a menos que se acepte que sea el propio Gayo quien efectuó la supresión. Pero, de ser así, dado el interés bizantino en mantener el género *litteris*, cabe preguntarse por qué no la interpolaron. Incluso, en el Epítoma visigótico de Gayo (2.9.12), se menciona el caso de las *litteris obligationem fieri*, refiriéndose a la *cautio* escrita en el caso de delegación.

§ 409. Estas obligaciones *litteris*, por lo que hemos visto, están referidas siempre a sumas de dinero. En consecuencia, están analógicamente vinculadas con la *stipulatio* y el mutuo. Como lo dice Cicerón (*Pro Roscio com.*, 3.4), una cantidad cierta de dinero (*pecunia certa*) puede ser "dada" (*data*), "prometida" (*stipulata*) o "anotada en el *expensum* del *codex*" (*expensa lata*). De ahí que la acción con que se la reclama por parte del acreedor es siempre la misma: *actio (condictio) certae creditae pecuniae*.

En el caso de los *nomina transcripticia*, estamos en presencia de créditos bancarios, que en cierto modo o están jugando como "préstimos" o como "promesas de pago", al igual que lo que ocurre con el mutuo o con la *stipulatio*. Algo parecido ocurre con los documentos crediticios (*syngrophae* y *chirographa*), que funcionan como "promesas de pago por escrito", pareciéndose al actual "pagaré". Por ello, a pesar de que media un consentimiento, resulta excesivo hablar acá de "contratos literales". Son simplemente *obligationes litteris*, es decir "nacidas por escrito". Solamente por la extensión dada por los bizantinos al *contractus*, es que luego se hablará de "contratos literales". Pero aún así, la mera "promesa escrita de pagar", el actual "pagaré", tampoco será considerado hoy día un "contrato", ni tampoco los negocios bancarios tipo "cuenta corriente".

CAPÍTULO 7

CONTRATOS CONSENSUALES

§ 410. *Características generales.* Los contratos consensuales se caracterizan por formarse mediante el mero consentimiento (*nudo consensu*). Una vez que las partes han convenido en realizarlos son desde ese momento obligatorios (Gayo; 3.136; D.44.7.2.1-2; Inst., 3.22).

1. Tal cual lo habíamos visto, si bien en todas las convenciones existe el *consensus*, el mero consentimiento en un negocio no constituye un "contrato consensual" (v. *supra*, § 325.C.5-6). Sólo en aquellos casos admitidos por el ius, el consentimiento conforma un contrato consensual (carácter "cerrado y nominado de los contratos").

2. Hay, pues, una neta oposición con los denominados "contratos formales". Así, tanto en las *stipulationes* como en las formas *litteris*, que si bien serán luego considerados por la doctrina romanística "contratos verbales" y "contratos literales", en realidad son "promesas de pago" constituidas verbalmente o por escrito. Más propiamente, como lo dice tanto Gayo como las Institutas de Justiniano son *obligationes verbis* y *obligationes litteris*.

También con los denominados "contratos reales" (incluidos los llamados "contratos reales inominados"), que son "préstamos", y donde la *obligatio* re nace de la *datio*.

En cambio, en los "contratos consensuales", el comienzo, es decir, el perfeccionamiento del contrato es el *nudus consensus*. Pero en las otras formas, por el solo consentimiento no nacen obligaciones.

Así, el haberse puesto de acuerdo en querer celebrar un mutuo no genera obligaciones, sino después de la *datio* de la cosa; lo mismo que el convenir celebrar una *stipulatio* no es obligatorio sino después de pronunciadas las palabras, y lo mismo ocurre con las formas *litteris*, que sólo valían luego de la "escritura".

3. El consentimiento en estos contratos consensuales es totalmente informal. Puede ser dado entre presentes, pero también entre ausentes, como, p.ej., por medio de una carta donde se acepte el ofrecimiento del otro, o por medio de un mensajero (*nuntius*) (Gayo, 3.136; D.44.7.2.1-2; Inst., 3.22).

Incluso, por un "gesto" que implique una declaración de la voluntad (Mod., D.44.7.52.10: "Pero aun con una sola señal (*nuntus*) se contraen obligaciones". El silencio, en cambio, en principio no tiene valor. Pero en el derecho posclásico se le admite cierta

eficacia; así, en los arrendamientos (se habla del colonato), si terminado el plazo las partes callan y lo continúan, se entiende que rige por un período más ("tácita reconducción"; Ulp., D.19.2.13.11).

§ 411. Las principales características de los contratos consensuales son las siguientes:

A) Mientras que las obligaciones nacidas *re, verbis* o *litteris* están protegidas por acciones de derecho estricto, principalmente la *condictio*, los contratos consensuales —debido a que no se trata de obligaciones unilaterales sino bilaterales y recíprocas— están amparados por "acciones de buena fe" (*bonae fidei iudicia*; Gayo, 4.61 ss.).

Por tanto, tienen un régimen de apreciación mucho más flexible, permitiendo al juez un *arbitrium* mayor para establecer la condena. Esto se ve en algunos aspectos importantes: a) Dada la bilateralidad recíproca de las obligaciones, puede directamente operar "compensaciones" entre ellas. b) Dado que la *fides* integra el contenido mismo de estos contratos, el juez puede considerar las *exceptiones* que el demandado quiera plantear, aun cuando éstas no se hubieran hecho figurar en la fórmula: c) Igualmente, el juez tiene en consideración los "pactos" (*pacta adiecta*) que las partes han tenido en consideración a propósito del contrato, y que funcionan como *leges privatae* que deben cumplir. d) Por último, por aplicación de la *bona fides*, la responsabilidad del demandado es examinada con mayor flexibilidad, según las características del contrato ("culpa contractual"), pudiéndose tener en cuenta no sólo el "daño emergente" directo del incumplimiento, sino también de los incrementos que por dicho incumplimiento dejó de percibir ("lucro cesante").

B) Lo propio de los contratos consensuales es la "reciprocidad" de las obligaciones. Una de las partes queda obligada respecto de la otra en virtud de la prestación que debe realizar (Gayo, 3.137; D.44.7.2.3; Inst., 3.22). Por eso se habla de que las obligaciones "son del uno respecto del otro" (*ultra citroque obligatio; alter alteri obligatur*). Son considerados "sinálgmáticos" (del griego *synallagma*: "contrato recíproco"; Lab.-Ulp., D.50.16.19).

1. Pueden darse varios casos;

a) En la compraventa y en el arrendamiento o locación, es evidente que surgen obligaciones recíprocas. Estas dan lugar a acciones que tienen nombre propio para cada una de las partes: así en la compraventa la *actio ex empto* para el comprador y la *actio ex vendito* para el vendedor; y en la locación la *actio ex locato* para el locador y la *actio ex conducto* para el locatario. Por ello la doctrina habla acá de "contratos sinalagmáticos perfectos".

b) En la sociedad, esta simetría de las relaciones entre los socios es aún más perfecta. Por ello cada uno de ellos goza de la misma acción respecto de los otros: *actio pro socio*. Es también un "contrato sinalagmático perfecto".

c) En cambio, en el mandato, las obligaciones recaen en principio en el mandatario, quien debe cumplir lo mandado por el mandante. Este tiene la *actio mandati*, pero eventualmente puede nacer una obligación a cargo del mandante (p.ej., para que éste pague los gastos que ha requerido el cumplimiento del mandato). En este caso el mandatario tiene la *actio mandati (contraria)*.

Si bien en el mandato parece que surge una obligación unilateral para el mandatario, dada la eventualidad de responsabilidad para el mandante, se entiende que el origen de la obligación radica en la "causa recíproca". Los modernos hablan de "contrato sinalagmático imperfecto".

C)-Por su carácter "consensual", estos contratos pueden extinguirse por el *contrarius consensus* (llamado también *dissensus*, *contraria voluntate*, etc.). Así, p.ej., si A ha vendido un fundo a B, cualquiera de las partes puede disolver el contrato antes de que el vendedor haya recibido el precio o el comprador la cosa (Inst., 3.29.4). Lo mismo ocurre respecto de los otros contratos consensuales.

1. En el caso de la compraventa el *contrarius consensus* puede suceder sin dificultades mientras el negocio no haya tenido principio de ejecución (mientras permanezca la *res integra*). Pero si, p.ej., el vendedor entregó la cosa vendida (*res secuta*), el negocio en principio continúa. Se puede convenir la revocación, pero ella no arrastra *per se* la obligación de restituir, sino que se entiende que ha nacido una nueva obligación (Neracio, D.2.14.38; lo mismo que si luego se pactó un cambio del precio (Pap., D.18.1.72, *in fine*; ver *infra*, § 485).

§ 412. Los contratos consensuales, esto es, las obligaciones recíprocas basadas en la *bona fides* y nacidas *nudo consensu*, son una de las grandes invenciones romanas, que posibilitará el desarrollo contractual del mundo occidental. Si bien estos contratos provienen del *ius gentium*, no se los conoce en los otros países del

mundo antiguo con este perfeccionamiento por el mero consentimiento. Así, entre los griegos la "venta" será considerada ya un "contrato real" (es decir, perfeccionada luego del pago de las arras o del precio); o como "venta escrita" (naciendo de un documento).

Los contratos consensuales figuran en el título XII del Edicto, que lleva por título *De bonae fidei iudicia*. Allí, junto a otras "acciones de buena fe", como la *actio rei uxoriae* y la *actio tutelae*, figuran como "contratos" el depósito (§ 106), la *fiducia** (§ 107; sobre *fiducia cum amico*, v. *supra*, § 368.a.1; sobre *fiducia cum creditore*, v. *supra*, § 286). Y luego, los considerados propiamente por Gayo y Justiniano "contratos consensuales": el mandato (§ 108), la sociedad (§ 109), la compraventa (§ 110) y la *locatio conductio* (arrendamiento o locación, § 111), aparte del *estimatium* (§ 112), que sería una forma vinculada a la compraventa (v. *supra*, § 375.B).

I. COMPRAVENTA

§ 413. Evolución de la compraventa romana. Si entendemos en forma muy genérica la compraventa como el negocio no formal por el cual se cambia una cosa por un precio en dinero, podemos decir que, al igual que en otros pueblos, existió siempre en Roma.

a) En un principio, se supone que la venta era un negocio manual en el cual la entrega de la cosa y el pago del precio prácticamente coincidían. Si se trataba de una *res Mancipi*, el monto de dinero era pesado en la *mancipatio* y de este modo el comprador adquiría la propiedad de la cosa. Si era una *res nec Mancipi*, el comprador pagaba la cosa y seguidamente se hacía propietario por la *traditio*, o viceversa.

b) Ya en la ley de las XII Tabas, según nos dice Justiniano (Inst., 2.1.41), aparece la posibilidad de no coincidencia temporal entre entrega de la cosa y pago del precio. Este último podía ser demorado mediante una garantía (*pignus* o *expromissio* personal).

Según piensan algunos, pudo haber existido la costumbre de recurrir a dos *stipulationes* recíprocas: por una de ellas el vendedor promete la entrega de la cosa y por la otra el comprador promete el pago del precio. Desde un punto de vista económico esto podía ser una compraventa, pero jurídicamente no era así. Las acciones que nacían no eran propiamente las de una *emptio venditio*, sino que cada uno tenía la correspondiente acción, si bien interrelacionadas.

c) La aparición de la compraventa (*emptio venditio*) como figura propiamente contractual debió haber ocurrido alrededor del siglo II a.C. La jurisprudencia admitió la validez de este negocio como meramente consensual, de tal modo que bastaba que las partes se pusieran de acuerdo para que nacieran las obligaciones de entregar la cosa y de pagar el precio. Podía ocurrir que ambas se cumplieran inmediata y simul-

áneamente, pero el *consensus* establecido, basado en la *fides*, hacía nacer acciones en favor del vendedor y del comprador. Podía ser celebrado entre ciudadanos romanos o entre éstos y extranjeros, y podía versar sobre *res Mancipi* y *nec Mancipi*.

d) En el derecho posclásico la compraventa se verá afectada por las reglas del derecho griego. Según éste, la perfección del contrato recién se efectuaba con el pago del precio, y si se trataba de cosas importantes, por la redacción de un documento escrito.

Así, por una constitución de Constantino (FV., 35 = CTh. 3.1.2, año 337), para la compraventa de inmuebles se requiere no sólo el pago del precio, sino también la redacción escrita, donde debía especificarse el cumplimiento de las obligaciones fiscales—éste fue el principal interés legal—y la presencia de testigos que garantizaran la propiedad del transmitente. Se ve acá, pues, que la compraventa de inmuebles adquiere un carácter "real"—al estilo griego—, tendiendo a coincidir con la adquisición del dominio.

e) Finalmente Justiniano recurrirá a una solución ecléctica. Por un lado mantiene la compraventa clásica, netamente consensual. Pero también, siguiendo las costumbres bizantinas, permite y da eficacia a la compraventa por escrito, la cual recién se perfeccionaría luego de firmada por las partes (C.4.21.17, año 528; Inst., 3.23 pr.). De todos modos, el contrato aparece separado de la adquisición de la propiedad de la cosa comprada, la cual se debía producir por la *traditio* u otro de los "modos" de adquisición.

§ 414. Concepto de compraventa. Cuando una de las partes quiere vender (*vendere*) una cosa y la otra quiere comprarla (*emere*) y se ponen de acuerdo en cuanto al precio, por este solo consenso, aunque la cosa no haya sido entregada ni el precio pagado, existe desde ese momento la compraventa (*emptio venditio*); Gayo, 3.139; Inst., 3.23 pr.

La compraventa queda perfeccionada desde ese mismo momento. Por ello es que de allí nacen obligaciones, tanto para el vendedor como para el comprador. El primero (*venditor*) se obliga a entregar a la otra parte la pacífica posesión (*habere licere*) de una cosa (*merx*), mientras que la otra, el comprador (*emptor*) se obliga a pagar por ella un precio en dinero.

1. Adviértase que el vendedor no se obliga directamente a la *domo* de la cosa (es decir, hacerlo propietario al comprador; Ulp., D.18.1.25.1; Jul.-Africano, D.19.1.30.1), sino sólo la posesión pacífica de la cosa. Por eso se habla de entregar la *vacua possessio* (Paulo, D.19.1.2.1; Ulp., D.19.1.11.2: *vacua possessio*, es decir, libre de ocupantes, arrendatarios u otros usuarios). Por eso su obligación es un *facere* (hacer la *traditio*; v. *supra*, § 318) que consiste en *praestare*

(no *dare*) *rem* (Ulp., D.19.1.11.2). O también para que el comprador la "tenga licitamente" (*habere licere*; Afric., D.19.1.30.1; Jul., D.21.2.8; Ulp., D.19.1.21.2).

En cambio, la obligación del comprador es una *dato*, es decir, que el dinero entregado es del vendedor (Ulp., D.19.1.11.2, *in fine*).

2. El *praestare possessionem* se piensa que surgió sobre la base de que de este contrato participaban también los extranjeros (que no podían tener el *dominium ex iure Quiritium*), o respecto de los fundos provinciales que no eran susceptibles de *dominium*.

Si la cosa era una *res nec Mancipi* entregada por el propietario, ello no reportaba mayores problemas, puesto que bastaba la mera *traditio* para que el comprador fuera propietario.

En cambio, se suscita el problema si la cosa era una *res Mancipi*. El comprador podía esperar usucapirla, puesto que la venta era un *iustus titulus*. Sin embargo, por tratarse de un contrato donde interviene la *fides*, el vendedor se obliga a tratar de hacer todo lo posible para que el comprador devenga propietario. En tal sentido, según Paulo (1.13a.4), si la *res Mancipi* no ha sido *municipada*, el comprador puede obligar al vendedor a hacer la *municipatio*. Y también Gayo (4.131a) nos habla de la posibilidad de una *praescriptio* para que agregada a la acción de traidir la cosa, se haga la *municipatio*.

3. Por la entrega de la posesión el vendedor queda obligado por todo acto doloso (Pomp., D.19.1.6.8), así como a prestar la "garantía de evicción", en el caso de que otro reclamara como suya la cosa (Ulp., D.19.1.11.2), también por la garantía de los vicios ocultos (vicios redhibitorios)* que pudiera tener la cosa (Lab.-Sab.-Ulp., D.19.1.11.3).

4. Tal como lo señalamos, Justiniano alterará—por influjo de las costumbres bizantinas—la regla clásica, de tal modo que las cosas compradas sólo se hacen de propiedad del comprador cuando éste pagó su importe al vendedor, o dando una garantía (real o personal), o si el vendedor tuviera confianza en que el comprador le pagara el precio (Inst., 2.1.41).

§ 415. Acciones. Estas dos obligaciones generan acciones *bonae fidei* (BP, § 110: *empti venditi*). Así, el vendedor tiene la *actio venditi* (para exigir el precio, así como los intereses de éste después de entregada la cosa; Ulp., D.19.1.13.19-20), mientras que el comprador cuenta con la *actio empti* (para reclamar la entrega de la cosa; Ulp., D.19.1.11 pr.2).

Así como las obligaciones nacidas son recíprocas, estas dos acciones se consideran interdependientes. En su ejercicio, ninguno de los contratantes puede exigir que el otro cumpla la prestación antes de haber cumplido, u ofrecido cumplir, la suya. Así, si el vendedor intenta la *actio venditi* debe haber entregado la cosa u ofrecer entrega coetáneamente con el inicio de la acción (Ulp., D.19.1.13.8). A su vez, tampo-

puede el comprador iniciar la *actio empti* sin haber pagado u ofrecido, al mismo tiempo, pagar el precio (Paulo, D.44.4.5.4).

1. Esta interconexión en el plan de las acciones era directamente solucionado por el *iudex*, quien consideraba el comportamiento de las partes *ex fide bona*.

Sin embargo, hay textos en los cuales se habla de que el comprador a quien no le habían entregado la cosa podía oponer la excepción "por la cosa que se vendió y que no se entregó" (Jul., D.19.1.25; Paulo, D.44.4.5.4; Ulp., D.50.16.66; Caracalla, C.8.44(45).5 —*exceptio doli*). Esta excepción debió ser una generalización de la *exceptio mercis non traditae*, que se daba contra el *argentarius* mediador que había vendido en subasta una cosa, habiéndose estipulado el precio y no habiéndose entregado la cosa (Gayo, 4.126a; EP, § 272).

Los autores modernos emplearán la terminología *exceptio non adimpleti contractus* para designar esta defensa del comprador o del vendedor para negarse a cumplir su obligación antes de que la otra parte lo haya hecho u ofrecido hacerlos.

I. Elementos esenciales de la compraventa.

Para que se pueda dar una compraventa es necesario que exista (a) un consentimiento respecto (b) de un precio que es determinado respecto de (c) una cosa.

§ 416. A) *Consentimiento*. El consentimiento debe ser libremente expresado. Nadie puede ser obligado a vender una cosa contra su voluntad (C.4.38.11; 18). Además, debe carecer de vicios como el dolo, el error o la violencia.

1. Sin embargo, por cuestión de equidad, la venta podía resultar obligada. Así, respecto de los esclavos tratados inhumanamente (Gayo, 1.53); el que enterró en terreno ajeno podía ser compelido a retirar el cadáver o comprar el *iter ad sepulchrum* (Ulp., D.11.7.12 pr.). Y en determinados casos por utilidad pública (Theod., Arcadio y Honorio, C.8.12.9, año 393). Sobre "expropiación" v. *supra*, § 233.A.2.

2. Respecto de los llamados "vicios de la voluntad", es decir, el error, el dolo y la violencia, los hemos tratado al hablar de "negocio jurídico". El tema del "error" tiene notablemente sus precisiones más importantes en la compraventa (y en los testamentos), v. *supra*, § 304. Sobre "dolo", v. *supra*, § 305, y sobre "violencia", § 306.

§ 417. *Las arras (arrahae)*. Existía la costumbre de entregar una suma de dinero o un anillo para reafirmar el consentimiento dado en la compraventa. En la época clásica, estas "arras"

tuvieron un carácter confirmatorio de que el consentimiento había sido dado, de tal modo que probaba la existencia de él (Gayo, 3.139). Una vez cumplido el contrato, las arras debían ser devueltas (caso del anillo), o se imputaba la suma de dinero al precio (Ulp., D.19.1.11.6).

1. Luego, algunos textos (Scév., D.18.3.6; y 8) y una constitución de Caracalla (C.4.54.1; año 216) nos muestran cómo, mediante un pacto comisorio, si el comprador no pagaba el precio en el término fijado, las arras quedaban en poder del vendedor y se resolvía el negocio.

2. Justiniano, luego de repetir el texto de Gayo acerca de las arras como confirmatorias de la compraventa, introduce la vigencia, de origen oriental, de las *arrahae poenitentiales* (*poenitentia* = arrepentimiento). De este modo, si se han dado arras, ya sea la venta sin escritura o con ella, ambas partes pueden arrepentirse, el comprador perdiendo las arras que había entregado y el vendedor restituyéndolas por el doble (Inst., 3.23 pr., bastante confuso; C.4.21.17, año 528).

§ 418. B) *El precio*. El precio debe tener estas características:

a) Debe ser verdadero (*verum*), es decir, no simulado: así, vender una cosa de cierto valor por una moneda pequeña: se entiende que vale como "donación", pero no como venta (Ulp., D.18.1.36 y 38). Y será válida siempre y cuando no esté prohibida (así, no está permitida la donación entre cónyuges: Ulp., D.18.1.38).

b) Debe ser cierto (*certum*), es decir, debe estar "determinado". Así, el caso común: "Te vendo esta cosa por 100 sesteracios" y tú aceptas. Pero se admite que aunque no esté determinado, sea "determinable". Así, "Te compro esta cosa por cuanto tú la compraste" o "por el dinero que tengo en la caja" (Ulp., D.18.1.7.1).

1. Mayor problema había si el precio quedaba librado a la determinación de un tercero: "Te compro esta cosa por lo que estime Ticio que vale". Para Labeo y Cassio, el negocio era nulo; en cambio, para Oñilio y Próculo la compraventa era válida (Gayo, 3.140).

Justiniano resolverá el problema siguiéndolo a Próculo, pero dándole carácter condicional al negocio: si el tercero fija el precio, la venta es válida; pero si éste no lo fija porque no quiere o no puede, la venta es nula (C.4.38.15, año 530; Inst., 3.23.1).

C) Además, debe consistir en dinero. Al respecto hubo una discusión entre las escuelas. Los proculeyanos se inclinaban decididamente por esta solución. Los sabianianos, buscando conseguir para la permuta los beneficios consensuales de la compraventa, aceptaban que el precio

podía ser otra cosa (Gayo, 3.141; v. *supra*, § 375. A.1). Triunfó la tesis proculeyana (Paulo, D.18.1.1.1; D.19.4.1 pr.; Inst., 3.23.2).

En principio, la fijación del precio quedaba al arbitrio de las partes (Paulo, D.19.2.22.3). Pero ya muy tardíamente, Justiniano estableció, en caso de venta de inmuebles, la posibilidad de rescindir la venta cuando el precio era inferior a la mitad del valor verdadero del fundo. Se habla entonces de *laesio enormis* ("lesión enorme"; Diocl. y Maxim., C.4.44.2, año 285; C.1.6.8, año 293 itps.).

1. Esta solución es la que formará la idea del *iustum pretium*, basado en los principios morales de la justicia conmutativa, que luego tendrá amplio desarrollo en los autores medievales.

En los textos citados se permite que el comprador pueda mantener el negocio pagando el suplemento de lo que falte para cubrir el valor de la cosa.

§ 419. C) *Cosas que pueden ser compradas y vendidas*. Desde su origen la compraventa fue el contrato mercantil por excelencia. Se dirigía propiamente a las "mercaderías" (= *merx*), es decir, a todo aquello que fuera susceptible de un precio. Así, podían ser vendidas y compradas las cosas corporales, actuales o futuras, las cosas incorpóreas, y aun las cosas ajenas.

1. Toda cosa corporal, siempre y cuando esté en el comercio, puede ser vendida y comprada. No una *res sacra* ni una *res religiosa* (Inst., 3.23.5), ni tampoco una *res publica* (Pomp., D.18.1.6 pr.; Paulo, D.18.1.34.1), ni un hombre libre (Paulo, D.18.1.6 pr.).

Estas ventas son nulas, pero si por engaño del vendedor las he comprado, se admite la *actio ex empto* a los efectos de resarcirme del perjuicio (Inst., 3.23.5). Tampoco son susceptibles de compraventa las cosas hurtadas (Gayo, D.18.1.35.4), ni las litigiosas (C.8.37.2 y 4).

2. Las cosas que se vendan deben estar determinadas. Así, si se trata de cosas "genéricas" (p.ej., vino, aceite, etc.) es necesaria una cierta delimitación: así, 100 tinajas de vino de mi bodega; 50 tejas de mi horno (Gayo, D.18.1.35.7). Para transferir cosas genéricas indeterminadas (p.ej., 100 medidas de trigo), hay que recurrir a una *stipulatio*.

3. No solamente las cosas "actuales" sino también las "futuras" pueden ser vendidas y compradas. Se podían dar dos hipótesis: a) la *emptio rei speratae* ("compra de la cosa esperada", p.ej., una cosecha; los partos futuros). Si no vienen, la venta es condicional, y, por tanto, fracasada; y b) la *emptio spei* ("compra de la esperanza"). P.ej., "Te compro lo que pesques echando la red"; tú la arrojas y si sacas 10 pescados o ninguno, yo te debo lo mismo el precio, porque compré una expectativa (Pomp., D.18.1.8 pr. y 1).

4. También las *res incorpóreas*, siempre y cuan-

do que sea posible la investidura del comprador en el derecho respectivo. Así, se puede vender el usufructo que deba ser constituido por el propietario; no, en cambio, el que tenga un usufructuario, ya que por el carácter "personalísimo" del usufructo, no se puede ceder (Paulo, D.18.6.8.2).

Igualmente, una servidumbre predial (Javol., D.8.1.20), una hereditas (Paulo, D.18.4.7); e incluso la herencia "futura" (*spes hereditatis*; Ulp., D.18.4.11), que Justiniano terminó considerándola inmoral, salvo que se hiciera con intervención del causante (C.2.3.30, año 531). También las obligaciones (*nomina*) debidas por otro (Ulp., D.18.4.17).

5. Generalmente se venden cosas "propias", pero también se Kita la de cosas "ajenas" (Ulp., D.18.1.28). En este caso, el vendedor se obliga a entregar la cosa, para lo cual deberá adquirirla del tercero; si no la puede obtener, deberá responder por su valor y otros perjuicios que se ocasionen por fracaso del contrato.

II. Riesgos de la cosa y garantías.

§ 420. *Riesgos de la cosa*. Supongamos la venta de una cosa cierta. Si antes de la tradición de ella al comprador ésta se pierde, o se deteriora, por caso fortuito o fuerza mayor, se presenta el problema de saber quién es el que debe soportar el riesgo sufrido (*periculum* = peligro). Si decimos que es el vendedor, por ser aún propietario de la cosa (regla *res perit domino* = la cosa perece para su dueño), no percibirá precio alguno en caso de que la cosa haya perecido; o un precio reducido, si ésta ha sufrido deterioro. Si, en cambio, decimos que el riesgo (*periculum*) recae en el comprador, éste deberá satisfacer totalmente el precio aunque la cosa perezca o se deteriore.

Según lo leemos en Inst., 3.23.3, se establece el principio general de que una vez que la venta se ha perfeccionado (*emptio perfecta*; Paulo, D.18.6.8 pr.) —es decir, desde que ha mediado el consentimiento, o para la época justinianea se ha formalizado la escritura—, el riesgo es para el comprador (regla: *periculum est emptoris*), aun cuando no se le haya hecho tradición de la cosa.

De este modo, si el esclavo vendido ha muerto, o ha sido herido; si el edificio en todo o en parte ha sido devorado por las llamas; o si el fundo, en todo o en parte ha quedado inevitablemente inundado, el daño lo sufrirá el comprador, quien está, ello no obstante, obligado a pagar el precio, aun cuando no haya recibido la cosa. A su vez, el vendedor, mientras no haya incurrido en dolo o en culpa, está en absoluta seguridad.

Para que se produzca la asunción del riesgo

por parte del comprador es necesario que la compra sea perfecta (*emptio perfecta*: que conste claramente lo que se vendió, la calidad, la cantidad; Paulo, D.18.6.8 pr.). Si se trata de cosas genéricas, para que la venta se perfeccione es necesario determinarlas (Gayo, D.18.1.35.5-7). Además, si la venta es condicional, se considera "perfecta" cuando se ha cumplido ésta (Paulo, D.18.6.8 pr.).

1. Se hace funcionar el principio del *periculum est emptoris*, en consonancia con el del *commodum-incommodum* de la cosa vendida, es decir, los "acrecimientos" o "disminuciones" que pase a tener la cosa vendida (así, p.ej., si el fundo acreció por aluvión; o si maduraron los frutos del campo vendido, o lo que haya conseguido el esclavo vendido; Ulp., D.19.1.13.10: 13 y 18; Alej. Severo, C.4.48.1).

En realidad el problema del *commodum-incommodum* es de otra naturaleza, puesto que se refiere en sí a la misma cosa vendida, de tal modo que se puede explicar por la *accessio* los aumentos o las disminuciones, sin interesar si hubo o no *traditio*. El error que cometen los bizantinos es considerar el *periculum* como una especie de *incommodum*.

2. En cuanto a la perplexidad que causa el hecho de que el comprador tenga que pagar el precio, aun no recibiendo nada, se lo pretende explicar por una cierta independencia de las obligaciones: la del vendedor se ha extinguido por el pericimio de la cosa sin culpa suya, mientras que la segunda continúa existiendo (Jul., D.18.5.5.2; Paulo, D.21.2.11). Esta separación de la interdependencia de las obligaciones resulta difícil de explicar en la compraventa, ya que ambas están ligadas a una con la otra (v. Labeón, D.19.1.50, donde establece que si la obligación de pagar el precio desaparece por efectos de una ley, cesa igualmente la obligación de entrega de la cosa por el vendedor).

3. Este problema ha preocupado a la doctrina romanística, la cual en general acepta la regla expuesta por Justiniano. Al contrario, pensamos que en la época clásica, el problema del *periculum* de la cosa vendida pasaba por otras reglas.

La cuestión es muy ardua, por cuanto los textos han sido manipulados por los bizantinos, y es la única fuente a la que podemos recurrir. Brevemente, en dicha época se debió haber seguido el principio de que hasta que se operara la tradición de la cosa vendida, el riesgo estaba a cargo del vendedor (Paulo, D.18.6.12 y 14; Afric., D.19.2.33), y después pasa al comprador.

Sin embargo, el vendedor respondía por dolo y culpa, y más aún, podía, por un pacto de responsabilidad, asumir la *custodia* de la cosa, obligándose por él a responder por el *casus minor*, así por el *furtum* de la cosa, o si el esclavo vendido se ha fugado (Inst., 3.23.3).

4. Los bizantinos, por un lado, establecerán el

principio de que los riesgos de la cosa vendida están a cargo del vendedor (regla *periculum est emptoris*). Pero además, para recompensar al comprador, ampliarán la cláusula de *custodia*, que debía ser para cada caso convenida, transformándola en un "elemento natural" de la compraventa, de tal modo que la *diligentia in custodiendo* se debe cumplimentar en todos los casos, es decir, guardarla como un *bonus paterfamilias* (Ulp., D.47.2.14 pr.; Paulo, D.18.6.3; Gayo, D.18.1.35.4 itps; en Inst., 3.23.3, *in fine*, Justiniano sigue hablando en lenguaje clásico, de tal modo que la cláusula debía convenirse). De este modo, compensaron los efectos de la regla *periculum est emptoris*, ya que el vendedor responde ampliamente (dolo, culpa o custodia), salvo si se produce el *casus maior* (fuerza mayor), es decir, por casos que escapan totalmente a su control y diligencia.

En estos casos, el vendedor debía prestar al comprador el poder actuar como mandatario suyo en las acciones pertinentes (*rei vindicatio* o *condictio furtiva*), en caso de *furtum*, o la acción de la *lex Aquilia*, en caso de "daño injusto", "porque mientras que la tradición no se haya hecho, continúa (el vendedor) siendo el propietario" (Inst., 3.23.3, *in fine*).

5. De este modo, mientras que la compraventa clásica es un negocio puramente obligatorio a partir del *nudus consensus*, y que lograba actualización por la *traditio* de la cosa, los bizantinos, al hablar de *emptio perfecta*, aplicando la regla de que los riesgos son para el comprador (*periculum est emptoris*), que potencia la expectativa del vendedor, le imputa una responsabilidad que anticipa y presupone la adquisición por parte de quien todavía no es propietario, estableciendo una excepción a la regla del *res perit domino*.

Sin embargo, no llegaron por ello a convertir la compraventa en un contrato traslativo de la propiedad. Ello hubiera chocado con la premisa fundamental de la distinción entre "título" (la compraventa) y "modo" (la tradición), que siempre quedó reafirmada (C.2.3.20). Quedaron a mitad de camino entre la compraventa clásica consensual y la compraventa traslativa de dominio que se dará en algunos códigos modernos.

§ 421. *Garantía por vicios jurídicos: la "evicción"*. El vendedor cumple su obligación entregando la cosa, de tal modo que el comprador pudiera tener el *habere licere*. Pero, si gozando de dicha posesión se presenta alguien reclamando ser propietario de la cosa, o alegando tener sobre ella un *ius in re aliena*, en caso de ser vencido en el juicio, el comprador quedará privado de su posesión ("evicción total"), o perjudicado ("evicción parcial": p.ej., admitiéndose una servidumbre). En estos casos el vendedor quedaba obligado a responder al comprador por evicción. Esto supuso una evolución en esta "garantía por vicios jurídicos".

I. En la época primitiva, cuando se operaba la *mancipatio*, se entendía que el adquirente que había comprado y pagado la cosa, se hallaba bajo la protección del vendedor (*auctor*). Si sucedía que un tercero le iniciaba una *vindicatio*, el vendedor debía asistir con su *auctoritas* al comprador. Si éste perdía el juicio, podía ir contra el vendedor por la *actio auctoritatis*, quien debía pagar al comprador el *duplum* del precio (Paulo, D.21.7.3). Si la evicción era parcial, la condena era por el *duplum* de la parte involucreada en el precio.

II. Pero ya en la época republicana y preclásica, cuando no había sucedido la *mancipatio* (que era "imaginaria", *nummo uno*), la garantía no existía. Las partes recurrían a una *stipulatio duplae* (*pecuniae*). De este modo se obtenía un resultado análogo: el vendedor promete al comprador para el caso de evicción pagarle el doble del importe del precio pagado (o el doble de la parte correspondiente). Aunque la *stipulatio duplae* era la normal, también se podía celebrar una *stipulatio triplae* o *quadruplae* (Paulo, D.21.2.56 pr.).

1. Para cosas de menor importancia (así, *res nec menci*) se utilizaba una *stipulatio* distinta: la *stipulatio habere licere*, que servía para comprometer por el *simplum* (*quod interest*) al vendedor y sus herederos —no así en el caso de terceros— por cualquier interferencia jurídica en la posesión de la cosa vendida (*habere licere*; Ulp., D.45.1.38 pr.).

III. El problema se presentaba si no se habían celebrado estas estipulaciones. Pero desde que se admitió el contrato consensual de compraventa, partiendo de la vigencia de la *bona fides*, que presidía este contrato, se fueron dando pasos importantes para proteger al comprador.

1. Así, se admitió que el comprador podía reclamar el importe de la venta por la *actio empti*, aun antes de efectuarse la evicción, contra el deudor de lo que le había vendido una cosa ajena, sin decirle nada al comprador (Afric., D.19.1.30.1).

2. Igualmente, a partir de Neracio, se admitió que el comprador por la *actio empti* podía accionar para conseguir la *stipulatio habere licere* (Ner.-Ulp., D.19.1.11.8), y más tarde, el comprador de una cosa, de cierto valor, podía por dicha misma acción obligar al vendedor a celebrar la *stipulatio duplae* (Ulp., D.21.2.37 pr., ss.).

Se llegó así, a partir de Juliano (D.21.2.8), a entender que la garantía de evicción debía ser entendida tácitamente agregada a toda compraventa (aunque no hubiera habido *stipulatio*). De este modo, esta garantía pasó a ser un "elemento

natural" de la compraventa. El comprador la hacía efectiva por el *simplum* mediante la interposición de la *actio empti*.

3. Esto funcionaba independientemente de la existencia de la *stipulatio duplae*, en caso de que ésta se hubiera realizado, en cuyo caso podía actuar por ésta.

4. El vendedor quedaba desobligado si previamente hacía un *pactum de non praestanda evictione*. Este pacto no se aplica en caso de venta de una cosa preñada, puesto que de lo contrario significaría un perjuicio para el acreedor desnaturalizándose la garantía (Tryph., D.20.5.12.1).

5. El comprador no puede reclamar nada si previamente no ha notificado al vendedor del litigio que se lleva a cabo en su contra, para que éste lo asista y lo defienda en el juicio (Paulo, D. 21.2.53.1).

IV. En la época de Justiniano se mantiene la garantía de evicción como elemento natural de la compraventa. El comprador podía seguir constriñendo al vendedor a prestar la *stipulatio duplae* (para las cosas de valor). Para el resto vale la interposición de la *actio empti* por el monto del interés del comprador vencido en el juicio. En ningún caso los perjuicios pueden exceder el doble del precio (Afric., D.19.1.44 itp; C.7.47.1).

§ 422. *Garantía por vicios ocultos de la cosa*. También por efectos de la *bona fides* implicada en la compraventa, el vendedor debe responder también por determinados defectos o vicios materiales ocultos que tenía la cosa.

I. En la época primitiva existía en la ley de las XII Tabas la *actio de modo agri*, que luego figurará en el Edicto (EF, § 74), por la cual, en el caso de la *mancipatio* de un fundo, si el vendedor había dicho que el inmueble tenía determinadas medidas, y éstas resultaban luego menores, podía reclamar el doble del valor de la parte correspondiente de dicha diferencia en el precio (Paulo, D.17.4).

II. Ya en los dos últimos siglos de la República, se acostumbraba establecer por medio de una *stipulatio*, que se solía agregar a la que se hacía por la evicción, según la cual el vendedor garantizaba que la cosa tenía determinadas cualidades o que carecía de vicios o defectos (Varro, *de re rust.*, 2.2.5; 2.10.5; 5.10.11). Cicerón, a su vez, admite que el vendedor quede responsabilizado por los vicios o defectos ocultos dolosamente (Cic., *de orat.*, 1.178; *de off.* 3.16.65).

1. Cuando la promesa se realizaba por medio de una *stipulatio*, el comprador gozaba de la *actio incerti* nacida de esta promesa obligacional.

2. En caso de ocultamiento doloso, el comprador

podía actuar por la *actio empti*. Al reclamar por los perjuicios, parece que podía conseguir ya la resolución del contrato, pero también una disminución del precio.

Pero al respecto los textos no lucen muy seguros, dada la conexión con las acciones del Edicto de los Ediles (v. Jul.-Ulp., D.19.1.13 pr. 2; Marciano, D.18.1.45; Ulp., D.19.1.11.3-5). Igualmente, incidió acá el problema del *error in substantia*, sobre todo a partir de Juliano, puesto que la afirmación de ciertos vicios latentes excluían el consentimiento y anulaban el contrato.

III Pero el gran aporte provino de la labor de los Ediles curules. Estos estaban encargados de la policía de los mercados. Para "poner coto a las falacias de los vendedores y amparar a los compradores" (Ulp., D.21.1.1.2), dado que estaban facultados a publicar edictos (Gayo, 1.6), se ocuparon de dos supuestos principales: la "venta de esclavos" (*de mancipiis vendendis*; EP, § 293; Ulp., D.21.1.1.1) y la "venta de animales de tiro" (*de iumentis vendundis*; EP, § 294; Ulp., D.21.1.38 pr.).

En estos casos, la responsabilidad por los vicios cualitativos de la cosa vendida se ampliaban, ya que el vendedor debía responder de ellos, tuviera o no conocimiento de tales vicios.

1. El vendedor debía declarar con total lealtad y buena fe las enfermedades crónicas (*morbi*) y los vicios (*vitia*), tanto de los esclavos como de los animales. En el primer caso, se mencionan ciertos vicios morales, p.e.j., el caso del esclavo fugitivo, o vagabundo, o que por haber cometido un delito estaba expuesto a la *actio noxalis* (Ulp., D.21.1.1.1).

La protección concedida al comprador consistía en lo siguiente:

A) El comprador puede exigir una caución estipulatoria, de tal modo que si el vendedor se niega, el comprador puede reclamar, para que se haga la caución o quede responsabilizado, dentro de los dos meses por la *actio redhibitoria*, o por la *quantum minoris* o cuanto interese al comprador, dentro de los seis meses.

1. La caución estipulatoria utilizada principalmente para el caso de venta de esclavos, dada la poca confianza que se tenía en ellos por ser extranjeros poco estimados, consistía en que "el esclavo era sano", o "no fugitivo", etc. Parece ser que era por el *sumplum*, y no por el *duplum*. Algunos piensan que era por el *duplum*, pero lo que puede llevar a error es que esta estipulación era generalmente empleada en forma conjunta con la *stipulatio duplae* de la garantía de evicción. Ver Paulo, D.21.1.58.1, donde se habla de recobrar el "precio del esclavo redhibido, en

virtud de la *stipulatio duplae*. Así hay que entender también Ulp., D.21.1.20 (cfr. Lenel, EP, § 293.5).

B) Si aparecía un vicio oculto, o del cual dolosamente se hubiera callado el vendedor, el comprador tenía la *actio redhibitoria* (de *rehabere*; o *reddere* = devolver; Ulp., D.21.1.21 pr.) dentro de los seis meses (Ulp., D.21.1.19.6), siendo su finalidad conseguir la restitución del precio contra la entrega de la cosa (Pap., D.21.1.55; Ulp., D.21.1.25.8 ss.).

C) Igualmente, para el supuesto de que por las características del vicio le interesara al comprador continuar teniendo la cosa, se le concedía una *actio quanti minoris*, ejercible dentro del año (Ulp., D.21.1.19.6), por la cual podía retener la cosa, pero obteniendo una reducción del precio y su reintegro (Ulp., D.21.1.31.16; Gayo, D.21.1.18 pr.; Jul., D.44.2.25.1).

1. La *actio redhibitoria* tenía una doble *condemnatio*: Si el demandado devolviera la cosa redhibida, era por el *sumplum*. Si en cambio se negara a ello, se manda que sea condenada por el *duplum* (Gayo, D.21.1.45).

2. Para que procedieran estas medidas protectoras era necesario:

a) que el vicio sea oculto, es decir, no visible, lo cual se puede manifestar por señales exteriores (Ulp., D.21.1.1.6);

b) que se trate de un vicio grave que disminuya el valor del esclavo o del animal. Así, no lo sería si el esclavo es supersticioso, o iracundo o contumaz (Ulp., D.21.1.1.7-9).

c) que sea anterior a la venta, así como que lo ignore el comprador (Pap., D.21.1.54).

IV. Durante el derecho posclásico, y más seguramente con los compiladores bizantinos, se amplía el espectro de los vicios redhibitorios para todas las cosas muebles e inmuebles (Ulp., D.21.1.1 pr. it.; D. id. 63 it.).

Además, se reafirma la garantía por vicios ocultos como "elemento natural" de la compraventa, bastando con interponer la *actio empti* (Ulp.-Jul., D.19.1.11.3). No desaparecen las acciones anteriores (*actio redhibitoria* y *quantum minoris*). Pero la *actio empti* tiene la ventaja de no tener los plazos limitados que tienen las otras dos específicas.

III. Pactos agregados:

§ 423. La compraventa puede asumir distintas modalidades en virtud de determinados pactos especiales establecidos en el negocio (*pacta adiecta*), llamados también *leges* (privadas), como serían:

a) *Lex commissoria*. Si el vendedor quiere asegurarse el pago del precio, establece que no se tendrá por ocurrida la compraventa si dentro de un determinado plazo el precio no se ha pagado (*lex commissoria*: D.18.3; v. Ulp., D. id. 1; Pomp., D. id. 2).

b) *In diem addictio*. La venta puede quedar supeditada a que dentro de determinado plazo no aparezca otro interesado ofreciendo pagar un precio mayor (*in diem addictio*; adjudicación a término, Paulo, D.18.2.1) o mejores condiciones: así, de pago o de solvencia (Ulp., D.18.2.4.6). Se solía usar en las subastas, a propósito de los postores que pujaban por un mejor precio; la subasta podía durar varios días, por lo que había que esperar. El vendedor debe preavisar al comprador anterior, por cuanto éste tiene preferencia y podría mejorar el precio (Paulo, D. id. 7.8). De todos modos, el vendedor tiene la facultad de aceptar la oferta que le parezca mejor (Sabino-Ulp., D.18.2.9).

c) *Pactum displicentiae*. Por medio de este pacto el comprador se puede quedar con la cosa hasta un cierto tiempo, y si no le agrada la operación, se reserva el derecho de devolverla al vendedor (Paulo, D.18.5.6). Es una "venta a prueba".

d) *Pactum de retroemendo* (pacto de retrocompra). El vendedor se puede reservar el derecho de rescatar la cosa devolviéndole al comprador el precio y otros gastos que hubiere demandado la conservación de ella (Próculo, D.19.5.12; se trata aquí del caso de bienes vendidos por el marido a su mujer, pero con la condición de que ella continúe casada, y en caso de no ser así, si el marido quería, podía recomprar la cosa, gozando de una *actio in factum*).

Este pacto es denominado por los romanistas como *de retroemendo* (de recompra) y por otros *de retrovendendo* (de retroventa). Las terminologías no son estrictamente romanas. Si hablamos del derecho de *de retrovendendo* por parte del comprador, lo estamos aproximando al *pactum displicentiae*.

1. Para la interpretación de estos pactos existió una evolución de la jurisprudencia. Si se consideraba que funcionaban como "condición suspensiva", la compraventa recién se perfeccionaba cuando sucediera la condición y el resultado de ésta confirmara la compraventa. En cambio, si se la consideraba "condición resolutoria" (mejor en términos romanos, suspensiva con efectos resolutorios), la compraventa ya se había perfeccionado, pero sujeta a un "pacto de resolución".

En un comienzo, según la opinión de Sabino (Sabino, Paulo, D. 41.4.2.3), la mayoría de estos pactos podían ser agregados a una compraventa bajo la forma de una condición suspensiva.

Luego, en el siglo II d.C., Juliano propuso otra

manera de ver el negocio. En principio, la venta estaba ya formada, pero sujeta a una condición que importaba la eventual resolución, de tal modo que de darse ésta se podía dar la resolución del contrato (quedaría como no comprada la cosa). Es decir, sería un pacto de resolución, suspensivamente condicionado. Esta opinión será aceptada por Ulpiano y parece haber resultado la preponderante (Ulp., D.18.2.2; D.18.3.1 y 4).

Los compiladores, siguiendo el principio de respetar la voluntad de las partes, dejaron a éstas que pudieran optar entre ambas soluciones (así respecto de la *lex commissoria*, Paulo, D.41.4.2.3 it. *in fine*; respecto de *in diem addictio*, Ulp., D.18.2.2 pr.; y 1 it.). El *pactum displicentiae* será considerada como formada bajo pacto resolutorio (Ulp., D.18.1.3; Paulo, D.41.4.2.5), pero Justiniano admite que se pueda considerar la venta con este plazo como formado bajo una condición puramente suspensiva (Inst., 3.23.4).

2. Si la cosa no había sido dada al comprador, los efectos de los pactos provocaban la resolución. Pero si el vendedor hubiese dado la cosa vendida al comprador, como la propiedad no es revocable en Roma (no se admite el dominio *ad tempus*), no se da una revocación *ipso iure* de la propiedad.

Los efectos de estos pactos son puramente personales. El vendedor debía reclamar la entrega de la cosa, que el comprador está obligado a devolverla con todos sus frutos, mediante la *actio venditi* o la *actio empti*, según la opinión sabiniana triunfante (Pomp., D.18.1.6.1; Ulp., D.18.3.4 pr.; Sab.-Paulo, D.18.5.6; Jul., D.18.2.4.4 ss.), o una *actio in factum* (Próculo, D.19.5.12; Neracio, D.18.3.5; *uicium* (*in factum*?).

Justiniano admite la propiedad sujeta a condición resolutoria, de tal modo que producida ésta, el vendedor puede reivindicar la cosa (Ulp., D.6.1.41 pr., it.; Marcelo-Ulp., D.18.2.4.3 it.).

3. La *lex commissoria* será interpretada en favor del vendedor (Ulp., D.18.3.3). De este modo puede renunciar a él, presentándosele entonces de que no pagado el precio, podrá optar entre reclamarlo por la *actio venditi*, o dejar resuelta la compraventa (Pomp., D.18.3.2) Pero si hubiera recibido el precio o una parte de él después de cumplido el término se entendía que había renunciado a los efectos de la *lex commissoria* (Scév., D.18.3.6.2; Hermog., D. id. 7).

Los otros pactos serán igualmente facultativos; así el de *in diem addictio* para el comprador (Ulp., D.18.2.9), y como resulta obvio, también el *pactum displicentiae* (Ulp., D.18.1.3).

II. LOCACIÓN (LOCATIO CONDUCTIO)

§ 424. Concepto. La *locatio conductio* (actualmente "locación" o "arrendamiento") es un contrato consensual por el cual una de las partes (*locator*, locador, arrendador) coloca en manos de otra (*conductor*, locatario, arrendatario),

ya una cosa, un trabajo o servicios, mediando una cierta finalidad y a cambio de un precio (*merces*) fijado y determinado por las partes (Gayo, 3.142 y ss.; Inst., 3.24 pr. y ss.; D.19.2).

1. *Locare* significa "colocar", esto es, confiar o entregar algo a una persona. *Conducere* vale tanto como *secum ducere* (llevar consigo).

§ 425. *Unidad del contrato: variedades*. Los romanos, estrictamente, cuando se refieren a este negocio hablan en forma unitaria de un solo contrato, la *locatio conductio*. Al igual que en la compraventa, contrato al cual se aproxima (Gayo, 3.142; Inst., 3.24 pr.), está protegido por una acción *in ius y bonae fidei*: la *actio locati conducti* (EP, § 111(112)), que tenía la forma *ex locato* para proteger al locador y la forma *ex conducto* para proteger al locatario. Pero dada la variedad del contenido, quedaron sentadas las bases para una tripartición —no romana— utilizada por los autores posteriores. Estas son:

a) *Locatio conductio rei* (Locación de cosa). En este caso el locador cede al conductor el uso de una cosa (inmueble rústico, casa, esclavo, u otra cosa mueble cualquiera), obligándose el conductor a pagar un precio por dicho uso de la cosa.

b) *Locatio conductio operis* (locación de obra). Aquí el conductor se compromete a la realización de una determinada "obra" (hacer una estatua, construir una casa, confeccionar un traje), obligándose el locador a pagar un precio por dicha "obra".

c) *Locatio conductio operarum* (locación de servicios). En este supuesto el locador arrienda sus "servicios" (así, trabajo doméstico) a cambio de una remuneración que debía pagar el conductor.

1. Como se ve, la terminología no resulta sencilla. En el segundo caso el trabajador es denominado *conductor*. En cambio, en el tercero es llamado *locator*.

Para poder comprender esto, el *locator* es siempre quien "coloca", ya la cosa (locación de cosas), ya la materia para hacer la obra (locación de obra), ya sus servicios laborales (locación de servicios). En cambio, el *conductor* es quien se lleva consigo, ya la cosa arrendada, ya la obra confeccionada, ya los servicios laborales.

Debido a esto, en la locación de cosas y en la de servicios, es el *conductor* quien debe pagar el precio, mientras que en la locación de obra el obligado a remunerar es el *locator*. En otras palabras, estas variaciones obedecen a que el precio debe ser pagado por quien obtiene las ventajas por la cosa, la obra o los servicios.

I. Locación de cosas (*locatio conductio rei*).

§ 426. *Obligaciones del locador (arrendador)*.

a) Debe entregar la tenencia de la cosa arrendada al locatario (si es un inmueble urbano es llamado *inquilinus*; si es un fundo rústico, *colonus*); para que éste pueda usarla y disfrutarla. Su obligación principal se resume en la expresión *praestare conductori frui licere* (prestar al locatario el disfrute lícito; Ulp., D.19.2.9 pr.).

1. Por detentar el *uti frui* de la cosa, su situación parece semejante al del usufructuario. Pero entre la *locatio conductio* y el usufructo hay una diferencia fundamental. La primera es simplemente un contrato que genera una acción *in personam*, mientras que el usufructo es un *ius in re aliena*, por lo cual el usufructuario tiene una *vindicatio*, que es una *actio in rem*.

b) La cosa debe entregarse en condiciones que pueda ser utilizada teniendo en cuenta las características de ella. Por ello, el locador responde por los vicios que pueda tener la cosa (así, por haber locado tinajas defectuosas que estaban rajadas; Ulp., D.19.2.19.1; o por haber locado un esclavo muletero que por impericia suya dejó morir un animal; Labeón, D.19.2.60.7). Igualmente responde por los vicios jurídicos (evicción; Ulp., D.19.2.9 pr.).

c) El locador debe hacer las reparaciones necesarias de la cosa (Ulp., D.19.2.15.1; 19.2; Gayo, D.19.2.25.2). Si la cosa se tornaba imposibilitada en su uso y disfrute, ya por culpa o por fuerza mayor (*vis maior*; p.ej., un terremoto que arruina la casa locada), los riesgos (el *periculum*) corren por cuenta del arrendador (*periculum est locatoris*; Gayo, D.19.2.25.6), no quedando obligado el locatario al pago del alquiler (Javel., D.19.2.59; Alfeno, D.19.2.30.1), debiendo entregar la cosa en el estado que esté.

1. Las reparaciones necesarias y útiles efectuadas por el locatario, deben ser pagadas por el locador (Paulo, D.19.2.55.1).

§ 427. *Obligaciones del locatario (arrendatario)*.

a) La principal obligación del locatario es pagar el alquiler por la cosa arrendada. El precio (*merces*) normalmente debía consistir en dinero, pero ya los juristas clásicos admitieron que en el caso de arrendamientos rústicos, el alquiler (*pensio*) podía consistir en una parte de los frutos (*colonia partiaria*).

1. El locatario no queda obligado al pago del alquiler en caso de que el uso o disfrute de la cosa

queden impedidos por casos de "fuerza mayor", es decir, "aquella que no se puede resistir" (así, p.ej., una inundación, un terremoto, una incursión de los enemigos, etc.), pero no si se le perjudicó la cosecha por daños en la cosa misma (así, p.ej., si los frutos fueron atacados por gusanos o cizañas); Ulp., D.19.2.15.2; Alfeno, D.19.2.30). Sin embargo, se admitió como causal de no pago ciertos defectos, como la vejez de los viñedos (Ulp., D.19.2.15.5).

2. El caso de la *colonia partiaria* corresponde a ciertas prácticas provinciales. Se podía dar la variedad de que el arrendatario pagase una cuota determinada de los frutos percibidos conforme a lo obtenido en la cosecha, o directamente una parte fija, cualquiera que sea el resultado de la cosecha.

Los Severos concedieron a los colonos que tenían una cosecha menguada, una reducción proporcional de la *pensio* (C.4.65.8). Esto se generaliza de tal modo, que por una mala cosecha el colono tenía derecho para pedir una disminución del alquiler (*remissio mercedis*), debiendo compensar la disminución si en los años siguientes se obtenían cosechas superabundantes (Ulp., D.19.2.15.3-7).

Sin embargo, se trata de una "locación", y no de una "sociedad". Pese a ello, los bizantinos lo acercarán a esta última figura (*quasi societatis*: como si fuera una sociedad, de tal modo que ambas partes se reparten las ganancias y las pérdidas. Por ello los efectos de la "fuerza mayor" se aplican solamente al caso en que el alquiler sea en dinero (Gayo, D.19.2.25.6, *itp., in fine*).

b) El locatario debe usar la cosa conforme a la naturaleza y destino de la cosa, según lo convenido en el contrato y siguiendo las reglas de la *bona fides* (*ex bono et aequo*). Por ello, responde no sólo por dolo y culpa, sino además por "custodia" (*diligentia in custodiendo*) para los bizantinos; Gayo, 3.205-6), de tal modo que se debe comportar en dicho uso como "el más diligente *paterfamilias*". (Inst., 3.24.5), respondiendo por el *furtum* de la cosa arrendada. Su responsabilidad sólo cede cuando aun habiendo tenido dicha *exacta diligentia*, aun así la cosa se hubiera deteriorado o destruido (Inst., *ibid.*; C.4.65.28).

1. Sin embargo, como no se requiere el uso personal, se permitió el "subarriendo" de la cosa alquilada, salvo pacto contrario (Alej. Sev., C.4.65.6).

c) A la conclusión del contrato está obligado a devolver la cosa locada. Si se trata de un esclavo o de una cosa mueble, el locador tendrá la *actio ex locato*, para obtener la devolución de ella, respondiendo el locatario por cuanto estimare en juicio dicho locador (Marcelo, D.19.2.48.1).

Respecto de los inmuebles, el emperador Ze-

nón (C.8.4.10, año 484) castiga la injustificada retención de la cosa locada como si fuera la "invasión" de posesión ajena, obligándolo a restituir o pagar la *aestimatio* de la cosa.

§ 428. *Situación del locatario*. El locatario (*conductor*) es un mero detentador (no poseedor) de la cosa (Ulp., D.10.3.7.11), gozando sólo de la *actio ex conducto* contra el locador. Precisamente por no ser poseedor carece de la defensa de los interdictos. Y en general carece de toda protección respecto de terceros.

a) Si el locador decide vender la cosa alquilada, o constituye sobre ella un usufructo o un *pignus*, el locatario no tiene ningún derecho contra dichos terceros, quienes podrían expulsarlo de la cosa, salvo que en la venta o en la constitución de los derechos mencionados, el locador hubiera tomado la precaución de que el adquirente se obligaba a respetar la locación. El único recurso que tiene el locatario es ejercer la *actio conducti* para reclamar del perjuicio sufrido contra el locador (no contra el tercero; Alej. Sev., C.4.65.9, año 234; Gayo, D.19.2.25.1).

1. Esto se expresa en el derecho medieval con la máxima *emptio tollit locatum* (la compraventa rompe la locación), fórmula no muy exacta, por cuanto la *locatio conductio* no queda suprimida; el contrario, queda intacta, y prueba de ello es que el locatario goza de la *actio conducti*. El arrendatario perjudicado, aunque limitado por cuanto no puede actuar contra el tercero, podrá obtener un resarcimiento pecuniario de su locador.

b) Si una de ambas partes fallece, en principio la *locatio conductio* continúa: los herederos del locatario continúan gozando del mismo contrato que su causante, y los herederos del locador seguirán cobrando los alquileres (Labeón, D.19.2.60.1; Ulp., D.19.2.19.8; Gordiano, C.4.65.10, año 239).

1. La situación no parece clara en el texto de Labeón (quizá *itp.*), quien habla de que el heredero del colono no es colono, aunque afirma que "posee para el dueño". Pero no hay dudas respecto de Ulpiano y de la constitución de Gordiano. Pero, si el arrendamiento se hubiera hecho "hasta que quisiera el locador", se extinguía con la muerte de éste (Pomp., D.19.2.4).

c) La *locatio conductio* dura el plazo que se haya establecido por las partes (para las locaciones de fundos rústicos, lo normal era fijarlo en 5 años; el "lustrum" de las locaciones censorias). Pero si luego de finalizado el plazo las partes guardaban silencio y continuaban la relación contractual, se admitió la llamada *relocatio*.

no *tácita* (hoy día, "tácita reconducción"). Si se trataba de fundos rústicos, la renovación *tácita* se efectuaba por un nuevo año, que era a su vez renovable. En cambio, respecto de los fundos urbanos; si se había establecido un nuevo plazo, había que estar a éste; de lo contrario, por el tiempo de efectiva ocupación ("que cada uno se obliguó por el tiempo que lo hubiese habitado"; Ulp., D.19.2.13.11; D.19.2.14).

Si en el contrato no había plazo para el arrendamiento, la relación podía cesar en cualquier tiempo, por decisión unilateral de las partes. Esta se expresaba en forma fáctica (*expellere* del arrendador; *relinquere* del arrendatario).

1. El *locator* podía también dar término al contrato, sin responsabilidad de su parte: a) cuando el locatario se haya conducido mal con la cosa locada (Caracalla, C.4.63.3; año 214); b) si necesitaba hacer reformas necesarias y urgentes a la cosa locada (C., *ibid.*); c) si la necesitaba para sus propios usos (C., *ibid.*).

Además, por una constitución de Zenón (C.4.65.34), ambos contratantes podrán rescindir unilateralmente la locación, pasado el primer año sin incurrir en el pago de la cláusula penal convenida.

También, en el derecho posclásico se admitió que el *locator* podía darlo por finalizado cuando el arrendatario no ha pagado los alquileres por dos años (Paulo, D.19.2.54.1, *id.*, 56 *itps.*).

2. Igualmente, el *conductor* podía rescindir el contrato: a) si no se le entregó la cosa, o se alteraron las condiciones de ella, según lo convenido (Paulo, D.19.2.24.4; Gayo, D.19.2.25; Labeón, D.19.2.60 pr.); b) si el uso de la cosa representaba un temor justificado para el arrendatario (Alfeno, D.19.2.7.1).

§ 429. En la última época del Derecho Romano, el arrendamiento de fundos rústicos se verá fuertemente influido por la "enfiteusis", que —aparte de su característica genérica de arrendamiento a largo plazo, aunque de naturaleza particular (Inst., 3.24.3)—, será más bien concebida como un derecho real, dentro del cuadro amplio de la propiedad que se observará en el Derecho vulgar.

Justiniano restablece la *locatio conductio* clásica, si bien para las locaciones rústicas admite las relaciones de dependencia de los subordinados cuasirerviles (caso de los "siervos de la gleba" y otros semejantes).

II. Locación de obra (*Locatio conductio operis*).

§ 430. Aquí, el *locator* es quien paga el precio, mientras que el *conductor* es quien debe realizar una "obra" (*opus*), entregando un trabajo ya terminado: así, construir una habitación o una casa, o reparar, o transportar cosas o perso-

nas. Tal como lo aclaramos, si bien en el Derecho moderno y actual es una figura específica de locación, para los romanos sólo existía el contrato genérico de *locatio conductio*.

1. En este caso, era esencial que el *locator* fuera el que proporcionara la materia de la obra a realizar por el *conductor*. Así, si convengo con un joyero que me haga anillos de oro, yo le debo dar el oro. En cambio, si el joyero debía hacer los anillos con su oro, Cassio opinaba que respecto de la materia prima se contraía una compraventa y respecto de los trabajos una locación. Gayo (3.147), seguido por Justiniano (Inst., 3.24.4), nos dice que ya para su época la opinión mayoritaria decía que en este último caso no hay dos contratos, sino uno solo de compraventa.

2. Lo debido es la obra que se debe realizar. Por tanto, su obligación es un *facere*, si bien lo que interesa no es tanto el trabajo, sino la obra realizada. Se podía pagarla en forma total, pero el hecho de fijar el precio por unidades de trabajo no altera el sentido de totalidad de la obra encargada (Javol., D.19.2.51.1).

El *conductor* que ha recibido el material con el cual debe trabajar responde por la *custodia* de la cosa; así, si es objeto de un *furtum*, deberá responder ante el *locator* (Gayo, 3.205-206). Además, responde por su *imperitia* por su falta de aptitudes para realizar la obra a la cual se comprometió (Celso-Ulp., D.19.2.9.5).

1. Si la cosa se destruía como consecuencia de "fuerza mayor" antes de haber sido aceptada por el *locator*, la pérdida era para el *conductor*. Así, si contrató la construcción de un canal y éste fue destruido por una tempestad.

Pero los juristas posteriores hicieron una distinción: si el vicio estaba en la obra misma, debía responder el constructor (*conductor*); en cambio, si fue por un vicio extraño, así por defectos del suelo, la pérdida es para quien la encargó (*locator*), quien debe el precio (Labeón, D.19.2.62 *itp.*, igual solución en Javoleno (D.19.2.59) y Africano (D.19.2.33)).

2. De este modo; la regla general era que, ya de pleno derecho o por haberse convenido entre las partes, el *conductor* deja de ser responsable desde que el *locator* ha aprobado la obra, verificando su buena ejecución. Pero si la obra se pierde o se deteriora ya por dolo o culpa del *locator*, o por fuerza mayor (en nada atribuible al *conductor*; así, un terremoto), aun antes de la aprobación el *locator* debe pagar el precio (Javol., D.19.2.59; D.19.2.37; Florentino, D.19.2.36).

§ 431. *Formas especiales vinculadas a la locatio conductio operis*. El contrato de transporte de mercaderías por mar era una de las formas que podía considerarse un arrendamiento de obra. Pero existían al respecto ciertas reglas especiales.

A) *Régimen de la lex Rhodia de iactu*. Ya desde la época republicana, en el mundo mediterráneo era de práctica usual la utilización de la *lex Rhodia de iactu* (de la isla de Rodas, sobre la "echazón"). Según ella, cuando el capitán de una nave (*magister navis*), como consecuencia de una tempestad o de una vía de agua, se veía obligado a aliviar la carga echando una parte de las mercaderías al mar, para salvar al resto, la pérdida ocasionada debía ser soportada proporcionalmente por todos los propietarios de mercaderías que habían cargado la nave (Paulo, D.14.2.1).

Si bien la regla es griega, la jurisprudencia clásica le dará un tratamiento romano, utilizando precisamente las reglas de la *locatio conductio*. El propietario de la mercancía que había sido echada (*iactus*) tiene la *actio locati* contra el transportista, para obtener indemnización por dicha mercancía perdida. El transportista gozaba a su vez de la *actio conducti* contra los propietarios de las mercaderías que se salvaron, para que se reparta proporcionalmente el perjuicio (Paulo, D.14.2.2 pr.).

Es el antecedente antiguo de lo que será el régimen de las "averías" en el Derecho marítimo moderno.

1. Quien perdió mercaderías por medio de la *actio locati* podía exigir que el patrón de la nave que retuviera las mercaderías de los demás transportistas hasta que paguen la parte del daño (Servio-Paulo, D.14.2.2 pr.).

2. La contribución debía hacerse proporcionalmente según la estimación de las mercaderías de cada uno, que se salvaron. Se tomaba en cuenta el valor presente, sin considerar el precio de compra ni el lucro que pudieran tener sus dueños al venderlas (Paulo, D.14.2.2.4).

Estaban incluidos en la obligación de contribución todos los pasajeros, lleven mercaderías o equipajes o no, ya que por haber ocupado un sitio en la nave, el beneficio del "alijo" o de la "echazón" benefició a todos (Paulo, D.14.2.2 pr.). Estaba incluido también el dueño de la nave (Paulo, D.14.2.2.2); aunque éste no es responsable de la insolvencia de los pasajeros (Paulo, D.14.2.6).

Por ello debían contribuir también quienes llevaban mercaderías que no representaban peso (p.ej., joyas), porque sus propietarios tuvieron interés en la "echazón" o "alijo". También de los vestidos y anillos de un viajero, pero no de los alimentos que se llevaban para ser consumidos "con tanta mayor razón, cuanto que, si hubieran faltado para la navegación, lo que cada cual tuviera lo hubiera aportado, en común (Paulo, D.14.2.2.2).

También entraña a contribución la "echazón" del mástil u otro instrumento de la nave (Paulo, D.14.2.3). Pero no de los hombres libres, respecto de quienes

no se puede estimar la vida (Paulo, D.14.2.2), ni de los esclavos que perecieron en el mar (Paulo, D.14.2.5).

3. Si la nave ha sido atacada por piratas, no se debe contribución. El propietario pierde las mercancías hurtadas. En cambio, se debía contribuir si se pagaba un rescate por la nave (Servio, Ofilio, Labeón-Paulo, D.14.2.2.3).

4. Si alguien se apodera de las cosas echadas al mar no comete *furtum*, salvo que se tratara de alguna cosa que esperaba conservar si se salvaba (Ulp., D.47.2.43.11; Paulo, D.14.2.2.8).

Si las cosas arrojadas al mar hubiesen aparecido, se prescinde de la contribución. Y si ésta ya fue hecha, los que pagaron tienen la *actio locati* contra el patrón de la nave para que éste ejerza la *actio conducti* contra los demás transportistas para rectificar la cuenta de las indemnizaciones pagadas (Paulo, D.14.2.2.7).

B) *Caso de la mezcla (aversio)*. Cuando se cargaba una nave con granos, de tal modo que en la bodega quedaban mezclados, el capitán de la nave se obligaba no sólo a transportarlos, sino a entregar la cantidad convenida a cada uno de los destinatarios. En esta variedad de locación de obra por transporte, se entendía que no se regía por las reglas de la *simple copropiedad* (como en el caso de la *commixtio* y de la *confusio*, v. *supra*, § 248), ni tampoco por la del mutuo (como si el transportista fuera mutuario), sino como una forma particular de transporte (*conductio navis per aversionem*: transporte de mercaderías por cantidad mezcladas). Quedaba abierta a los propietarios de los granos una *actio oneris aversi* (*aversio* = mezcla), para recuperar las respectivas cantidades, siendo el capitán responsable por culpa en el transporte (Alfeno, D.19.2.31; EP, § 111 (112)).

C) Recordemos, a su vez, que los transportistas marítimos (*nautae*), al igual que los dueños de albergues (*caupones*) y de establos (*stabularii*), tenían una responsabilidad especial por la declaración expresa de seguro respecto de las cosas transportadas (*receptum res salvas fore*); v. *supra*, § 357.D.

III. Locación de servicios (*Locatio conductio operarum*).

§ 432. Se trata acá del caso de que una de las partes (*locator*) arrienda sus servicios o trabajos a otra (*conductor*) que se obliga a pagarle un precio por ellos. Esta variedad, que no está especificada como figura independientemente en los textos romanos, sino como uno de los supuestos de *locatio conductio*, no tuvo en Roma el desa-

rollo que tuvo en los tiempos modernos (de donde surgirá el "contrato de trabajo" actual). Lo que ocurre es que en el mundo antiguo, la mano de obra, cuando no era personal, estaba ampliamente cubierta por los esclavos y los libertos (con las *operae* debidas al patrono). El trabajo de hombres libres pagados por otro resultaba bastante limitado.

1. La *locatio conductio* de un esclavo es una "locación de cosa", en el sentido de que es el esclavo mismo la cosa locada. Dentro de esta figura se podía dar una mera variante, cual sería locar determinados "servicios del esclavo". Así, podía ocurrir como una modalidad para otorgar la manumisión (*operae dare*; Paulo, D.40.7.4.4); o en el caso de un esclavo fructuario que *locat operas suas* (Pap., D.45.3.18.3).

2. En cambio, en el caso de un hombre libre que "coloca" sus servicios, él es el *locator*, siendo el *conductor* quien aprovecha de ellos y debe retribuirlo. Su obligación principal es pagarle el *salarium*, o *merces* (de allí, *mercennarius*).

Si los servicios no han sido prestados por causas no imputables al trabajador, se le deben los salarios que se haya convenido. Así, Ulpiano (D.19.2.19.9-10) nos da dos casos: en el primero, un copista contratado por alguien que murió; en el segundo, los subordinados de un Legado del César, que falleció. En ambos casos, se decidió que los términos del contrato debían mantenerse y los herederos debían pagarles los salarios.

Pese a ello, no se encontrará en Roma una protección social en caso de despido. Por esto, los antecedentes romanos no proporcionan ninguna ayuda al "contrato de trabajo" actual. Simplemente hay que tomar en consideración la módica aplicación que tuvo esta figura de la llamada *locatio conductio operarum*, en un medio económico totalmente distinto del que ocurrirá en los tiempos modernos, sobre todo a partir de la "sociedad industrial".

Vinculadas con la *locatio conductio operis* (y en su caso, también la *locatio conductio operarum*) había una gama muy amplia vinculada con las labores que hoy día llamaríamos "liberales" (así, los *rethorici*, *geometrae*, *grammatici*, abogados, institutrices, etc.) No serán considerados como habiéndose convenido una *locatio conductio*. Las profesiones liberales, por la dignidad que tenían parecen estar fuera del marco de los contratos. Las retribuciones no son consideradas *merces*, sino *honorarium*. En la época imperial la labor de estos profesionales genera para su cobro un juicio *extra ordinem* (Ulp., D.50.13.1 pr. y ss.).

III. SOCIEDAD

§ 433. *Concepto y evolución.* La sociedad (*societas*) es un contrato consensual, por el cual

dos o más personas (*socii*) se unen, aportando ya la totalidad de sus bienes o sólo una parte de ellos, para realizar un fin común, repartiéndose las ganancias y soportando las pérdidas.

I. En la época antigua existía la costumbre de que a la muerte de un *paterfamilias*, los bienes continuaran indivisos entre los *sui heredes*, conformándose entre ellos una especie de sociedad llamada *erectum non cito* (dominio indiviso; Gayo, 3.154a).

Pero también se permitió que otras personas pudieran crear artificialmente una sociedad semejante por medio de una *legis actio*, como si fueran hermanos (*ad exemplum fratrum suorum*; Gayo, 3.154b).

Ya en la época clásica, tanto la sociedad "natural y legítima" (*erectum non cito*), como la "artificial" (creada "a su ejemplo") han desaparecido. Es muy probable que sobre la base de esta última, surgiera la *societas omnium bonorum*.

II. En la época clásica, podemos observar la existencia de varias clases de sociedades (Ulp., D.17.2.5 y 7):

a) *Societas omnium bonorum* (sociedad de todos los bienes): Se caracteriza porque todos y cada uno de los socios aportan en común todo su patrimonio (tanto los bienes actuales como los futuros). De este modo, los socios se "comunican" todos los bienes, en forma inmediata; lo mismo que sus deudas, a partir del consentimiento, conformándose un *consortium* común (Paulo, D.17.2.1.1).

1. Las cosas se hacen inmediatamente comunes, aunque no haya mediado *traditio*, entendiéndose a ésta como *táctita* (Gayo, D.17.2.2 itp.). Esto no debió haber sido así en el derecho clásico, por lo menos respecto de las *res mancipi*. Si se trata de créditos, los socios deben cederse las acciones para su cobro (Paulo, D.17.2.3). Cada socio tiene su parte en la propiedad, tal como ocurre, p.ej., en la *hereditas*.

2. De algún modo, continúan ciertos vestigios de la vieja sociedad "artificial". Así, aparte de la comunidad de bienes, cuando un socio debe responder ante los otros podía usar del *beneficium competentiae* (pagar conforme a sus posibilidades), lo cual es propio entre familiares (Ulp., D.17.2.63 pr.). Además, la *actio pro socio*, por estar implicada la *fides*, tenía para el vencido la tacha de infamia (Gayo, 4.182; Inst., 4.16.2).

b) *Societas quaestus* (de ganancias y adquisiciones): Los socios guardan su patrimonio propio, pero ponen en común todas las ganancias y adquisiciones que provengan de su trabajo, o de su actividad comercial o industrial (Ulp., D.17.2.7). Se deja a un lado lo que se obtenga por otras causas (legados, donaciones, herencia); Alfeno Varo-Paulo, D.17.1.71.1; id.74.

1. Esta especie de sociedad servía en el caso de que existieran varios esclavos manumitidos por el mismo *dominus*. Como, en general, no tenían otra fuente de recursos que su trabajo, encontraban una gran ventaja en poner, en común sus esfuerzos y ganancias (Paulo, D.17.2.71.1).

2. Ante el silencio de las partes que hubieran convenido otra cosa, se entiende que han querido unirse por esta especie de sociedad de adquisiciones y ganancias (Ulp., D.17.2.7 y 9; Paulo, D.17.2.8).

c) *Societas alicuius negotiationis* (sociedad por negocios determinados de la misma naturaleza). Los socios realizan aportes, poniendo en común el uso (también la propiedad, pero no era necesario) de determinadas cosas o el trabajo personal para la realización de un negocio determinado, como, p.ej., para comprar y vender esclavos, aceite, vino o trigo (Gayo, 3.148; Inst., 3.25 pr.).

1. La forma más antigua fue la asociación de trabajadores libres que ofrecen sus servicios al propietario agricultor para levantar la cosecha (Catón, de re rust., 144 ss.). Típicas de la época clásica son las sociedades de banqueros (*argentarii*) y de vendedores de esclavos (*venedictarii*); así como las empresas de trasportes y suministros (Tit.Liv., 23.48-49).

2. Una forma especial eran las sociedades *vectigalis*, encargadas de la percepción de impuestos (*vectigalis*). En la época republicana el arriendo de estos impuestos se sacaba a subasta. Aquellos a quienes se adjudicaban este encargo, eran llamados *publicani*. Podían retener los *vectigalia* cobrados, debiendo pagar una suma fija al *aerarium*. Tenía reglas especiales que las distinguían de las otras especies de sociedades. Así, a la muerte de uno de los asociados, la sociedad no se disolvía, sino que continuaba con los que quedaban y los herederos del difunto, salvo que la personalidad de este último hubiera sido causa principal de la formación o de la administración de la sociedad (Pomp., D.17.2.59 pr.).

d) *Societas unius rei* (sociedad por un solo negocio). Es semejante a la anterior, pero está constituida para un solo negocio. Así, p.ej.: dos personas, una teniendo tres caballos, y otra un solo, se unen para constituir una cuadrilla y venderla (Celso-Ulp., D.17.2.58 pr.). O también dos personas se asocian para comprar un fundo y explotarlo, repartiéndose los beneficios (C.4.37.2).

1. Incluso se considera sociedad que cada vecino ponga en común cada uno medio pie de su terreno para edificar un muro medianero (Ulp., D.17.2.52.13).

2. No era necesaria la comunicación de la propiedad de los aportes, ya que pueden éstos consistir en poner el uso de ellos a disposición de los demás socios.

§ 434. *Características de la sociedad.*
A) El contrato de sociedad es consensual. Se constituye por el mero consentimiento y dura mientras ésta continúe (Gayo, 3.151). Es de buena fe, en el sentido de que la *fides* es la que preside todo su contenido. A diferencia de lo que ocurre en la compraventa y en la locación, no existen roles distintos de las partes (así, comprador y vendedor; locador y locatario), sino que todos los socios están sometidos a las mismas obligaciones, sancionadas por la *actio pro socio*, que tiene igual amplitud para todos ellos.

1. Para señalar ese concernimiento de todos los socios en el interés común, Ulpiano, en texto aislado (D.17.2.63 pr.), nos habla de que en la sociedad existe de algún modo un *ius fraternitatis* (lo cual sería otro vestigio de las formas primitivas ya vistas). También se emplea la expresión *affectio societatis*, que es Justiniana (Ulp., D.17.2.31 itp.).

2. Los miembros de la sociedad son los que convinieron en constituirse como socios en un comienzo. La admisión de un socio nuevo requiere el consentimiento de los demás. Si uno de ellos se asocia con un tercero, será sólo socio suyo (Ulp., D.17.2.30: "porque el socio de mi socio no es socio mío").

B) La *societas* no es una persona jurídica. Por tanto, no hay un patrimonio de la sociedad. Si los bienes están en común (como es la especie *omnium bonorum*), éstos están en condominio de todos los socios, teniendo sus respectivos derechos en dicho *consortium*. Si los aportes han sido sólo en cuanto al uso de las cosas (caso de la especie *alicuius negotiationis* o de la *unius rei*), siguen siendo propiedad de cada socio, quien deberá permitir el uso por parte de los otros.

Tampoco existen deudas de la *societas*, y sí sólo de los socios singulares. Se ve de este modo que la sociedad es sólo una relación contractual interna entre los socios, que carece *per se* de efectos en el exterior.

1. En cuanto a la administración de la sociedad, no había normas especiales. Podían designar a alguien como "mandatario", o actuar cada uno como "gestor de los negocios". El régimen es el de la "representación indirecta". Los actos jurídicos de un socio, en principio sólo es realizado por él. Así, si compra una cosa, será un negocio particular entre dicho socio y el tercero vendedor. También, si contrae una obligación, él es el deudor.

2. Pero siendo socio, deberá participar jurídicamente de los actos realizados a los otros socios. Esto se expresa con el verbo *communicare* (Paulo, D.17.2.1.1; D.17.2.74). Así, si ha comprado algo como aporte y hay un *consortium* está obligado a transferir la propiedad al patrimonio común, pudiendo exigir de sus consocios la parte correspondiente del precio pagado.

Si ha contraído una obligación, podrá descargar su monto, hasta la concurrencia de su parte (Paulo, D.17.2.38.1; D.17.2.39).

3. Solamente Justiniano permitirá que la responsabilidad de los actos de un socio pueda alcanzar a los demás socios (Paulo, D.17.2.63). Está interpolada la parte final: "Por derecho de sociedad, un socio no se obliga por otro socio a una deuda" (clásico), pero se agregó "si las cantidades no se ingresaron en la caja común".

§ 435. *Distribución de las ganancias y de las pérdidas.* Los socios están facultados a participar de las ganancias e igualmente a tener que soportar las pérdidas (*communicatio lucri et damni*).

A) Si nada se hubiera convenido acerca del reparto de las ganancias y de las pérdidas, se entendía que se debía producir por "partes iguales" (*partes aequas*) (Gayo, 3.150; *aequales partes*; Inst., 3.25.1).

1. Acá "partes iguales" debe ser interpretado como divididas *per capita*, y no en forma proporcional a los aportes (Ulp., D.17.2.29 pr.; Pompo, D.17.2.6; Próculo, D.17.2.76 y 80). De lo contrario, sería difícil de establecer cuál es la proporción si el aporte de un socio consiste en el trabajo.

B) Pero las partes podían convenir un régimen distinto. Así, se puede establecer que el socio A tenga los 2/3 tanto en las ganancias como en las pérdidas, y el otro socio B tenga en ambas solamente 1/3. Es una manera de reconocer que el primero aportó más a la sociedad, ya sea en dinero, en trabajo o en otra cosa (Inst., 3.25.1; Ulp., D.17.2.29 pr.).

1. En cambio, mayores dificultades podría traer que se conviniera que uno de los socios tuviera una parte mayor en las ganancias que en las pérdidas. Así, este caso. Ticio y Seyo han convenido que a Ticio le correspondieran los 2/3 de las ganancias y sólo 1/3 de las pérdidas; y que a Seyo le correspondieran los 2/3 de las pérdidas y sólo 1/3 en las ganancias (Gayo, 3.149; Inst., 3.25.2).

Quinto Mucio Scévola consideró que esto estaba en contra de la naturaleza de la sociedad. Pero Servio Sulpicio consideró que un convenio semejante era válido. Esta última opinión resultó triunfante ya en la época clásica, admitiéndola igualmente Justiniano. La razón dada era la distinta importancia de los aportes; así, si uno de los socios contribuía con su trabajo, que resultaba tan valioso, que por ello se justificaba la desigualdad (Ulp., D.17.2.29.1-2).

Este principio no resulta contrario a que todo socio debe participar en las pérdidas. Hay que tener en cuenta que acá, "ganancias" y "pérdidas", no son entendidos como números aislados, sino estableciendo

la respectiva compensación interna. Así, habrá ganancia si efectuada la compensación, el "saldo neto" era positivo, y pérdida si dicho "saldo neto" es negativo. Es en torno de este cálculo que se producirá el reparto entre los socios. Lo que no está permitido es que un socio nunca pueda tener participación en las ganancias (Inst., 3.25.2, *in fine*; Paulo, D.17.2.30).

2. Para el caso de que se hubiera convenido algo en un solo sentido, ya en las ganancias o en las pérdidas, se entiende que hay que aplicar el mismo criterio respecto del rubro omitido (Inst., 3.25.3).

C) Lo que estaba totalmente prohibido, por inmoral, era la denominada "sociedad leonina" (*societas leonina*), denominada así por la fábula de Fedro (1.5), según la cual el león forma una sociedad con otros animales, y luego se queda con toda la caza realizada, dejando sin nada a sus "socios". Se trata de la sociedad en que uno participa sólo de las "ganancias", y el otro debe soportar todas las pérdidas, sin tener derecho a las ganancias. Se considera un género de lo más inequitativo de sociedad (*iniquissimum genus societatis*: Aristón-Cassio-Ulp., D.17.2.29.2).

1. Está permitido que se convenga la decisión de un árbitro para resolver el problema del reparto de las ganancias y de las pérdidas (Pompo, D.17.2.6, D.17.2.76-80). Si el socio se considera perjudicado, puede actuar por la *actio pro socio* para obtener una decisión distinta.

§ 436. *Disolución de la sociedad.* Toda sociedad es temporal. Una sociedad establecida *in aeternum* es nula (Paulo, D.17.2.70). Por ello se puede disolver por varias causas:

A) Por la muerte de uno de los socios (o su *capitis deminutio*). Dado el carácter eminentemente personalísimo de la sociedad, en la cual se había elegido el socio, o los socios de manera muy especial, la muerte o la incapacidad de uno de ellos acarrea la finalización del contrato (Gayo, 3.152.153; Inst., 3.25.7-8).

1. Aun si la sociedad es de varios socios, la muerte de uno de ellos disuelve la sociedad "aunque muchos sobrevivan" (Inst., 3.25.5). No puede continuar la sociedad con el heredero del socio muerto; lo que se permite es constituir "una nueva sociedad" integrada por los socios que quedan (Gayo, 3.153).

Justiniano permitirá que por convenio previo se establezca la continuación de la sociedad primera (Inst., 3.25.5; Paulo, D.17.2.65.9 itp.).

2. Respecto de la *capitis deminutio*, en la época de Gayo, las tres clases ocasionaban la disolución de la sociedad. Luego se establecerá que sólo provocan este efecto la *c.d. maxima* y la *c.d. media*, pero no la *c.d. minima*. Así el hijo socio no deja de ser tal por su emancipación; tampoco el que se da en *adrogatio*, sin

englobar al *adrogator* "para que ninguno se haga socio contra su voluntad" (Paulo, D.17.2.65.11 itp.; Ulp., D.17.2.63.10 itp.).

3. La muerte de un miembro de una *societas vecigalium* (*supra*, § 440.II (c) 2) no ocasiona la finalización de la sociedad, sino que continúa entre los supervivientes y los herederos del fallecido, salvo que éste hubiera sido causa determinante en su formación o administración (Pompo, D.17.2.59 pr.).

B) Por la renuncia (*renuntiatio*) de un socio. Si uno de los socios se quiere retirar, también se disuelve la sociedad, puesto que nadie puede ser obligado a permanecer como socio contra su voluntad (Gayo, 3.151; Inst., 3.25.4).

1. Pero la *renuntiatio* no debe ser dolosa. Así, si un socio advierte que ha recibido una herencia y renuncia a la *societas omnium bonorum* a cuyo *consortium* ingresaría ella, con el fin de aprovechar el solo el lucro de la herencia, entonces, como dice Cassio, "libera de sí a los socios, pero él no se libera de ellos". Por la *actio pro socio* se lo obliga a tener que soportar como "común" la utilidad, y si existe algún "daño" derivado de la herencia, de éste responde únicamente el socio renunciante (Paulo, D.17.2.65.3).

2. La *renuntiatio* tampoco debe ser intempestiva. Así, si la sociedad es por un plazo determinado y el socio se retira antes. En este caso, si hay alguna ganancia, el renunciante no participa de ella, pero si hay una pérdida, deberá pagar su parte. Todo ello salvo que la renuncia haya sido hecha por necesidad (Paulo, D.17.2.65.6).

C) Si la sociedad se convino para la realización de un sólo negocio, concluido éste, termina la sociedad (Inst., 3.25.6), e igualmente, si fue constituida por un plazo determinado y éste se cumplió (Paulo, D.17.2.1 pr.).

1. Otras causas son: la quiebra (*venditio bonorum*) o la confiscación de los bienes de un socio (Gayo, 3.153; Inst., 3.25.7-8); la pérdida de los aportes entregados por los socios (Ulp., D.17.2.63.10); cuando por una *stipulatio* o un juicio se hubiera mudado la causa de la sociedad (Paulo, D.17.2.65 pr.).

§ 437. *Actio pro socio.* Cuando se extingue la sociedad, se abre la posibilidad para que cada uno de los socios pueda ejercer la *actio pro socio*, cuya fórmula estaba redactada *in ius* y con la cláusula *ex fide bona* (EP, § 109). La condena traía para el vencido la tacha de infamia (Gayo, 4.182); pero gozaba del *beneficium competentiae*, es decir, pagar según sus posibilidades (Ulp., D.17.2.63 pr. itp.).

1. En la época clásica, la *actio pro socio* sólo se podía ejercer al finalizar la sociedad. Mientras per-

manezca ésta, el *ius* no regula la vida interna entre los socios. El que esté desconforme puede pedir la disolución de la sociedad.

2. Justiniano permitirá el ejercicio de la *actio pro socio* antes de la finalización de la sociedad (*inveniente societate*), p.ej., para reclamar los aportes que no han sido hechos (Paulo, D.17.2.65.15 itp.).

En cuanto al *beneficium competentiae*, en la época clásica sólo regía para la *societas omnium bonorum* (Pompo, D.42.1.22.1), que Justiniano extiende para las otras clases (Ulp., D.17.2.63 pr. itp.).

La finalidad de esta *actio pro socio* es reclamar por el saldo que le pueda corresponder al socio, es decir, el que resulte de la compensación de las ganancias y pérdidas, y por las indemnizaciones procedentes de aportes no efectuados, gastos necesarios efectuados por interés social y por los daños efectuados por otro socio. Los socios responden no sólo por dolo, sino también por culpa (Paulo, D.17.2.36; Celso-Ulp., D.17.2.52.2), e incluso, en ciertos casos, por "custodia" (Ulp., D.17.2.34.4).

En la época de Justiniano, la culpa debía ser apreciada *in concreto*. No debe medirse por una "exacta diligencia" (*exactissima diligentia*), bastando que el socio ponga en las cosas societarias el mismo cuidado que habitualmente pone en sus propios negocios (Inst., 3.25.9; Gayo, D.17.2.72 itp.). La razón que se da es "porque el que ha admitido a un socio poco diligente, a él sólo debe culparse".

Si existían bienes en común, es decir, que estaban en copropiedad (*communio pro indiviso*), era necesaria la partición por la *actio communis dividundo*, ya que no bastaba con la *actio pro socio* (Paulo, D.10.3.1; Ulp., D.17.2.43). En este caso, el *iudex* por la *adiudicatio* producía el reparto entre los socios copropietarios. Esta *communio pro indiviso* será considerada por Justiniano como una figura de *quasi ex contractu* (Inst., 3.28.3).

IV. MANDATO

§ 438. *Concepto.* El *mandatum* es un contrato consensual, por medio del cual una parte (*mandatarius*) se obliga gratuitamente a realizar uno o varios negocios en favor de la otra (*mandans* o *mandator*), quedando ambos recíprocamente obligados el uno al otro a cumplir todas las prestaciones que la *fides* ordena (Gayo, 3.155).

1. La expresión *mandare* deriva de *manum dare*, porque antiguamente una vez celebrado el negocio, el uno daba la mano al otro (*manum dabat*; *manus datum* = *mandatum*); pero también en latín vulgar in-

manum dare es confiar un encargo a otro. Quien encomienda es denominado *mandans*; también *mandator*. La expresión *mandatarius* es tardía; en la época clásica se lo denomina como *qui mandatum accipit* (quien acepta el mandato).

2. El origen del *mandatum* estuvo precedido por los encargos que se realizaban en el marco de la *amicitia*. Esta tenía en Roma una vigencia tal que imponía serios deberes en cuanto al cumplimiento. De ahí que se regían por la *bona fides*, y por supuesto en forma gratuita. Todo ello (gratuidad, *fides*, *amicitia*) nos hace ver que estamos en realidad fuera del ámbito jurídico. Con mucha discreción, a fin de evitar problemas en las relaciones surgidas, es que en la época republicana se lo configura como un contrato, a partir de la *actio mandati* que era *in ius concepta* y la fórmula contenía la cláusula *ex fide bona* (EP, § 108).

§ 439. *Representación indirecta en el mandato*. Tal como lo vimos (*supra*, § 314), en Roma no se da noción de "representación directa", es decir, aquella en la cual el representante actúa en nombre del representado, sino solamente aquella en la cual alguien actúa por cuenta de otro.

De este modo, en el mandato, cuando el mandatario acepta el contrato y realiza el negocio encomendado, los efectos de éste recaen en su propia persona, si bien por los efectos internos del mandato, debe luego transferirlos por los modos adecuados a la persona del mandante.

Así, A le encarga a B comprar una casa. B se la compra a C. La compraventa tiene efectos entre B y C, quienes se pueden reclamar por la *actio venditi* (C contra B) y la *actio empti* (B contra C). Pero por efectos del mandato, B se ve obligado a ceder la *actio empti* a A, e igualmente A queda obligado a liberar a B de las obligaciones contraídas respecto de C.

1. Como se puede apreciar, el mandatario es un "agente" o un "comisionista" del mandante. Esta "representación indirecta" también se puede ver en la figura del *procurator* (v *supra*, § 314.A.2). Generalmente era un liberto del *pater* que se ocupaba de la administración de todos sus bienes (*procurator omnium bonorum*) o de un asunto determinado (*procurator unius rei*), así como también de su defensa procesal. Todo ello más para cumplir un deber moral (*officium procuratoris*; Pap., D.17.1.56.2) que para lograr una retribución.

§ 440. Caracteres:

A) Es meramente consensual. Por ello no tiene formas solennes de celebración. Debe existir un "mandar", un "autorizar" (*iubere*) por parte del mandante y una aceptación del encargo por parte del mandatario.

1. El consentimiento puede ser "expreso" (p.ej. por medio de palabras o por una carta que diga simplemente "Te ruego", "Quiero", "Mando", aceptada por la otra parte; Paulo, D.17.1.1.2). Pero también "tácito" (p.ej., cuando estando uno presente o en conocimiento, permite que otro maneje sus negocios; Ulp., D.17.1.6.2; Pap., D.17.1.58).

2. Pero el consentimiento no puede dejar de existir, ya que si en ausencia del "dueño del negocio" (*dominus negotii*) alguien realiza una gestión favorable a él, entonces se da la figura de la "gestión de negocios" (*negotiorum gestio*; Inst., 3.27.1; D.3.5).

3. El mandato se puede constituir a plazo o bajo condición (Inst., 3.26.12).

B) El mandato es eminentemente gratuito, ya que en principio se entiende que si hubiera una retribución estaríamos en presencia de una *locatio conductio* (Gayo, 3.162; Inst., 3.26.13).

Sin embargo, en el derecho clásico tardío, se permite la recepción de un voluntario *honorarium*, que es entendido como un reconocimiento, y no como un precio, y que no afecta la validez del negocio (Ulp., D.11.6.1 pr.; D.17.1.6 pr.).

1. En el derecho imperial este *honorarium* podía convenirse y ser exigido por *extraordinaria cognitio* (D.50.13), pero no por la *actio mandati* (Justiniano insistirá en el carácter clásico de la gratuidad del mandato; Inst., 3.26.13).

2. Si se trataba de un mandato procesal, el *procurator* no podía convenir un *honorarium* que fuera una determinada porción de lo que se obtendría en la sentencia (es decir, el "pacto de cuota litis" actual), por considerárselo inmorale (Pap., D.17.1.7).

§ 441. *Contenido del mandato*. a) El cometido del mandato debe ser lícito y acorde con las buenas costumbres. Así, no se contrae la obligación, p.ej., si te mando que cometas un *furtum* o una *iniuria* contra Ticio (Gayo, 3.157; Inst., 3.26.7).

1. En general, se trata de la realización de determinados actos jurídicos. Gayo (3.162, repetido en Inst., 3.26.13) nos habla también de actividades fácticas; así, dar a un tintorero vestimentas para que las limpie o a un sastre, para que las repare. Pero parece más un ejemplo escolar para subrayar la gratuidad del mandato; en efecto, si estos labores son realizadas gratuitamente serían casos de mandato, si son pagadas, serían locaciones de obra.

b) El asunto o negocio encomendado puede ser (i) en interés del mandante (p.ej.: que mi mandatario me compre una casa) o (ii) en el de éste y también del mandatario (p.ej., te debo 100 y te mando que le cobres a Ticio los 100

que él me debe, de tal modo que al cobrarlos te los quedes como pago de mi deuda) o (iii) de un tercero (p.ej., te mando que le salgas de fiador (*fideiussor*) a Ticio); Gayo, 3.153; Inst., 3.26 pr.

Lo que no puede ocurrir es que sea en interés exclusivo del mandatario. Los juristas clásicos establecieron que un *mandatum tua tantum gratia* (es decir, sólo en el interés del mandatario) equivale a un *consilium* (consejo). En efecto, se entiende que lo que tú harás en tu propio provecho debes hacerlo por tu propia determinación, y no por mi mandato. Así, si te hubiera aconsejado que prestaras el dinero ocioso que tienes, dándoselo en mutuo a alguien, y tú sigues mi consejo, ello no obstante no podrías reclamarme nada por la *actio mandati* (Gayo, 3.156; Inst., 3.26.6).

1. Tanto Gayo (D.17.1.2 pr. y ss.) como Justiniano (Inst., 3.26 pr. y ss.), establecieron toda una serie de posibilidades de mandato válido: a) en favor exclusivo del mandante; b) del mandante y del mandatario; c) del mandante y de un tercero; d) sólo en el interés del tercero; e) del mandatario y del tercero; y f) sólo en el interés del mandatario. Todo esto no pasa de ser un mero ejercicio escolástico, careciendo de importancia, salvo el de determinar que el último caso (*mandatum tua tantum gratia*: "mandato solo en tu interés") es un mero "consejo", y no un "mandato".

2. Sin embargo, en el caso que hemos planteado acerca del "consejo" hay que distinguir: si se trata de que te aconseje que te resultaría conveniente invertir tu dinero poniéndolo en préstamo a interés, ello es un simple consejo (*tua tantum gratia* = solamente en tu interés). Tú lo puedes seguir o no, prestándole el dinero a quien se te ocurra, y yo no seré responsable.

Pero si yo te pido que le prestes dinero a Ticio en mutuo, y tú aceptas, ¿habría mandato? Servio Sulpicio interpretaba que era una forma de consejo, por lo que no había mandato. Pero triunfó la opinión posterior de Sabino, quien pensaba que si bien había acá el pedido de que prestaras Ticio, lo cual era "en tu interés" (*tua gratia*) no era, sin embargo, "en tu solo interés" (*tua tantum gratia*), sino también en el interés de Ticio que quería recibir el préstamo. Acá había, pues, válidamente un mandato, puesto que tú no habrías prestado a Ticio si yo no te lo hubiera mandado.

Tú haces tu negocio, y en caso de que Ticio no te pague, podrás demandarlo por la *condictio certae creditae pecuniae*. Y si no hallas satisfacción me podrás demandarme por la *actio mandati contraria*, pues he asumido el riesgo (*periculum*); (Gayo, 3.156; Inst., 3.26.5-6; Marcelo, D.46.1.24).

Sobre "mandato de prestar dinero" (*mandatum pecuniae credendae*) ver *infra*, § 445.

§ 442. *Obligaciones y acciones nacidas del mandato*. A diferencia de los otros contra-

tos consensuales, el mandato es "sinalagmático imperfecto". En principio, genera obligaciones para una sola de las partes, el mandatario, quien debe cumplir lo mandado. Pero eventualmente, el principio de reciprocidad del *synallagma* está presente, puesto que el mandante puede resultar obligado.

Esto se ve bien claro en el ejercicio de la *actio mandati*, que tiene dos acciones distintas. Por la *actio mandati directa*, el mandante puede exigir que el mandatario le rinda cuentas y, en su caso, le transfiera todo el beneficio adquirido; se ejerce contra el mandatario y sus herederos (Paulo, D.17.1.5.1; Ulp., D.17.1.10). Por la *actio mandati contraria*, el mandatario puede demandar al mandante para que se le restituyan todos los dineros que hubiere pagado, los gastos que hubiere necesitado hacer y se lo indemnice de los perjuicios ocasionados (Ulp., D.17.1.12.9; Paulo, D.17.1.45 pr.).

1. Parecería que el mandatario, dado que el contrato está basado en la *fides* y es gratuito, sólo responde por el "dolo". El criterio en tal sentido está fijado en un texto de Modestino (*Coll.10.2.3*), quien establece la responsabilidad por la *actio mandati* sólo en caso de dolo, pero no de culpa.

¿Respondía por ello el mandatario por culpa en el derecho clásico? Para algunos, la opinión es negativa, sospechándose que los textos del *Digesto* han sido manipulados por los bizantinos.

El problema estaría en tratar de comprender el caso del mandatario que no haya hecho nada para cumplir el mandato, lo cual no siempre sería por "dolo". Así, Ulpiano lo responsabiliza por su total inactividad (D.17.1.6.1) y habla de *culpa lata* (D.17.1.8.10) y de *dissoluta negligentia* (D.17.1.29 pr.), la cual es equiparable al dolo. Además, Cicerón (*pro Rose Amer.*, 39.111) nos dice que en el mandato no sólo se responde por dolo (*malitiosus*), sino también por demasiada negligencia (*negligentius*).

También en algunas constituciones se incluye la culpa: así, Diocleciano (C.4.35.11, año 293) exige una *exacta diligentia*; e incluso hace responder al mandatario de toda culpa (*omnis culpa*; C.4.35.13, año 294). Igualmente Constantino (C.4.35.21; del 313-15) tampoco exime al mandatario por culpa.

Se nota, por tanto, el fácil deslizamiento que se produjo del dolo a la negligencia grave (*culpa lata*), y finalmente a toda clase de culpa (Ulp., D.50.17.23: *dolus et culpa*), e incluso si el mandatario pierde el dinero entregado por el mandante, aun *sine culpa* (Afric., D.15.3.17 pr.). En términos generales podemos decir que el mandatario no responde por la falta de éxito en su gestión (así, te mandé comprar algo para mí y no lo conseguiste), pero sí por no haber obrado diligentemente para conseguirlo (Ulp., D.17.2.12.9; D.17.2.6.6).

La *actio mandati* arrastra con su condena la infamia (Gayo, 4.182; Inst., 4.16.2). Cicerón (*pro Rosc. Amer.*, 38.111) decía que "el juicio de mandato no resulta menos deshonroso (*minus turpe*) que el de *furtum*".

§ 443. *Excesos en el cumplimiento del mandato*. El mandatario debe cumplir regularmente las instrucciones dadas por el mandante (Paulo, D.17.1.5). ¿Qué es lo que ocurre si actúa en forma distinta o excediendo las órdenes impartidas? Aquí hay que distinguir:

a) Cuando el mandatario se aparta totalmente de lo encomendado. Así, te mandé comprar la casa de Seyo y compraste la casa de Mevio. No había mandato para tal cometido, por lo que el negocio queda para el mandatario, quien se responsabiliza por cualquier perjuicio ocasionado por dicho negocio (Paulo, D.17.1.5.1-2).

b) Cuando se apartó de las instrucciones respecto de un acto divisible; así, te pedí que salieras fiador por la suma de 100 y tú te comprometiste por 50. En este supuesto, quedo obligado como mandante, porque te había autorizado por una suma mayor; en consecuencia, no te has excedido. Pero, en el mismo ejemplo, si afianzaste una suma superior: así, 150, Juliano y la mayoría entienden que hay mandato hasta el monto ordenado (es decir, 100), pero no por el resto (Jul., D.17.1.33).

c) Cuando el mandatario se apartara de las instrucciones en un acto indivisible; así, te mando comprar una casa por 100.000 sesterces, podía suceder que tú la compraras por 150.000 o que lo hicieras por 90.000. En este último caso, no ocurre un "exceso", por lo que no hay dudas acerca de que existe el mandato, ya que quien fue autorizado por un precio determinado y logró comprar por uno menor, está evidentemente beneficiando al mandante (Gayo, 3.161; Inst., 3.26.8).

En cambio, en el caso primero (la has comprado por más), discutieron la dos escuelas: los sabiananos opinaban que no había mandato, mientras que los proculeyanos —opinión triunfante— decían que existía la *actio mandati contraria* hasta el monto autorizado (Gayo, 3.161; D.17.1.4; Inst., 3.26.8).

Por lo visto, se puede establecer la regla general de que si el mandatario excede las instrucciones dadas por el mandante, se considera que el mandatario "hace una cosa distinta", respecto de lo cual no se puede responsabilizar al mandante (Paulo, D.17.1.5 pr.), salvo hasta la medida del interés de éste en la ejecución del mandato (Gayo, 3.161; D.17.1.41).

§ 444. *Cesación del mandato*. A) Siendo el mandato un encargo basado en la *fides*, se ex-

tingue cuando una de las partes, antes de haberse realizado lo encomendado (*re integra*), desisten del contrato (*revocare* del mandante y *denuntiare* del mandatario); Gayo, 3.159; Inst., 3.26.9).

1. La revocación del mandante puede ocurrir en cualquier momento, pero sólo surte efectos a partir de la notificación del mandatario. Así, si te mandé que compraras un fundo, y luego revocando el mandato te escribí que no lo compraras, y tú ya lo habías hecho con anterioridad, te estaré obligado por la *actio mandati* (Paulo, D.17.1.15).

2. El mandatario también puede renunciar (Inst., 3.26.11), pero para quedar desligado debe ocurrir: (a) que renuncie cuando la ejecución del mandato pueda ser continuada por el mandante o por otro que éste mande, de manera normal y sin perjuicios (Paulo, D.17.1.22.11); (b) o que existan razones edmentes, por motivos graves, así una súbita enfermedad, o un viaje necesario, o por haberse generado una gran enemistad (Hermog. Paulo, D.17.1.23-25).

Igualmente, por el carácter personalísimo del mandato, si antes de cumplido el mandato una de las partes muere, ya sea el mandante o el mandatario, el mandato se disuelve. Pero, *utilitatis causa*, si el mandante falleció, e ignorándolo el mandatario cumpliera el mandato, éste tiene la *actio mandati* contra los herederos del mandante (Paulo, D.17.1.26 pr.; Gayo, 3.160; Inst., 3.26.10).

1. El mandato *post mortem* del mandatario (así, que se me mande hacer luego después de mi muerte) era inútil (Gayo, 3.158).

2. En cambio, se admite el mandato *post mortem* del mandante (es decir, para que sea cumplido después de la muerte del mandante). Era válido y debía ser cumplido respecto de su heredero. Así, "para que después de mi muerte se hiciera un monumento" (Ulp., D.17.1.13.17); o también "Te mando que después de mi muerte compres un fundo para mis herederos" (Gayo, D.17.1.3; o "Te mando manumitir el esclavo que te he dado después de mi muerte" (Gayo, D.17.1.27.1).

§ 445. *Mandato de prestar dinero* (*mandatum pecuniae credendae*).

Consiste precisamente en que el mandante encarga al mandatario prestar dinero, o abrir un crédito, a otra persona. Se lo usaba como una forma más cómoda de "fianza", de tal modo que si alguien quería afianzar una deuda, sin recurrir a las formas usuales de garantía (*sponsio**, *fidei-promissio** y luego la *fideiussio**) mandaba tomar el préstamo al mandatario asumiendo la responsabilidad en caso de que el deudor no pagara.

Ello podía tener utilidad en casos como los siguientes:

a) Necesitas dinero, se lo pides a Ticio. Pero él te exige un fiador. En lugar de recurrir a las figuras de fianza, le mando a Ticio que lo dé en mutuo. Al aceptar Ticio el mandato y otorgarte el préstamo, como acreedor tuyo te podrá demandar por la *condictio certae creditae pecuniae*, y si es satisfecho podrá accionar contra mí por la *actio mandati contraria* (Inst., 3.26.5).

b) Tú me debes 100. En lugar de pagarte directamente a tí, te mando que estipules con Ticio, que es deudor mío por 100, para que él como deudor "delegado" te pague.

Mediante esta *stipulatio* ambas obligaciones (la que yo tenía contigo y la que me debía Ticio) se extinguen por novación*. Pero ello no obstante, yo quedo obligado hacia tí por mi responsabilidad como mandante. Y tú tendrás oportunidad de cobrarle a Ticio por lo prometido en la *stipulatio*, pero también la *actio mandati contraria* contra mí, si Ticio no te paga (Inst., 3.26.2; Paulo, D.17.22.2; D.17.26.2; D.45.7).

c) Lo mismo ocurría si en un caso como el anterior, en el cual yo te debo 100 y Ticio me debe 100 a mí. En lugar de pagarte directamente, te mando que se lo reclames como "fiador" (*fideiussor*) en mi favor a Ticio, pero a mi cuenta y riesgo (Inst., 3.16.2). Tú lo podrás reclamar a Ticio, y si no te satisface podrás venir contra mí por la *actio mandati contraria*.

1. En el fondo, este *mandatum pecuniae credendae* cumple la función de una fianza por parte del mandante. Pero en el derecho clásico había diferencias con la *fideiussio*.

Por de pronto, el mandante (que aparece como deudor respecto del mandatario) obtenía una cierta ventaja al estar obligado el mandatario a accionar primero contra el deudor delegado, antes que contra él.

Además, este tipo de mandato no creaba solidaridad entre mandante y mandatario como ocurría con la *fideiussio* entre deudor y fiador. De este modo, en cualquiera de los casos que hemos visto, si simplemente se hubiera tratado de una fianza (*fideiussio*), el acreedor que demandaba al deudor principal agotaba la *actio* por los efectos de la *litis contestatio**, de tal modo que luego no podía volver a accionar contra el *fideiussor*. En cambio, si se trataba de esta especie de mandato, el mandatario contaba, en caso de no ser pagado, con la *actio mandati contraria* (Paulo, 2.17.16; D.17.1.32).

Pero, a su vez, los mandantes no podían aprovecharse de las excepciones que tuviera el deudor, como ocurría con los *fideiussores* (Javol., D.39.5.24). Y el *beneficium divisionis* en caso de pluralidad de *fideiussores*, aprovechaba sólo a éstos (Gayo, 3.121), y no a los mandantes.

2. Con Justiniano, el *mandatum pecuniae credendae* fue una figura de mandato especial y prácticamente se fusionó con la *fideiussio* a). Desapareció el efecto consuntivo de la *litis contestatio*, de tal modo

que se equipararon ambas figuras (C.8.41.28). b) Lo mismo el derecho de oponer excepciones, tanto para los fiadores como para los mandantes (C.4.30.12; Ulp., D.46.1.32 itp.). c) Se extiende a los mandantes de préstamo de dinero el *beneficium divisionis* (C.4.18.3; Pap., D.27.7.7 itp.). d) Finalmente, se concede tardíamente a ambos el "beneficio de excusión", para obligar al acreedor a demandar primero al deudor principal y luego al fiador o mandante de esta especie (Nov.4.1).

Los juristas modernos lo calificarán de *mandatum qualificatum*.

§ 446. *Gestión de negocio sin mandato* (*negotiorum gestio*). El mandato como contrato exige el consentimiento de las partes. Pero podía ocurrir que alguien, sin existir mandato se ocupase de los negocios de una persona ausente. De esta intervención (*negotiorum gestio* = gestión de negocios) nacía una acción, válida para una y otra parte: Bajo la forma de *actio negotiorum gestorum directa* la tenía el "dueño del negocio" (*dominus negotii*) contra el gestor para pedirle cuentas y obligarlo al traspaso de todo lo conseguido a propósito de su gestión, así como la indemnización por los perjuicios ocasionados por su intervención; y como *actio negotiorum gestorum contraria*, la que tenía el gestor contra el "dueño del negocio" para resarcirse de los gastos y daños sufridos en su gestión.

1. La *negotiorum gestio* es una creación típicamente romana, que no encontramos en otros pueblos de la Antigüedad. Es una aplicación de la *humanitas* romana, en virtud de la cual aquel que ayuda a los demás cuando éstos lo necesitan merece protección jurídica (Ulp., D.3.5.1; Inst., 3.27.1).

2. El caso básico de esta gestión sin mandato es el de la representación judicial de un ausente (caso del *procurator*, v. *supra*, § 113). Ello explica que en el Edicto Perpetuo, el tema de la *negotiorum gestio* aparezca ubicado en el tít. VIII que habla de los *cognitores* y *procuratores*, es decir, los representantes procesales.

3. Prontamente el pretor, ya en época republicana, concedió primero una *formula in factum* y luego también una *formula in ius* con la cláusula *ex fide bona* (EP, § 35). En principio era para el caso de la administración de bienes de un "ausente" (Ulp., D.3.5.1; Gayo, D.17.2), a la que se agregó la de una persona fallecida (Ulp., D.12.12(11) pr.-2).

4. Una acción *in factum* especial se concedía a aquel que había hecho gastos para el entierro de alguien extraño, llamada *actio funeraria* (Ulp., D.11.7.12.2 y ss.; D.14.6; EP, § 94) contra los herederos del difunto.

5. Las dificultades que surgen, porque lo poco que conocemos de la evolución de la *negotiorum ges-*

no es lo que luce en D.3.5 (C.2.18(19)), cuyos textos fueron muy trabajados por los compiladores. Uno de los datos más importantes es la ampliación en la fórmula, donde se hablaba de "negocios de un ausente", por "negocios de otro" (*alterius*; Ulp., D.3.5.3 pr.; Inst., 3.27.1).

§ 447. Para que se pueda dar la *negotiorum gestio* es necesario:

a) Que el gestor se haya ocupado de un negocio que fuera ajeno. El interés subjetivo de "querer hacerlo así", prácticamente hay que suponerlo desde el momento en que el gestor esté interviniendo en los negocios de otro. Precisamente de este actuar nace la obligación de que dicho gestor pudiera resarcirse de los dineros empleados. Esto entra dentro de la naturaleza primigenia de la "gestión de negocios", protegiendo a aquel que de algún modo enriqueció a otro. En el derecho justinianeo, en cambio, parece exigirse el elemento subjetivo por parte del gestor (*animus, contemplatio*) acerca de la intención de hacerse resarcir los gastos.

1. Todo esto despierta fuertes controversias acerca de la presencia de este elemento subjetivo (*animus aliena negotia gerendi*), por lo menos en el derecho clásico. Parecería que, pese a las dificultades de las fuentes, los clásicos insistieron más en el "elemento objetivo" (que se trate de un negocio ajeno). Pese a ello, la intención del gestor podía tener importancia en ciertos casos.

Así, por supuesto, si por error hubiera administrado bienes propios creyendo que eran ajenos, evidentemente no procede ninguna *actio* (Jul., D.3.5.6 4), lo cual se explica porque los bienes no son objetivamente ajenos. Pero si creyendo que mediaba un contrato de mandato, administré los bienes de otro, también se entiende que procede la *actio negotiorum gestorum* (Ulp., D.3.5.5 pr.).

Igualmente tiene importancia la voluntad de querer administrar los bienes ajenos, cuando ésta no estaba dirigida a crear una obligación para el "dueño del negocio". Así, en el caso de que el gestor hubiese, p.ej., prestado una fianza con ánimo de donación (Ulp., D.3.5.4); y también, si no ha hecho más que cumplir con un deber familiar, como p.ej., si dio alimentos a su sobrina (Modest., D.3.5.27.1). En estos casos no hay *negotiorum gestio*.

2. En el caso de la gestión realizada por alguien en contra de la voluntad de su dueño, hubo disputas entre los autores clásicos, puesta que algunos opinaban que al gestor le correspondía directamente la *actio negotiorum gestorum*; otros, como *actio utilis*, siempre en razón de los gastos que representaban una ventaja objetiva para el dueño. Otros, como Juliano, denegaban la *actio*. Justiniano (C.2.18(19).24), donde figuran estas opiniones, terminó decidiendo que el gestor carecía de acción, salvo que el dueño

"afectando doloso disimulo" le hubiera entonces prohibido hacer nada al gestor, para no pagarle.

4. El requisito de exigir la "intención" (*animus*) por parte del gestor, aparece en algunos textos (Alej. Severo, C.2.18.11 y ss.; *animus recipiendi*; Gordiano, C.1d.15). Y será subrayado por los compiladores bizantinos. Así, en Paulo (D.10.3.14.1 itpr.: "gestionar un negocio con el *animus* de obligarse respecto de alguno"). Y también en Juliano (D.3.5.6.3) a propósito de alguien que cuidó los negocios de otro pero no por consideración (*contemplatio*) a mí, sino por lucro suyo. De todos modos, si lo realizó para cometer depredaciones tendrá acción contra él, e igualmente, si no fuera con mala intención, tendrá dicho gestor acción contra mí, "por aquello en que me hice más rico". Se ve, por lo tanto, la relatividad del requisito bizantino, ya que acá no aparece el elemento subjetivo.

b) Igualmente, esa intervención en los negocios del ausente o del fallecido, debía ser realizada "útilmente" (*utiliter*). Este requisito, para los clásicos, era entendido como que la gestión debió haber sido realizada de manera razonable para favorecer al "dueño del negocio", sin intresar el resultado final del negocio, que puede no ser favorable para éste. Así, es "útil" la intervención del gestor que cuidó de una casa ajena, aunque ésta finalmente se haya incendiado, o curado a un esclavo ajeno, aun cuando luego éste se haya muerto (Ulp., D.3.5.10(9).1). Sólo se requiere que haya comenzado siendo "útil" (*utiliter coeptum*; Ulp., D.3.5.10(9).1, *in fine*).

§ 448. Acciones. En la época clásica aparece la *actio negotiorum gestorum*, con dos fórmulas: la *actio n.g. directa* y la *actio n.g. contraria*, nacidas para el caso de la administración de negocios de un ausente o de un fallecido. Ambas fueron al principio *in factum*, pero luego *in ius* y con la cláusula *ex fide bona* (EP, § 35).

A) El "dueño del negocio" tiene la *actio negotiorum gestorum directa* para obligar al gestor a rendir cuentas de su actuación, y restituírle todo lo que hubiese recibido por la gestión (Gayo, D.3.5.2; Inst., 3.27.1).

1. En principio, el gestor de negocios responde por el dolo cometido en su gestión (Ulp., D.3.5.3.3; Lab. Ulp., D.1d.3.9), pero también por la culpa (Pomp., D.3.5.11; Pap., D.3.5.31 pr.; Paulo, D.47.2.54.3), debiendo actuar con total diligencia (*exactissima diligentia*; Inst., 3.27.1). Incluso, por el caso fortuito cuando el gestor ha realizado actos riesgosos que el "dueño del negocio" no estaba acostumbrado a hacer (Proc. Pomp., D.3.5.11(10)).

2. Podía ocurrir que luego de comenzada la gestión, el "dueño del negocio" la hubiera ratificado.

¿Continúa como tal o se transforma en mandato? Los textos son ambiguos. Según Ulpiano (D.50.17.50), la ratificación de lo hecho por el gestor, lo obliga al "dueño del negocio" por la *actio mandati*, mientras que Scévola establece que continúa, gozando de la *actio neg. gestorum* (D.3.5.9(10)). El interés que tiene la ratificación es que el "dueño del negocio" está reconociendo su utilidad. Incluso Marcelo nos dice que si alguien comenzó a ser gestor, y luego se le dio mandato, son válidas ambas acciones (Marcelo-Ulp., D.3.5.3.11).

B) A su vez, el gestor del negocio puede reclamar por la *act. neg. gest. contraria*, por gastos realizados, siempre y cuando que la gestión haya sido "útil", aunque no haya resultado totalmente eficaz (Ulp., D.3.5.9(10).1). En todo caso puede reclamar hasta el monto de la utilidad que haya proporcionado al "dueño del negocio" (Jul., D.3.5.6.3; Gayo, D.1d.2: "si administró útilmente"; Pomp., D.1d.11(10)).

§ 449. En la época clásica, la "gestión de negocios" es concebida como una forma "contractual", aunque no haya consentimiento. Así, Gayo (D.3.5.2) nos dice que en este caso la acción nace "de una u otra parte" (*ultra citroque nascitur actio*), con lo que reconoce la reciprocidad propia de los contratos.

Justiniano, por la falta de consentimiento, la considerará como un *quasi ex contractu* (Inst.,

3.27.1), extendiendo su aplicación, reducida en la época clásica al caso del ausente y del fallecido, a todo caso de "gestión de los bienes de otro" (*alterius*; Ulp., D.3.5.3 pr. itpr.). De este modo, la gestión de negocios tiene un carácter muy general, aplicándola a la administración de patrimonios ajenos.

1. De este modo, queda aproximada al caso de la tutela (Inst., 3.27.2), al igual que para las gestiones de una comunidad incidental de copropiedad sobre una cosa sin haber sociedad (Inst., 3.27.3), así como también entre coherederos (Inst., 3.27.4).

En la época clásica existían casos de acción directa y de "acción útil", los cuales desaparecen "como sutilezas" del procedimiento formulario, que nada tienen que hacer con el procedimiento cognitorio *extra ordinem* (Paulo; D.3.5.46.1 itpr.). En tal sentido, cabe conjeturar que al *curator furiosus* o *prodigi*, se le debía conceder (salvo que actuara por un pupilo ausente) una *actio utilis*. Rastros de esto todavía se conservan en Justiniano, que concede al *curator*, en forma directa las *utiles curationis causa actiones* (D.27.3). En cambio, las relaciones entre tutor y pupilo, al igual que en la época clásica se conceden la *actio tutelae directa* y *contraria*.

En caso de la comunidad incidental, aproximada al condominio, las cuestiones sobre gestiones realizadas se ven en la *actio communi dividundo*; y en el caso de los coherederos por la *actio familiae erciscundae* (Inst., 3.27.3-4).

CAPÍTULO 8 LAS DONACIONES

§ 450. *Concepto*. Se habla de donación (*donatio*) cuando una persona (donante), sin que nadie lo obligue le atribuye a otra (*donatario*) de manera gratuita, ya la propiedad de una cosa u otro beneficio económico.

A) En un principio, la donación consistió en transferir una cosa a otro, en forma gratuita, haciendo que la adquiriera en propiedad, por medio de una *mancipatio*, si se trataba de una *res Mancipi* o de una *traditio*, si era una *res nec Mancipi*.

1. Por ello recuerda Paulo que "donación fue llamada así de «don» (*dono*), como cosa dada en don" (D.39.6.35.1; cf. FV, 275: *dono res data est* (el "don" es la cosa dada); FV, 281; 283). Acá la expresión *donare* (v. también en FV, 275; 281; 283) tiene un sentido muy riguroso en lo jurídico. *Dare* es expresión de que la cosa es transferida en propiedad. Y *dono*, que lo es en forma gratuita, por pura liberalidad.

B) Pero prontamente se llega a la noción de la donación como *donationis causa* (causa de donación), con lo que se amplía el campo de aplicación, puesto que aparte de transferir gratuitamente la propiedad, involucra todo acto que signifique un enriquecimiento gratuito para el donatario a expensas del donante que de algún modo se empobrece. Así, por *donationis causa* se puede perdonar una deuda no cobrándotela (Ulp., D.39.5.17); o constituirte gratuitamente una servidumbre a tu favor, o renunciar a la servidumbre que tenía sobre tu fundo (Pap., D.8.4.17).

1. Lo que hay que tener en claro es que en el derecho clásico la donación no es propiamente un negocio típico, ni menos aún un contrato. Es simplemente una "causa lucrativa" (llamada así porque enriquece a alguien), a la que se denomina *causa donationis*. En tal sentido acompaña a un acto jurídico cuando por medio de éste se quería beneficiar gratuitamente a otro; así, una *mancipatio* o una *traditio*; o una *stipulatio* o una *acceptilatio*.

2. La *donationis causa* es una causa en sí misma. Quien la realiza tiene sus "motivos" (generosidad, benevolencia, ganas de ayudar a otro, pero también ánimo de captarse, su adhesión para que haga algo; así, un político para que voten por él etc.). Pero éstos

funcionan siempre como "motivos" de la donación, pero no como su "causa jurídica".

3. La *donationis causa* funciona siempre como gratuita, estando ausente "jurídicamente" la contraprestación. Así, lo dice Papiniano: "Se entiende como donado lo que se concede sin que el *ius* obligue a hacerlo" (D.39.5.29 pr., D.50.17.82). De aquí nace la cierta desconfianza o suspicacia con que se ha mirado siempre a las donaciones, puesto que se aparta de lo que sucedía normalmente en los actos onerosos, donde el detrimento o el enriquecimiento tenían siempre una contrapartida.

Una prueba de ello es que los juristas clásicos elaboran sus dichos sobre la base de los comentarios efectuados en torno de la *lex Cincia*, que limita ostensiblemente los negocios por causa de donación, y de la prohibición de donaciones entre cónyuges (v. *infra*, § 542).

4. La *donationis causa* involucra siempre, por un lado, un beneficio lucrativo para el donatario y un desmedro o empobrecimiento para el donante. Por ello, a pesar de que también son "gratuitos", ni el comodato, ni el depósito ni el mandato, no son donaciones.

Aquí es útil establecer una diferencia entre "actos gratuitos" y "actos lucrativos". En estos últimos, tal como el caso de la donación, se logra una adquisición definitiva de un bien económico (Gayo, D.50.17.51). En cambio, en los primeros, los que prestan el servicio gratuito no logran una adquisición patrimonial definitiva, ni tampoco la otra parte sufre un desmedro o un empobrecimiento.

I. DONACIONES ENTRE VIVOS

§ 451. *Derecho clásico*: A) Tal como dijimos la donación no es un contrato, ni una obligación, sino directamente el negocio por el que normalmente se trasladaba a otro la propiedad (*datio*), por razón de liberalidad (*donationis causa*). Así, por la *mancipatio* si se trataba de *res Mancipi*, o la *traditio* si era una *res nec Mancipi*.

Por ello, la mera convención o pacto por el cual una persona promete donar algo a otra no produce ningún efecto para ninguna de las partes. Era simplemente la manifestación de una voluntad de querer donar, pero sin consecuencias prácticas (FV, 268a; 268 y 263). Si se que-

ría realmente donar, era necesario operar el acto jurídico pertinente: así, la *mancipatio*, o la *in iure cessio* o la *traditio*, y también prometerla por una *stipulatio*, o si se trataba de la liberación de un deudor, por una *acceptilatio*, que extinguía la obligación *ipsa iure* (C.8.44.2) o por medio de un *pactum de non petendo*, que daba al deudor la defensa de la *exceptio pacti conventi* (D.20.6.1.1).

1. Para que sea válida la donación es necesario que quien quiere hacer la liberalidad tenga, empleando el lenguaje de los bizantinos, el *animus donandi*, es decir que la está haciendo por causa de donación, sin estar obligado por derecho.

La expresión clásica es *donationis causa*, que es bien objetiva. En cambio, *animus donandi*, que señala un aspecto "subjetivo" distinto, parece más bien bizantina.

2. Normalmente, el acto que involucra una donación va acompañado de la aceptación del beneficiario. Así, no se podría concebir una *mancipatio* o una *traditio* sin esa aceptación. Pero no siempre ocurre de este modo. Así, p.ej., si alguien paga la deuda de otro *donationis causa* sin saberlo el deudor, o si un acreedor perdona la obligación del fiador también *donationis causa*, sin saberlo el deudor principal, hay sin embargo donación (Venuleyo, D.42.8.25). Pero el beneficiario puede rechazar la donación, pues nadie está obligado a recibir una donación que no quiere (Paulo, D.50.17.69; Ulp., D.39.5.19.2).

B) En los casos en que la donación involucre que el donatario se vuelva propietario, se pueden presentar problemas para el caso de que se haya dispuesto que la donación se haya hecho en forma condicional.

Juliano (D.29.5.1 pr.) analiza estos tres casos:

a) El primero, cuando el donante da de manera que la cosa pertenezca inmediatamente al donatario, y que de ningún modo vuelva a él. Juliano dice que ésta es propiamente la que se llama donación. En tal sentido la donación es irrevocable.

b) El segundo, cuando el donante da de manera que la cosa no sea del beneficiario sino después que se haya cumplido un cierto acontecimiento (condición). En realidad, no hay acá todavía en forma propia una donación, por cuanto ésta está dependiendo del acaecimiento o no de la condición. De cumplirse ésta, se perfecciona la condición.

c) El tercero, cuando el donante da la cosa para que el beneficiario se haga propietario inmediatamente, pero con la condición de que suceda o no suceda determinado acontecimiento, podrá reclamar su restitución. Así, si el esposo (no el cónyuge, sino el "prometido") da algo

a la esposa, pero que la misma se resolverá si no se producen las nupcias (Jul., D.10.1.1).

1. Hoy día se diría que en el segundo caso la donación está sujeta a una "condición suspensiva", y en el tercero, a una "condición resolutoria", de tal modo que la propiedad dada quedaba suspensivamente adquirida o resuelta.

Los romanos decían que en el segundo caso la donación era una "donación suspensiva", mientras que en el tercero, como ignoraban la existencia de "condición resolutoria", hablaban de que la donación era en principio inmediata, pero estaba cargada de efectos resolutorios, subordinados a que no se cumpliera una condición suspensiva.

2. Hay además otro aspecto: el *dominium* romano no podía ser afectado en el tiempo por una cláusula resolutoria, puesto que existe o no, pero no limitado en el tiempo (Dioc. Maxim., FV, 283).

Por tanto, en este caso de donación suspensivamente condicionada a un efecto resolutorio, si bien la donación era resuelta, el adquirente quedaba como propietario. El donante tenía la posibilidad de obligarlo a restituir el dominio por medio de la *condictio* (Alej. Sev., C.4.6.2, año 228; Valer. Galieno, C.8.55.1 it., in fine).

Más tarde se admitió, aparte de la *condictio*, una *vindicatio utilis*. Esta figura en el texto citado del Código (8.55(54).1), pero resulta sumamente sospechoso, al igual que el de Diocleciano (C.8.55(54).2, comparado con su auténtico de FV, 283), ya que serán los bizantinos y Justiniano quienes se manifestarán proclives a admitir la propiedad revocable.

§ 452. Limitaciones a las donaciones: *lex Cincia*. Esta ley, en realidad un plebiscito del año 204 a.C., estableció la prohibición de donaciones que superaran un determinado monto (*modus legitimus*) —desconocido para nosotros—, salvo que se tratara de parientes (*personae exceptae*). Los motivos de esta ley no aparecen muy claros, pero están vinculados con la necesidad de evitar los regalos y donaciones excesivas.

1. La ley *Cincia* tenía dos capítulos. En el cap. I se prohibía a los oradores que defendían a otros en un juicio, recibir regalos. Así, Tácito (Ann., 11.5) recuerda el caso de un caballero romano, Samius, quien se atravesó con su espada en la casa de su defensor que lo había traicionado en el juicio, luego de haberle pagado 400.000 sesteracios, lo que provocó indignación en Roma.

Esta prohibición de la ley fue mal observada en la práctica. Posiblemente se le concediera al donante una acción por el *simpulum*. Augusto estableció por un s.c. una pena del *quadruplum* contra el orator contraveniente (Dion Cassio, 54.18). Claudio estableció

un monto lícito (10.000 sesteracios; Tác., 11.7). Finalmente, habiéndose admitido que los honorarios podían ser reclamados *extra ordinem*, esta parte de la ley decayó totalmente.

2. En cuanto al cap. II sobre las donaciones, el texto principal es el capítulo *ad legem Cinciam* de los *Fragmenta Vaticana*. Pese a la extensión (§§ 260-316), el tema del *quantum* del monto permitido no está revelado.

En cuanto a las *personae exceptae*, una lista, puede ser incompleta, menciona a los cognados hasta el 5° grado, y el *sobrino* y la *sobrina* en el 6° grado, los aïnes, tutores y pupilos, esclavos y libertos (Paulo, FV, 298-309; Paulo, 5.11.6).

A) La ley *Cincia* no preveía ninguna sanción, ni penal para el infractor, ni tampoco la nulidad de la donación; era una *lex imperfecta*. Sin embargo, el pretor, para hacerla cumplir otorgó una excepción (*exceptio legis Cinciae*), siempre y cuando que el acto no se hubiera perfeccionado.

1. Se entendía que la donación quedaba perfeccionada (*donatio perfecta*) si se había logrado transmitir la propiedad. Así, si se había realizado la *mancipatio* respecto de una *res mancipi* habiéndose entregado la cosa, o la *traditio* respecto de una *res nec mancipi* (Pap., FV, 264; Paulo, FV, 310-311). En este caso, la donación, pese a estar prohibida, era inextinguible.

2. En cambio, veamos estos otros casos:

a) Ticio ha hecho una donación prohibida a Mevio respecto de una *res mancipi*. Ha *mancipado* la cosa, pero aún no se la entregó. Si Mevio se la reclama por la *rei vindicatio*, Ticio le puede oponer la *exceptio legis Cinciae* (Paulo, FV, 311).

b) Ticio ha hecho una donación prohibida a Mevio, habiéndole entregado una *res mancipi* pero sin hacer la *mancipatio*. Ticio se la puede reclamar por la *rei vindicatio*, puesto que es aún el propietario. Si Mevio le opone la *exceptio rei donatae et traditae* (semejante a la *exc. rei venatae et traditae*), Ticio le puede replicar con la *replicatio legis Cinciae* (Dioc., FV, 312).

c) Ticio prometió por una *stipulatio* hacer una donación prohibida a Mevio. Si éste le reclamara por la *condictio*, Ticio le puede oponer la *exceptio legis Cinciae* (Ulp., FV, 266; Paulo, FV, 311).

Ulpiano (FV, 266) nos dice que incluso habiendo una suma prometida, en contra de la ley *Cincia*, el donante podía repetir lo pagado con exceso, es decir, más allá del monto permitido como posible de donación por la ley *Cincia*, y si el donatario le oponía la *exceptio leg. Cinciae*, el donante le podía replicar por la *replicatio doli*.

B) En la última época clásica se determinó que si el donante persistía en su donación, prohi-

bida por la ley aunque todavía no perfeccionada, hasta su muerte, conforme a la regla "*Cincia morte removeatur*" (Pap., FV, 259, in fine: "con la muerte se deja sin efecto la ley *Cincia*"), la donación se perfeccionaba, de tal modo que los herederos no podían ante el reclamo del donatario oponer la *exceptio legis Cinciae*, puesto que serían rechazados por la *replicatio doli* (Pap., FV, 259; Ulp., FV, 266; Dioc., FV, 312).

Ya en la época posclásica esta ley cayó en desuso, quedando abolida en el año 428 (CTh., 8.12.4).

§ 453. Reformas posteriores. A) Según una constitución de Constantino del año 316 (FV, 249; CTh., 8.12.1 = C.8.54(53).25), para prevenir las dificultades de probar una donación, subordinó la perfección de ella, a la que hizo un negocio típico, al cumplimiento de estos tres requisitos: a) la redacción de un escrito indicando las partes intervinientes, así como la cosa que se donaba; b) la tradición efectiva de la cosa donada ante un gran número de testigos; y c) la testificación del documento en los registros de los magistrados locales (*insinuatio*). Cumplidos estos requisitos la propiedad es del donatario.

1. El uso de la donación por documento (*professio apud actum*) era usado mucho tiempo antes (Alej. Sev., FV, 266a; Dioc., FV, 297). La *insinuatio* parece haber sido requisito obligatorio establecido por Constantino Cloro, padre de Constantino (CTh., 3.5.1).

2. La *insinuatio* tenía una doble finalidad: por un lado, en interés del donante y su familia, ya que es más difícil donar algo más o menos ligeramente, que proceder a su forma escrita y posterior registro. Y por el otro, en interés de los terceros, ya que la publicidad pone en guardia contra los peligros de una donación clandestina (FV, 249).

B) Justiniano tendió a una fusión entre las soluciones clásicas y las posclásicas.

a) Por un lado, rescata el sentido de la donación como "causa de adquisición del dominio", ubicándola en las Institutas luego de hablar de las "usucapiones y de las posesiones *longi temporis*" (Inst., 2.7 pr. y 2), separándola de la transmisión de la propiedad, manteniendo la distinción entre "título" (*donatio*) y "modo" (*traditio*).

b) Pero eleva la promesa de donación a la categoría de "pacto legítimo" sancionado por la ley. De este modo, sin necesidad de recurrir a la *stipulatio* como en la época clásica, ahora es un negocio típico que genera la *actio ex lege* para su cumplimiento (C.8.54 (53).35.5, año 530; 36.3). Incluso, hasta llega a hablar de *contractus donationum* (C.4.21.17 pr.), si bien no se

atrevió a hacerlo figurar en la lista oficial de los contratos.

1. En principio, el pacto de donación es de carácter consensual pudiéndose perfeccionar por escrito, o sin escrito. Desde que se ha manifestado así la voluntad del donante, nace para éste la obligación de hacer la *traditio* de la cosa (Inst., 2.7.2; C.8. 54 (53).35, año 530). Como lo dijimos, el donatario tiene la *condictio ex lege* (C.8.54(53).35.5, año 530).

2. Se suele mencionar como antecedente clásico una regla establecida por Antonino Pío, según la cual las donaciones entre ascendientes y descendientes (*inter parentes et liberos*), exceptuadas de la ley *Cincia*, se podían realizar mediante la sola voluntad del donante, quizá expresada en un documento, sin necesidad de la *mancipatio* o de la *traditio* (CTh, 8.12.4). Pero resulta muy dudoso que Antonino Pío haya querido constituir un "pacto de donación" para este caso. Más bien se trataba de evitar investigaciones indiscretas entre estos familiares (*scrupulosae inquisitiones*, FV, 314). Otros textos de los *Fragmenta Vaticana* están en contra de este pretenso "pacto de donación" (263; 293; 297).

c) Por otro lado, exige la *insinuatio* de las donaciones, pero sólo si superan un determinado monto (primero era de 300 sólidos de oro; C.8.54(53).34 pr.; y luego de 500 sólidos (C., id. 36.3, año 531). Están exentas de la insinuación las donaciones hechas al emperador o por el emperador, el rescate de cautivos, las destinadas a obras pías, etc. (C., id.34.36; C.5.12.31).

3. La donación no "insinuada" es nula, pero sólo por el monto que excede los 500 sólidos (C., id. 34.1). Si la cosa donada no puede ser dividida sin inconvenientes, por esta nulidad en el exceso se formaría, una *communio* entre el donante y quien aceptó la liberalidad.

Así, supongamos que se donó un fundo cuyo valor era de 1.500 sólidos: la comunidad estaría formada por el donante por 1.000 y por el beneficiario de la donación por 500. Se le ofrece al de la mayor parte conservar el fundo pagando al otro la suma menor. Si no lo quiere hacer, entonces se le ofrece análoga posibilidad al de la suma menor (C., id.34.2).

Si el donante ha efectuado sucesivas liberalidades, hay que considerar si cada una por separado no supera el monto de los 500 sólidos para la *insinuatio*. No corresponde hacer la suma de todas ellas (C., id.3).

§ 454. *Revocación de las donaciones.* En principio toda donación *inter vivos* (distinto es el régimen para las *mortis causa*) es definitiva. Por tanto, no cabe la revocación por parte del donante. Ello ocurre así, mientras a) no se trate de una donación *sub condicione*, como p.ej., cuando se donaba a propósito de nupcias ("Te doy

esta cosa por tu próximo casamiento con Julia"), que luego no se realizaban (Jul., D.8.5.1.1); b) en un caso análogo, no se cumpla el cargo en la donatio *sub modo*, que veremos luego; y por supuesto, siempre que procesalmente se pudiera hacerlo, para las donaciones prohibidas por la ley *Cincia*.

Pero este principio genérico de la "irrevocabilidad" irá conociendo excepciones:

A) Por causa de *ingratitude*. El primer caso surgirá, aproximadamente en el siglo III d.C., a propósito de la donación que hiciera un patrono a su liberto. Si éste realizaba un acto de ingratitude, el patrono podía revocarle la donación efectuada (Filipo, C.8.56(55).1, año 249; FV, 272).

Constantino extenderá esta posibilidad al padre en casos determinados de ingratitude de sus hijos (FV, 248). Constantino y Clemente le concederán la misma posibilidad también a la madre respecto de ingratitude de los hijos (C.8.56(55).7; año 349). Y Theodosio y Valentiniano extenderán el mismo derecho respecto de las hechas entre ascendiente y descendiente (C.8.56(55).9).

Finalmente, Justiniano establecerá la posibilidad de revocar todas las donaciones por causas taxativamente determinadas de ingratitude: injurias graves, o "ponga en él (el donante) sus manos implas, o con insidias grandes le provoque un daño patrimonial, o haya atentado a la vida del donante"; las causales de ingratitude debían quedar perfectamente probadas (C.8.56(55).10; año 530).

La posibilidad de revocar sólo la tiene el donante, por medio de la *condictio ex lege*, pero si éste soportó las afrentas y no hizo nada, sus herederos carecen de derecho para hacerlo (C., ibid.).

B) También por una constitución de Constantino y Constante, se permite al patrono que había donado todos sus bienes o una parte de ellos, sin tener hijos en el momento de la donación, y luego los tuviera, que pudiera revocarla (C.8.56(55).8, año 355).

II. FIGURAS ESPECIALES DE DONACIÓN

§ 455. I. *Donación sujeta a una carga* (donatio *sub modo*). No obstante su carácter gratuito, la donación puede estar acompañada de una carga (*modus*), establecida por pacto no formal, que debía cumplir el beneficiario. Así, A da la propiedad de una casa *donationis causa* a B, pero le impone la carga de ceder en forma vitalicia una habitación al donante o a un tercero. Esta carga no suspende los efectos del acto, como ocurre en la condición, ni tampoco significa una contraprestación.

En el derecho clásico, el donante (así como también el beneficiario de la carga si era un tercero) no podía exigir el cumplimiento de la carga, salvo que hubiere mediado una *stipulatio*, o un *pactum fiduciae*, acompañando al acto de la *mancipatio*.

Sin embargo, en el derecho clásico tardío se le concede al donante, aun sin haber mediado una *stipulatio*, una *condictio* (*ob causam*) para resolver la donación (por haberse ido contra la *fides* de lo pactado); Alej. Sev., C.4.6.2; Diocl., FV, 286.

1 En este último texto se menciona el caso de una donatio *sub modo*: Te doy esta casa como donada, pero luego de cierto tiempo se la tendrás que dar a Ticio. E indica que a éste, *benigna iuris interpretatione* por constituciones imperiales se le concede una *actio utilis*.

En la época de Justiniano, la donatio *sub modo* pasa a configurarse como un contrato innominado (del tipo *do ut facias*. El donante podía: a) reclamar el cumplimiento del *modus* por la *actio praescriptis verbis* (C.8.54 (53).9 itp.), o b) recobrar la cosa si el *modus* no se cumplía, por medio de una *condictio causa data causa non secuta* (C.4.6.2). Si el beneficiario del *modus* era un tercero contaba con una *actio utilis* (C.8.54(55).3.1).

§ 456. II. *Donaciones mortis causa*. Se trata de "donaciones por causa de muerte". Así, cuando alguien teme una muerte inminente, dona p.ej., un fundo para cuando efectivamente muera. De este modo, si el donante ha logrado salvar el peligro de muerte, o también si el beneficiario ha premuerto en relación a él, la donación cae por haber fallado la causa.

1. Según explica Paulo (D.39.6.35.4), podía ocurrir, ya que el donante se encontraba en el momento de hacer la donación ante el temor de sufrir una muerte presente o futura, pero también, sin sospecha de peligro alguno para su vida, estando bueno y sano, pero teniendo el pensamiento puesto en que la muerte de todos los humanos es la muerte (*sola cogitatione mortalitatis*; cfr. Jul.-Ulp., D.39.6.2).

2. Se explicaba esto diciendo que en esta clase de donación, el donante quiere tener más bien la cosa para sí antes que para el donatario; y a su vez, que la tenga éste antes que el heredero (Marciano, D.39.6.1 pr.).

3. También la donación podía quedar subordinada a la muerte de una tercera persona. Así un *pater* temiendo la muerte de su *filius* o de su hermano le hiciera donación a Mevio con la condición de que si convalciera uno de aquéllos se le devolviera a él la cosa, y si hubiera fallecido, permanezca en poder de Mevio (Jul., D.39.6.18 pr.; Ulp., D. id.11).

4. Por *benigna interpretatio*, la donación de vestidos y otras cosas "que yo tuviera el día de mi muerte" a un liberto, se la consideró válida como *mortis causa* (Ulp., D.39.15.16).

A) La donación *mortis causa* podía estar subordinada a la muerte de dos maneras distintas.

Así, entregando la cosa donada, pero de tal modo que el beneficiario no se hiciera propietario de ella sino luego de la muerte del donante (Ulp., D.39.6.2; D. id. 29; Marcelo, D. 40.1.15). Se trataría de una condición puramente suspensiva, de tal modo que si ocurría la muerte, la propiedad se adquiría directamente (Marcelo, D.40.1.15). Si no ocurría o premoría el beneficiario, el donante puede ejercer la *rei vindicatio*, puesto que la cosa no ha dejado de ser suya (Juliano-Ulp., D.39.6.2, *in fine*).

Y también transfiriendo directamente la propiedad de la cosa donada, pero con la condición de que le será devuelta si no ocurre la muerte, o si premuere el beneficiario (Ulp., D.39.6.2; D. id.29). Acá estamos en presencia también de una condición suspensiva, pero con efectos resolutorios. El donante puede demandar la devolución de la cosa por la *condictio* (*ob causam; ob rem datam*); ocurre acá lo mismo que habíamos visto en las donaciones *inter vivos* (v. *supra*, § 451.B; Jul., D.39.6.13 y 19; Afric., D. id.23; Marciano, D. id.26; Paulo, D. id.35.3; Ulp., D. id.37.1).

B) La donación *mortis causa* se consideró que era perfecta e irrevocable por la ocurrencia de la muerte. A partir de la época posclásica, criterio que mantiene Justiniano, se la consideró revocable por el propio donante en vida (Paulo, 3.7.2; Inst., 2.7.1).

1. Así, se consideró que la donación se mantenía si el donante se mantuvo perseverando en su voluntad de donar (Marcelo, D.40.1.15 itp.). Esta perseverancia de voluntad era supuesta mientras el donante no expresara una voluntad contraria (Marcelo, D. id. id.). Pero el cambio de intención provocaba la autorización al donante de pedir la devolución de la cosa (Jul., D.39.6.13.1; Ulp., D. id.30 itps.), aun en caso de duda acerca de si el donante mejoraba o no de salud (Jul., D.39.6.16).

2. Al igual que para las donaciones *inter vivos*, Justiniano le otorga no solamente la *condictio* para la devolución de la cosa, sino directamente una *rei vindicatio utilis* (Ulp., D.39.6.29-30 itps.), fiel al principio bizantino de que podía existir una propiedad "revocable".

C) Esta clase de donaciones tenía la ventaja de poder disponer cosas para después de la muerte, evitando ciertos inconvenientes que podía tener hacerlo por testamento (institución de heredero o legado). Pero ya desde la época clá-

sica no dejó de sorprender a los juristas la semejanza que, por lo menos desde el punto de vista económico, tenían las donaciones *mortis causa* con los legados.

1. Sin embargo, mantenían diferencias importantes:

a) La donación *mortis causa* estaba sometida sólo a la condición de la muerte del donante; en cambio, el legado estaba siempre dependiendo de la aceptación de la herencia, por lo menos para el caso del heredero "extraño";

b) Los legados podían quedar ineficaces, alcanzados por la *querella inofficiosa testamenti*; en cambio, las donaciones *mortis causa* no se veían afectadas (Paulo, D.34.9.5.17).

2. En cambio, había aproximaciones importantes:

a) Las leyes *Furia* y *Vocconia* eran aplicables a los legados y a las donaciones *mortis causa* (Gayo, 2.225.226; 4.23).

b) Las prohibiciones de las leyes caducarias de Augusto fueron extendidas, por un s.c. a las donaciones *mortis causa* (Paulo, D.39.6.35 pr.).

c) Por una constitución de Septimio Severo, el heredero podía deducir las donaciones *mortis causa* para el cómputo de la *quarta pars* de la *lex Falcidia* (C.8.57.2.2; C.6.50.5).

3. A diferencia de las donaciones *inter vivos*, no se aplica a las *mortis causa* la ley *Cincia*.

D) Finalmente Justiniano, por una constitución especial (C.8.57.4, año 530), termina por asimilar las donaciones *mortis causa* a los legados, "surtiendo todos los efectos que tienen (éstos), y no se entienda que en alguna cosa es diferente de ellos".

1. En cuanto a la forma, las donaciones *mortis causa* podían ser hechas por escrito o sin documento alguno, pero siempre debe ocurrir en presencia de cinco testigos, sin necesidad de ninguna *insinuatio*, cualquiera que fuera su monto, a diferencia de lo que ocurría en las donaciones *inter vivos*.

2. Si la cosa había sido ya *traditida*, producida la muerte del donante, el beneficiario adquiere la propiedad. Si la *traditio* no había sucedido, había que pedirle al heredero, como se hacía para los legados, que en esta época no tienen diferenciación en clases.

3. En el texto de Institutas (2.7.1), Justiniano pese a lo rotundo de lo afirmado en su constitución, habla de que las donaciones por causa de muerte sean contadas "casi en todo" en el número de los legados, sin indicar las diferencias a que se refiere.

E) La denominación de *mortis causa capiones* (adquisiciones *mortis causa*) resulta en principio muy amplia y abarca todo aquello que se adquiere

re a título hereditario, o por legado, o por fideicomiso, y también por una donación *mortis causa*.

Pero, con un sentido más restringido, sirve para designar todo aquello que se adquiere por causa de herencia que no esté comprendido en los supuestos ya mencionados "que tienen nombre propio". Así, sería el caso de lo que el esclavo manumitido por testamento, o el legatario queda obligado a pagar al heredero para cumplir la condición que le fue impuesta por el testador (Ulp., D.39.6.8 pr.; Gayo, D.íd. 31 pr. 2; Marcelo, D.íd.38). Uno de los efectos principales es lo ingresado por estas *capiones mortis causa* no se computa a los efectos de la *quarta pars* de la *lex Falcidia* (Gayo, D.35.2.76(75) pr.).

§ 457. III. *Donaciones nupciales*. Nos remitimos a lo tratado en el régimen de bienes en el matrimonio (v. *infra*, § 543).

§ 458. IV. *Otras liberalidades*. Hay ciertos casos de liberalidades prometidas por una persona, que no son propiamente donaciones.

a) La principal es la *pollicitatio*, que consiste en la promesa efectuada por alguien a la *res publica*, de hacer una obra, o de que dará dinero, en ocasión de habérsele conferido un cargo (*honor*), o que se le conferirá, promesa que podrá dar lugar a exigir lo prometido por medio de un procedimiento *extra ordinem*.

1. Cuando la *pollicitatio* era por estos motivos (*ob honorem*; para los justinianos *ob iustam causam*), el promitente quedará obligado a cumplirla (Ulp., D.50.12.1.1; D., íd. 3 pr.).

En cambio, tratándose de una *pollicitatio* por otra causa cualquiera (*non ob honorem*; para los justinianos *sine causa*, o *non ex causa*), sólo es obligatoria si hubo principio de cumplimiento, es decir, p.ej., si se comenzó la obra (Ulp., D.íd.1.2-4; D.50.12.3).

2. Para los bizantinos, la *pollicitatio* quedará incluida entre las donaciones, aproximándola a la *promissio donationis causa*, estableciendo la distinción entre las prometidas *ob causam iustam* (obligatorias) y *non ob iustam causam* (en principio no obligatorias, salvo principio de ejecución) (Ulp., D.39.5.19 pr.).

b) El *votum* es la promesa que se hace a la divinidad. En principio sólo tiene una sanción sacral, pero se lo terminó considerándolo obligatorio, asimilándolo a la *pollicitatio* (Ulp., D.50.12.2).

c) También entran como liberalidad ciertos casos de "recompensa" por devolución de una cosa perdida o hurtada (así, inscripciones respecto de una urna perdida en una taberna, y respecto de un esclavo fugitivo; Bruns, n° 159.1-2; Girard, *Textes*, p.864 1-2).

CAPÍTULO 9

EFFECTOS Y EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

§ 459. *Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones*. La obligación no es una situación permanente, como lo puede ser el dominio o cualquiera de los otros *iura in re aliena*. Al contrario, la obligación es siempre una situación temporal, que de alguna manera debe concluir. Puede suceder:

a) Que la obligación se cumpla, esto es, que la prestación debida por el deudor al acreedor sea satisfecha. Con ello, la obligación, en principio se extingue, ya en forma plena (*ipso iure*) o dando la posibilidad de una *exceptio*. Igualmente, la obligación puede quedar extinguida por otros modos que no sea el cumplimiento. Sobre esto nos ocuparemos a propósito de la extinción de las obligaciones.

b) Pero si la obligación no se cumple, ni tampoco queda extinguida, ello genera efectos determinados. Así, en principio, se abre para el acreedor la posibilidad de iniciar la correspondiente *actio*, precisamente para exigir el cumplimiento por parte del deudor. Y además para éste, se origina un estado de responsabilidad.

I. La responsabilidad del deudor.

Los juristas romanos, lejos de construir una teoría general de esta responsabilidad, siguieron un criterio casuístico. Éste no resultaba de tan fácil apreciación, ya que había que atender no solamente a la naturaleza de cada obligación, y consiguientemente a cada una de las clases de *actiones* que se generaban, sino que además dentro de cada *actio* se conformaban a su vez grupos reducidos de casos.

§ 460. A) *Responsabilidad del incumplimiento del deudor según la naturaleza de la obligación y de la actio*. En principio, la responsabilidad del deudor va a depender de la naturaleza de la obligación y de la pertinente acción que tenga el acreedor:

1. En el caso de las obligaciones nacidas de un delito, en principio se exige el dolo, o sea, la intención deliberada de producir el daño. Tal es lo que ocurre con el *furtum**, la *rapina** y las *iniuriae**. Sin embargo, hay que recordar que

para el caso del *damnum iniuria datum* (daños ocasionados a esclavos, animales o cosas ajenas), sancionado por la *lex Aquilia*, lo único que se exige es que sean cometidos con *iniuria*, por lo que basta la mera culpa, es decir, la comisión del daño por una negligencia (falta de cuidados; *diligentia*; Gayo, 3.211; Alfeno, D.9.2.52.3 ss.; Labeón-Javol., D.íd.52).

1. Hay que recordar que en principio, en el caso del *damnum*, la comisión del perjuicio tenía que ser realizado en forma inmediata (principio del *corpore corpori datum**), no bastando la mera emisión. Sin embargo, ya en la época clásica se amplió el concepto mediante la concesión de *actiones in factum* por parte del pretor.

2. No es considerada *iniuria* la acción que es motivada por un estado de necesidad: así, el destruir la casa del vecino para impedir el avance de un incendio (Celsus-Ulp., D.48.24.7.4), o si por causa de los vientos una nave es llevada contra otra, y por ello se cortan las sogas, o si se cortan las redes de los pescadores en las que se había enredado una nave de pesca (Labeón-Próculo-Ulp., D.9.2.29.3). Y en general, los actos de defensa propia, para repeler la violencia ajena (Cassio-Ulp., D.43.16.1.27).

II. Si se trata de responsabilidad por incumplimiento negocial, hay que distinguir según la naturaleza de la obligación y de la *actio* que le correspondía al acreedor:

a) En caso de que se trate de una obligación de *dare* una cierta cantidad de dinero, o una cantidad de cosas genéricas, en el caso de acciones de derecho estricto (así, *condictio* (*actio certae creditae pecuniae*), o la *actio ex stipulatu* (*actio trilateralis*) o *actio ex testamento*, el vínculo obligacional se mantiene aunque las cosas con que se pensaba pagar se hayan extinguido (principio de que las cosas genéricas no perecen; *genera non pereunt*).

b) En cambio, es distinto si se trata de una obligación de *dare* una cosa cierta y determinada nacida de un negocio de derecho estricto; p.ej., de una *stipulatio*. En principio, al extinguirse la cosa cierta, la obligación se debía extinguir, porque el *dare oportere* de la fórmula presupone la existencia de la cosa. Pero, por la

construcción de los juristas, se interpretó que cuando la cosa ha perecido por hecho (dolo o culpa) del deudor, la obligación se "perpetuaba" (*perpetuator obligatio*; Paulo, D.45.1.91.3). Ocurrir lo mismo si el deudor se hubiera encontrado en mora en cuanto a la *datio* de la cosa (Pomp., D.45.1.23 y 33; Ulp., D.18.2.1; Paulo, D.18.91 pr.1 y 3).

De este modo, el deudor quedaba en este caso obligado a pagar "aquello que en menos me diera" (*quominus mihi dare*; Pomp., D.12.1.5), por lo que se consideraba que la cosa aún estaba subsistente. La condena debía alcanzar el valor objetivo de la cosa en el momento de la *litis contestatio** (*quanti res est*).

1. En caso de entregarse la cosa, pero dañada (p.ej., un esclavo herido), se permitía en principio la acción de dolo (Labedón-Ulp., D.4.3.7.3). A partir de Juliano, se permitía reclamar el menor valor directamente por la acción de derecho estricto pertinente (Jul., D.30.34.4; D.46.3.33.1).

2. Si se trataba del caso de acciones con fórmula incerta (*est, actio incerta ex stipulatu*), como ésta está redactada reclamando "todo aquello que el adversario deba dar o hacer (*quidquid parat dare facere oportere*; Gayo, 4.54); no es necesario recurrir a la *perpetuatio obligationis*, porque la extinción de la cosa no extingue la obligación. Deberá el deudor, en este caso, pagar el valor del perjuicio, considerando el interés de la cosa para el acreedor (*id quod interest*; Prócuro, D.45.1.113.1; Ulp., D.114; Afric., D.7.1.36.2).

C) Si se trataba de una obligación que motivaba un *bonae fidei iudicium**, en caso de incumplimiento, el juez está facultado para apreciar la falta de lealtad del deudor, otorgando una amplia indemnización en el interés del demandante, no solamente teniendo en cuenta el "perjuicio directo" ocasionado (lo que los comentaristas llamarán *damnum emergens*: "daño emergente"), sino además la ganancia que el acreedor hubiera podido haber sacado y de la cual se privó por el incumplimiento (lo que se llamará el *lucrum cessans*: "lucro cesante"); (Paulo, D.46.8.13 pr.; Justiniano, C.7.47.1).

§ 461. B) Responsabilidad por infracciones negociales por actos del deudor. En la época clásica, la consideración de infracciones cometidas por el deudor, se debió principalmente a la aparición de los *bonae fidei iudicia*, pasando luego a los otros negocios. Sin embargo, se mantuvo siempre un criterio casuístico. Será recién con Justiniano y los compiladores bizantinos que se establecerá, sobre la base de los conceptos clásicos, una graduación de los casos de responsabilidad, sobre todo en lo que se refiere a la "culpa".

1. Los *bonae fidei iudicia* protegían las obligaciones en las cuales la *bona fides* estaba necesariamente presente (casos de la compraventa, la locación, el mandato, la sociedad, la gestión de negocios, la tutela, la restitución de bienes doteales —*actio rei uxoriae*—, el depósito, la *fiducia*; Gayo, 4.52).

Debido a ese deber de lealtad nacido de la *fides*, el deudor responde por "dolo", es decir, por una conducta que arrastra la intención deliberada de no cumplir la obligación. El dolo es considerado como un "fraude" (*fraus*; así, Pap., D.6.1.63) en el sentido de que se ha "defraudado" la confianza. Pero también se agregó la responsabilidad de casos graves de negligencia, como opuesta a la *diligentia* que por la *fides* se debe observar. Esta negligencia grave queda asimilada al dolo (Cic., *pro Rosc. Amer.*, 111; Celso, D.16.3.32).

2. En ciertos casos, en los cuales el deudor detenta cosas muebles del acreedor, que en su momento debe restituir, se habla del deber de la *custodia*. Se trata de ciertos supuestos en los cuales el deudor queda comprometido en forma más amplia respecto de la entrega de la cosa.

Así, Gayo (3.205-206) menciona el caso del "comodatario", del "tintorero" (*fullo*) y del "sastre" (*sarcinator*). A ellos habría que agregar el supuesto de los "dueños de navíos", "casas de hospedaje" y "establos" por las cosas de los clientes respecto de las cuales deben *praestare custodiam*. Y también, el vendedor antes de la entrega de la cosa, lo mismo que el locatario y el acreedor *pignoraticio* respecto de la cosa preñada.

En estos supuestos, el deudor no sólo responde por dolo y culpa, sino que además, por el extravío o pérdida de la cosa. Es, por tanto, una responsabilidad ampliada. Así, si le hurtan la cosa, aunque el deudor no haya tenido directamente culpa por el *furtum*; se trataba del *casus minor* (Gayo, 3.205-207; Ulp., D.13.6.5.5 itp.). En cambio, no responden de la pérdida de la cosa por "fuerza mayor" (*casus maior*), es decir, cuando ha ocurrido por un hecho inevitable como un naufragio, un incendio, el arrebato por violencia, etc. (Gayo, D.44.7.1.4).

§ 462. Tal como dijimos, los compiladores, apoyados en las reglas clásicas, pero introduciendo nuevas distinciones y criterios elaboraron una graduación esquemática de la responsabilidad.

Para poder comprender los distintos supuestos de esta responsabilidad del deudor, debemos mencionar, dentro de la terminología romana, las distintas hipótesis por las cuales el deudor dejó incumplida su obligación:

I. Dolo. El incumplimiento también puede haber acaecido por "dolo". Aquí, la palabra "dolo" tiene un sentido distinto del empleado cuando hablamos de maniobras ejecutadas por una

persona para equivocar a otra, provocándole un error para hacerle dar su consentimiento en un acto (es decir, como "vicio de la voluntad"; Labedón-Ulp., D.4.3.1.2). En cambio, acá es todo acto perjudicial realizado por el deudor para impedir el cumplimiento de la prestación (así, p.ej., debía entregar una cosa determinada y en forma intencional la destruí).

Todo deudor debe responder siempre de su dolo. Incluso es nulo todo pacto previo en virtud del cual el deudor no responde del dolo (Paulo, D.2.14.27.3; Ulp., D.50.17.23).

II. Culpa. También el incumplimiento pudo haber sucedido por "culpa". Esta palabra tiene varias tonalidades que conservan una idea común, cual es la de ausencia de una intención perjudicial. Se parte de la idea de que el deudor tiene que obrar con *diligentia*, por lo que su omisión es la *negligentia* (Paulo, D.50.16.226). Pero puede ocurrir tanto en supuestos de la comisión de actos "imprudentes" (*culpa in faciendo*) como de la omisión de aquellos que la *diligentia* requería (*culpa in non faciendo*).

Se suele distinguir entre *culpa lata* (*culpa latior, magna culpa*), es decir, la "culpa grave", diferenciándola de la *culpa levis*, es decir, la "culpa leve" (en un solo pasaje se habla de *culpa levissima*; Ulp., a propósito de la ley Aquilia, D.9.2.44).

A) La *culpa lata* consiste en la comisión u omisión de actos que implican una falta de cuidados tan excesiva que un hombre común no hubiera incurrido en ellos. Por ello, se la termina asimilando al dolo.

1. Así, es *culpa lata* "la demasiada negligencia, esto es, no entender lo que todos entienden" (Ulp., D.50.16.213.2; Paulo, D.11.223 pr.).

2. Por ello, esta *magna culpa* es asimilada al dolo (*magna culpa dolus est*; Paulo, D.50.16.226; Gayo, D.44.7.1.5; Ulp., D.11.6.1.1; D.17.1.29 pr.).

B) Cuando la *negligentia* o *culpa* no alcanza este grado extremo, se hablaba meramente de "culpa" (*culpa levis*), la cual podía ser apreciada conforme a uno de estos dos criterios: el primero abstracto o absoluto —más exigente—; el segundo relativo o concreto —más atenuado—.

(i) En algunos casos se habla de *exacta diligentia*. A los efectos de la apreciación se toma como *standard* jurídico una figura abstracta, representada por la conducta que seguiría un *diligens paterfamilias* en el cuidado de sus propias cosas (Gayo, D.19.2.25.7: *diligentissimus*; D.13.6.18 pr.). Los autores modernos hablarán acá de *culpa in abstracto*.

(ii) En otros casos, la responsabilidad resulta atenuada por el principio de que sólo se

responde de la negligencia que alguien ha tenido cuando no aportó a la cosa los cuidados y la diligencia que acostumbra poner en sus propias cosas (Gayo, D.44.7.1.4; Paulo, D.18.6.3; Gayo, D.17.2.72; Ulp., D.27.3.1 pr.). Los autores modernos emplearán para estos casos la expresión *culpa in concreto*.

1. Uno de los principios liminares establecido por los bizantinos será el de diferenciar ambos casos de culpa (abstracta y concreta), atendiendo al criterio de la ventaja que proporcionaba a cada una de las partes —"utilidad de los contratantes" (*utilitas contrahentium*; Afric., D.30.108.12; Ulp., D.13.6.5.2; 18; Modest., Coll.9.2). Pero, a su vez, hay que distinguir entre los diversos casos que pueden presentarse:

a) Cuando el deudor es el único que obtiene las ventajas del negocio, debe responder no sólo por el dolo, la culpa lata, sino también de toda culpa juzgada a la luz del *standard* de lo que hubiese hecho un *diligentius paterfamilias*. Tal es el caso del "comodatario" (Inst., 3.14.2; Gayo, D.13.6.18 pr.; Ulp., D.13.6.5.2), al igual que la del "depositante" (no el "depositario"); así, por haber dado en depósito un esclavo ladrón (Afric., D.47.2.61.5).

—Pero también cuando ambas partes obtienen ventajas: caso de quien ha dado y de quien ha recibido una cosa en *pignus* (Inst., 3.14.4); e igualmente, el vendedor y el comprador (Inst., 4.23.3); el locador y el locatario (Ulp., D.13.6.5.15, *in fine*; Gayo, D.19.2.25.7); el mandante y el mandatario (Ulp., D.50.17.23; C.4.35.11; v., sin embargo, Mod., Coll.9.2). En este último caso, a pesar de que el beneficiario es sólo el mandante, se impone el criterio de la culpa al mandatario por la *fides* que rige este negocio. También el gestor de negocios ajenos, que se ha inmiscuido en los intereses de otro (Inst., 3.27.1).

En todos estos casos se responde por la culpa interpretada a la luz del *diligentius paterfamilias* (*culpa in abstracto*).

b) En cambio, responden en forma más atenuada de la culpa, interpretada conforme al parámetro concreto del "cuidado puesto en sus propias cosas", los "socios" (Gayo, D.17.2.72), los "coherederos" y "colegatarios" (Paulo, D.10.1.25.16), y el marido respecto de los bienes doteales (Paulo, D.23.3.17 pr.; Ulp., D.24.3.24.5). Acá se justifica la atenuación de la culpa (no responden como *diligentius paterfamilias*), porque no se trata, para ellos, sólo de asuntos de otros, sino también de los propios (Paulo, D.10.2.25.10). Igualmente, el tutor y el curador, ya que sus funciones les son impuestas (Ulp., D.27.3.1 pr.).

C) En determinados casos se exige la máxima diligencia (*exactissima diligentia*), de tal modo que se responde con una responsabilidad mayor. Se trata de los casos en los cuales, en el derecho clásico, se hablaba de "custodia". Se

responde
minor).
do suce-
maior; C
rán de

III. C
obligad
imputab
de "cas
"imprev
asi, p.ej.
o el edif
(vis ma
hubiera
evitar".
tada po

1. A.
como cas
sería cas
lidad mu
2. E.
por "cas
D.50.17.
Sin
respons
a) C.
por la es
caso fort
D.19.2.9.
b) E.
casus ma
del cora
D.17.2.3.
caballer
c) Si
que "los
pudiéndo
cosas q
no se p
"fuerza
d) C.
por cas
(perpet

De
niano
lidad
dolo c
vis ma
Entre
culpa,
divers
ma di
famili
dad po
adhibe
gigen

II. La responsabilidad por retraso (la mora).

§ 463. *Concepto.* La mora supone la existencia de un crédito exigible respecto del cual el deudor en forma consciente ha retrasado el cumplimiento sin estar justificado en dicha demora (*mora debitoris*).

En general la mora se produce por el retraso injustificado por parte del deudor. En muchos casos la situación de mora quedaba perfectamente fijada por la índole de la obligación. Así, cuando la deuda estaba sometida a un plazo, sea que éste esté fijado en un testamento o en general en el propio negocio o en el contrato (Gayo, D.13.3.4; Paulo, D.19.1.47; Ulp., D.45.1.114; D.50.10.5 pr.; C.4.49.10; C.8.38.12). De aquí surge la regla, que no está en los textos romanos, sino que proviene de los juristas medievales: *dies interpellat pro homine* (el plazo interpela por el hombre).

Igualmente, si se trata de una obligación de restituir una cosa como consecuencia de un delito o una cosa que se poseía de mala fe (Ulp., D.5.3.18 pr. y 20.20; D.6.1.15.3; D.13.1.8.1; Tryfon., D.13.1.20; D.43.16.19; C.4.7.7).

Se hablaba de que la mora se había producido *ex re*, es decir, como consecuencia del hecho mismo (Ulp., D.40.5.26; Marciano, D.22.1.32 pr.).

En otros casos se solía emplear una "intimación" (*interpellatio*), o reclamación extrajudicial por parte del acreedor al deudor. Entonces se hablaba de mora *ex persona*. Sin embargo, para los juristas romanos, esta *interpellatio* no es un requisito imprescindible para que se produzca la mora. Tenía más bien una importancia probatoria, sobre todo en ciertos casos dudosos. Los juristas romanos no produjeron sobre esto reglas fijas, dejando el análisis para cada caso en particular.

1. Marciano (D.22.1.32 pr.) establece que si se realizaba la *interpellatio* la mora no era *ex re*, sino *ex persona*. Pero dejaba indicado que la situación debía ser examinada por el juez. Y cita a Pomponio, acerca de que este tema es "de difícil definición". Y también un rescripto de Antonino Pio según el cual no puede decidirse ni por una constitución ni por la autoridad de los juristas cuando se debe entender que se está en mora, "puesto que es más una cuestión de hecho que de derecho".

2. Para que se pueda considerar que alguien está en mora, es necesario que el acreedor cuente con una *actio* (Scév., D.50.17.88), y que el deudor no cuente con una *exceptio* (Paulo, D.12.1.40, *in fine*: "no está en mora aquel a quien no se puede reclamar dinero a causa de una *exceptio*").

Así, si por un mutuo, se ha estipulado un plazo, la mora se produce *ex re* desde que éste venza sin

pagarse el dinero prestado. Pero si no hay plazo, el dinero se debe desde el primer momento. A su vez, si el deudor ha pactado un plazo de espera cuenta con la *exceptio pacti conventi*, o si por otra causa (p.ej., un reclamo intempestivo) tiene la *exceptio doli*, no se hallará en mora, aunque haya mediado la *interpellatio*. Pero si no cuenta con ninguna excepción que pueda esgrimir, estará en mora, aunque no haya habido *interpellatio*. Sin embargo, se ve aquí la utilidad práctica probatoria de la intimación, la cual, sin embargo, no es requisito imprescindible.

3. Serán los autores medievales los que definirán la mora *ex persona* como mora *ex interpellatione*, considerándolo el caso normal, a diferencia de la mora *ex re*, que funciona como excepción (*mora sine interpellatione*).

§ 464. *Efectos de la mora.* En general, la mora agrava la responsabilidad del deudor. Sin embargo, hay que tener en cuenta diversas situaciones:

a) Si se trata de la obligación de dar una "cosa determinada" (*certa res*), si el deudor no la entregó en tiempo oportuno, se interpreta que la "obligación se ha perpetuado" (*perpetuatio obligationis*; Paulo, D.45.1.91.3), de tal modo que el deudor queda responsabilizado, aun si la cosa hubiera perecido por "caso fortuito". Esto se justifica por cuanto la mora supone dolo o culpa por parte del deudor y el riesgo de la cosa corresponde a dicho deudor moroso.

1. Así, si por un legado o por una *stipulatio* me debías entregar un esclavo, si éste hubiera fallecido sin culpa de tu parte antes de cumplido el plazo, nada me debes, pero estando tú en mora, estás obligado a pagar su *aestimatio* (Pomp., D.45.1.23).

2. Se considera que incurrió en mora, quien prefirió litigar a restituir la cosa. Así, en el caso de dar un esclavo, el deudor queda obligado como si el esclavo viviese (Ulp., D.45.1.82.1).

3. La responsabilidad abarca el "interés" del acreedor (*quod quanti mea intersit*; Ulp., D.45.1.114). Sin embargo, el deudor podía quedar exculpado probando que la cosa debida hubiera igualmente perecido teniendo al acreedor (Sabino-Cassio-Gayo, D.16.3.14.1, *in fine*, a propósito del depósito).

b) Si se trata de una obligación de dar una suma de dinero, había que distinguir.

Si estamos en presencia de una *actio stricti iuris*, caso de la *condictio (actio) certae creditae pecuniae* (caso del mutuo o de la *stipulatio*), la mora del deudor en nada aumenta la deuda, es decir, no corresponde el agregado de intereses. Esto se explica por cuanto tanto la *intentio* como la *condemnatio* son *certae*, de tal modo que el juez no puede ni disminuir el monto ni aumentarlo con los intereses (Gayo, 4.32).

En cambio, es distinto el caso si se trataba de un *bonae fidei iudicium*, ya que el deudor moroso debe los intereses que eran fijados por el juez (Marciano, D.22.1.32.2; Paulo, D. id. 17.4), así como también los frutos percibidos durante la mora (Paulo, D.22.1.38.8; Paulo, 2.12.7).

1. En el caso de los fideicomisos, el deudor moroso en su cumplimiento debe los intereses y los frutos. No ocurría lo mismo en los legados que se exigían por la *actio ex testamento*, pero ya en la época clásica se los admitía para los legados *sinendi modo*, según la opinión prevaleciente de Juliano (Gayo, 2.280).

En la época justinianeas, al igualarse los legados a los fideicomisos (C.6.43.1, año 529), los frutos y los intereses pesan sobre el deudor moroso (Ulp., D.22.1.34 itp.).

c) El hecho de estar en mora es personal de cada deudor, por lo que habiendo varios, en principio la mora de uno no perjudica a los demás. Así, tratándose de varios deudores solidarios, como cada uno de ellos tiene un nexo distinto con el acreedor, la mora de uno no tiene efectos respecto de los otros (Marciano, D.22.1.32.4; Paulo, D.50.17.173.2), salvo que el estado de mora haya sido producido por un hecho doloso o culposo de uno de los deudores, que haya ocasionado la pérdida de la única cosa debida (Pomp., D.45.2.18).

En el caso de una obligación garantizada con una fianza, en cambio, la mora del deudor principal se extiende al fiador (Paulo, D.22.1.24.1; D.45.1.88).

C) El estado de mora puede cesar (*enmendatio* o *purgatio morae*) por el hecho de que el deudor ofrezca cumplir la obligación tal como ésta era debida, aun cuando el acreedor injustificadamente no la acepte (Celso-Paulo, D.45.1.91.3; Marcelo, D.46.3.72 pr.) o la obligación fuera novada (Ulp., D.46.2.8 pr.).

§ 465. *Mora del acreedor.* El acreedor es la parte beneficiada en la obligación. Normalmente está aguardando que se cumpla en su favor la prestación por parte del deudor. Pero si en forma injustificada se niega a recibirla, entonces se habla de *mora accipiendi* (mora en recibir; o *mora creditoris*). Siendo así, se protege al deudor que real y efectivamente quiso, y no pudo, cumplir la obligación.

1. Si se trataba de la obligación de dar una "cosa específica", una vez que el deudor hubiera ofrecido en tiempo, lugar y forma la cosa, si la cosa se pierde por "caso fortuito" el deudor queda exculpado. Sólo queda responsabilizado el deudor si hubiera cometido dolo (Pomp., D.24.3.9; Paulo, D.13.6.5; Pomp., D. id. 17).

2. Si se trataba de dar "cosas genéricas" (incluido el dinero), el acreedor moroso pasa a asumir todos los riesgos, salvo que se trate de dolo por parte del deudor. De no ser así, a éste el pretor le concede la *exceptio doli mali* (Marcelo, D.46.3.72 pr.; Paulo, D.18.6.5). Excepcionalmente, el pretor podía directamente denegarle la *actio* al acreedor liberándolo al deudor (Ulp., D. 46.3.30).

3. El deudor puede "sellar" el dinero debido (*obligatio*) y depositarlo (*depositio*) en un templo o establecimiento público. Si hace esto cesan para él los intereses convencionales (Pap., D.22.1.7; Paulo, D.14.7, Marcelo, D.26.7.28.1). Si quien depositó públicamente es el fiador, puede reclamar su reembolso al deudor principal por la *actio mandati* (Pap., D.17.1.56).

En el derecho posclásico el deudor que ha consignado en forma pública el dinero queda directamente liberado (Diocl., C.8.42.9) Justiniano concede al acreedor una *actio utilis* para poder cobrar el dinero depositado (C.4.32.19.4 itp.).

4. El deudor que ha ofrecido el pago al acreedor, negándose éste de manera injustificada a aceptarlo, puede hacerse pagar los gastos de conservación y custodia y perjuicios que le ocasione dicha mora (Ulp., D.19.1.38.1; Pomp., D.33.6.8). Así, el vendedor que tenía la obligación de entregar vino por medidas determinadas, en caso de mora del comprador (acá acreedor), podía en caso de necesitar los toneles, vender directamente el vino, aunque se aconseja no hacerlo, pudiendo el vendedor vender el vino o arrendar otros toneles, a cargo del comprador (Ulp., D.18.6.1.3).

III. Revocación de los actos fraudulentos del deudor.

§ 466. El deudor que no ha cumplido su obligación, puede ser demandado y, en su caso, ser condenado. La sentencia era normalmente ejecutada por medio del procedimiento de la *venditio bonorum*. Cabe suponer que el deudor insolvente, por cuanto no pudo pagar sus deudas ha realizado malos negocios. Pero, aún después de haber sido condenado, como tiene aún el poder de disponer de sus bienes, pudo seguir realizando negocios que disminuyan su patrimonio, tales como enajenaciones, contraer nuevas deudas o liberar de sus deudas a sus deudores. Estas operaciones resultaban perjudiciales para sus acreedores, que al ver disminuidos los bienes, cobrarían menos en el resultado final de la *venditio bonorum*. Se daba entonces el caso de "fraude" (*fraus*) por parte del deudor.

El pretor, en su Edicto, proporcionó algunas medidas para proteger en este supuesto a los acreedores perjudicados. Estas dependerán del momento respectivo de la ejecución (*venditio bonorum*).

a) Por de pronto, se concede al *curator bo-*

norum, es decir, a aquel a quien el pretor ha puesto en posesión de los bienes del deudor, para preparar la *venditio bonorum* una *in integrum restitutio*, ejercible dentro del año, de tal modo que el magistrado tenía por no realizados ciertos actos jurídicos hechos por el deudor con terceros, que conociendo la situación de fraude, han participado en una operación que disminuyó el patrimonio del deudor (*fraudator*; Ulp., D. 42.8.1, itp.; D.42.5.8.1).

1. La *restitutio in integrum* era concedida al *curator bonorum*, si bien en beneficio de todos los acreedores. Hubiera sido impracticable concederla a todos ellos actuando cada uno en forma particular. Por eso en el Edicto figuraba en el título 41, que se refiere al *curator bonorum*.

2. La restitución se refería a todos los negocios, en forma general: el haber enajenado una cosa, haber liberado por la *acceptilatio* a un deudor, o haber liberado prendas, o haber entregado dinero, o haber dejado fenecer un juicio, o haber dado al demandado una excepción, etc. (Ulp., D.42.8.1.1-2; 2 y ss.).

3. Si bien el Edicto contenía esta cláusula de *restitutio in integrum*, no cabe descartar que ella estaría incardinada en una *actio*. Ésta era rescisoria respecto de los actos realizados en fraude de los acreedores y con cláusula ficticia ("como si la *manipatio* o la *traditio* no hubiera sucedido"; Cic., *ad Att.* 1.1.3; EP, § 225).

b) La *restitutio in integrum* se otorgaba mientras duraba el procedimiento concursal de la *venditio bonorum*. Pero concluida ésta, los acreedores que no se vieran totalmente satisfechos por cuanto sólo habían recibido una porción (*portio*) de sus créditos tenían un *interdictum fraudatorium* que tenía la finalidad de hacer restituir los bienes transmitidos a terceros conscientes de la situación del fraude (Ulp., D.42.8.10 pr.; EP, § 268). Le era dado a los acreedores, respecto de los actos fraudulentos que no habían sido reclamados por el *curator bonorum*. Pero no lo podían pedir globalmente todos los acreedores, sino cada uno en forma particular. Sin embargo, era la masa total de los acreedores la que se beneficiaba.

1. Este interdicto podía abarcar ciertos supuestos que no entraban en la *in integrum restitutio*; así, actos unilaterales del deudor como el abandono de una cosa (Gayo, D.42.8.5).

2. Debía ser planteado dentro del año de sucedido el negocio, si se trataba de terceros que estaban en conocimiento del fraude. Pero el pretor lo concedía también más allá del año, bajo la forma de *utilis* y previo conocimiento de la causa, contra el tercero de buena fe, que hubiera lucrado gratuitamente de la cosa (Ulp., D.42.8.10 pr. y 24).

3. El demandado perdidioso debía restituir la cosa dentro del patrimonio del deudor, en beneficio de los acreedores. Debía retransmitir la propiedad del bien enajenado, o conceder en su caso la acción que había obtenido por el acto fraudulento. Si se trataba de obligaciones liberadas, debía volver a constituir las (Ulp., D.42.8.10.22). Sin embargo, no alcanzaba para constreñir al acreedor prendario a restituir el *pignus* obtenido en garantía de una deuda anterior (Paulo, D.42.8.13).

4. Además, el pretor protegía al *bonorum emptor*, es decir, al adquirente de los bienes del concurso, respecto de acreedores fraudulentos (constituidos falsamente por el deudor *fraudator*) que pretendieran cobrar sus créditos, ya denegando la acción, o permitiendo que el *bonorum emptor* se defendiera con una *exceptio* (Ulp., D.42.5.25; D.12.2.9.5).

Como lo vemos, la *restitutio in integrum* estaba fuertemente vinculada con la *venditio bonorum*, en el interés de un *bonorum emptor*, quien al adquirir *per universitatem* todos los bienes del concurso, se obligaba a pagar, hasta un monto determinado las deudas. Pero la *venditio bonorum* será reemplazada en el procedimiento *extra ordinem* por la *distractio bonorum** (venta de las cosas una por una), no existiendo ya el interés que podía tener el *bonorum emptor*. Se comprende así que ya en el siglo III, la medida que tenía importancia era el *interdictum fraudatorium*, que daba protección de restitución por los actos fraudulentos del deudor (Diocl., C.7.75.5, año 293).

§ 467. *Actio Pauliana*. Justiniano (Inst., 4.6.6) refundirá las soluciones clásicas (*in integrum restitutio* e *interdictum fraudatorium*) en una acción revocatoria única. Esta acción será conocida por los comentaristas como *actio Pauliana*, con la circunstancia extraña de que esta denominación aparece una sola vez en los textos (Paulo, D.22.1.38.4). En la parte que la trata en el Digesto (42.8) y en el Código (7.75), sólo se habla de una *actio in factum* destinada a revocar las enajenaciones y los actos que han sido realizados por el deudor en fraude de sus acreedores (así, Ulp., D.42.8.10.16; 10.18).

Esta "acción revocatoria" (*actio Pauliana*) era concedida al acreedor que denunciara, dentro del año, la realización de un acto o actos fraudulentos, contra el deudor *fraudator* y contra los terceros que habían participado en ellos (Ulp., D.42.8.1 pr.).

Se debían dar las siguientes circunstancias:
a) Es necesario que el acto realizado haya disminuido o empobrecido el patrimonio del deudor (Ulp., D.42.8.6 pr.).

1. Así, al haber vendido un fundo por un precio menor (Paulo, D.42.8.7); al haber liberado al deudor,

dando por recibido el pago de una deuda (Ulp., D.42.8.1.2, *in fine*; D.10.14; Jul., D.17.17); al no haberse presentado a juicio, o haber consentido en que feneciera, o haber proporcionado una *exceptio* al deudor del *fraudator* (Ulp., D.42.8.2-4); el haber abandonado una cosa suya, de modo que otro se la apropió (Gayo, D.14.5). A diferencia del *interdictum fraudatorium*, también procede la acción revocatoria contra la constitución de una prenda fraudulenta, por una deuda anterior (Scév., D.42.8.22 itp.; *in fine*).

2. En cambio, no procede contra los actos por los cuales el deudor decidió no enriquecerse, p.ej., no aceptando una herencia, una donación o un legado, puesto que como dice Ulpiano, "este Edicto se refiere a los que disminuyen su patrimonio, no a los que obran de modo que no se hagan más ricos" (D.42.8.6 pr.).

b) El acto fraudulento tiene que ocasionar un perjuicio a los acreedores, creando o acrecentando el estado de insolvencia. Basta con probar la necesidad de vender los bienes del deudor, ya que con ello se demuestra que el deudor no puede satisfacer a los acreedores (Ulp., D.42.8.10.1).

c) Si el acto fraudulento aprovechó a un tercero, hay que establecer una diferencia: (i) Si se trata de un acto oneroso (p.ej., una venta) es necesario que el tercero adquirente haya tenido conocimiento de la situación del deudor y del fraude que se ha cometido (*consciis fraudis*). Si se demuestra ello, el acto o negocio podrá ser revocado; de lo contrario, si no existía el *consilium fraudis*, el acto resulta inatacable (Ulp., D.42.8.6.8). (ii) Ahora, si se trata de un acto a título gratuito, exista o no dicho *consilium fraudis*, el acto o negocio es siempre revocado (Ulp., D.42.8.6.11).

1. Se explica esta diferencia por cuanto cuando se trata de un acto oneroso, el tercero ha desembolsado una suma de dinero. Por ello, siendo adquirente de buena fe a título oneroso merece estar protegido. Pero, siendo de mala fe, sería sancionado con la revocación.

En cambio, siendo el tercero adquirente a título gratuito, éste está lucrando a costa de los acreedores, por lo que el acto debe ser siempre revocado, sin investigar si dicho adquirente estaba o no compartiendo el fraude del deudor. Sin embargo, si era de buena fe, la acción progresa solamente hasta el monto en "que se hizo más rico" (*locupletior*) y no más allá de ello (Ulp., D.42.8.6.11).

En cuanto a la situación del tercero adquirente a título gratuito, en la época clásica se concedía el *interdictum fraudatorium* como *utile* (Venuleyo, D.42.8.25 pr.; C.7.75.5).

2. Si el adquirente a título oneroso la hubiese a su vez vendido a otro tercero, éste sólo podía ser

perseguido si es de mala fe (*consciis fraudis*). Si es de buena fe, el acto es inatacable, pero el acreedor podrá ir en ese caso contra el adquirente primero, siempre que lo sea de mala fe, reclamando el total del precio (Paulo, D.42.8.9).

§ 468. En cuanto a los efectos de la *actio in factum* revocatoria (*actio Pauliana*), fundamentalmente tiene por finalidad la revocación del acto fraudulento. Era "arbitraria", y según el *arbitrium* del juez se debía restablecer el orden de las cosas en el estado anterior a la celebración del acto, restituyendo la propiedad de la cosa con sus productos y frutos, o volviendo a constituir la obligación, en caso de haber sido liberado el tercero deudor (Ulp., D.42.8.10.22; Paulo, D.22.1.38.4). Si el tercero restituye la cosa o reconstituye la obligación antes de la condena, queda liberado (Venuleyo, D.42.8.25.1: "porque esta acción se da para que se restituya la cosa, no a título de pena, y por ello suele ser absuelto el demandado si ha restituido").

1. Se ha discutido si esta *actio* (rescisoria y ficticia) era *in personam* o *in rem*. Paulo (D.22.1.38 pr. y 4) habla de que esta *actio* era *in personam*, mientras que Theóphilo, comentando el texto de las Institutas (4.6.6), le da a esta *actio*, a la que denomina como *Pauliana*, un carácter *in rem*. Estos textos son contradictorios, por lo que han preocupado a la doctrina.

Los textos hablan meramente de una *actio in factum*. Es dada no contra cualquier detentador, sino contra el deudor que ha cometido el fraude y contra los terceros de mala fe (que tenían conocimiento del fraude), aunque ellos no posean, y aun contra los adquirentes a título gratuito, si bien siendo de éstos de buena fe, sólo hasta el monto del enriquecimiento. Todo ello hace dudar que se tratara realmente de una *actio in rem* que alcanza a todo detentador.

Sin embargo, Justiniano (Inst., 4.6.6) habla de esta acción diciendo que si se ha transmitido la cosa en fraude de los acreedores, éstos pueden, después de haberseles puesto en posesión del bien, "vindicar esta cosa haciendo rescindir la tradición, es decir, diciendo que la cosa no ha sido traidada, y que en consecuencia, ha quedado entre los bienes del deudor", con lo que parece asignarle efectos *in rem*.

Algunos piensan que podían existir dos formas: la primera (*in personam*), que se aplicaba para rescindir todos los actos fraudulentos, y la segunda (*in rem*) cuando se trataba de actos de enajenación, y que no era sino una clase especial de *rei vindicatio* construida sobre una base ficticia.

2. La acción se da contra el deudor *fraudator* y contra los terceros involucrados en los actos fraudulentos. Mola opinaba que si el deudor hubiera vendido un bien, no correspondía la acción contra él, pero los bizantinos le admiten responsabilidad para todo

caso en que sea imposible la restitución, dando a ello un carácter de pena (Venuleyo, D.42.8.25.7).

3. Cuando la acción era intentada dentro del año, a contar desde la realización del acto fraudulento (Ulp., D.42.8.6.14), la condena abarca la totalidad del perjuicio, aun cuando el tercero adquirente no hubiera conservado la totalidad del beneficio procurado (Ulp., D.42.8.10.18-19).

Pero también se la permitió luego de pasado el año después de la venta fraudulenta, ya contra el *fraudator* a quien le volvió la cosa, como respecto de terceros, pero sólo en la medida de lo que se hubiere enriquecido (Ulp., D.42.8.10.24). Compete igualmente al heredero del acreedor y va contra los herederos de las personas involucradas en el fraude (Ulp., D.42.8.25.1).

IV. Extinción de las obligaciones.

§ 469. *Concepto y clases*. Toda obligación vale siempre como una atadura (*un ligare*), que es necesario desatar (*solvere* = "disolver"). Desde este punto de vista, si toda obligación engendra un *dare praestare facere oportere*, cuando ese *debitum* se cumple, satisfaciendo con ello al acreedor, por lo menos desde la época clásica, la obligación se extingue. Pero pueden existir otras causas de disolver una obligación, las cuales pueden tener efectos más o menos intensos, según sus características.

a) En algunos casos, como p.ej., el "pago" (por lo menos a partir de la época clásica), siempre y cuando éste reúna los requisitos necesarios para satisfacer plenamente al acreedor, la extinción de la obligación se produce de manera automática, "de pleno derecho" (*ipso iure*).

b) En cambio, en otros casos, la obligación en principio subsiste, pero puede verse extinguida por una *exceptio* que le opone al deudor demandado al acreedor. Así, ocurriría en el caso de haberse celebrado un "pacto de remisión de la deuda" (*pactum de non petendo*) por el cual el acreedor la perdonaba. En principio, el pacto no genera acción, pero si el acreedor que había hecho remisión de la deuda pretende cobrarla, entonces el demandado gozará de una "excepción" (*exceptio pacti conventi*; Gayo, 4.116b). Se dice entonces que la obligación no se extingue *ipso iure*, sino "por obra de una excepción" (*ope exceptionis*).

1 Esta clasificación, generalmente expuesta en los manuales, tiene su punto de partida en el texto de Gayo (3.168), donde habla del pago como modo de extinción *ipso iure*, planteando el problema de si la *datio in solutio* (cuando se paga una cosa distinta, aceptándolo el acreedor) extingue la obligación *ipso iure*, o se debía operar *ope exceptionis*.

2. Pero, en realidad, esta división resulta bastan-

te escolástica, quizá para denotar una mayor intensidad en la fuerza de extinción. Además, resulta bastante relativa, ya que si no obstante haberse producido el pago en la *datio in solutio*, el acreedor insiste en que ello no ocurrió, el pretor podía, ante prueba fehaciente, denegar directamente la acción (*denegatio actionis*); aunque también si no le constaba fehacientemente, dejar que el hecho controvertido se introdujera en el juicio, otorgando al deudor una *exceptio doli mali*.

Ya para la época de Justiniano, con la vigencia de la *extra ordinem cognitio*, esta clasificación carece de importancia: Ni siquiera la mención en el capítulo pertinente de las Institutas (3.29).

Por ello resulta más conveniente referirse concretamente a cada uno de los modos de extinción.

§ 470. I. *Pago*. La palabra empleada para designar lo que hoy llamamos "pago" era *solutio*, derivada de *solvere* (= "disolver"). A veces, puede tener un sentido restringido al cumplimiento de las obligaciones de *dare* (así, pagar una suma de dinero), pero se terminó por darle un sentido muy amplio, de tal modo que significó directamente el cumplimiento de aquello a lo cual el deudor se obligó.

1. Así, según se atribuye a Paulo (D.46.3.54), *solutio* corresponde a "toda liberación hecha de cualquier modo", refiriéndose más bien a la sustancia de la obligación que al pago de una suma de dinero.

Igualmente, Ulpiano (D.50.16.176) entiende por *solutio* toda satisfacción de una obligación, incluyendo también las obligaciones de "hacer" (en lenguaje clásico, para éstas se solía utilizar la expresión *satisfactio*).

Por ello, en Inst., 3.29 pr., se dice que "toda obligación (*omnis obligatio*) se extingue (*tolliitur*) por la *solutio* de lo que es debido".

§ 471. ¿Qué es lo que se debe pagar? En sentido amplio se "paga" cumpliendo la prestación debida. Así, si ésta consiste en un *dare*, transmitiendo el dominio de la cosa debida (p.ej., por una *mancipatio* o una *traditio*); si lo es de un *facere*, haciendo aquello a lo que comprometiéndose (así, p.ej., haciendo el vendedor la *traditio* al comprador entregando la posesión de la cosa; o realizando la obra en una *locatio conductio operis*); y si se trata de un *praestare* efectivizando la garantía asumida (v. *supra*, § 318.c).

a) Se acepta también que el deudor se libere pagando "una cosa por otra" (*aliud pro alio*), siempre y cuando que el acreedor consienta en ello, puesto que éste no queda obligado a aceptarla (Paulo, D.12.1.2.1). Este caso se denomina la *datio in solutio* ("dación en pago").

1. Según nos dice Gayo (3.168), los sabios nos le dan a esta *datio in solutio* un sentido más intenso,

hablando de que aceptada por el acreedor, la obligación se extingue *ipso iure*. En cambio, los procleranos decían que el deudor continuaba técnicamente obligado, si bien se podía defender por la *exceptio doli*. Justiniano se inclinó por la primera solución, entendiendo que pagando una cosa por la realmente debida y aceptando ello el acreedor, "también se paga" (Inst., 3.29 pr.; Diocly Maxim., C.8.43.16-17).

2. Si la cosa dada en pago era ajena y fuera objeto de una "evicción" por su verdadero dueño, se entendió que no hubo *datio*, y por ello, que no existió pago, por lo que el acreedor sigue manteniendo su primitiva *actio* contra el deudor (Marciano, D.46.3.46).

3. En la última época, Justiniano (Nov. 4.3) le concede al deudor que no puede pagar una deuda de dinero, liberarse ofreciendo bajo justa estimación, los bienes inmuebles que posee y que nadie quiso adquirir (Nov. cit., 120 6.2). Se la denomina *datio in solutio necessaria*, por oposición a la *datio in solutio voluntaria*, que como hemos visto exige el consentimiento de aceptación por parte del acreedor.

b) El pago debe ser "íntegro" respecto de la cosa debida. El acreedor no puede ser obligado a recibir pagos parciales contra su voluntad. Justiniano permitirá por razones de *humanitas* que se puede constreñir al acreedor por medio del magistrado a recibir una suma menor (5 en lugar de los 10 de la deuda), dándole acción solamente por el resto (Jul., D.12.1.21 itp.).

Hay ciertos casos en que el acreedor se ve obligado a aceptar una suma parcial. Ello ocurre si el garante (*fideiussor*) le opone el "beneficio de división", o si el deudor le opone una "compensación". Igualmente, para ciertos deudores especiales, se les permite pagar dentro del límite de sus posibilidades económicas. Es lo que posteriormente se denominará el "beneficio de competencia" (*beneficium competentiae*).

1. En el caso de este *beneficium competentiae* se limitaba la condena por una *taxatio* para que el deudor pagara "lo que podía" (*in id quod facere potest*). En el derecho clásico, el *iudex* condenaba hasta el monto activo del patrimonio del deudor, es decir, lo que quedaba deducidas las deudas.

Justiniano autoriza a que el deudor pudiera retener lo necesario para su subsistencia (Paulo, D.42.1.19.1; D.50.17.173 pr.). Precisamente *competentia* hace relación a la "suficiencia de medios para vivir".

La denominación *beneficium competentiae* no aparece en los textos romanos, siendo acuñada por los juristas del siglo XVI, y llegando a la época actual.

2. Los casos más significativos de quienes gozaban de este beneficio son: (i) el deudor que hizo "cesión de los bienes" a los acreedores (Inst., 4.6.60); (ii) el donante (Paulo, D.42.1.19.1); (iii) el socio (Ulp.,